

《【문제1】 경영상 이유에 의한 해고(정리해고)에 관하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 경영상 이유에 의한 해고의 의의, 요건, 절차 및 구제, 재고용 의무

**I. 경영상 이유에 의한 해고(정리해고)의 의의**

- 사용자 측의 경영상 필요에 의하여 근로자에게 귀책사유가 없음에도 불구하고 일정 수의 근로자를 집단적으로 해고하는 것을 의미한다. 이는 기업의 생존권과 근로자의 고용 안정이라는 기본권적 측면이 첨예하게 대립하는 영역이다. 정리해고는 근로자의 생활 기반을 일방적으로 붕괴시킨다는 점에서, 근로기준법(이하 '근기법') 제23조 제1항의 정당한 이유보다 고도의 정당성을 필요로 한다. 따라서 근기법 제24조는 정리해고의 남용을 엄격히 통제하고 근로자 보호를 강화하기 위해 긴박한 경영상의 필요, 해고회피 노력, 합리적이고 공정한 기준 마련 및 적용, 근로자 대표와의 성실한 협의라는 네 가지 실체적·절차적 요건을 모두 충족하도록 강제하고 있다.

**II. 경영상 이유에 의한 해고의 요건**

**1. 긴박한 경영상의 필요**

- 정리해고의 실체적 정당성을 확보하기 위한 첫 번째 요건이다.

**(1) 의미**

- 기업의 도산 회피나 경영 악화 개선에 국한되지 않으며, 장래의 경영 위기에 미리 대처하기 위한 조직 통폐합 또는 기업의 객관적 경쟁력 강화를 위한 인원 감축의 필요성까지 포함하는 광범위한 개념으로 해석된다. 정리해고의 필요성은 사용자의 경영 판단을 존중하되, 그 판단이 객관적으로 합리성이 있다고 인정될 때에만 정당성이 부여된다. 단순한 인건비 절감 목적만으로는 긴박성을 인정받기 어렵다.

**(2) 판단 기준**

- 긴박한 경영상의 필요성 유무는 객관적 증거에 의해 뒷받침되는지 여부, 즉 객관적 합리성을 기준으로 사법 심사를 거쳐 판단된다.

**① 도산 회피**

- 당장의 재정적 파탄이나 부도를 피하기 위하여 인원 감축이 불가피한 경우로, 경영상의 필요성이 가장 명백하게 인정된다. 이는 기업의 존립 자체를 위협하는 수준의 심각한 재정 위기가 현실화되었을 때 인정된다.

**② 경영상 위기 극복**

- 상당한 규모의 적자 누적이나 시장 상황 악화 등으로 인해 장래 경영 악화가 예측되어, 이를 극복하고 기업 활동을 유지하기 위해 인력 감축이 필요한 경우이다. 이 경우, 사용자는 구체적인 재무적 지표를 통해 위기의 현실성을 입증해야 한다.

**③ 경쟁력 강화**

- 경영 합리화 또는 구조조정의 일환으로 조직 효율을 높이는 과정에서 인력 감축이 필요한 경우를 말하며, 현재 재정 상태가 양호하더라도 장래 경영 환경 변화에 대한 사전 대처로서 합리성이 있다면 정당성이 인정될 수 있다. 다만, 경영 효율성 제고를 목적으로 할지라도, 인력 감축이 없었다면 기업이 중대한 경영상 위기에 처했을 것이라는 개연성이 객관적으로 입증되어야 한다.

**2. 해고회피 노력**

- 정리해고가 근로자의 생존권을 침해하는 최후의 수단임을 입증하기 위하여 사용자가 해고를 피하기 위해 성실하고 최대한의 노력을 다해야 한다는 요건이다.

**(1) 의미**

- 사용자가 경영 위기를 타개하고 근로자의 고용을 최대한 유지하기 위하여 진정성 있게 취한 모든 조치를 의미한다. 사용자는 해고 규모를 최소화하기 위해 경영상 기대할 수 있는 모든 조치를 성실하게 이행했어야 하며, 노력의 정도는 기업의 규모, 재정 상태, 사회적 책임 등을 종합적으로 고려한 객관적 합리성을 기준으로 판단된다.

**(2) 노력의 내용**

- 법에 명시되어 있지 않으나, 판례는 다음 조치들을 요구한다.

**① 비용 절감**

- 임원 급여 삭감, 신규 채용 중단, 비업무용 자산 매각 등 인건비 외의 고정 비용을 최소화하기 위한 노력을 포함하며, 근로 조건 불이익 변경을 통한 인건비 절감 노력도 포함된다. 이러한 노력은 해고 외의 고정 비용 절감 노력을 선행하거나 병행하는 방식으로 진행되어야 한다.

**② 전환 배치**

- 해고 대상 부서의 근로자를 다른 유류 부서나 업무로 배치 전환하여 고용을 유지하려는 노력을 말한다. 이는 고용 유지를 위한 가장 적극적인 조치로 간주되며, 직무 내용이나 근로 조건의 일부 변경을 포함할 수 있다. 이 때, 근로자의 능력과 적성 등을 종합적으로 고려해야 한다.

**③ 해고 외 방법**

- 자발적인 희망퇴직 또는 명예퇴직 실시, 유급 또는 무급 일시 휴직 실시, 순환 휴직, 근로시간 단축 등을 포함하며, 강제성이 없는 자발적 의사에 기반해야 한다.

**3. 합리적이고 공정한 해고의 기준 마련 및 적용**

- 정리해고 대상자를 선정함에 있어 객관적이고 합리적인 기준을 수립하고, 그 기준을 공정하게 적용하여 자의적인 해고를 방지해야 한다는 요건이다.

**(1) 의미**

- 해고 대상자 선정 기준과 절차가 자의적이지 않고 공정성을 확보해야 함을 말한다. 수립된 기준은 구체적이고 명확해야 하며, 대상자 선정이 객관적 근거를 가질 때 정당성이 인정된다.

**(2) 기준의 내용**

- 해고 대상자 선정 기준은 기업 특성에 따라 다르지만, 일반적으로 다음 요소들을 종합적으로 고려한다.

**① 주요 고려 요소**

- 근로자의 업무 능력, 생산성, 경력, 근속연수, 부양가족의 수, 생활 안정성, 징계 유무 등이다. 이러한 요소들은 종합적으로 평가되어야 하며, 특히 업무 평가와 같은 주관적 요소를 반영할 경우 평가 과정의 공정성과 객관성을 확보하기 위한 제도적 장치가 요구된다.

**② 노동조합 활동**

- 해고 기준 적용 시 노동조합 활동이나 근로자 대표 활동을 이유로 특정 근로자에게 불이익을 주거나 차별해서는 안 된다. 차별적 목적이 입증된다면, 이는 부당노동행위에 해당하여 정리해고의 정당성을 상실시킨다.

#### 4. 근로자 대표와의 성실한 협의

- 사용자가 정리해고를 실시하기 전에 근로자 대표와 충분하고 진정성 있는 협의 과정을 거쳐야 한다는 가장 중요한 절차적 요건이다.

##### (1) 의미

- 사용자가 정리해고를 일방적으로 결정하는 것을 방지하고, 근로자 대표에게 의견을 제시하고 대안을 모색할 실질적인 기회를 부여하여 해고의 필요성과 기준에 대한 합리적인 합의를 도출하도록 노력해야 함을 의미한다. 협의는 단순히 통보에 그치지 않고 실질적인 대화 과정이어야 한다. 근로자 대표는 과반수 노동조합 또는 근로자 과반수를 대표하는 자이다.

##### (2) 협의 내용

- 사용자는 근로자 대표에게 통보하고 다음의 주요 사항들에 대하여 성실하게 협의해야 한다.

###### ① 해고 회피 노력의 내용

- 사용자가 취한 및 앞으로 취할 해고 회피 조치에 대하여 근로자 대표와 논의하고 의견을 수렴해야 한다.

###### ② 해고의 기준

- 해고 대상자 선정에 사용될 합리적이고 공정한 기준의 타당성 및 공정성에 대하여 협의해야 한다.

###### ③ 정리해고 시기 및 규모

- 실제 정리해고를 실시할 시기와 해고할 인원의 규모에 대하여 협의해야 한다.

###### ④ 기타 사항

- 해고 대상 근로자의 재취업 지원 방안, 퇴직 위로금 등 근로자 보호를 위한 기타 조치에 대해서도 성실하게 협의해야 한다.

##### (3) 협의 기간

- 사용자는 정리해고를 실시할 50일 전까지 근로자 대표에게 통보하고 성실하게 협의해야 한다(근기법 제24조 제3항). 이 기간 동안 근로자 대표의 의견을 경청하고 반영하려는 성실 의무를 다했는지 여부가 정당성 판단의 중요한 요소로 작용한다.

### Ⅲ. 해고의 절차 및 구제

#### 1. 해고 예고 및 서면 통지

- 경영상 이유에 의한 해고 역시 일반 해고와 동일하게 법이 정하는 해고의 절차적 제한을 모두 준수해야 한다.

##### (1) 해고 예고 [근기법 제26조]

- 사용자는 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고하거나, 예고를 하지 않았을 경우 30일분 이상의 통상임금을 해고예고수당으로 지급해야 한다.

##### (2) 해고 사유 서면 통지 [근기법 제27조]

- 해고는 서면으로 그 사유와 시기를 통지하여야 효력이 발생한다. 서면 통지 의무 위반은 정리해고의 절차적 무효 사유가 된다. 서면 통지에는 긴박한 경영상의 필요성 등 근기법 제24조의 정당성 요건이 구체적으로 명시되어야 하며, 이는 근로자의 불복 여부 결정에 필수적인 정보를 제공한다.

#### 2. 부당해고 구제 신청

- 정리해고가 근기법 제24조의 요건을 충족하지 못하여 부당하다고 판단될 경우 근로자는 노동위원회에 구제를 신청할 수 있다.

##### (1) 노동위원회 구제 신청

- 근로자는 해고가 있는 날로부터 3개월 이내에 관할 지방노동위원회에 부당해고 구제 신청을 제기할 수 있으며, 노동위원회는 근기법 제24조의 네 가지 요건 충족 여부를 심사하여 정당성을 판단한다.

##### (2) 구제 내용

- 노동위원회가 부당해고로 판정하면 사용자에게 구제 명령을 내린다.

###### ① 원직 복직

- 부당해고로 판정된 근로자를 해고가 없었던 상태로 되돌려 놓는 것을 말한다.

###### ② 임금 상당액 지급

- 해고 기간 동안 근로를 제공하지 못함으로써 발생한 임금 상당액을 사용자에게 지급하도록 명한다.

### Ⅳ. 재고용 의무 및 기타 사항

#### 1. 해고된 근로자의 재고용 의무 [근기법 제25조]

- 정리해고 이후 근로자의 고용 안정을 도모하기 위해 사용자에게 부과되는 법률상의 노력 의무이다.

##### (1) 의무

- 사용자는 정리해고 후 3년 이내에 해고 당시와 동일하거나 유사한 직책에 근로자를 채용하려는 경우, 해고된 근로자가 원한다면 우선적으로 재고용하도록 노력해야 한다.

##### (2) 위반 시 제재

- 재고용 노력 의무는 노력 의무이므로, 위반 시 직접적인 벌칙이나 과태료는 부과되지 않는다. 다만, 향후 정리해고 시 해고회피 노력 의무 위반을 판단하는 데 불리한 정황으로 고려될 수 있다.

#### 2. 단체협약과의 관계(단체협약의 우선)

- 단체협약에서 정리해고에 관하여 근기법 제24조보다 근로자에게 유리한 조건을 정하고 있는 경우, 그 단체협약의 내용이 유리한 조건 우선의 원칙에 따라 법에 우선하여 적용된다.

#### 3. 구조조정의 정당성

- 정리해고가 기업의 경영 합리화, 조직 재편 등 정당한 구조조정 목적을 달성하기 위한 필수 불가결한 최후의 수단으로 활용될 때 그 정당성이 인정된다.

### Ⅴ. 결론

- 경영상 이유에 의한 해고(정리해고)는 기업의 생존과 근로자의 고용 안정이라는 상충되는 법익을 근기법 제24조를 통하여 사회적 합리성 있게 조화시키는 제도이다. 사용자는 네 가지 엄격한 법적 요건을 형식적으로 넘어, 해고회피를 위한 최대한의 노력과 근로자 대표와의 진정성 있는 협의를 통해

정리해고의 실질적인 정당성을 확보해야 한다. 기업은 해고 대상 근로자에 대한 보호와 재고용 노력을 통해 사회적 책임을 다해야 한다.

<제10장 업무상 재해 등.제01절 업무상 재해>

[기출][1][2008-2-1]근로기준법과 민법·산업재해보상보험법 간의 재해보상 관계

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음1) 근로기준법상 재해보상에 있어서 민법 및 산업재해보상보험법과의 관계 (25점)》

<문제2의 물음1> 근로기준법과 민법·산업재해보상보험법 간의 재해보상 관계

**I. 문제의 제기**

- 근로기준법상 재해보상은 사용자의 귀책사유 유무를 불문하는 무과실책임을 원칙으로 하나, 동일한 재해에 대하여 민법상 손해배상이나 산업재해보상보험법(이하 '산재보험법')상 보험급여가 중복될 경우 그 조정 문제가 발생한다. 따라서 각 제도 간의 보상 범위와 책임의 성격, 보상 및 배상의 청구권 조정 원리를 파악할 필요가 있다. 이하에서는 근로기준법상 재해보상 제도와 타 법령인 민법 및 산재보험법과의 상호 관계에 대하여 검토한다.

**II. 근로기준법상 재해보상과 민법의 관계**

**1. 책임의 성격과 배상 범위의 차이**

**(1) 무과실책임과 과실책임**

- 근로기준법상 재해보상은 사용자의 과실 유무와 상관없이 업무상 재해라는 사실만으로 보상 의무가 발생하는 무과실책임이다. 반면 민법 제750조에 따른 손해배상은 사용자의 고의 또는 과실이 입증되어야 하는 과실책임 원칙을 따른다.

**(2) 정액보상과 실손배상**

- 근로기준법은 평균임금을 기준으로 산정되는 정액보상 방식을 취하여 신속한 구제를 도모한다. 반면 민법은 일일이익, 향후 치료비, 위자료 등을 포함하여 실제 발생한 손해 전체를 배상하는 실손배상 방식을 취한다.

**2. 보상과 배상의 조정 (병존적 관계)**

**(1) 보상에 의한 면책**

- 재해보상을 한 사용자는 동일한 사유에 대하여 민법에 따른 손해배상 책임이 면제된다. 다만 이는 보상한 금액의 한도 내에서만 면제되는 것이므로, 민법상 손해배상액이 근로기준법상 재해보상액을 초과하는 경우에는 그 차액에 대하여 여전히 손해배상 의무를 진다.

**(2) 손해배상 우선 시의 공제**

- 근로자가 민법에 따라 손해배상을 먼저 받은 경우 사용자는 그 가액의 한도 내에서 근로기준법에 따른 보상 책임을 면한다. 이는 동일한 재해에 대한 이중 보상을 방지하기 위함이다.

**III. 근로기준법상 재해보상과 산재보험법의 관계**

**1. 제도의 취지와 책임의 전환**

**(1) 사회보험화에 따른 책임 면제**

- 산재보험법은 사용자의 재해보상 책임을 사회보험 체계로 흡수한 것이다. 이에 따라 산재보험 가입 사업장에서 업무상 재해가 발생하여 근로자가 산재보험법에 따른 보험급여를 받는 경우, 사용자는 근로기준법상 재해보상 책임이 면제된다.

**(2) 보상 수준의 일치와 상회**

- 산재보험법상의 보험급여는 근로기준법상 재해보상 항목을 대부분 포함하고 있으며, 실제 보상 수준은 근로기준법보다 유리하게 설정되어 있는 경우가 많다. 따라서 산재보험 처리는 사실상 사용자의 근로기준법상 의무를 완전히 대체하게 된다.

**2. 직접 보상의 예외적 존속**

**(1) 산재보험 미가입 및 적용 제외**

- 산재보험법이 적용되지 않는 사업장이거나 보험 가입 절차를 마치지 않은 상태에서 재해가 발생한 경우, 근로자는 사용자에게 직접 근로기준법상 재해보상을 청구할 수 있다.

**(2) 보험급여 외의 항목**

- 산재보험법에서 정하지 않은 특수한 보상 항목이 근로기준법이나 단체협약 등에 명시되어 있는 경우, 근로자는 차액이나 추가 항목에 대하여 사용자에게 직접 청구할 수 있다.

**IV. 세 제도 간의 상호 조정 원리**

**1. 이중 보상의 금지**

- 동일한 사유로 근로기준법상의 보상, 산재보험법상의 급여, 민법상의 배상이 중복되는 경우 근로자는 실제 손해액을 초과하여 이중으로 이득을 취할 수 없다. 이는 부당이득 금지의 원칙 및 손익상계의 원리에 기초한다.

**2. 과실상계의 적용 여부**

**(1) 재해보상에서의 부인**

- 근로기준법 및 산재보험법상 보상은 근로자의 과실이 있더라도 원칙적으로 감액하지 않는다. 다만 근로자의 중대한 과실로 인한 재해 시 노동위원회 등의 인정을 받아 일부 면제될 수 있을 뿐이다.

**(2) 민법상 배상에서의 적용**

- 민법상 손해배상 청구 시에는 근로자의 과실 비율만큼 배상액이 감액되는 과실상계가 엄격히 적용된다. 따라서 전체 손해액에서 과실상계를 거친 금액이 이미 수령한 재해보상액보다 적다면 추가적인 배상을 받을 수 없다.

**V. 결론**

- 근로기준법상 재해보상은 근로자의 생존권을 보호하기 위한 최저한의 무과실책임 보상 제도이다. 민법과는 보상액 범위 내에서 상호 면책되는 보완적 관계에 있으며, 산재보험법과는 책임의 사회보험화를 통해 산재보험급여가 근로기준법상 보상을 전적으로 대체하는 관계에 있다. 결론적으로 근로자는 재해 발생 시 산재보험법을 통해 신속한 정액 보상을 받고, 만약 실제 손해액이 이에 미달하는 부분이 있다면 사용자의 과실을 입증하여 민법상 손해배상을 청구하는 구조를 취하게 된다. 사용자는 산재보험 가입을 통해 민사상 배상 책임의 상당 부분을 경감받을 수 있으므로, 세 제도의 유기적인 이해는 노사 양측의 법적 안정성을 확보하는 데 필수적이다.

<제04장 근로시간.제02절 근로시간의 보호>

[기출][1][2008-2-2]근로기준법상 연장근로 제한의 원칙, 예외, 위반의 효과

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음2) 근로기준법상 연장근로의 제한(제53조) (25점)》

<문제2의 물음2> 근로기준법상 연장근로 제한의 원칙, 예외, 위반의 효과

**I. 문제의 제기**

- 연장근로란 법정 근로시간인 1일 8시간, 1주 40시간을 초과하여 근로하는 것을 의미하며, 근로자의 건강권을 보호하고 실근로시간을 단축하기 위해 법률로 엄격히 제한하고 있다. 이에 따라 이하에서는 근로기준법 제53조에서 규정하고 있는 연장근로의 제한에 관하여 당사자 간 합의의 원칙, 1주 12시간의 한도, 특별한 사정 발생 시의 예외적 연장근로 등의 법리적 내용을 중심으로 상세히 분석한다.

**II. 연장근로의 일반적 제한 원칙**

**1. 당사자 간 합의의 원칙**

**(1) 합의의 주체와 방법**

- 연장근로는 당사자 사이의 합의가 있어야 성립한다. 여기서 당사자란 개별 근로자와 사용자를 의미한다. 판례는 개별 근로자의 동의를 원칙으로 하되, 단체협약이나 취업규칙에 연장근로의 근거가 있고 그에 따라 개별 근로자의 포괄적 동의가 있는 경우에도 합의가 있는 것으로 본다.

**(2) 합의의 유효성**

- 연장근로에 대한 합의는 사전에 이루어져야 하며, 사용자가 일방적으로 연장근로를 명령할 수는 없다. 다만, 근로계약 체결 시 연장근로를 하기로 명시적으로 약정하였다면 특별한 사정이 없는 한 개별적인 연장근로 명령에 따를 의무가 발생한다.

**2. 연장근로의 시간 한도**

**(1) 1주 12시간의 제한**

- 근로기준법 제53조 제1항에 따라 당사자 사이의 합의가 있더라도 1주간에 12시간을 초과하여 연장근로를 할 수 없다. 따라서 1주 최대 근로시간은 법정 근로시간 40시간과 연장근로 12시간을 더한 52시간이 된다.

**(2) 1일 연장근로의 제한 여부**

- 현행법상 성인 근로자의 경우 1일 연장근로의 상한에 대해서는 직접적인 규정이 없다. 다만, 1주 12시간 한도 내에서 운용되어야 하며, 근로자에게 11시간 이상의 연속 휴식 시간을 부여해야 하는 탄력적 근로시간제 등 특수한 상황에서는 간접적인 제한을 받게 된다.

**III. 특별한 사정에 따른 연장근로의 예외**

**1. 인가 등에 의한 연장근로(특별연장근로)**

**(1) 사유 및 절차**

- 사용자는 특별한 사정이 있어 고용노동부 장관의 인가와 근로자의 동의를 얻으면 제53조 제1항의 한도를 초과하여 연장근로를 할 수 있다. 특별한 사정이란 재해나 사고의 수습, 인명 구조, 갑작스러운 설비 고장 등 긴급한 조치가 필요한 경우를 의미한다.

**(2) 사후 승인**

- 사태가 급박하여 고용노동부 장관의 인가를 받을 시간이 없는 경우에는 지체 없이 사후에 승인을 받아야 한다. 만약 장관이 해당 연장근로가 부적당하다고 판단하면 그에 해당하는 휴게시간이나 휴일을 줄 것을 명할 수 있다.

**2. 근로시간 및 휴게시간의 특례**

**(1) 특례 업종의 지정**

- 운송업, 보건업 등 공익상 필요하거나 업무의 특성상 근로시간의 엄격한 준수가 어려운 특정 업종에 대해서는 사용자가 근로자대표와 서면 합의를 한 경우 1주 12시간을 초과하여 연장근로를 시킬 수 있다.

**(2) 적용 요건**

- 이 경우에도 근로자에게 퇴근 후 다음 출근 시까지 연속하여 11시간 이상의 휴식 시간을 주어야 한다. 이는 무제한적인 연장근로로부터 근로자의 최소한의 건강권을 보호하기 위한 장치이다.

**IV. 연장근로 제한 위반의 효과**

**1. 형사처벌 및 행정적 제재**

- 사용자가 당사자 간 합의 없이 연장근로를 시키거나, 1주 12시간의 한도를 위반한 경우에는 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처해진다. 이는 강행규정으로서 노사 간에 합의가 있었다 하더라도 법정 한도인 12시간을 초과했다면 처벌을 면할 수 없다.

**2. 연장근로수당의 지급 의무**

- 연장근로가 제한 시간을 위반하여 이루어진 경우라 하더라도, 이미 제공된 근로에 대해서 사용자는 근로기준법 제56조에 따른 연장근로 가산수당(통상임금의 50% 이상)을 지급해야 한다. 법 위반 여부와 근로의 대가 지급 의무는 별개의 사안으로 취급된다.

**V. 결론**

- 근로기준법상 연장근로의 제한은 근로자의 생존권과 건강권을 보호하기 위한 필수적인 안전장치이다. 원칙적으로 당사자 간의 자유로운 합의에 기초해야 하며, 합의가 있더라도 1주 12시간이라는 절대적 한도를 준수해야 한다. 사안과 같이 특별한 경영상 장애나 긴급한 사정이 있는 경우에는 예외적으로 고용노동부 장관의 인가를 얻어 연장근로가 가능하나, 이 역시 근로자의 동의와 사후적인 건강 보호 조치가 병행되어야 한다. 결론적으로 사용자는 연장근로를 운용함에 있어 단순히 경영상의 효율성만을 고려할 것이 아니라, 법이 정한 합의 요건과 시간적 한도를 엄격히 준수해야 한다. 이를 위반할 경우 형사적 책임은 물론 민사상 가산수당 지급 의무가 발생하므로, 노사 양측은 법정 근로시간 체계 내에서 유연하면서도 적법한 근로시간 관리를 도모해야 할 것이다.

<제08장 근로관계의 종료.제03절 해고의 절차적 정당성>

[기출][1][2009-1]해고의 예고와 해고의 서면 통지에 대한 의의, 내용, 예외, 법적 효과

《【문제1】 근로기준법상 해고절차의 제한 가운데 해고의 예고 및 해고의 서면통지에 관하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 해고의 예고와 해고의 서면 통지에 대한 의의, 내용, 예외, 법적 효과

I. 문제 제기

- 근로기준법은 정당한 이유 없는 해고를 금지하는 실체적 제한(근로기준법 제23조) 외에도 해고의 시기, 방법, 절차 등에 관한 절차적 제한을 규정하여 근로자를 보호한다. 이러한 절차적 제한 중 핵심은 사용자가 근로자를 해고할 때 최소한의 예고 기간을 부여하여 근로자의 생계를 보호하고(근로기준법 제26조), 해고의 사유와 시기를 서면으로 명확히 통지하여 근로자의 방어권과 다툼 기회를 보장하는(근로기준법 제27조) 제도이다. 이하에서는 근로기준법상 해고 절차의 주요 제한인 해고의 예고 및 해고의 서면 통지 제도에 관하여 그 의의, 내용, 예외, 법적 효과를 중심으로 논한다.

II. 해고의 예고 [근로기준법 제26조]

1. 해고 예고 제도의 의의 및 취지

- 근로기준법 제26조는 사용자가 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고를 하거나, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 해고예고수당으로 지급하여야 한다고 규정한다. 그 취지는 근로자가 갑작스러운 해고로 인해 받게 될 경제적 어려움에서 벗어나 새로운 직장을 구할 수 있는 시간적·경제적 여유를 부여함으로써 근로자의 생활 안정을 도모하는 데 있다.

2. 해고 예고의 방법 및 내용

- 해고 예고 자체는 반드시 서면으로 할 것을 요구하는 강행규정은 아니다. 구두, 서면 등 그 방법을 불문하며, 해고일이 명확하게 명시되어 통보되었다면 유효하다. 다만, 해고의 서면 통지(근로기준법 제27조) 규정의 취지와 실무적 관행을 고려할 때, 예고 역시 서면으로 하는 것이 바람직하다. 예고의 내용에는 해고의 의사와 실제 해고가 이루어지는 날짜(30일 이후)가 명확하게 포함되어야 한다.

3. 해고 예고 의무의 예외

- 근로기준법 제26조 단서 및 근로기준법 시행규칙 제4조는 해고 예고 의무가 적용되지 않는 예외적인 경우를 규정하고 있다. 이러한 예외 사유가 인정되는 경우 사용자는 30일분의 통상임금을 지급하지 않고 즉시 해고할 수 있다.

(1) 근로자의 계속 근로 기간이 짧은 경우

- 계속 근로 기간이 3개월 미만인 근로자에게는 해고 예고 의무가 적용되지 않는다. 이는 고용 초기 단계에서는 고용 관계의 안정성이 낮고, 해고 예고를 통한 보호 필요성이 상대적으로 낮다는 점을 고려한 것이다.

(2) 천재·사변, 그 밖의 부득이한 사유로 사업이 불가능한 경우

- 천재지변 등 사업주에게 책임이 없는 불가항력적인 사유로 인하여 사업의 계속이 불가능하게 된 경우를 말한다. 다만, 사업 계속이 불가능한지 여부는 사용자의 노력에도 불구하고 객관적으로 사업장 전체의 존립이 위태로울 정도에 이르렀는지 여부를 엄격히 판단해야 한다.

(3) 근로자가 고의로 사업상·재산상 손해를 끼친 경우

- 근로자의 중대한 귀책사유가 있는 경우 해고 예고 의무가 면제된다. 구체적인 사유는 근로기준법 시행규칙 별표에 열거되어 있으며, 해고 예고의 면제는 노동위원회의 승인을 얻어야 한다.

① 시행규칙상의 사유

- 근로기준법 시행규칙 제4조 별표1에는 불량품 수령으로 생산 차질 야기, 영업용 차량 대리운전, 사업 기밀 유출, 허위 사실 날조, 공금 착복·횡령·배임, 제품·원재료 절도 및 불법 반출, 근로자 근무 실적 조작, 사업장 기물 파손, 기타 사업 지장 및 재산상 손해 초래 등 9가지 사유가 열거되어 있다.

② 판단 기준

- 법원 및 행정해석은 근로자의 행위가 고의 또는 이에 준할 정도의 중대한 과실로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼쳤는지 여부를 구체적이고 엄격하게 심사해야 한다고 본다.

4. 해고 예고 수당

(1) 수당의 성격

- 해고 예고 수당은 해고 예고 기간(30일)을 두지 않고 즉시 해고하는 경우, 근로자의 생활 보장과 전직 기회 제공을 위해 지급되는 법정 손해배상금 내지 전직 활동 지원금의 성격을 가진다. 이는 근로의 대가인 임금인 아니므로, 임금채권보장법상의 대지급금 지급 대상에 포함되지 않는다.

(2) 위반의 효과

- 사용자가 해고 예고를 하지 않고 해고예고수당도 지급하지 않은 경우에도, 해고예고수당을 지급할 때까지 해고의 효력이 발생하지 않는 것은 아니다. 즉, 해고 자체의 유효성은 근로기준법 제26조의 위반 여부와 관계없이 실체적인 정당성(근로기준법 제23조)에 따라 결정된다. 다만, 해고 예고 의무를 위반하고 수당을 지급하지 않은 사용자는 근로기준법 제110조에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해지는 벌칙의 대상이 된다.

III. 해고의 서면 통지 [근로기준법 제27조]

1. 해고 서면 통지 제도의 의의 및 취지

- 근로기준법 제27조는 해고는 서면으로 그 사유와 시기를 통지하여야 효력이 있다고 규정하는 강행규정이자, 해고의 유효 요건 중 하나인 절차적 요건이다.

(1) 해고의 존재 명확화

- 해고 통지의 방법과 시기를 명확히 함으로써 해고의 존부를 둘러싼 분쟁을 예방하고, 사용자의 자의적인 해고를 억제한다.

(2) 해고의 사유 명확화

- 서면 통지를 통해 사용자가 근로자에게 해고 사유를 객관적으로 명시하도록 강제하여, 향후 해고 정당성 여부에 대한 다툼의 범위를 한정하고 심리를 용이하게 한다.

(3) 근로자의 방어권 보장

- 근로자에게 해고 사유를 정확하게 알려줌으로써 근로자가 구제 절차를 진행할지에 대한 판단과, 구제 절차 시 방어 준비를 효율적으로 할 수 있도록 방어권을 보장하는 데 가장 큰 취지가 있다.

2. 서면 통지의 방법 및 내용

## (1) 통지의 방법

### ① 서면 통지의 강제

- 근로기준법 제27조는 해고 통지는 서면으로 하여야 한다고 명시하고 있으므로, 구두나 문자 메시지, 이메일 등 비서면 방식의 통지는 원칙적으로 무효이다. 서면은 종이 문서를 의미한다.

### ② 전자 문서의 허용 가능성

- 대법원 판례는 근로자가 해고 통지의 내용을 확인할 수 있고, 그 서면을 보존할 수 있는 등 종이 문서에 의한 통지와 동등하게 근로자의 방어권 보장에 지장이 없는 경우라면, 전자 문서(전자우편, 문자 메시지)에 의한 통지도 근로기준법 제27조의 서면 통지로 볼 수 있다는 가능성을 인정하고 있다. 다만, 근로자에게 해고 통지가 정확하게 전달 및 수신되었는지와 근로자가 이를 출력 또는 보존할 수 있는지에 대한 엄격한 확인이 필요하다.

## (2) 통지의 내용

### ① 해고 사유의 구체성

- 통지된 서면에는 해고의 정당성을 뒷받침할 수 있는 구체적인 사실과 해고의 징계 사유가 명확하게 기재되어야 한다. 단순히 취업규칙의 해당 조항이나 징계 사유를 나열하는 것에 그치지 않고, 근로자가 어떠한 행위를 하였기 때문에 해고되는지를 충분히 알 수 있도록 구체적인 비위 사실을 적시해야 한다.

### ② 해고 시기의 명확성

- 해고의 효력이 발생하는 날짜를 명확하게 기재해야 한다. 해고 시기가 불분명하거나 통보일로부터 30일 이내에 해고일이 지정되지 않은 경우에는 해고의 효력이 불분명해져 법적 분쟁의 소지가 발생한다.

## 3. 서면 통지 의무 위반의 효과 (판례 법리)

### (1) 절차적 무효

- 근로기준법 제27조 제2항은 해고는 서면으로 통지하여야 효력이 있다고 규정하므로, 서면 통지 의무를 위반한 해고는 절차적 정당성을 결여하여 해고 전체가 무효가 된다. 해고 사유의 실체적 정당성이 인정되더라도, 서면 통지 절차를 거치지 않은 이상 해고는 그 효력을 가질 수 없다.

### (2) 서면 통지 후의 효력

- 해고 통지가 서면으로 이루어지지 않아 무효인 경우, 사용자가 추후 해고의 효력 발생 시점을 명시하여 다시 서면으로 통지하면, 그때부터 새로운 해고 통지로서 효력을 발생할 수 있다. 이때 새로운 서면 통지는 징계 해고의 경우 징계 사유의 시효 등을 준수해야 한다.

## IV. 해고 예고와 해고 서면 통지 규정의 관계

### 1. 제도의 목적 및 성격

#### (1) 해고 예고 [제26조]

- 근로자의 경제적·시간적 여유를 부여하여 이직을 준비하고 생활 안정을 도모하는 경제적 보호 제도의 성격이 강하다.

#### (2) 해고 서면 통지 [제27조]

- 해고의 존재 및 사유를 명확히 하여 근로자의 방어권을 보장하고 분쟁을 예방하는 절차적 정당성 확보 제도의 성격이 강하다.

### 2. 적용의 관계

#### (1) 별개의 절차 요건

- 근로기준법 제26조와 제27조는 해고의 효력을 위한 별개의 절차적 요건이다. 즉, 해고 예고를 충실히 하였다고 하더라도 해고 사유와 시기를 서면으로 통지하지 않았다면 그 해고는 무효이다. 반대로 서면 통지를 완벽하게 하였더라도 30일의 예고 기간을 두지 않았거나 예고 수당을 지급하지 않았다면 그 해고의 효력이 부정되는 것은 아니나 사용자는 벌칙의 대상이 된다.

#### (2) 해고 예고 수당 지급과 서면 통지

- 사용자가 해고 예고 기간(30일)을 준수하지 않고 즉시 해고하면서 해고 예고 수당을 지급하였다 하더라도, 해고 사유와 시기를 서면으로 통지하는 의무(근로기준법 제27조)는 면제되지 않는다. 해고 예고 수당의 지급은 해고 예고 의무 위반에 대한 대체적 이행일 뿐, 서면 통지 의무의 면제 사유가 될 수 없다.

#### (3) 검토

- 두 규정은 목적과 법적 효과가 다르므로, 사용자는 해고 시 해고 예고와 해고 서면 통지라는 두 가지 절차적 의무를 모두 충족해야 한다.

## V. 결론

- 근로기준법상 해고 절차의 제한인 해고 예고(근로기준법 제26조)와 해고 서면 통지(근로기준법 제27조)는 근로자의 생활 안정을 도모하고 방어권을 보장하는 중요한 절차적 장치이다. 특히, 해고의 서면 통지는 해고의 효력 요건으로서 그 위반 시 해고가 무효가 되는 중대한 절차적 하자를 구성하므로, 사용자는 해고 시 그 사유와 시기를 명확하게 기재한 서면을 근로자에게 교부해야 할 의무를 엄격히 준수해야 한다. 이러한 절차적 제한의 준수는 해고의 정당성을 확보하는 데 필수적인 전제 조건이 된다.

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음1) 근로기준법상 위약 예정의 금지(제20조) (25점)》

<문제2의 물음1> 근로기준법상 위약예정의 금지의 의의, 내용, 효력 및 법률관계

**I. 근로기준법상 위약 예정 금지의 의의**

- 근로계약은 사용자와 근로자가 대등한 당사자로서 체결되는 것이 원칙이나, 현실의 노사관계는 경제력과 교섭력에서 현저한 불균형이 존재한다. 이러한 상황에서 사용자가 근로자에게 불리한 조건을 부과하는 경우 근로자의 자유의사와 권익이 침해될 우려가 크다. 이에 따라 근로기준법 제20조는 사용자는 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다고 규정하여, 사용자가 일방적으로 근로자에게 불리한 약정을 강제하는 것을 원칙적으로 금지하고 있다. 이는 근로자의 퇴직의 자유와 직업선택의 자유를 보장하고, 근로자에 대한 부당한 경제적 예측을 방지하는 사회적 보호규정으로서 강행규정의 성격을 가진다.

**II. 규제의 내용**

**1. 위약금 예정 금지**

- 위약금 예정이란 계약 위반이 있을 경우 위반자가 상대방에게 일정 금액을 지급하기로 약정하는 금전적 제재를 의미한다. 근로계약에서 근로자가 일정 기간 근무하지 않거나 조기 퇴직할 경우 사용자가 미리 정한 금액을 위약금으로 징수하는 형태가 이에 해당한다. 근로기준법 제20조는 이러한 약정을 전면적으로 금지하여, 근로자가 경제적 불이익의 두려움 때문에 퇴직의 자유를 제한받지 않도록 하고 있다.

**2. 손해배상액 예정 금지**

- 손해배상액 예정이란 계약 불이행 시 발생할 손해와 무관하게 미리 일정액을 손해배상으로 정하는 것을 말한다. 근로관계에서 근로자가 계약기간을 채우지 않고 중도 퇴직할 경우 실제 손해와 관계없이 일정 금액을 손해배상으로 지급하도록 한 약정이 대표적이다. 이러한 손해배상액 예정도 근로자의 퇴직을 심각하게 제약하므로, 근로기준법은 이를 금지하고 있다.

**III. 위반 시 효력 및 법률관계**

**1. 규정의 효력**

- 근로기준법 제20조는 강행규정이므로, 위반하는 약정은 전부 무효가 된다. 따라서 사용자가 근로계약서 등에 위약금이나 손해배상액 예정 조항을 삽입하더라도 법적 효력이 발생하지 않는다.

**2. 실제 손해배상 청구의 가능성**

- 근로자가 중도퇴직으로 인해 사용자가 현실적으로 손해를 입었다면, 이는 민법상 일반 불법행위나 채무불이행에 따라 실제 발생한 손해의 범위 내에서 배상청구가 가능하다. 그러나 사용자가 입증하지 못한 추상적, 예상적 손해에 대한 청구는 허용되지 않는다. 결국 제20조는 손해배상액의 사전 예정을 금지할 뿐, 현실적 손해에 대한 배상청구 자체를 배제하는 것은 아니다.

**IV. 유사 조항과의 구별**

**1. 강제 근로 금지(제7조)**

- 근로기준법 제7조는 폭행, 협박, 감금 등으로 근로자의 자유의사를 억압하여 근로를 강요하는 행위를 금지한다. 제20조가 경제적 예측을 통한 간접적 강제를 금지하는 규정이라면, 제7조는 물리적 강제를 금지하는 규정이라는 점에서 차이가 있다.

**2. 근로자의 비위행위에 대한 위약벌**

- 근로자가 횡령, 배임 등 불법행위를 하여 손해를 입힌 경우, 이는 위약예정 금지와 무관하다. 이 경우 사용자는 실제 손해에 대한 손해배상청구가 가능하며, 근로기준법 제20조의 보호 범위는 정상적인 근로계약 불이행의 경우에 한정된다.

**3. 기술 연수 비용 상환 약정**

- 판례는 순수한 직무능력 향상을 위한 교육훈련비나 연수비용을 사용자가 부담한 경우, 근로자가 약정된 의무복무기간을 채우지 않고 퇴직할 때 그 비용의 반환을 약정하는 것은 원칙적으로 유효하다고 판시한다. 이는 위약금이나 손해배상액의 예정이 아니라, 사용자가 지출한 비용에 대한 현실적 손해의 보전으로 보기 때문이다. 다만 그 약정이 과도하여 근로자의 퇴직의 자유를 본질적으로 침해하는 경우에는 무효로 판단된다.

**V. 결론**

- 근로기준법 제20조는 근로자가 사용자와의 경제적 불균형 속에서 퇴직의 자유를 심각하게 제한받는 것을 방지하기 위한 규정으로, 위약금이나 손해배상액의 예정 약정을 전면적으로 금지하고 있다. 이는 강행규정으로서 위반 약정은 무효이며, 사용자는 실제 손해가 발생한 경우에 한하여 그 범위 내에서만 배상청구가 가능하다. 또한 제20조는 강제근로 금지, 근로자의 불법행위에 대한 손해배상 책임, 교육훈련비 상환 약정 등과 구별되어 이해될 필요가 있다. 따라서 사용자는 근로계약 체결 및 운영 과정에서 제20조의 취지를 존중하여야 하고, 근로자는 불합리한 위약금 약정에 구속되지 않는다는 점에서 노동기본권의 중요한 보호 장치로 기능한다.

《【문제2】 다음 문제를 약술하시오.

(물음2) 고용보험법상 육아휴직 급여 (25점)》

<문제2의 물음2> 고용보험법상 육아휴직 급여의 의의, 지급 요건, 지급 기간 및 금액, 특례 및 기타 사항

**I. 고용보험법상 육아휴직 급여의 의의**

- 육아휴직 제도는 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 법에서 보장하는 휴직 제도로서, 근로자의 일·가정 양립과 고용 안정을 도모하기 위한 핵심적인 가족친화 정책이다. 고용보험법상 육아휴직 급여는 이러한 육아휴직 사용기간 동안 소득이 단절되는 근로자에게 일정 금액을 지급하여 생계 안정을 도모하고, 동시에 직장 복귀를 유도하기 위한 사회보험 급여이다. 이는 출산휴가 급여와 함께 고용보험의 모성보호 급여 중 중요한 제도로 기능하며, 헌법상 모성 보호와 가족생활의 보장 이념을 구체화하는 수단으로서 그 의의가 크다.

**II. 지급 요건**

**1. 육아휴직 요건**

- 육아휴직은 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제19조에 따라 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하 자녀를 양육하기 위하여 신청할 수 있다. 근로자가 신청하면 사용자는 원칙적으로 이를 허용해야 하며, 고용보험법상 급여 지급은 이러한 법정 육아휴직 사용을 전제로 한다.

**2. 피보험 단위기간**

- 육아휴직 급여를 받기 위해서는 휴직 시작일 이전 피보험 단위기간이 180일 이상이어야 한다. 피보험 단위기간은 고용보험에 가입되어 피보험자로서 근로한 일수를 의미한다. 이는 보험 재정의 건전성과 제도의 남용 방지를 위한 최소 요건이다.

**3. 육아휴직 사용**

- 근로자가 실제로 육아휴직을 개시하여 근로를 제공하지 않는 기간이어야 한다. 다만 형식적으로 휴직 신청만 하고 실질적으로 근로를 제공하는 경우에는 급여 지급 대상이 되지 않는다.

**4. 급여 수령 요건**

- 육아휴직 개시와 동시에 사용자가 고용보험 전산망을 통해 휴직 사실을 신고하고, 근로자는 관할 고용센터에 급여를 신청하여야 한다. 신청은 보통 1개월 단위로 가능하며, 지급도 월 단위로 이루어진다.

**III. 지급 기간 및 금액**

**1. 지급 기간**

- 육아휴직 급여는 자녀 1인당 부모 각각 최대 1년의 범위 내에서 지급된다. 다만 자녀가 둘 이상인 경우 각각의 자녀별로 사용이 가능하되, 동일 자녀에 대하여 부모가 동시에 휴직을 사용할 수는 없다.

**2. 지급 금액 (고용보험법 시행령 제95조)**

**(1) 휴직 시작일로부터 3개월까지**

- 첫 3개월간은 근로자의 통상임금에 해당하는 금액을 지급하되, 상한액은 월 250만원, 하한액은 월 70만원으로 규정되어 있다. 이는 초기 육아휴직 사용을 촉진하기 위한 인센티브 성격을 가진다.

**(2) 휴직 4개월부터 6개월까지**

- 다음 3개월은 통상임금에 해당하는 금액을 지급하되, 상한액은 200만원, 하한액은 70만원으로 제한된다.

**(3) 휴직 7개월부터 종료일까지**

- 7개월 이후부터 종료 시까지는 통상임금의 80%를 지급하되, 상한액은 160만원, 하한액은 70만원이다. 이러한 단계적 체계는 초기 집중 지원과 장기 휴직에 대한 부담 완화를 동시에 고려한 제도 설계이다.

**IV. 특례 및 기타 사항**

**1. 아빠 육아휴직 보너스제**

- 같은 자녀에 대해 부모가 모두 육아휴직을 사용하는 경우, 두 번째로 사용하는 부모에게는 첫 3개월간 급여가 통상임금의 100%로 상향된다. 다만 상한액은 250만원으로 설정되어 있다. 이른바 아빠의 달 제도로서 부성 육아 참여를 확대하기 위한 특례이다.

**2. 육아기 근로시간 단축 급여**

- 육아휴직 대신 근로시간 단축을 선택한 경우에도 급여가 지급된다. 근로시간 단축 급여는 단축된 시간에 비례하여 지급되며, 육아휴직 급여와 합산하여 자녀 1인당 1년을 초과할 수 없다.

**3. 신청 절차**

- 육아휴직 개시 후 근로자는 매월 관할 고용센터에 신청서를 제출하여야 하며, 근로자의 계좌로 급여가 직접 지급된다. 신청 지연 시에는 소급 청구가 가능하나, 원칙적으로 12개월 이내에 신청해야 한다.

**4. 부당 이득의 환수**

- 육아휴직 중 근로를 제공하거나 허위로 신청한 경우, 지급된 급여는 부당 이득으로서 환수된다. 이 경우 고용보험법상 제재로 반환 명령뿐 아니라 형사처벌도 병행될 수 있다.

**V. 결론**

- 고용보험법상 육아휴직 급여는 근로자의 육아 부담을 사회가 분담함으로써 일·가정 양립을 촉진하는 제도로서, 지급 요건·기간·금액이 체계적으로 설계되어 있다. 특히 초기 3개월 집중 지원, 아빠 육아휴직 보너스제 등은 성별 균형적 육아 참여를 촉진하는 장치이다. 다만 실제 지급액이 생계 유지에 충분하지 않다는 지적과 비정규직·중소기업 근로자의 활용률이 낮은 한계가 존재한다. 따라서 향후 제도의 보완을 통해 실질적 육아휴직 사용 확대와 고용 안정 보장이 필요하다.

<제02장 근로관계의 성립.제02절 근로계약의 체결>

<제03장 임금.제04절 임금지급의 원칙>

[기출]1][2010~1]해외연수 후 의무근로기간 약정 위반 시 연수비용 반환의 적법성 및 퇴직금과 연수비용의 상계 가능성

《[문제1] 甲은 A회사에서 10년째 근로하던 중 회사의 해외연수프로그램에 응모, 선정되어 2년간 외국 대학에서 학위를 취득하고 귀국하였다. 유학중 甲은 A회사로부터 업무상 지휘·명령은 받지 아니하였으며, 다만 해외연수직원관리규정에 따라 6개월에 한 번씩 회사에 연수상황을 보고하였다. 甲은 귀국 후 A회사에 1년간 근로한 후 사직원을 제출하고 퇴직하였다. A회사의 해외연수직원관리규정은 해외연수기간 중 정상급여 및 유학중 소요되는 학교등록금, 생활비, 자녀교육비, 주택비, 왕복항공료 등의 유학비용은 A회사가 부담하고, 해외연수직원은 해외연수 후 국내 귀임시 회사 또는 관계 회사에 해외연수기간에 해당하는 2년 이상을 근무하여야 하며, 이를 위반한 때에는 정상급여를 제외한 유학비용 일체를 반환해야 한다고 규정하고 있다. 이러한 규정에 따라 A회사는 甲의 사직원을 수리하면서 甲에게 지급해야 할 퇴직금을 유학비용과 상계하고 지급하였다. 이상의 사례를 읽고 노동법상 쟁점이 되는 문제에 관하여 논하시오. (50점)》

<문제1> 해외연수 후 의무근로기간 약정 위반 시 연수비용 반환의 적법성 및 퇴직금과 연수비용의 상계 가능성

## I. 문제 제기

- 본 사안은 근로자 甲이 A회사의 해외연수프로그램을 통해 교육 훈련을 받은 후 의무 복무 기간을 채우지 않고 퇴직하자, A회사가 해외연수직원관리규정에 근거하여 퇴직금과 반환 비용을 상계한 사례이다. 쟁점으로 <유학비용 반환 약정의 근로기준법 제20조(위약 예정 금지) 위반 여부 및 퇴직금과 반환 비용 상계의 근로기준법 제43조(임금 전액 지급) 위반 여부라는 두 가지 핵심적인 노동법상 쟁점>에 대해 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점에 대해 논한다.

## II. 근로기준법상 위약 예정 금지 원칙 (제20조) 위반 여부

### 1. 위약 예정 금지 원칙

- 근로기준법 제20조는 사용자는 근로계약 불이행에 대한 위약금 또는 손해배상액을 예정하는 계약을 체결하지 못한다고 규정하고 있다. 이는 근로자가 근로계약을 불이행(예: 중도 퇴직)할 경우 재산상의 불이익을 예정하여 근로자의 퇴직의 자유를 부당하게 제한하는 것을 방지함으로써 헌법상 보장된 직업선택의 자유를 실질적으로 보호하기 위한 강행규정이다.

### 2. 유학비용 반환 약정의 성격

- <근로자가 회사로부터 교육 훈련을 받고 일정 기간 의무적으로 근로할 것을 약정(의무 복무 약정)하고, 이를 위반할 경우 그 비용을 반환하도록 하는 약정(비용 반환 약정)이 근로기준법 제20조에 위반되는지> 여부가 쟁점이 된다.

#### (1) 위약 예정 해당 여부

- 만일 이 약정이 단순히 근로자의 중도 퇴직이라는 근로계약 불이행 자체에 대한 손해배상액을 미리 정한 것이라면, 이는 제20조에 위반되어 무효이다.

#### (2) 비용 상환 약정 해당 여부

- 반면, 이 약정이 사용자가 지출한 교육 비용을 근로자에게 대여하고 의무 복무를 조건으로 그 상환 의무를 면제해 주되, 의무 복무를 불이행할 경우 다시 상환 의무를 부과하는 성격이라면, 이는 손해배상액의 예정이 아닌 채무 면제의 취소로 보아 제20조 위반의 문제가 발생하지 않는다.

### 3. 판례의 입장

- 대법원 판례는 의무 복무 및 비용 반환 약정의 유효성을 판단함에 있어 해당 비용이 순수한 교육 훈련 비용인지 아니면 근로의 대가(임금 성격)가 혼재되어 있는지를 중심으로 엄격하게 판단한다.

#### (1) 순수한 교육 훈련 비용

- 판례는 해당 비용이 근로관계의 계속을 전제로 하지 않고 근로자 개인의 업무 능력 향상이나 기술 습득을 위한 목적으로, 사용자가 전적으로 지출한 비용으로서, 그 효과가 근로자 개인에게 주로 귀속되는 교육에 소요된 비용이라면, 이는 순수한 교육 훈련 비용으로 본다. 이 경우, 해당 약정은 근로자의 자유의사에 따라 체결된 것이라면 근로기준법 제20조에 위반되지 않고 유효하다고 판단한다.

#### (2) 반환 약정의 유효성

- 순수한 교육 훈련 비용의 반환 약정이 유효하기 위해서는 다음의 요건을 충족해야 한다.

##### ① 비용의 성격

- 반환해야 할 비용이 실제 교육 또는 연수에 소요된 객관적인 비용이어야 한다.

##### ② 합리적인 의무 복무 기간

- 약정된 의무 복무 기간이 교육 훈련의 내용 및 비용 규모 등에 비추어 합리적이고 상당한 범위 내에 있어야 한다. 기간이 과도하게 길면 근로자의 퇴직의 자유를 부당하게 제한하여 제20조에 위반되어 무효가 된다.

##### ③ 비례적 반환

- 의무 복무 기간을 채우지 못할 경우 반환해야 할 금액이 남은 의무 복무 기간에 비례하여 감액되는 구조여야 한다. (즉, 기왕에 근로한 기간만큼은 반환 의무를 면제해야 함)

#### (3) 부당한 강제

- 만일 지원 비용에 근로자가 통상적으로 제공하는 근로의 대가(임금)의 성격이 포함되어 있거나, 의무 복무 기간이 불합리하여 근로자의 퇴직의 자유를 부당하게 제약하는 경우, 해당 약정은 제20조에 위반되어 전부 또는 일부가 무효로 판단된다.

### 4. 사안의 적용

#### (1) 유학의 성격

##### ① 지휘·명령 여부

- 甲은 유학 중 A회사로부터 업무상 지휘·명령을 받지 않았으며, 다만 6개월에 한 번씩 연수상황을 보고하는 정도에 그쳤다.

##### ② 목적

- 유학의 목적은 2년간 외국 대학에서 학위를 취득하는 것으로, 이는 근로자 개인의 업무 역량 향상에 주된 목적이 있다.

##### ③ 비용

- 회사가 부담한 유학 비용(학교 등록금, 생활비, 자녀 교육비, 주택비, 왕복 항공료)은 정상 급여를 제외하고 유학에 필요한 실비용이므로 순수한 교육 훈련 비용의 성격을 가진다고 볼 수 있다.

## (2) 의무 근무 기간 및 비용

### ① 의무 복무 기간

- 해외연수 기간(2년)에 해당하는 2년이다. 이는 교육 비용의 규모 및 교육 기간과 동일하므로 합리적인 범위 내의 의무 복무 기간으로 인정된다.

### ② 비례적 반환

- 甲은 2년 의무 복무 기간 중 1년만 근로하고 퇴직하였으므로, 남은 1년의 의무 복무를 위반하였다. 약정이 의무 복무 기간에 비례하여 반환액을 감액하는 방식(즉, 1년 치 비용만 반환)을 취하고 있다면 유효하며, 비례적 감액을 전제로 甲은 유학 비용의 1/2을 반환할 의무를 진다.

### (3) 검토

- A회사의 유학비용 반환 약정은 순수 교육 훈련 비용의 상환 약정으로서, 근로기준법 제20조에 위반되지 않고 유효하다. 따라서 甲은 유학 비용 일체의 1/2을 회사에 반환할 의무가 있다.

## III 퇴직금 상계의 적법성 여부

### 1. 퇴직금의 성격

- 퇴직금은 근로자퇴직급여 보장법(이하 '퇴직급여법')에 따라 근로자가 상당 기간 근로를 제공하고 퇴직하는 경우에 지급하는 것으로서, 후불적 임금의 성격과 사회보장적 기능을 동시에 가지며, 근로자 및 그 가족의 안정적인 생활을 보장하기 위한 중요한 재산이다. 따라서 퇴직금 역시 근로기준법상 임금 채권에 대한 보호 규정이 준용된다.

### 2. 상계의 제한

- 근로기준법 제43조 제1항 본문은 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다고 규정하여, 임금 전액 지급의 원칙을 명시하고 있다. 이 원칙은 사용자(A회사)가 근로자(甲)에게 퇴직금 채무를 지는 경우, 사용자의 근로자에 대한 채권(유학 비용 반환 채권)과 상계하는 것을 원칙적으로 금지한다. 이는 근로자에게 퇴직금 전액을 현금으로 수령할 수 있도록 보장하여 근로자의 생활을 보호하기 위함이다.

### 3. 예외적 상계 허용

- 대법원 판례는 임금 전액 지급의 원칙에도 불구하고, 상계가 근로자의 자유로운 의사에 기하여 이루어졌거나, 그 의사가 불이익을 주는 것이라고 인정되지 않는 경우에 한하여 예외적으로 유효성이 인정될 수 있다고 본다.

#### (1) 자유로운 의사

- 판례는 임금 채권 발생 전에 근로자와 사용자가 장래 임금을 상계하기로 합의한 경우라도, 그것이 근로자의 퇴직 시점 등 궁박한 상태에서 이루어진 합의라면 자유로운 의사에 의한 것으로 보기 어려워 무효가 될 수 있다고 본다. 반면, 퇴직 후 임금 전액을 지급받은 뒤에 근로자가 자신의 채무를 변제하기 위해 자발적으로 상계에 동의한 경우에는 자유로운 의사로 인정될 여지가 크다.

#### (2) 사전 약정의 효력

- 사안과 같이 의무복무 약정을 위반할 경우 비용을 반환하고, 이를 퇴직금과 상계할 수 있다는 사전 약정(해외연수직원관리규정)은 근로자에게 퇴직금 전액을 지급받지 못하게 하는 불이익을 야기하므로, 자유로운 의사에 의한 상계 합의로 보기 어렵다.

### 4. 사안의 적용

- A회사는 甲의 사직원을 수리하면서 甲에게 지급해야 할 퇴직금을 유학비용과 일방적으로 상계하고 지급하였다.

#### (1) 퇴직금과 유학비용 채권의 성격

- 퇴직금은 근로자의 생존권 보장을 위한 임금 채권인 반면, 유학비용 반환 채권은 회사에 대한 계약상 채무 불이행에 따른 청구 채권이다. 두 채권은 법적 성격이 상이하다.

#### (2) 상계의 위법성

- A회사가 甲의 명시적이고 자유로운 동의 없이 퇴직금을 일방적으로 상계한 행위는 근로기준법 제43조 제1항이 정한 임금 전액 지급의 원칙을 위반한 것이므로, 위법하여 무효이다.

#### (3) 검토

- A회사는 甲에게 상계된 퇴직금 전액을 다시 지급해야 할 의무가 있으며, 유학 비용 반환 채권에 대해서는 별도의 민사 소송 또는 임의 변제를 통해 해결해야 한다.

## IV 결론

- 본 사안의 노동관련법상 쟁점에 대한 검토 결과는 다음과 같다. ① 해외연수 비용 반환 약정의 유효성 : 甲이 반환해야 할 유학 비용은 순수한 교육 훈련 비용의 성격이 강하고, 의무 복무 기간(2년)도 합리적이므로, 약정은 근로기준법 제20조에 위반되지 않고 유효하다. 따라서 甲은 잔여 의무 복무 기간(1년)에 비례하여 유학 비용의 1/2에 해당하는 금액을 A회사에 반환할 의무가 있다. ② 퇴직금 상계의 적법성 : A회사가 甲의 퇴직금과 유학 비용 반환 채권을 일방적으로 상계한 행위는 근로기준법 제43조 제1항의 임금 전액 지급 원칙을 위반한 것으로서 무효이다. A회사는 상계된 퇴직금 전액을 甲에게 지급해야 할 법적 의무가 발생한다. 결론적으로, 甲은 유학 비용 반환 채무를 부담하지만, A회사는 그 채권을 이유로 甲의 퇴직금을 상계할 권리가 없으므로, 퇴직금을 전액 지급해야 하며, 유학 비용 반환은 별도로 청구해야 한다.

《【문제2】 사용자의 전적(轉籍)명령의 유효요건에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 전적명령의 법적 성격, 유효요건, 남용 판단 기준

I. 문제 제기

- 전적(轉籍)은 근로자가 종전 사용자와의 근로관계를 종료하고 새로운 사용자와 근로계약을 체결하는 인사처분으로, 인사이동의 일환인 전근이나 전보와는 달리 근로관계의 주체가 변경되는 특징을 가진다. 따라서 전적은 근로자의 권리·의무에 중대한 영향을 미치므로, 그 유효성을 판단함에 있어 보다 엄격한 요건을 필요로 한다. 이하에서는 전적명령의 법적 성격, 유효요건, 그리고 남용 여부 판단 기준을 체계적으로 설명한다.

II. 전적명령의 법적 성격

- 전적은 사용자의 인사권 행사 중 하나로 볼 수 있으나, 근로자의 고용관계가 본질적으로 변경된다는 점에서 일반적인 전보나 전근과 구별된다. 전적은 근로자의 동일성 있는 지위 승계가 아닌 새로운 근로계약 관계의 성립을 의미하므로, 근로자의 동의 없이는 일방적으로 강제될 수 없다. 따라서 전적명령은 인사명령의 성격을 가지면서도, 실질적으로는 근로계약의 해지와 신규 체결을 수반하는 법률행위적 성격을 가진다.

III. 전적명령의 유효요건

1. 개별 근로자의 동의

(1) 원칙

- 전적은 종전 사용자와의 근로계약이 종료되고, 신 사용자와 새로이 근로계약이 성립되는 것이므로, 근로자의 명시적 동의가 필요하다. 이는 근로계약의 자유 원칙과 근로자의 직업선택 자유를 보장하기 위한 필수 요건이다.

(2) 동의의 형식

- 동의는 서면이나 구두 등 형식에 제한은 없으나, 명시적이고 구체적인 동의여야 한다. 다만 단순히 인사이동 가능성을 전제로 한 포괄적 동의가 문제되는 경우가 있다.

(3) 동의의 취소

- 동의가 강압이나 기만에 의하여 이루어진 경우에는 민법상 의사표시의 하자에 따라 취소할 수 있다. 또한 근로자가 동의를 철회하더라도 사용자가 이를 존중하지 않고 전적을 강행한다면, 이는 무효로 평가된다.

2. 단체협약 또는 취업규칙의 근거(포괄적 동의)

(1) 포괄적 동의의 유효성

- 단체협약이나 취업규칙에 전적 가능성이 규정되어 있는 경우, 근로자가 이를 수락하고 근로계약을 체결하였다면 포괄적 동의가 인정될 수 있다.

(2) 포괄적 동의의 한계

- 그러나 포괄적 동의는 개별 근로자의 명시적 동의와 동일시될 수 없고, 전적의 구체적 내용이나 근로자에게 미치는 불이익의 정도에 따라 제한된다. 즉, 포괄적 동의가 있다고 하더라도 근로자가 현저한 불이익을 입는 경우에는 유효하지 않다.

IV. 전적명령권 남용 판단 기준

- 전적명령이 근로자의 동의에 기초한다고 하더라도, 사용자가 권리를 남용하는 경우에는 무효로 판단된다. 판례는 전보명령 남용 법리를 유추 적용하여 다음의 기준을 제시한다.

1. 업무상 필요성

(1) 의미

- 전적이 합리적 경영상 필요에 기초한 것인지 여부를 살핀다. 단순히 인사권 행사라는 형식적 사유만으로는 부족하다.

(2) 판단

- 기업 구조조정, 인력 재배치, 사업 효율화 등 객관적으로 인정되는 필요성이 존재해야 한다.

2. 생활상 불이익

(1) 의미

- 근로자가 전적에 따라 입게 되는 생활상의 불이익(근무환경 변화, 임금 저하, 통근·주거 여건 악화 등)을 의미한다.

(2) 판단

- 불이익이 과도하여 근로자의 생활안정에 중대한 침해를 야기하는 경우 전적은 권리남용으로 무효가 된다.

3. 근로자와의 협의 등 절차

(1) 의미

- 전적명령의 과정에서 근로자와 충분한 협의가 이루어졌는지 여부가 중요하다.

(2) 판단

- 사전 협의, 설명, 의견 수렴 등 절차가 적절히 이루어졌는지 여부는 전적명령의 정당성 판단에서 핵심 요소로 고려된다.

V. 결론

- 전적명령은 근로자의 근로관계 주체가 변경되는 중대한 인사조치로서, 유효하기 위해서는 ① 근로자의 명시적 동의 또는 단체협약·취업규칙에 따른 포괄적 동의가 존재해야 하며, ② 업무상 필요성과 합리성이 인정되고, ③ 근로자에게 과도한 불이익이 부과되지 않아야 하며, ④ 절차적 정당성이 확보되어야 한다. 따라서 근로자의 동의 없는 일방적 전적명령은 원칙적으로 무효이고, 설령 동의가 존재하더라도 사용자가 남용적으로 행사하였다면 권리남용으로서 효력이 부인된다. 이는 근로자의 직업 선택의 자유와 근로관계의 본질적 안정성을 보장하기 위한 법리라 할 것이다.

<제04장 근로시간 제03절 시간외근로>

[기출][1][2011-1]포괄임금제의 의의, 유효요건, 유효성 판단 시 고려 사항

《【문제1】 실제 근로시간 수 등에 상관없이 일정액을 시간외근로 등에 대한 법정수당으로 지급하기로 하는 내용의 임금지급계약의 유효 요건에 대한 판례법리를 논하시오. (50점)》

<문제1> 포괄임금제의 의의, 유효요건, 유효성 판단 시 고려 사항

**I. 문제 제기**

- 포괄임금제 계약은 실제 근로시간 등에 상관없이 일정액을 시간외근로 등 법정수당으로 지급하기로 하는 계약이며, 근로기준법상 근로시간 규정의 강행성 및 법정수당 지급 원칙에 대한 예외로서 그 유효성이 엄격하게 판단된다. 이하에서는 포괄임금 약정의 의의와 유형을 정리하고, 핵심적인 유효요건인 근로시간 산정의 곤란성과 근로자에게 불이익이 없는 계약 내용에 대한 판례 법리를 심층적으로 분석한다.

**II. 포괄임금제 계약의 의의 및 유형**

**1. 포괄임금제 계약의 의의**

- 포괄임금제 계약이란 근로시간 산정이 어렵거나 그 밖의 사정으로 근로시간을 산정하지 아니하기로 하는 대신, 연장·야간·휴일근로수당 등 법정수당을 비롯한 제반 수당을 기본 임금에 포함하거나, 별도 정액으로 지급하는 내용의 임금 지급 계약을 의미한다. 근로기준법은 근로시간을 엄격히 규율하고, 이에 따라 발생하는 시간외근로수당 등 법정수당을 정확히 산정하여 지급할 것을 강제하고 있으므로, 포괄임금제 계약은 이러한 강행 규정에 대한 예외로서 근로자에게 불이익이 없고 제반 사정에 비추어 정당하다고 인정되는 경우에만 제한적으로 유효성이 인정된다.

**2. 포괄임금제 계약의 유형**

- 포괄임금제는 그 수당 지급 방식에 따라 크게 두 가지 유형으로 분류할 수 있다.

**(1) 정액급형**

- 정액급형은 기본급에 각종 법정수당을 포함하여 매월 일정액을 급여로 지급하고, 기본급과 법정수당을 명확히 구분하지 않는 유형이다. 포괄임금제의 가장 전형적인 형태로, 근로시간 산정이 매우 곤란한 업종에서 주로 나타난다.

**(2) 정액수당형(고정OT)**

- 정액수당형은 기본급 외에 시간외근로수당 등을 매월 일정액으로 정하여 수당 항목으로 지급하는 방식이다. 이 유형은 실제 근로시간을 초과하는 연장근로수당이든, 실제 미달하는 연장근로수당이든 동일한 금액을 지급한다. 근로시간 산정이 비교적 가능함에도 불구하고 노무관리 편의를 위해 설정되는 경우가 많다. 이 경우에도 법정수당이 기본급에 포괄되어 지급되는 정액급형과 동일하게, 그 유효성은 엄격한 기준에 따라 판단된다.

**III. 포괄임금제 계약의 유효 요건에 대한 판례 법리**

- 대법원은 포괄임금제 계약의 유효성을 판단함에 있어 ① 근로시간 산정의 곤란성 ② 근로자에게 불이익이 없는 계약 내용이라는 두 가지 핵심 요건을 제시하고 있으며, 특히 포괄임금 약정이 근로자에게 불이익이 없는지 여부를 가장 중요한 판단 기준으로 삼고 있다.

**1. 근로시간 산정이 어려운 업무의 특성**

**(1) 의의**

- 포괄임금제는 원칙적으로 근로시간 산정이 어려운 경우에 인정되는 예외적 제도이다. 따라서 근로계약 체결 시점에 업무의 성격상 근로시간을 정확하게 산정하는 것이 실질적으로 곤란하다는 사정이 인정되어야 그 유효성이 긍정될 여지가 생긴다.

**(2) 판단 기준**

**① 근로시간 산정의 곤란성**

- 근로시간 산정의 곤란성은 단순히 회사의 노무관리 편의를 위한 것이 아니라, 업무의 특수성 또는 사업 운영의 특수성으로 인해 객관적으로 근로시간 측정이 어려운 경우를 의미한다. 판례는 영업직, 운송직, 경비직 등 사업장 밖에서의 근로 또는 감시·단속적 업무와 같이 근로자가 사용자의 지휘·감독 범위 밖에 있어 출퇴근 시간 관리나 실제 근로시간 측정이 어려운 경우, 근로시간 산정의 곤란성을 인정한다. 반대로 근로자가 사용자의 지휘·감독 아래 출퇴근 시간이 명확하게 정해져 있고, 근무 장소가 고정되어 있어 사용자의 관리 시스템 내에서 근로시간 측정이 충분히 가능함에도 불구하고, 단순히 노무관리의 편의를 위해 포괄임금제를 택하는 경우에는 근로시간 산정의 곤란성을 부정한다.

**② 근로시간 산정 가능성**

- 판례는 근로시간 산정이 기술적으로나 현실적으로 가능한 경우(예 : 출퇴근 기록, 컴퓨터 사용 기록 등을 통해 근로시간 측정이 가능한 경우)에는 원칙적으로 포괄임금 약정의 유효성을 부정한다. 이러한 경우 근로기준법의 강행규정을 회피하기 위한 탈법적인 수단으로 포괄임금제를 활용하는 것을 막기 위함이다.

**2. 근로자에게 불이익이 없는 계약 내용**

**(1) 의의**

- 포괄임금제 계약이 유효하기 위한 가장 핵심적인 요건은 그 계약 내용이 근로자에게 불이익이 없어야 한다는 것이다. 이는 근로기준법이 정한 근로조건의 최저기준을 보장하기 위한 원칙이다.

**(2) 판단 기준**

**① 합의의 존재**

- 포괄임금제 약정은 근로자와 사용자 간의 명시적 또는 묵시적 합의가 있어야 한다. 다만, 근로자에게 불이익을 초래하는 약정이므로, 합의의 존재는 엄격하게 해석되어야 한다. 판례는 근로계약서 등에 시간외근로수당을 포함한다는 내용이 명시되어 있는지, 근로자가 그 내용을 충분히 인지하고 동의했는지 등을 종합적으로 고려한다.

**② 실제 법정수당과의 비교**

- 포괄임금제 계약의 유효성을 판단하는 결정적인 기준은 약정된 임금액이 근로자가 실제로 근로한 시간에 대하여 근로기준법에 따라 산정한 법정수당에 미달하는지 여부이다. 미달 여부는 약정된 임금액이 실제 법정수당(시간외·야간·휴일근로수당)의 합계액보다 적은 경우에 그 포괄임금 약정을 근로자에게 불이익하다고 보고 무효로 판단한다. 이 경우, 사용자는 실제 근로시간을 기준으로 산정한 법정수당액과 이미 지급한 포괄임금액의 차액을 추가로 지급해야 한다. 약정된 임금액이 실제 법정수당보다 많거나 같은 경우에는 근로자에게 불이익이 없다고 보아 포괄임금 약정의 유효성이 인정될 수 있다.

**③ 명확한 구분**

- 판례는 포괄임금 계약이 유효하기 위해서는 포괄된 임금 속에 법정수당(특히 연장·야간·휴일근로수당)이 구체적으로 얼마만큼 포함되어 있는지가 명확하게 구분될 수 있어야 한다고 요구한다. 임금총액 속에 법정수당이 포괄되어 있다고 하더라도, 그 금액이 명확하게 구분되지 않아 근로자에게 법정수당이 제대로 지급되었는지 여부를 판단하기 어렵다면 포괄임금 약정의 유효성은 부정될 수 있다.

**Ⅳ. 포괄임금제 계약의 유효성 판단 시 고려 사항**

**1. 근로계약, 취업규칙, 단체협약의 내용**

- 포괄임금제 계약의 유효성은 단순히 근로계약서상의 문구에 의해서만 결정되는 것이 아니라, 취업규칙, 단체협약 및 실제 임금 지급 실태를 종합적으로 고려하여 판단된다. 단체협약이나 취업규칙에 포괄임금제에 관한 명확한 규정이 있다면, 이는 근로자와 사용자 간 합의의 근거가 될 수 있으나, 이 역시 근로기준법의 최저기준을 하회하는 경우에는 무효이다.

**2. 실제 근로시간의 증명 책임**

- 포괄임금제 계약이 무효로 판단될 경우, 사용자는 근로자에게 미지급된 법정수당을 지급할 의무를 진다. 이 경우, 실제 근로시간을 증명할 책임은 원칙적으로 근로기준법상 사용자에게 있다. 그러나 근로자가 주장하는 초과 근로시간의 실재 여부 및 그 시간이 통상적인 근로시간을 초과하는지 여부에 대해서는 근로자가 입증할 책임을 부담할 수도 있다.

**3. 유효성이 부정될 경우의 효과**

- 포괄임금제 계약이 유효하지 않은 것으로 판단될 경우, 해당 약정은 무효가 되고, 이미 지급된 포괄임금액 중 법정수당 명목으로 지급된 금액은 부당이득으로 반환될 필요 없이 기본급 등에 대한 임금으로 간주된다. 사용자는 근로자가 실제로 근로한 시간을 기준으로 근로기준법이 정한 가산율을 적용하여 산정한 법정수당액과 이미 지급된 임금총액을 비교하여 미달하는 차액을 근로자에게 추가로 지급해야 한다.

**Ⅴ. 결론**

- 실제 근로시간 수 등에 상관없이 일정액을 법정수당으로 지급하기로 하는 포괄임금제 계약은 근로기준법상 강행규정에 대한 예외로서, 대법원 판례 법리에 따라 매우 엄격한 유효 요건을 충족해야 한다. 핵심적으로 포괄임금 약정의 유효성을 위해서는 업무의 특성상 근로시간 산정이 실질적으로 곤란해야 하며, 무엇보다 포괄된 금액이 근로자가 실제로 근로한 시간에 대한 법정수당의 합산액에 미달하여 근로자에게 불이익을 주지 않아야 한다. 설령 근로자에게 불이익이 없더라도, 근로시간 산정이 객관적으로 가능한 경우에는 원칙적으로 포괄임금 약정의 유효성은 부정될 수 있다. 따라서 포괄임금제 계약의 유효성 여부를 판단함에 있어 근로계약서, 취업규칙 등 명시적 합의 내용뿐만 아니라, 업무의 실태, 근로시간 관리의 현실적 곤란성, 그리고 실제 법정수당액과의 비교 등 모든 사정을 종합적으로 검토하여 근로기준법의 최저 근로조건 보장 원칙이 훼손되지 않도록 엄정하게 판단해야 한다.

<제08장 근로관계의 종료.제03절 해고의 절차적 정당성>

<제09장 비정규근로자.제01절 기간제근로자>

<제15장 부당노동행위.제06절 부당노동행위에 대한 구제>

[기출]11[2011~2]기간제 근로자와 회사가 주장할 수 있는 해고 관련 노동법상 쟁점(해고의 절차 및 구제신청의 이익)

《[문제2] 근로자 甲은 상시근로자 10인이 근무하는 A회사와 2010년 8월 1일부터 2011년 7월 31일까지를 계약기간으로 하는 근로계약을 체결하고 근무해 왔다. 2011년 6월 30일 甲은 대표이사로부터 직장질서 문란으로 오늘자로 해고한다.라는 전화를 받았다.

甲은 2011년 7월 20일 관할 지방노동위원회에 (i) 2011년 6월 30일 자 해고가 부당함을 인정할 것, (ii) 원직복직 및 해고기간 동안의 임금상당액을 지급할 것을 내용으로 하는 부당해고 구제신청을 제기하였고, 이에 대해 관할 지방노동위원회는 2011년 8월 30일 심판회의를 개최할 예정이다.

이 사례에서 甲과 A회사가 주장할 수 있는 노동법상 모든 쟁점들을 적시하고 간략하게 설명하시오(직장질서 문란으로 인한 해고의 정당한 이유는 인정되고, 근로계약 갱신에 대한 기대가능성은 없는 것으로 전제한다). (25점)》

<문제2> 기간제 근로자와 회사가 주장할 수 있는 해고 관련 노동법상 쟁점(해고의 절차 및 구제신청의 이익)

## I. 문제의 제기

- 사안은 상시근로자 10인이 근무하는 A회사가 기간제 근로자 甲에 대해 해고 당일 전화 해고 통보를 한 상황이다. 쟁점으로 <A회사가 실시한 해고의 실체적 사유의 정당성 여부(사안은 인정)와 절차적 의무가 준수되었는지>, <절차적 의무 중 해고예고의무 위반으로 인한 해고예고수당의 청구가 가능한지>, <부당해고심판 계속 중 계약기간이 만료된 경우 구제신청의 이익이 존재하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 구체적이고 실체적인 쟁점들의 쟁점들을 판례의 태도를 바탕으로 설명한다.

## II. 해고의 서면통지 의무 위반과 실체적 사유의 경합

### 1. 근로자 甲의 주장

#### (1) 서면주의 강행규정 위반

- 근로기준법 제27조에 의하면 사용자가 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 하며, 서면으로 통지하지 않은 해고는 효력이 없다. 甲은 대표이사가 전화로 단행한 구두 해고 처분이 명백히 서면통지 의무를 위반하여 사법상 무효라고 주장할 것이다.

#### (2) 실체적 정당성 판단의 불필요성

- 절차적 요건인 서면통지 의무를 위반한 이상, 해고의 실체적 정당성 여부를 불문하고 해당 해고는 법적으로 부당해고로 귀결된다는 점을 강조할 것이다.

### 2. 사용자 A회사의 주장

#### (1) 실체적 정당성 강조

- A회사는 전화 통지를 한 경위에 직장질서 문란이라는 근로자의 중대한 귀책사유가 존재했음을 피력할 것이다. 실체적으로 해고할 만한 정당한 이유가 존재하므로 형식적 하자만을 이유로 해고 전체를 부당하다고 보는 것은 불합리하다고 주장할 여지가 있다.

#### (2) 서면주의 판단에 대한 반박

- A회사는 신속한 인사 조치의 필요성과 구두 통지를 통한 사실의 전달력에 비추어 실질적으로 해고의 사유와 시기가 근로자에게 인지되었으므로 절차적 하자가 치유되었거나 가벼운 하자에 불과하다고 항변할 수 있으나, 판례의 엄격한 서면주의 태도에 비추어 수용되기는 어렵다.

## III. 해고예고의무 위반과 예고수당 청구의 당부

### 1. 근로자 甲의 주장

#### (1) 30일 전 예고의무 위반

- 근로기준법 제26조에 따르면 사용자는 근로자를 해고하려면 적어도 30일 전에 예고를 하여야 하고, 30일 전에 예고를 하지 아니하였을 때에는 30일분 이상의 통상임금을 예고수당으로 지급하여야 한다. 甲은 계속근로기간이 11개월에 달하므로 해고예고 제외 대상이 아니며, 즉시해고를 단행한 A회사를 상대로 예고수당 지급 청구를 주장할 것이다.

#### (2) 법정 청구권의 확립

- 해고예고를 하지 않은 정황이 명백하므로, 통상임금 30일분 이상의 예고수당 지급 청구권이 당연히 성립한다는 점을 주장할 것이다.

### 2. 사용자 A회사의 주장

#### (1) 해고 효과의 무관성 주장

- A회사는 해고예고를 하지 않았거나 예고수당을 지급하지 않았더라도, 이는 근로기준법상 단속규정에 불과하여 해고 자체의 사법상 효력에는 아무런 영향이 없다고 주장할 것이다. 즉, 해고예고의무 위반이 해고를 부당해고로 만드는 사유는 아님을 지적할 것이다.

#### (2) 구제절차 내 청구의 부적절성 제기

- A회사는 해고예고수당의 지급 청구는 노동위원회의 구제명령 대상이 아니므로, 구제신청 절차 내에서 임금 상당액과 함께 예고수당을 청구하는 甲의 청구 범위는 각하되거나 기각되어야 한다고 방어할 것이다.

## IV. 기간 만료에 따른 구제신청의 이익 존부

### 1. 근로자 甲의 주장

#### (1) 임금 상당액 지급을 구하는 구제이익 존재

- 甲은 비록 2011. 7. 31.자로 계약기간이 만료되어 원직복직은 불가능하게 되었으나, 부당한 해고 기간(2011. 6. 30. ~ 2011. 7. 31.) 동안 근로를 제공했다면 받을 수 있었던 임금 상당액을 지급받을 필요가 있으므로 구제신청의 이익이 여전히 유지된다고 주장할 것이다.

#### (2) 판례 변경에 따른 권리 보호

- 대법원 전원합의체 판결에 의하여 계약기간 만료 등으로 소급 복직이 불가능한 경우에도 해고기간 중의 임금상당액 청구를 위한 구제이익이 인정되므로 노동위원회가 심리를 계속하여 인용 판정을 내려야 한다고 주장할 것이다.

### 2. 사용자 A회사의 주장

#### (1) 원직복직 불능에 따른 각하 주장

- A회사는 갱신에 대한 기대가능성이 없는 기간제 근로계약이므로 2011. 7. 31.자로 근로관계가 완전히 당연히 종료되었다는 점을 강조할 것이다. 복직 대상인 근로관계가 소멸하였으므로 행정적 구제절차인 구제신청은 대상 소멸로 각하되어야 마땅하다고 주장할 것이다.

## (2) 민사적 해결의 원칙 제시

- A회사는 이미 종료된 계약관계에 대하여 임금당상액을 청구하는 것은 사법상의 민사소송을 통해 해결할 성질의 것이며, 행정적 소급 구제 수단인 노동위원회 절차를 유지하는 것은 행정력 낭비에 해당한다고 주장할 것이다.

## V. 사안의 적용

### 1. 해고의 정당성 및 예고의무 판단

- A회사의 해고는 실제적 사유가 인정되더라도 서면통지 요건을 결여한 치명적인 절차 위반이 존재하므로 부당해고임이 명백하다. 甲의 해고예고수당 청구권은 성립하나 이는 민사 소송의 영역에 해당하므로 노동위원회 절차에서는 다루어질 수 없다.

### 2. 구제신청 이익의 귀속

- 사용자 A회사의 당연종료 및 각하 주장은 종래 판례에 부합하는 면이 있었으나, 변경된 전원합의체 판례의 법리에 의하면 근로자 甲에게 해고기간 동안의 임금 상당액 수령을 위한 구제이익이 인정된다. 따라서 구제절차는 각하되지 않으며 임금 상당액 지급 명령의 범위에서 인용되어야 한다.

## VI. 결론

- <근로자 甲>은 절차 위반에 따른 해고의 사법상 무효와 전원합의체 판례에 근거한 임금 상당액 범위 내의 구제이익 유지를 주장할 수 있으며, 이 주장은 정당하다. 반면, <사용자 A회사>는 계약 만료에 따른 복직 불능을 이유로 구제이익의 소멸(각하)과 해고예고의무 위반이 해고 효력에 영향을 미치지 않음을 주장할 수 있으나, 임금당상액 청구에 관한 구제이익을 인정하는 최근 판례의 확립된 태도에 밀려 각하 주장은 기각될 것이다. 결국 <노동위원회>는 복직 청구는 각하하되 1개월분의 임금 상당액을 지급하라는 명령을 내려야 한다.

<제03장 임금.제03절 통상임금>

[기출][1][2012-1-1]통상임금 범위를 규정한 취업규칙 조항의 효력

《【문제1】 상시 근로자 100명을 사용하는 A회사의 취업규칙 제33조제1항에는 2009년 1월 1일부터 명절휴가비로 설날과 추석에 월 기본급의 50%를 각각 지급하도록 규정되어 있고, 제33조제2항에는 명절휴가비가 통상임금의 범위에 포함되지 아니한다고 규정되어 있다. 또한 제34조에는 근로자가 1년간 개근할 경우 연말에 100만원을 지급하여 표창하도록 규정되어 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50점)》

(물음1) 통상임금의 범위를 규정한 A회사 취업규칙 제33조제2항의 효력을 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 통상임금 범위를 규정한 취업규칙 조항의 효력

I. 문제 제기

- 본 사안은 A회사의 취업규칙 제33조 제2항이 '명절휴가비는 통상임금의 범위에 포함되지 않는다'고 규정하고 있는 경우, 그 규정의 효력이 인정될 수 있는지에 관한 것이다. 이는 <통상임금의 법적 성격이 사용자와 근로자의 합의로 변경할 수 있는 사항인지>, 또는 <근로기준법상 강행규정으로서 사용자 자율의 범위를 벗어나는지> 여부가 핵심 쟁점이다. 이에 따라 먼저 통상임금의 개념과 법정성을 살핀 후, 명절휴가비가 통상임금에 해당하는지를 검토하고, 나아가 취업규칙상 통상임금 배제 규정의 효력에 대해 논한다.

II. 통상임금의 개념 및 성격

1. 통상임금의 개념

- 근로기준법 시행령 제6조는 통상임금을 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급 금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.라고 정의한다. 즉, 통상임금이 되기 위해서는 정기성·일률성·고정성의 3요건을 충족해야 하며, 이는 근로시간 외의 근로(연장·야간·휴일근로 등)에 대한 가산임금 산정의 기초가 되는 임금이다. 통상임금은 근로계약 또는 취업규칙에 의해 형성되는 개념이 아니라, 근로기준법에 의해 당연히 정해지는 법정 개념이다. 따라서 어떤 임금이 통상임금에 해당하는지는 사용자나 근로자의 명시적 합의와 무관하게 법률상 요건 충족 여부로 판단된다.

2. 통상임금의 법정성

- 대법원은 통상임금은 근로기준법이 정한 법정 개념으로서, 그 범위나 성질은 당사자의 합의나 취업규칙의 규정에 따라 임의로 정할 수 없다고 본다. 따라서 사용자가 통상임금의 범위를 축소하거나 특정 임금을 통상임금에서 제외하도록 규정하더라도, 이는 근로기준법상 강행규정을 위반하여 무효가 된다. 즉, 통상임금 여부는 임의적 약정의 대상이 아니라, 법이 강행적으로 정한 기준에 의해 판단된다.

III. 사안의 적용 - 명절휴가비의 통상임금성 판단

1. 명절휴가비의 성격

- A회사의 취업규칙에 따르면, 명절휴가비는 설날과 추석에 각각 월 기본급의 50%를 지급하도록 규정되어 있다. 이는 지급 기준이 일정하고, 특정 조건이나 성과와 무관하게 모든 근로자에게 부여되는 금품으로서 근로의 대가로 기능한다. 즉, 근로자의 근무 실적, 성과, 평가 결과 등과 무관하게 일률적으로 지급되며, 임의의 포상금이나 경조금과는 구별된다.

2. 통상임금 요건 충족 여부

(1) 정기성

- 명절휴가비는 설날과 추석이라는 일정 시점마다 계속적·반복적으로 지급된다. 지급 간격이 반기에 1회로 다소 길더라도, 매년 일정 시기에 정기적으로 지급되는 이상 정기성 요건을 충족한다.

(2) 일률성

- 취업규칙에 따르면 모든 근로자에게 동일하게 지급되며, 근속기간이나 직급에 따른 차등은 존재하더라도 지급대상 자체가 보편적이다. 따라서 일률성 요건도 충족된다.

(3) 고정성

- 명절휴가비는 지급일 이전에 근로자가 정상적으로 근무했다면, 사용자의 재량이나 평가와 무관하게 확정적으로 지급된다. 지급액 또한 월 기본급의 50%로 미리 정해져 있어, 근로자가 일정한 조건(명절 시점 재직 등)을 충족하면 사용자에게 지급의무가 발생하므로 고정성 요건 역시 인정된다.

3. 검토

- 명절휴가비는 정기성·일률성·고정성을 모두 충족하므로 근로기준법상 통상임금에 해당한다. 따라서 사용자가 임의로 이를 통상임금에서 제외하더라도, 그 법적 효력은 인정되지 않는다.

IV. 사안의 적용 - 통상임금 배제 규정의 효력

1. 취업규칙의 법정 기준 준수 의무

- 근로기준법 제96조는 취업규칙은 법령이나 해당 사업 또는 사업장에 대하여 적용되는 단체협약과 어긋나서는 아니 된다고 규정한다. 따라서 통상임금과 같이 법이 정한 강행규정을 근로자에게 불리하게 변경하는 취업규칙의 규정은 그 자체로 무효가 된다.

2. 통상임금의 법정성 위반

- A회사 취업규칙 제33조 제2항은 명절휴가비를 통상임금에서 제외한다고 규정하고 있다. 그러나 통상임금에 대한 규정은 당사자 합의로 정할 수 있는 임의규정이 아니라 근로기준법이 정한 법정 개념이므로, 사용자가 규정을 통해 그 범위를 축소하는 것은 강행규정 위반이다. 이는 근로자에게 법이 보장한 연장·야간·휴일근로수당 등의 산정기초를 축소시키는 결과를 초래하므로, 근로자 보호 원칙에도 반한다.

3. 검토

- 대법원은 통상임금에서 특정 수당을 제외한다고 명시한 취업규칙이라도, 그 수당이 실질적으로 통상임금 요건을 충족한다면 해당 규정은 효력이 없다고 본다. 따라서 A회사 취업규칙 제33조 제2항은 근로기준법상 통상임금 개념을 제한함으로써 근로자에게 불리하게 작용하므로 무효이다. 이 경우 명절휴가비는 통상임금으로 인정되어야 하며, 이에 기초하여 연장·야간·휴일근로수당 등을 재산정해야 한다.

V. 결론

- 명절휴가비는 설날과 추석에 매년 정기적·일률적으로 지급되고, 지급액이 사전에 확정되어 있으므로 근로기준법상 통상임금의 요건인 정기성·일률성·고정성을 모두 충족한다. 따라서 A회사가 취업규칙을 통해 명절휴가비는 통상임금에 포함되지 아니한다고 정한 것은 근로기준법상 강행규정에 위

배되어 효력이 없다. 결국 명절휴가비는 통상임금에 포함되어야 하며, 이를 제외한 임금 산정은 부당하다. 따라서 A회사 취업규칙 제33조 제2항은 무효이며, 근로자는 명절휴가비를 포함한 통상임금을 기준으로 각종 수당을 청구할 수 있다.

<제03장 임금.제03절 통상임금>

[기출][1][2012-1-2]부당해고기간 중 지급받지 못한 개근 표창의 청구 가능성

《[문제1] 상시 근로자 100명을 사용하는 A회사의 취업규칙 제33조제1항에는 2009년 1월 1일부터 명절휴가비로 설날과 추석에 월 기본급의 50%를 각각 지급하도록 규정되어 있고, 제33조제2항에는 명절휴가비가 통상임금의 범위에 포함되지 아니한다고 규정되어 있다. 또한 제34조에는 근로자가 1년간 개근할 경우 연말에 100만원을 지급하여 표창하도록 규정되어 있다. 이와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사의 근로자 甲은 부당해고로 인하여 2011년 1월 1일부터 1년간 근로를 제공할 수 없었다. 甲이 부당해고기간 중 지급받지 못한 취업규칙 제34조에 따른 표창의 지급을 구할 수 있는지 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 부당해고기간 중 지급받지 못한 개근 표창의 청구 가능성

I. 문제의 제기

- 본 사안의 쟁점은 <사용자의 귀책사유(부당해고)로 근로를 제공하지 못한 기간을 개근한 것으로 간주할 수 있는지>, 그리고 <해당 표창 금품이 부당해고 기간 중 사용자가 지급해야 할 임금의 범위에 포함되는지> 여부이다. 이하에서는 부당해고로 인하여 근로를 제공하지 못한 근로자 甲이 취업규칙 제34조에 규정된 개근 표창(연말 100만 원 지급)을 청구할 수 있는지에 대해 논한다.

II. 개근 요건과 표창 금품의 성격

1. 개근 여부 판단의 원칙

(1) 판례의 태도

- 사용자의 부당한 해고로 인하여 근로자가 출근하지 못한 기간은 사용자의 귀책사유로 인한 것이므로, 이를 근로자의 결근으로 처리할 수 없다. 판례는 부당해고 기간을 출근한 것으로 간주하거나, 적어도 결근으로 보아 근로자에게 불이익을 주어서는 안 된다는 입장을 견지하고 있다.

(2) 연차유급휴가와와의 비교

- 연차유급휴가 산정 시에도 부당해고 기간은 근로자가 출근한 것으로 간주하여 출근율을 계산한다. 이는 사용자의 불법행위로 인해 근로자가 권리를 상실하는 것을 방지하기 위함이다.

2. 표창 금품의 성격 및 지급 조건 분석

(1) 임금성 여부

- 취업규칙에 지급 근거가 명시되어 있고, 조건(개근)을 충족할 경우 확정적으로 지급되는 금품이라면 이는 명칭 여하를 불문하고 근로의 대가인 임금에 해당한다. 비록 출근율이나 개근을 조건으로 하는 금품은 고정적이고 확정적인 임금이 아니라는 이유로 통상임금 산정 범위에서 제외되는 경우라 할지라도 임금성을 부인할 수는 없다.

(2) 개근 조건의 성취 간주

- 근로자가 1년간 개근하지 못한 유일한 원인이 사용자의 부당해고에 있다면, 근로자는 신의칙상 또는 민법상 법리에 따라 해당 조건을 성취한 것으로 주장할 수 있다. 즉, 해고가 없었더라면 甲은 개근하여 해당 표창을 받았을 것이라는 인과관계가 인정되어야 한다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 근로 제공 불능 원인 분석

- 甲은 2011년 1월 1일부터 1년간 근로를 제공하지 못하였으나, 이는 부당해고로 인한 것이다. 사용자의 위법한 행위로 인해 甲은 자신의 근로 의사를 실현할 수 없었으며, 이는 명백히 사용자 A회사의 귀책사유에 해당한다.

2. 취업규칙 제34조의 요건 검토

- A회사의 취업규칙 제34조는 1년간 개근을 지급 조건으로 정하고 있다. 甲이 실제로는 출근하지 않았으나, 이는 사용자의 거부로 인한 것이므로 해당 기간은 결근으로 처리될 수 없다. 법리적으로 甲은 해고가 없었을 경우를 상정하여 개근한 것으로 평가받을 수 있다.

3. 표창 금품의 지급 의무

- 해당 표창은 연말에 100만 원 지급이 규정되어 있어 지급 의무가 확정적인 임금의 성격을 가진다. 甲이 해고되지 않고 계속 근무하였더라면 1년간 개근하여 100만 원을 지급받았을 것이라는 점이 합리적으로 추론되므로, A회사는 해고 기간 중의 임금으로서 이를 지급할 의무가 있다.

IV. 결론

- 사용자의 부당해고로 인하여 근로자가 근로를 제공하지 못한 경우, 근로자는 계속 근무하였더라면 받을 수 있었던 임금을 청구할 수 있다. 취업규칙상 개근을 조건으로 지급되는 표창 금품의 경우에도, 개근하지 못한 원인이 사용자의 부당해고에 있다면 근로자는 출근한 것으로 간주되거나 결근으로 인한 불이익을 받지 않아야 한다. 따라서 甲은 A회사를 상대로 부당해고 기간인 1년에 대한 표창 금품 100만 원의 지급을 청구할 수 있다.

<관련판례>

- 92다39860 : 해고처분이 무효인 경우의 임금청구 가능성

- 93다11463 : 청구가능한 임금의 범위 → 평균임금 산정 기초가 되는 모든 임금이면 충분, 통상임금으로 국한되지는 않음 ★

<보충 - 표창 지급 청구 불가능>

I. 문제 제기

- A회사는 취업규칙 제34조에 따라 1년간 개근한 근로자에게 연말에 100만원의 표창금을 지급하도록 규정한다. 쟁점은 <사용자의 귀책사유(부당해고)로 근로를 제공하지 못한 기간을 개근한 것으로 간주할 수 있는지>, 그리고 <해당 표창 금품이 부당해고 기간 중 사용자가 지급해야 할 임금 상당액의 범위에 포함되는지> 여부이다. 이하에서는 부당해고로 인하여 1년간 근로를 제공하지 못한 근로자 甲이 복직 후 그 표창금의 지급을 청구할 수 있는지에 대해 논한다.

II. 부당해고 기간 중 임금 지급의 법리

1. 원직 복직 및 임금 상당액 지급

- 근로자가 부당해고를 당한 경우, 해고는 무효이므로 근로계약관계는 소급하여 계속된 것으로 본다. 이에 따라 사용자는 근로자를 원직에 복직시켜야 하며, 근로자는 해고 기간 중 비록 근로를 제공하지 못했더라도 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액을 청구할 수 있다. 이때 지급의

법적 성격은 손해배상적 성질이 아닌 임금 지급 의무의 존속에 따른 임금 상당액의 청구권이다.

## 2. 임금 상당액의 범위

- 부당해고 기간 중 임금 상당액의 범위는 근로자가 정상적으로 근로를 제공하였다면 통상 지급받았을 임금 전부를 포함한다. 즉, 기본급뿐만 아니라 정기적·일률적으로 지급되는 각종 수당(정근수당, 명절수당, 상여금 등)도 포함된다. 그러나 전제가 되는 요건이 근로를 제공하였더라면 당연히 받을 수 있었던 것이어야 하며, 근로자의 출근율, 성과, 평가 등의 불확정적 요소에 따라 달라지는 조건부 지급금품은 포함되지 않는다. 따라서 부당해고 기간 중 지급되지 않은 금품이 임금 상당액에 포함되기 위해서는, 그것이 근로자의 근무실적이나 출근성적과 무관하게 지급되는 성질을 가져야 한다.

## III. 개근 표창의 성격 판단

### 1. 개근 표창의 의의

- 취업규칙 제34조의 규정은 근로자가 1년간 개근할 경우 연말에 100만원을 지급하여 표창한다고 되어 있다. 이는 근로자가 일정 기간 동안 결근 없이 성실히 근무한 사실을 장려·보상하기 위한 성취형 금품으로서, 통상적 근로의 대가라기보다는 근태에 대한 포상적 성격을 가진다. 따라서 지급 여부는 근로자의 출근일수라는 조건 충족에 달려 있으며, 이는 일반적인 근로의 제공만으로는 확정되지 않는다.

### 2. 개근 요건의 충족 여부

- 개근 표창은 명문상 1년간 개근이라는 명시적 조건이 부가되어 있다. 여기서 개근은 해당 기간 동안 1일의 결근도 없이 출근한 경우를 의미하며, 정당한 사유로 인한 근로제공 불이행(예: 병가, 육아휴직, 징계정직 등)도 원칙적으로 개근으로 보지 않는다. 따라서 부당해고로 인해 근로를 제공하지 못한 기간이 존재한다면, 형식적으로는 1년간의 개근 요건을 충족하지 못하게 된다.

## IV. 사안의 적용

### 1. 개근 요건 불충족

- 근로자 甲은 2011년 1월 1일부터 1년간 부당해고 상태에 있었으므로, 그 기간 동안 근로제공이 이루어지지 않았다. 설사 부당해고가 사용자 책임에 기인한 불법행위라 하더라도, 실질적으로 출근 사실이 존재하지 않음은 부정할 수 없다. 따라서 형식적으로 볼 때 甲은 1년간 개근한 근로자의 요건을 충족하지 못한다.

### 2. 부당해고기간의 임금 상당액 포함 여부

- 부당해고기간에 대한 임금 상당액에는, 甲이 근로를 제공하였다면 당연히 지급되었을 기본급 및 정기적·일률적 수당이 포함되나, 개근 표창금처럼 근로자의 근태성적에 따라 지급 여부가 달라지는 조건부·포상적 금품은 포함되지 않는다는 것이 판례의 입장이다. 즉, 부당해고가 없었더라도 근로자가 1년간 계속 근무했을 경우에만 지급되는 성질의 금품은, 해고가 존재함으로써 사실상 그 조건이 충족되지 않았으므로 임금 상당액에 포함되지 않는다.

### 3. 사용자의 책임과 근로자의 보호 한계

- 부당해고는 사용자에게 귀책사유가 있으므로, 근로자의 보호 필요성이 인정된다. 그러나 개근표창은 성실한 출근 및 근태에 대한 성과형 금품으로서, 이는 단순한 임금이 아닌 조건 충족 시 지급되는 포상이다. 임금 상당액의 범위는 근로의 제공만으로 확정적으로 발생하는 임금에 한정되므로, 조건부 성격의 개근표창을 포함시키는 것은 법리적으로 인정되지 않는다. 따라서 甲이 부당해고로 인해 실질적으로 근무하지 않은 이상, 그 기간을 포함하여 1년간 개근의 요건을 충족했다고 볼 수 없으며, 표창금은 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액으로 평가될 수 없다.

## V. 결론

- 부당해고는 무효이므로 근로관계는 계속되나, 부당해고기간 동안 실제 근로가 이루어지지 않은 이상 개근 요건은 충족되지 않는다. 또한 임금 상당액은 근로자가 정상적으로 근로를 제공하였다면 당연히 지급되었을 금품에 한정되며, 근태성과에 따라 지급 여부가 결정되는 개근 표창금은 이에 포함되지 않는다. 따라서 근로자 甲은 부당해고 기간 중 지급받지 못한 표창금의 지급을 청구할 수 없으며, A회사 취업규칙 제34조에 따른 개근 표창금 지급청구는 인정되지 않는다.

## <보충 - 표창 지급 청구 불가능(ChatGPT)>

### I. 문제의 제기

- 부당해고로 인하여 1년간 근로를 제공하지 못한 근로자 甲이 취업규칙 제34조에 따른 연말 표창금 100만원의 지급을 청구할 수 있는지가 문제된다. 이는 부당해고기간 중 임금 상당액의 범위와, 개근을 지급요건으로 하는 금품의 법적 성질 및 지급요건 충족 여부가 쟁점이 된다.

## II. 임금 상당액 및 개근 여부

### 1. 부당해고기간 중 임금 상당액의 범위

- 근로기준법에 따라 해고가 무효인 경우 근로관계는 계속 존속하므로, 사용자는 근로자를 복직시키고 해고기간 중 정상적으로 근로를 제공하였다면 받을 수 있었던 임금 상당액을 지급하여야 한다. 판례는 이를 민법상 채무불이행에 따른 손해배상으로 보면서도, 실질적으로는 근로계약이 유효하게 존속함을 전제로 한 임금청구권으로 본다. 다만 지급범위는 근로자가 실제로 근로를 제공하였다면 취득하였을 임금으로 한정된다. 즉 고정적·정기적 임금은 포함되나, 일정 요건 충족을 전제로 한 금품은 그 요건 충족 여부에 따라 판단한다.

### 2. 개근요건이 있는 금품의 법적 성질

- 취업규칙 제34조는 1년간 개근할 경우 연말에 100만원을 지급하여 표창하도록 규정한다. 이는 근속 중 성실근무를 장려하기 위한 성격의 금품으로, 단순한 고정상여금과 달리 1년간 개근이라는 요건을 충족하여야 비로소 지급청구권이 발생한다. 판례는 개근수당이나 근태와 연동된 상여금에 대하여, 지급요건을 충족하지 못한 경우에는 부당해고기간이라 하더라도 당연히 지급하여야 하는 것은 아니라고 본다. 특히 근로제공이 전혀 이루어지지 않은 경우에는 개근이라는 요건이 충족될 수 없다.

### 3. 부당해고기간과 개근요건의 관계

- 부당해고가 무효라 하더라도 현실적으로 근로제공이 없었던 이상, 개근요건은 형식적으로 충족되지 않는다. 다만 사용자의 위법행위로 근로제공이 불가능해진 경우, 이를 이유로 불이익을 주는 것이 신의칙에 반하는지 문제가 될 수 있다. 그러나 판례는 부당해고기간을 실제 근로제공과 동일하게 의제하지는 않는다. 즉, 해고기간 중 임금은 지급되지만, 근로실적이나 근태를 요건으로 하는 금품까지 당연히 인정되는 것은 아니다. 개근은 현실적인 출근과 근로제공을 전제로 하는 개념이기 때문이다.

## III. 사안의 적용

- 甲은 2011년 1월 1일부터 1년간 전혀 근로를 제공하지 못하였다. 이는 사용자의 부당해고로 인한 것이나, 취업규칙 제34조는 1년간 개근을 지급요건으로 명시하고 있다. 甲은 해당 연도에 현실적으로 출근하여 근로를 제공하지 않았으므로 개근요건을 충족하지 못하였다. 표창금은 매월 고정적으로 발생하는 임금과 달리, 일정 근태요건을 충족하여야 비로소 발생하는 조건부 급부이다. 따라서 부당해고기간 중 통상적인 임금 상당액은 청구할 수 있으나, 개근이라는 요건을 충족하지 못한 이상 표창금에 대한 권리는 발생하지 않는다.

#### **IV. 결론**

- 부당해고로 인하여 1년간 근로를 제공하지 못한 경우라 하더라도, 1년간 개근을 지급요건으로 하는 취업규칙 제34조의 표창금은 그 요건을 충족하지 못하므로 지급청구권이 발생하지 않는다. 따라서 甲은 부당해고기간 중 표창금 100만원의 지급을 구할 수 없다.

《【문제2】 근로기준법상 중간착취의 배제에 관하여 설명하시오. (25점)》

<문제2> 중간착취의 배제 원칙의 의의, 요건, 중요성

**I. 중간착취 배제 원칙의 의의**

**1. 법령**

- 근로기준법 제9조는 누구든지 법률에 따르지 아니하고는 영리로 다른 사람의 취업에 개입하거나 중간인으로서 이익을 취득하지 못한다고 규정하고 있다.

**2. 취지 및 목적**

- 중간착취의 배제 원칙은 근로자가 자신의 노동력 제공에 대한 대가를 제3자에게 착취당하지 않고 정당한 임금 전액을 확보할 수 있도록 하기 위한 것이다. 과거 근로자가 중간 알선인이나 중개업자에게 취업 대가로 수수료를 지급하거나, 사용자가 임금 일부를 가로채는 행위가 빈번하였던 사회적 배경에서, 이러한 불공정한 구조를 근절하고 근로자의 인격적·경제적 독립을 보장하려는 데 그 입법 목적이 있다.

**3. 위반 시 효과**

- 동 조항은 강행규정이므로, 이를 위반한 중간착취 행위는 무효이며, 근로기준법 제107조에 따라 관련자에게는 형사처벌이 부과된다. 따라서 법률상 허용된 직업소개사업 등 합법적 근로중개 이외의 모든 형태의 영리적 취업개입이나 임금 갈취는 금지된다.

**II. 중간착취 배제 요건**

**1. 「누구든지」의 의미**

- 누구든지란 사용자, 근로자, 제3자 등 모든 자를 의미하며, 특정한 자격을 불문한다. 따라서 개인, 법인, 단체 등 모든 주체가 본 조항의 적용 대상이 되며, 중간착취 행위의 주체가 근로자 자신이거나 사용자 내부의 인사담당자라 하더라도 원칙적으로 규제 대상에 포함된다.

**2. 「법률에 따르지 아니하고는」의 의미**

- 법률에 따르지 아니하고는은 직업안정법 등 관계 법령에서 허용된 경우를 제외하고는 영리로 다른 사람의 취업에 개입하거나 중간착취를 할 수 없다는 의미이다. 즉, 국가의 인가를 받은 공인 직업소개소, 파견사업 등 법령상 근거가 있는 경우에는 예외적으로 허용되지만, 이를 벗어난 무허가 중개행위나 비공식적 알선 수수행위는 모두 위법으로 본다.

**3. 「영리로」의 의미**

- 영리란 단순한 호의적 소개나 비영리적 알선이 아닌, 경제적 이익을 얻으려는 목적으로 하는 것을 말한다. 따라서 취업 알선이나 근로자 공급을 통해 금전적 대가를 받거나, 임금의 일부를 편취하는 행위는 모두 영리 목적의 중간착취로 평가된다. 반면 친족 간의 무상 소개, 공익적 취업지원센터의 활동 등은 영리 목적이 없으므로 본 조항의 금지대상에 포함되지 않는다.

**4. 「다른 사람의 취업에 개입」의 의미**

- 다른 사람의 취업에 개입은 제3자가 근로자의 사용자에 대한 고용계약 체결 과정에 관여하는 행위를 의미한다. 즉, 근로자와 사용자 간의 계약이 직접 체결되는 것을 방해하거나, 자신이 중개자로 개입하여 그 대가를 취하는 행위가 이에 해당한다. 다만, 단순히 구직정보를 제공하거나 직업상담을 하는 정도의 비영리적 행위는 취업 개입으로 보지 않는다.

**5. 「중간인으로서 이익을 취득」의 의미**

- 중간인으로서의 이익을 취득은 근로자와 사용자 사이에 개입하여 경제적 이익을 얻는 일체의 행위를 말한다. 그 형태는 다양하며, 대표적인 유형은 ① 취업 소개·알선 대가 수수 ② 임금의 일부 갈취 ③ 노무도급의 위장 등이 있다.

**III. 중간착취 배제 원칙의 중요성**

**1. 근로자의 인격 보호 및 노동력 착취 방지**

- 근로자는 임금 외에는 생계수단이 없는 경제적 약자이므로, 중간착취 금지 규정은 근로자의 인격적·경제적 독립을 보장하고 노동력 매매의 대상을 방지하는 기능을 가진다. 이를 통해 근로자는 노동력 제공의 대가를 온전히 보장받고, 불법 중개인이나 착취자에 대한 종속을 예방할 수 있다.

**2. 임금 전액 지급 원칙의 실현**

- 근로기준법 제9조는 제43조(임금 지급)와 결합하여, 근로자가 노동의 대가를 전액 직접 수령하도록 보장한다. 중간착취 금지 규정이 없으면, 근로자가 받는 실질임금이 감소하고 사용자의 임금지급 의무도 형해화될 위험이 있으므로, 본 조항은 임금보호제도의 근간을 이룬다.

**3. 근로관계의 투명성 및 안정성 확보**

- 근로계약은 사용자와 근로자 간의 직접적이고, 명확한 관계를 전제로 한다. 중간착취를 배제함으로써 근로관계의 구조가 명확해지고, 근로자의 권리·의무 관계가 투명하게 규율된다. 이는 불법 파견, 위장도급 등 근로형태의 왜곡을 방지하고, 근로감독행정의 실효성을 높이는 데에도 기여한다.

**IV. 결론**

- 근로기준법 제9조의 중간착취 배제 원칙은 근로자의 인격적 존엄과 경제적 이익을 보호하기 위한 근로관계의 기본규범으로서, 모든 형태의 영리적 취업개입 및 임금갈취를 금지하고 있다. 이는 단순한 알선행위의 규제가 아니라, 임금 전액 지급 원칙 및 근로계약의 직접성 원리를 실현하기 위한 핵심 장치로서 기능한다. 따라서 법률이 허용한 경우를 제외하고 제3자가 근로자의 취업에 개입하여 이익을 취득하는 행위는 무효이며, 형사상 제재의 대상이 되는 물론 근로자에게 손해가 발생한 경우 민사상 불법행위책임도 부담하게 된다. 결국 중간착취의 배제 원칙은 근로관계의 정의와 신뢰를 유지하기 위한 근본적 보호장치로서 기능한다.

<제05장 취업규칙.제02절 취업규칙의 변경>

[기출][1][2013-1-1]노사협의회의 의결을 거친 인사규정(취업규칙) 변경의 효력

《[문제1] 상시 근로자 5,000명을 사용하는 A회사에 근무하는 직원들의 직급체계는 사원, 대리, 과장, 차장, 부장이다. 그런데 과장 또는 차장으로 근무하는 직원들의 인사적체가 심화되자 그 해결책으로, A회사는 2010. 1. 31. 노사협의회의 의결을 거쳐 인사규정의 일부를 다음과 같이 변경하였다.

「중전 인사규정」

제5조(정년)

회사에 근무하는 모든 직원은 만60세가 만료되는 날자에 퇴직한다.

「변경된 인사규정」

제5조

제1항(정년) 회사에 근무하는 모든 직원은 만60세가 만료되는 날자에 퇴직한다.

제2항(직급정년) 제1항에도 불구하고 2012. 1. 1.부터 과장에서 부장까지 직급정년을 시행한다. 과장에서 차장 또는 차장에서 부장으로 7년간 승진하지 못한 직원은 그 기간이 만료되는 시점에 퇴직한다.

근로자 甲은 2006. 1. 1.부터 차장으로 근무하여 왔는데 A회사가 2012년 12월 발표한 부장승진 인사에서 탈락하였다. 그 후 A회사는 인사규정 제5조 제2항에 의해 근로자 甲에게 직급정년의 도달(2012. 12. 31.)로 퇴직을 서면으로 통보하고 퇴직에 따른 금품청산을 완료하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사가 변경한 인사규정의 법적 효력을 논하시오. (30점)

<문제1의 물음1> 노사협의회의 의결을 거친 인사규정(취업규칙) 변경의 효력

I. 문제 제기

- 근로기준법 제94조 제1항은 사용자가 취업규칙을 근로자에게 불이익하게 변경하려면 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있으면 그 노동조합, 그렇지 아니하면 근로자의 과반수의 동의를 받아야 한다고 규정한다. 본 사안에서 A회사는 인사적체 해소를 이유로 인사규정을 개정하여 일정 직급(과장~부장)에게 직급정년을 신설하였다. 이에 따라 승진하지 못한 근로자는 정년에 이르지 않았더라도 자동퇴직되도록 규정하였다. 따라서 문제의 핵심은 <A회사의 인사규정 변경이 근로기준법상 불이익변경에 해당하는지, 그 동의절차가 적법하게 이루어졌는지> 여부이다. 이하에서는 이러한 인사규정의 효력에 대해 논한다.

II. 취업규칙의 불이익 변경과 동의[근로기준법 제94조]

1. 취업규칙의 불이익 변경

- 취업규칙은 근로조건을 최소화하는 기준으로서, 사용자는 일방적으로 근로자에게 불리한 방향으로 이를 변경할 수 없다. 대법원은 취업규칙의 변경으로 근로자에게 불이익이 발생하는 경우, 근로자에게 효력이 미치지 않는다고 본다. 불이익 여부는 형식이 아니라 근로자의 근로조건 전체를 종합적으로 비교하여 판단한다. 즉, 일부 조건이 향상되더라도 근로자의 지위·생활에 중대한 불이익이 있으면 불이익변경으로 본다.

2. 동의의 주체 및 방식

(1) 노동조합이 있는 경우

- 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 존재할 때에는 그 노동조합의 동의가 필요하며, 단순한 협의나 통보만으로는 부족하다. 판례는 근로자의 과반수로 조직된 노동조합의 명시적·적극적 동의가 있어야 한다고 본다.

(2) 노동조합이 없는 경우

- 과반수 노동조합이 없을 때에는 근로자 과반수의 명시적 동의를 얻어야 하며, 근로자대표의 일방적 의견 표명으로는 충분하지 않다. 즉, 개별적 서면동의나 전체 근로자 총회의 의결 등 집단적 동의절차가 필요하다.

(3) 동의의 의미

- 근로자의 동의는 진정한 의사에 기초한 자유로운 의사표시이어야 하며, 단순한 노사협의회의 협의·의결만으로는 동의로 볼 수 없다. 노사협의회의는 근로자의 복지·고충 등 협의기구로서 법적으로 동의권을 가진 기관이 아니기 때문이다.

III. 사안의 적용

1. 불이익 변경 여부

- A회사의 인사규정 개정은 기존의 일반 정년(만 60세)보다 앞서 근로관계를 종료시키는 직급정년제를 도입한 것이다. 이는 근로자의 생계·고용안정에 중대한 영향을 미치는 불이익한 조치로 평가된다. 따라서 본 규정은 근로기준법 제94조상 불이익변경에 해당하며, 원칙적으로 근로자의 동의를 요한다. 또한 이러한 불이익은 단순히 진급기회의 제한이 아니라 조기퇴직의 강제라는 중대한 불이익이다.

2. 동의 방식의 적법성

- A회사는 인사규정 변경 시 노사협의회의 의결을 거쳤으나, 이는 근로기준법 제94조가 요구하는 근로자의 과반수 동의 절차에 해당하지 않는다. 노사협의회의는 근로자참여 및 협력증진에 관한 법률에 따른 협의기구로서, 취업규칙의 제정·변경에 대한 동의권을 부여받지 않는다. 대법원 또한 노사협의회의 합의만으로는 취업규칙 불이익변경의 유효한 동의로 볼 수 없다고 본다. 따라서 A회사가 노사협의회의 의결만을 거쳐 직급정년제를 도입한 것은, 동의주체와 방식 모두 근로기준법이 정한 요건을 충족하지 못한 것으로 평가된다. 즉, 근로자 과반수의 명시적 동의가 없었으므로, 변경된 인사규정은 효력이 없다.

3. 사안의 해석상 가정

- 설령 회사가 인사적체 해소, 조직 효율성 제고 등 합리적 목적을 주장하더라도, 대법원은 근로자에게 중대한 불이익이 발생하는 경우, 단지 경영상 필요만으로는 사회통념상 합리성이 인정되지 않는다고 본다. 직급정년제는 단순한 인사관리방안이 아니라 고용관계를 단속시키는 실질적 해고제도이므로, 근로자 측의 실질적 동의 없이 도입할 수 없다. 또한 해당 규정이 시행일을 2012.1.1.로 정하고, 7년간 승진하지 못한 자를 퇴직 처리하도록 한 점에 비추어 볼 때, 2006년부터 차장으로 근무한 甲은 시행 즉시 직급정년에 도달하는 구조가 된다. 이는 사실상 과거 근무자에게 소급 적용되어 퇴직을 강제하는 효과를 가져오므로, 불이익성이 더욱 크다. 따라서 이러한 규정은 합리적 경과조치 없이 소급 적용된 불이익변경으로서, 법적 유효성을 인정받기 어렵다.

#### **N. 결론**

- 종합하면, A회사가 인사적체 해소를 이유로 신설한 직급정년제는 근로자에게 중대한 불이익을 주는 취업규칙의 변경에 해당하며, 그 절차로서 노사 협의회의 의결만을 거친 것은 근로기준법 제94조의 동의요건을 충족하지 못한다. 또한, 본 제도는 시행 즉시 일부 근로자의 고용을 단축시키는 결과를 초래하여, 사회통념상 합리성도 인정되기 어렵다. 따라서 변경된 인사규정 제5조 제2항(직급정년제)은 근로기준법상 적법한 동의절차를 거치지 않았으므로 무효이다.

<제05장 취업규칙.제02절 취업규칙의 변경>

[기출][1][2013-1-2]노사협의회의 의결을 거친 인사규정(취업규칙)을 근거로 한 퇴직 통보의 효력

《【문제1】 상시 근로자 5,000명을 사용하는 A회사에 근무하는 직원들의 직급체계는 사원, 대리, 과장, 차장, 부장이다. 그런데 과장 또는 차장으로 근무하는 직원들의 인사적체가 심화되자 그 해결책으로, A회사는 2010. 1. 31. 노사협의회의 의결을 거쳐 인사규정의 일부를 다음과 같이 변경하였다.

「중전 인사규정」

제5조(정년)

회사에 근무하는 모든 직원은 만60세가 만료되는 날자에 퇴직한다.

「변경된 인사규정」

제5조

제1항(정년) 회사에 근무하는 모든 직원은 만60세가 만료되는 날자에 퇴직한다.

제2항(직급정년) 제1항에도 불구하고 2012. 1. 1.부터 과장에서 부장까지 직급정년을 시행한다. 과장에서 차장 또는 차장에서 부장으로 7년간 승진하지 못한 직원은 그 기간이 만료되는 시점에 퇴직한다.

근로자 甲은 2006. 1. 1.부터 차장으로 근무하여 왔는데 A회사가 2012년 12월 발표한 부장승진 인사에서 탈락하였다. 그 후 A회사는 인사규정 제5조 제2항에 의해 근로자 甲에게 직급정년의 도달(2012. 12. 31.)로 퇴직을 서면으로 통보하고 퇴직에 따른 금품청산을 완료하였다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음2) A회사가 근로자 甲에게 통보한 퇴직의 효력을 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 노사협의회의 의결을 거친 인사규정(취업규칙)을 근거로 한 퇴직 통보의 효력

I. 문제 제기

- 본 사안은 A회사가 근로자 甲에게 직급정년제 도입을 근거로 퇴직을 통보한 행위가 근로기준법상 유효한 근로관계 종료로 볼 수 있는지, 즉 직급정년 규정이 적법하게 취업규칙으로 변경되어 근로자에게 효력을 미치는지 여부가 핵심 쟁점이다. 특히, 문제의 본질은 첫째, <A회사의 인사규정 변경(직급정년 도입)이 근로자에게 불이익한 변경임에도 불구하고 근로자 과반수의 동의 없이 이루어진 경우 그 효력이 있는지>, 둘째, <무효인 취업규칙에 근거한 퇴직통보가 실질적으로 해고에 해당하는지>, 셋째, <그 해고가 정당한 이유 없이 이루어진 부당해고에 해당하는지> 여부이다. 이와 관련하여 대법원은 직급정년제의 실질적 성격을 근로관계 종료 사유로 본 바 있어, 이하에서는 이를 중심으로 퇴직의 효력에 대해 논한다.

II. 취업규칙 변경 무효 시 근로관계 종로의 효력

1. 취업규칙 변경의 무효성

- 근로기준법 제94조 제1항은 사용자가 근로자에게 불리하게 취업규칙을 변경하려면 근로자 과반수로 조직된 노동조합의 동의 또는 근로자 과반수의 동의를 받아야 한다고 규정한다. 직급정년제는 일정 직급에서 승진하지 못하면 근로관계를 종료시키는 제도로써, 종래 만60세로 보장되던 정년을 단축하는 효과를 가져오므로 근로자에게 현저히 불리한 내용이다.

2. 무효인 규정에 근거한 근로관계 종료

- 무효인 취업규칙은 법적으로 아무런 효력이 없으므로, 이에 기초한 근로관계 종료는 정년퇴직이 아니라 사용자의 일방적 의사에 의한 해고에 해당한다. 정년은 근로관계 종로의 시점을 미리 정하는 것이므로, 정년이 단축되는 것은 곧 근로계약 기간이 단축되는 것과 같은 효과를 가져온다. 따라서 무효인 직급정년에 근거한 퇴직통보는 근로계약의 기간이 만료되어 종료되는 것이 아니라, 사용자에 의한 근로관계의 일방적 종료로서 해고로 평가되어야 한다. 대법원 또한 사용자가 불이익하게 변경된 취업규칙에 근거하여 근로자를 퇴직시킨 경우, 이는 정년퇴직이 아니라 해고에 해당하며, 그 정당성이 인정되지 않으면 부당해고로 본다고 판시한다.

3. 해고의 정당한 이유 [근로기준법 제23조 제1항]

- 근로기준법 제23조 제1항은 사용자가 근로자를 해고하려면 정당한 이유가 있어야 한다고 규정한다. 여기서 정당한 이유란 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 근로자에게 책임 있는 사유가 존재하거나, 경영상 불가피성이 인정되는 경우를 의미한다.

III. 사안의 적용

1. 적용될 정년 규정

- A회사 중전 인사규정에 따르면 모든 직원의 정년은 만60세로 정해져 있었다. 직급정년 규정의 변경은 무효이므로, 甲에게 적용될 정년은 중전 규정에 따른 만60세 정년이다. 甲은 2006년 1월 1일부터 차장으로 근무해 왔으며, 2012년 12월 당시에 만60세에 도달하지 않았다. 따라서 그는 여전히 재직 중인 근로자 신분을 유지해야 했다.

2. 甲의 퇴직 사유 부존재

- A회사는 직급정년 도달을 이유로 甲에게 퇴직을 통보하였으나, 앞서 본 바와 같이 해당 규정은 무효이므로 근로관계를 종료시킬 근거가 존재하지 않는다. 또한 A회사는 인사적체 해소라는 조직관리상의 필요만을 이유로 하였을 뿐, 甲의 근로능력 부족이나 업무태만 등 개별적 사유가 없다. 따라서 甲에게 퇴직을 정당화할 수 있는 객관적 사유는 존재하지 않는다. 이에 따라 A회사의 퇴직통보는 법적 근거가 결여된 사용자의 일방적 근로관계 종료행위로서, 부당해고에 해당한다.

3. 해고 통보의 무효성

- 취업규칙 변경이 무효이고, 그에 기초한 근로관계 종료에 정당한 이유가 없으므로 A회사의 퇴직통보는 무효이다. 따라서 甲의 근로자 지위는 계속 유지되며, 사용자는 해고기간 동안의 임금 상당액을 지급할 의무를 진다. 대법원은 직급정년제의 도입이 근로자에게 불이익함에도 근로자 동의 없이 시행된 경우, 그 규정은 무효이며, 이에 근거한 퇴직은 정년퇴직이 아니라 부당해고에 해당한다고 본다. 즉, 본 사안과 동일한 사실관계에서 대법원은 근로자 甲의 퇴직통보를 무효로 판단하고 근로자 지위를 인정하였다.

IV. 결론

- 결국 A회사가 직급정년제를 근거로 甲에게 한 퇴직통보는 근로기준법 제94조 제1항을 위반한 무효인 취업규칙에 근거한 것이며, 근로기준법 제23조 제1항의 정당한 이유 요건도 충족하지 못한다. 따라서 甲의 퇴직은 정년퇴직이 아니라 정당한 이유 없는 해고로서 무효이며, 甲은 여전히 근로자 지위를

유지한다. 이와 같은 법리는 직급정년제의 도입이 근로조건을 실질적으로 악화시키는 경우에는 반드시 근로자의 동의가 필요하며, 이를 위반한 일방적 변경은 근로관계를 종료시키는 효력을 가질 수 없다는 점을 명확히 보여준다. 결론적으로, A회사의 직급정년 규정은 무효이며, 이에 따른 甲의 퇴직통보는 부당해고로서 효력이 없다. 甲은 원직복직 및 해고기간 임금 상당액을 청구할 수 있다.

<제07장 근로관계의 이전.제01절 영업양도>

[기출][1][2013-2]영업양도 상황에서 근로관계 승계 거부 시 회사와 근로자의 법률 관계

《【문제2】 A회사는 자신이 운영하던 2개의 사업부문 중 하나를 B회사에 양도하였다. B회사에 양도된 사업부문에 소속된 근로자 甲이 B회사로의 근로관계의 승계를 거부하는 경우, A회사와 근로자 甲 사이의 법률관계를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 영업양도 상황에서 근로관계 승계 거부 시 회사와 근로자의 법률 관계

**I. 문제 제기**

- 본 사안은 A회사가 운영하던 두 개의 사업부문 중 하나를 B회사에 양도한 경우, 그 부문에 소속된 근로자 甲이 B회사로의 근로관계 승계를 거부하였을 때, 원래의 사용자 A회사와 근로자 甲 사이의 법률관계가 어떻게 되는지를 묻고 있다. 쟁점은 <사업양도가 근로관계에 미치는 효과로서 근로관계의 포괄적 승계 원칙이 적용되는지>, <근로자가 근로관계 승계를 거부할 수 있는지 및 그 법적 근거>, <근로자가 승계를 거부한 경우 원소속 사용자(A회사)와의 관계가 계속 유지되는지 혹은 근로계약이 종료되는지> 여부이다. 이하에서는 이러한 법률관계에 대해 설명한다.

**II. 사업 양도 시 근로관계의 포괄적 승계 원칙**

**1. 사업 양도의 의미**

- 근로기준법은 명문으로 사업양도에 관한 규정을 두고 있지 않으나, 판례는 사업의 동일성이 유지된 채로 일체로서 이전되는 경우를 사업양도로 본다. 즉, 단순한 자산매각이나 일부 인적 이동이 아니라 유기적 조직체로서의 사업을 포괄적으로 이전하는 경우를 말한다.

**2. 근로관계의 포괄적 승계**

- 판례는 사업양도 시 근로관계는 원칙적으로 포괄적으로 양수인에게 승계된다고 본다. 이는 개별 근로자의 동의가 없더라도 근로관계가 사업과 함께 이전된다는 의미이다. 다만, 이는 사용자의 일방적 의사에 의한 전적과 구별되며, 사업의 동일성과 조직적 일체성이 유지되는 경우에 한정된다. 그 결과, 사업양도 이전에 발생한 근로자의 근속기간, 임금, 복무규율 등 근로조건은 원칙적으로 양수인에게 포괄 승계되며, 양도인과의 근로계약은 양도 시점에서 종료된다.

**3. 승계 배제 특약의 효력**

- 사업양도 과정에서 근로자와의 근로관계는 승계하지 않는다는 특약은 근로자의 법적 지위에 영향을 미치지 못한다. 사업양도에 따라 근로자의 지위는 법률상 당연히 승계되므로, 이러한 특약은 근로자에게 불리하여 무효이다. 따라서 근로자의 의사에 의하지 않는 한, 근로관계의 승계 배제는 허용되지 않는다.

**III. 근로자의 근로관계 승계 거부권**

**1. 거부권의 인정 근거**

- 비록 근로관계가 원칙적으로 포괄 승계되더라도, 근로자는 근로계약의 당사자로서 승계를 거부할 자유를 가진다. 헌법상 직업선택의 자유 및 근로계약의 자유는 근로자가 새로운 사용자와의 근로관계 형성 여부를 결정할 권리를 포함한다. 즉, 승계는 법률상 당연승계가 원칙이지만, 근로자의 승계거부는 개별적 자유의사로 존중되어야 한다.

**2. 거부권 행사의 방식과 시기**

- 근로자는 양도계약 체결 후, 자신의 고용관계가 B회사로 승계되는 것에 대해 명시적(서면·구두) 또는 묵시적(출근 거부, 고용계약 거절 등) 방식으로 거부 의사를 표시할 수 있다. 거부의사는 양도계약의 효력이 발생하기 전후를 불문하되, 양도 시점 내지 승계 효력 발생 시점 전후 합리적 기간 내에 행사되어야 한다.

**IV. 사안의 적용**

**1. A회사와의 근로관계 존속 여부**

- 근로자가 B회사로의 승계를 거부한 경우, A회사와의 근로관계는 당연히 소멸하는 것은 아니다. 사업양도는 법률상 사용자 지위의 이전일뿐, 근로자가 이를 거부한 경우에는 근로관계가 양수인에게 이전되지 않으므로, 그 근로관계는 여전히 양도인에게 존속한다. 즉, A회사는 甲을 여전히 자사 소속 근로자로서 취급해야 하며, 고용계속의무를 부담한다. A회사는 근로계약상의 임금지급의무와 근로제공수령의무를 이행하여야 한다. 다만, 사업부문이 완전히 양도되어 甲이 종전과 동일한 업무를 수행하기 어렵게 되었다면, A회사는 다른 부서로 배치전환을 시도하는 등 근로계속을 위한 노력의무를 다행해야 한다. 이러한 조치 없이 일방적으로 근로계약 종료를 통보하는 것은 해고에 해당한다.

**2. A회사의 해고 가능성 및 정당성**

- 근로자가 승계를 거부하였다는 사정만으로 해고의 정당한 이유가 되지는 않는다. A회사가 단순히 '사업이 양도되었으므로 더 이상 고용할 수 없다'는 사정만으로 甲을 해고한다면 이는 정당한 이유 없는 해고로서 근로기준법 제23조 제1항에 위반된다. 다만, A회사가 사업의 일부를 양도함으로써 해당 부문이 폐지되어 더 이상 근로제공의 장소와 업무가 존재하지 않는 경우, 일정 요건을 충족한다면 경영상 해고(근로기준법 제24조)가 가능하다. 그러나 단순히 사업부문을 양도하였다는 사정만으로는 곧바로 긴박한 경영상 필요가 인정되지 않으며, A회사가 고용유지 노력을 다하지 않았다면 경영상 해고로서도 정당성이 부인된다. 결국 A회사가 정당한 절차와 이유 없이 고용관계를 종료하면 부당해고가 된다.

**V. 결론**

- 사업양도는 근로관계의 포괄적 승계를 원칙으로 하지만, 근로자는 계약자유 원칙상 승계를 거부할 권리를 가진다. 근로자가 그 권리를 행사한 경우, 근로관계는 양수인에게 이전되지 않으며 원사용자인 A회사와의 근로계약이 그대로 존속한다. A회사는 甲을 계속 고용할 의무를 부담하고, 이를 이유로 일방적으로 근로관계를 종료한다면 이는 정당한 이유 없는 해고로서 무효이다. 다만, 사업부문 양도로 인한 불가피한 인력 감축이 존재하고 근로기준법 제24조의 요건을 충족한 경우에 한해 예외적으로 경영상 해고가 가능하다. 결국 본 사안에서 근로자 甲이 승계를 거부하였다면, A회사는 여전히 사용자로서의 지위를 유지하며, 甲의 근로관계를 존속시켜야 한다.

<제06장 인사처분.제06절 직위해제(대기발령)>

[기출][1][2014-1-1]근무성적 불량 직원에 대한 직위해제 · 대기발령 처분의 정당성

《【문제1】 A회사(보험업)의 인사규정은 근무성적이 불량한 직원에 대해 인사위원회의 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령을 할 수 있고, 대기발령 기간에는 기본급을 지급하되 대기발령 후 3개월이 경과해도 재발령을 받지 못하였을 때에는 당연퇴직된 것으로 간주한다고 규정하고 있다. A회사는 영업팀장(과장급) 및 영업사원에 대해 기본급의 15배에 해당하는 월 거수목표액(보험계약의 체결에 따른 보험료 입금액)을 부여하고 있다. 10년 전에 입사해 서울 남부지점 영업1팀장으로 근무하고 있는 근로자 甲의 최근 3년 간 월 평균 거수실적은 거수목표액 대비 22%였다. 이러한 거수실적은 같은 기간 甲보다 직급이 낮은 A회사 전체 영업사원 평균 실적의 10%에 불과했고, 이를 이유로 甲은 경고 및 견책 각 2회, 감봉 1회의 처분을 받은 바 있다. 한편, 위 기간 동안 甲의 월 평균 급여액은 약 500만원이었다(기본급의 비중은 약 70%). A회사는 인사위원회(甲은 인사위원회에 출석해 의견을 진술함)의 의결을 거쳐 2014년 1월 10일부로 甲에 대해 직위해제 및 대기발령, 직무능력향상 교육의 이수를 명했다. 그 후 2014년 4월 10일에 개최된 인사위원회는 甲의 거수실적이 장기간 현저히 불량할 뿐만 아니라 직무능력향상교육의 결과도 하위등급이어서 향후 개선의 여지가 없기 때문에 甲에 대해 재발령을 하지 않기로 의결했다. 같은 날 A회사는 2014년 4월 11일부로 당연퇴직처리 됨을 甲에게 통지했다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲에 대한 A회사의 직위해제 · 대기발령 처분이 정당한지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 근무성적 불량 직원에 대한 직위해제 · 대기발령 처분의 정당성

I. 문제 제기

- 사안에서 근로자 甲은 최근 3년간 영업실적이 매우 저조하여 인사위원회 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령 처분을 받았고, 이후 3개월간 직무능력향상교육 후 재발령되지 않아 인사규정에 따라 당연퇴직 처리되었다. 쟁점으로 <직위해제 및 대기발령 처분의 업무상 필요성과 정당성>, <그 과정의 절차적 적법성 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 쟁점과 관련하여 甲에 대한 A회사의 직위해제 · 대기발령 처분이 정당한지 논한다.

II. 직위해제 · 대기발령의 의의 및 정당성 (판례 법리)

1. 개념

- 직위해제란 근로자가 일정 사유로 당해 직위를 유지하기 부적절하다고 인정될 때, 사용자가 직무수행을 일시적으로 배제하는 인사조치를 말한다. 대기발령은 근로자에게 새로운 직무를 부여하지 않고 일정 기간 대기상태에 두는 조치로, 통상 직위해제와 결합하여 이루어진다. 이들은 통상 징계가 아닌 인사권의 행사로서, 징계해고나 감봉과 달리 반드시 징계절차를 거칠 필요는 없으나, 업무상 필요성과 절차적 정당성이 요구된다.

2. 정당성 판단 기준

(1) 업무상 필요성 (징벌적 성격 여부)

- 직위해제나 대기발령은 징벌이 아니라 업무상 필요에 근거해야 하며, 단순히 실적 불량이나 인사상의 불만 해소를 위한 수단으로 사용되어서는 안 된다. 대법원은 직위해제나 대기발령이 사용자의 인사재량 범위를 벗어나거나 그 목적이 부당할 경우, 이는 위법하다고 본다.

(2) 직무 능력 부족 또는 근무성적 불량

- 직무수행능력이 현저히 부족하거나 근무성적이 계속적으로 불량한 경우, 회사의 조직 운영상 효율을 위해 직위해제나 대기발령이 불가피할 수 있다. 다만, 단기간의 실적 저하나 일시적 성과 부진만으로는 정당성이 인정되지 않는다. 지속적 · 현저한 부진이 입증되어야 한다.

(3) 비위 사실 조사

- 비위 행위가 있어 직위를 유지하기 어려운 경우에도 직위해제가 가능하나, 본 사안과 같이 성과 부진을 이유로 한 경우에는 비위행위가 아닌 능력 · 성과 문제가 판단 기준이 된다.

(4) 취업규칙 등 근거 규정의 존재

- 직위해제 · 대기발령은 근로자에게 급여상 불이익을 초래할 수 있으므로, 취업규칙이나 인사규정에 근거가 명시되어 있어야 한다. 명확한 근거 규정이 있고 그 요건에 해당하면, 사용자의 인사재량이 폭넓게 인정된다.

(5) 절차적 정당성

- 절차적 정당성은 인사위원회 개최, 의견 진술 기회 부여, 사전 통지 등 공정한 절차를 거쳤는지를 의미한다. 대법원은 근로자에게 의견 진술의 기회를 부여하지 않은 대기발령은 무효라고 본다.

III. 사안의 적용

1. 인사규정의 존재

- A회사의 인사규정은 '근무성적이 불량한 직원에 대해 인사위원회의 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령을 할 수 있다'고 명시하고 있으며, 대기발령 기간 중 기본급을 지급하도록 규정한다. 또한 3개월 경과 시 재발령이 없으면 당연퇴직으로 간주한다고 되어 있다. 따라서 본 사안의 직위해제 및 대기발령은 명시적 규정에 근거한 인사권 행사로 볼 수 있다.

2. 근무성적 불량의 정도

- 甲의 최근 3년간 거수실적은 목표 대비 22%에 불과하고, 전체 영업사원 평균의 10% 수준으로 극히 저조하다. 또한 과거에도 실적 부진으로 인해 경고 · 견책 · 감봉 등의 조치를 받은 점을 고려하면, 일시적 부진이 아니라 지속적이고 구조적인 성과 미달로 평가된다. 이에 따라 A회사가 조직 운영 효율을 위해 직위해제를 한 것은 업무상 필요성이 인정된다고 판단된다.

3. 업무상 필요성

- A회사는 영업성과를 주요 평가요소로 하는 보험업종으로, 영업목표 달성도는 직무 수행능력의 핵심 지표이다. 장기간 성과가 현저히 미달한 甲을 계속 팀장 직위에 두는 것은 영업조직의 사기와 효율성을 저해할 우려가 있다. 또한, 회사는 甲에게 대기발령 후 직무능력향상교육의 기회를 부여한 점에서 징계가 아닌 개선을 위한 인사조치로 볼 수 있다. 따라서 직위해제 및 대기발령은 징계적 목적이 아닌 업무상 필요에 따른 합리적 조치로 평가된다.

4. 절차적 정당성

- A회사는 인사위원회를 개최하여 甲에게 출석 및 의견진술 기회를 부여하였고, 그 결과에 따라 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령 처분을 하였다. 이는 인사규정이 정한 절차를 준수한 것으로 보이며, 절차상 하자는 존재하지 않는다. 또한 대기발령 기간 중 기본급이 지급되었고, 이후 교육결과 및 실적을 종합하여 인사위원회에서 재발령 불가 결정을 내렸으므로, 절차적 · 내용적 정당성이 모두 충족된다.

IV. 결론

- 종합하면, ① A회사는 인사규정에 근거하여 근무성적이 현저히 불량한 甲에 대해 인사위원회의 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령을 명하였다. ② 그 사유는 장기간의 실적 부진이라는 객관적 사실에 기초하며, 영업조직의 효율성 유지라는 업무상 필요성에 부합한다. ③ 절차 또한 인사규정에 따라 공정하게 진행되었고, 甲에게 의견진술의 기회를 부여하였다. 따라서 본 사안의 직위해제 및 대기발령 조치는 인사권 범위 내의 정당한 조치로서 정당하다.

《[문제1] A회사(보험업)의 인사규정은 근무성적이 불량한 직원에 대해 인사위원회의 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령을 할 수 있고, 대기발령 기간에는 기본급을 지급하되 대기발령 후 3개월이 경과해도 재발령을 받지 못하였을 때에는 당면퇴직된 것으로 간주한다.고 규정하고 있다. A회사는 영업팀장(과장급) 및 영업사원에 대해 기본급의 15배에 해당하는 월 거수목표액(보험계약의 체결에 따른 보험료 입금액)을 부여하고 있다. 10년 전에 입사해 서울 남부지점 영업1팀장으로 근무하고 있는 근로자 甲의 최근 3년 간 월 평균 거수실적은 거수목표액 대비 22%였다. 이러한 거수실적은 같은 기간 甲보다 직급이 낮은 A회사 전체 영업사원 평균 실적의 10%에 불과했고, 이를 이유로 甲은 경고 및 견책 각 2회, 감봉 1회의 처분을 받은 바 있다. 한편, 위 기간 동안 甲의 월 평균 급여액은 약 500만원이었다(기본급의 비중은 약 70%). A회사는 인사위원회(甲은 인사위원회에 출석해 의견을 진술함)의 의결을 거쳐 2014년 1월 10일부로 甲에 대해 직위해제 및 대기발령, 직무능력향상 교육의 이수를 명했다. 그 후 2014년 4월 10일에 개최된 인사위원회는 甲의 거수실적이 장기간 현저히 불량할 뿐만 아니라 직무능력향상교육의 결과도 하위등급이어서 향후 개선의 여지가 없기 때문에 甲에 대해 재발령을 하지 않기로 의결했다. 같은 날 A회사는 2014년 4월 11일부로 당면퇴직처리 됨을 甲에게 통지했다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 甲에 대한 A회사의 당면퇴직 처분이 정당한지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 직위해제 및 대기발령 이후 재발령 없이 당면퇴직된 처분의 정당성

I. 문제 제기

- 본 사안은 보험업을 영위하는 A회사가 근로자 甲에 대하여 근무성적 불량을 이유로 직위해제 및 대기발령을 한 후, 대기발령 기간 3개월이 경과하였음에도 재발령이 이루어지지 않아 인사규정에 따라 당면퇴직 처리한 사안이다. 쟁점으로 <인사규정상 당면퇴직 조항의 법적 성질과 효력>, <능력 부족을 이유로 한 해고의 정당성 요건 충족 여부>, <절차적 정당성의 확보 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 당면퇴직 처분의 정당성에 대해 논한다.

II. 당면퇴직 규정의 법적 성질 (판례 법리)

1. 개념

- 당면퇴직이란 일정한 사유가 발생하면 별도의 해고 의사표시 없이 근로관계가 자동 종료된다고 정한 제도를 의미한다. 그러나, 판례는 명칭 여하를 불문하고 근로관계를 사용자의 일방적 의사에 의해 종료시키는 경우에는 실질적으로 해고에 해당한다고 본다. 따라서 당면퇴직 간주 규정이라 하더라도, 사용자가 해고의사표시를 통보하고 그 결과 근로관계가 종료되었다면, 이는 실질적 해고로서 정당한 이유가 존재해야 한다.

2. 징계해고와의 구별 및 규정의 유효성

- 당면퇴직은 징계해고와 달리 비위행위에 대한 제재가 아니라 근무능력 부족, 자격상실, 장기결근 등 객관적 사유에 따른 비징계적 해고의 성격을 가진다. 다만, 그 사유가 모호하거나 사용자가 자의적으로 판단할 수 있도록 규정되어 있다면, 근로기준법 제23조의 정당한 이유 요건을 충족하지 못해 무효로 판단된다. 즉, 단순히 '재발령을 받지 못한 경우 당면퇴직된다'는 포괄적 규정은 자칫 사용자의 재량 남용 위험이 있어 엄격히 제한된다.

3. 능력 부족으로 인한 해고의 정당성 기준

(1) 객관적이고 합리적인 기준

- 근무성적이 일정 수준 이하로 현저히 불량하고, 그 상태가 장기간 지속되어 향후 개선이 어렵다고 인정되는 경우에는 능력부족을 이유로 한 해고의 정당성이 인정될 수 있다. 그러나 일시적 부진이나 상대평가상의 저성과만으로는 해고 사유로 삼을 수 없다.

(2) 개선 가능성 및 노력

- 판례는 근로자의 능력 부족을 이유로 해고하려면 사용자가 교육, 전환배치, 경고 등의 조치를 통해 개선의 기회를 부여했음이 인정되어야 한다고 본다.

(3) 고용 유지의 어려움

- 근로자의 성과 부족이 단순히 회사의 불만족에 그치지 않고, 계속 고용하는 것이 현저히 곤란할 정도로 업무수행이 불가능하거나 조직의 운영에 중대한 지장을 초래해야 한다.

(4) 다른 직무로의 전환 가능성 검토

- 직무능력이 특정 부문에 한정된 경우, 사용자는 가능한 범위 내에서 타부서 전환이나 보직 변경을 통한 고용유지 노력을 다해야 한다. 이를 검토하지 않고 곧바로 퇴직 처리하는 것은 사회통념상 합리성을 상실한 것으로 본다.

III. 사안의 적용

1. 형식적 요건 충족

- A회사의 인사규정에는 '근무성적이 불량한 직원에 대해 인사위원회의 의결을 거쳐 직위해제 및 대기발령을 할 수 있으며, 대기발령 후 3개월이 경과하여도 재발령을 받지 못하면 당면퇴직된 것으로 본다'고 규정되어 있다. 또한, A회사는 인사위원회를 개최하여 甲에게 출석 및 의견진술 기회를 부여하였고, 대기발령과 직무능력향상교육을 실시하였다. 따라서 형식적 절차는 규정에 부합하였다고 볼 수 있다.

2. 실질적 정당성 (해고의 정당한 이유 유무)

(1) 객관적이고 합리적인 기준 (근무성적 불량 정도)

- 甲의 최근 3년간 거수실적은 목표 대비 22%, 회사 영업사원 평균의 10% 수준으로 극히 저조하다. 이는 단순한 성과 부진을 넘어, 장기간 지속된 구조적 부진으로 볼 수 있으며, 인사위원회에서 객관적 자료에 근거하여 판단한 이상 근무성적 불량 사유는 인정된다.

(2) 개선 가능성 및 노력

- A회사는 대기발령 기간 중 甲에게 직무능력향상교육의 기회를 부여하였으나, 그 결과에서도 하위등급을 받아 향후 개선 가능성이 낮다고 평가되었다. 또한 그 이전에도 경고·견책·감봉 등 여러 차례의 징계성 조치로 개선을 촉구했음에도 성과가 개선되지 않았다. 따라서 회사가 개선 노력을 다했다고 볼 수 있다.

(3) 고용 유지의 어려움 (회사에 미치는 영향)

- 보험업은 영업성과가 곧 조직의 존립을 좌우하는 업종으로, 영업관리자로서의 실적 저하는 조직 전체 사기와 수익성에 직결된다. 이에 따라 회사가 장기간 실적 부진한 甲을 계속 고용하기 어려웠다는 사정은 충분히 인정된다.

(4) 다른 직무로의 전환 가능성

- 다만, 회사가 甲의 장기근속이나 경력, 연령 등을 고려하여 타부서 전환이나 지원직 배치 등의 대체가능성을 구체적으로 검토했는지 여부는 불분명하다. 판례는 단순히 실적이 저조하다는 이유만으로 해고에 이를 수 없으며, 다른 직무로의 전환 가능성을 검토하지 않은 경우 해고의 사회적 타당성이 결여된다고 본다. 따라서 본 사안에서도 만약 이러한 검토가 없었다면, 고용유지 노력의 불충분으로 정당성 판단에 일부 한계가 있다.

### 3. 절차적 정당성

- A회사는 인사위원회를 개최하여 甲에게 출석 및 의견 진술의 기회를 부여했고, 교육 결과 및 성과를 근거로 재발령 불가를 결정하였다. 이는 절차적으로 공정성이 확보된 것으로 평가된다. 또한 대기발령 기간 중 기본급을 지급하였고, 해고통보 역시 서면으로 이루어졌으므로 절차적 요건 위반은 없다고 판단된다.

### IV. 결론

- 사안의 당연퇴직 처분은 형식상 인사규정에 근거한 자동퇴직의 형태를 취하였으나, 실질적으로는 능력 부족을 이유로 한 해고에 해당한다. A회사는 甲의 장기간 현저한 성과 부진, 반복된 개선 기회 부여, 직무능력향상교육 이수 결과 등을 종합하여 재발령을 하지 않은 것이므로 객관적·합리적 이유는 인정된다. 절차적 요건도 대체로 준수되었다. 다만, 다른 직무로의 전환 가능성을 충분히 검토하지 않았다면 그 부분에서 일정한 한계가 존재한다. 따라서 본 사안의 당연퇴직 처분은 원칙적으로 정당한 이유가 인정되며, 사회통념상 합리성을 결여한 해고로 보기는 어렵다. 그러나 사용자가 재배치나 교육 등 고용유지 노력을 전혀 하지 않았다면 그 정당성이 부정될 여지도 있어, 구체적 사실관계에 따라 법원이 판단할 사안이라 할 것이다.

<제03장 임금.제04절 임금지급의 원칙>

[기출][1][2014~2]근로자의 임금채권과 사용자의 채권 간 상계 가능성

《【문제2】 근로자에 대하여 사용자가 가지는 채권과 근로자의 임금채권 간에 상계가 가능한지에 관한 판례법리를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 근로자의 임금채권과 사용자의 채권 간 상계 가능성

I. 문제의 제기

- 근로관계에서 근로자의 임금채권과, 손해배상채권과 같은 사용자의 채권 사이 상계 가능성은 실무상 빈번히 문제되는 사항이다. 특히, <임금은 근로자의 생계 유지와 직접적으로 관련되므로, 민법상 일반적 상계권을 그대로 적용할 수 있는지> 여부가 논란이 된다. 이하에서는 관련 판례를 중심으로 근로자의 임금채권과 사용자의 채권 간 상계 가능성에 대해 설명한다.

II. 임금 전액 지급의 원칙

1. 근로기준법상 원칙

- 근로기준법 제43조 제1항 본문은 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다고 규정한다. 또한, 근로자의 동의 없는 공제는 금지하며, 사용자의 채권을 근로자의 임금에서 일방적으로 공제하는 행위는 법적으로 제한된다. 이는 근로자가 임금의 전액을 보장받음으로써 최소한의 생활 수준을 유지하도록 보호하는 조치이다.

2. 원칙의 취지

- 임금은 단순 채권과 달리 근로자의 생활과 직결되는 특수 채권으로서, 사회적·경제적 보호가 필요하다. 따라서 임금을 상계에 사용함으로써 근로자의 생활에 직접적 위험이 초래되지 않도록 보호하는 것이 법의 입법 취지이다.

III. 상계의 원칙적 금지

1. 일방적 상계의 금지

- 대법원은 임금채권의 사회적·생활적 성격을 고려하여, 사용자가 근로자의 동의 없이 자신의 채권과 임금을 상계하는 것을 원칙적으로 금지하고 있다. 즉, 근로자의 임금채권은 생계 보호를 위해 민법상 상계권의 일반원칙에서 예외로 취급된다.

2. 위반 시 효과

- 일방적 상계가 이루어진 경우, 근로자는 공제된 금액의 반환을 청구할 수 있으며, 해당 공제는 불법행위로 평가되어 손해배상 청구의 근거가 될 수 있다.

IV. 상계의 예외적 허용 (판례 법리)

1. 근로자의 자유로운 동의에 의한 상계

(1) 원칙

- 근로자가 자발적이고 명시적인 동의를 한 경우에 한하여, 사용자가 채권과 임금을 상계할 수 있다.

(2) 동의의 엄격성

- 판례는 동의가 자유롭고 명확하며 임금 전액 지급의 권리가 훼손되지 않도록 엄격하게 해석한다.

(3) 적용 예시

- 근로자가 채권의 존재, 금액, 상계 의사 등을 충분히 인지한 상태에서 서면으로 동의한 경우 등이다.

2. 과오급된 임금의 상계 (조정적 상계)

(1) 원칙

- 사용자가 근로자에게 지급한 금액이 과오로 초과된 경우, 초과금액을 회수하는 목적의 상계는 예외적으로 허용된다.

(2) 허용 요건

- 상계 대상 금액이 객관적으로 산정 가능하고, 근로자에게 회수 사실과 방법을 명확히 통지해야 한다.

(3) 적용 예시

- 연말 정산 과정에서 실수로 초과 지급된 급여를 차후 지급액에서 공제하는 경우 등이다.

3. 퇴직금 채권과의 상계

- 퇴직금채권도 본질상 임금의 일종으로 보호된다. 다만, 판례는 사용자의 채권과 퇴직금채권 간 상계는 근로자의 동의가 있는 경우에 한해 제한적으로 허용될 수 있음을 인정한다.

4. 압류금지채권과의 상계 제한

- 근로자의 임금 중 최저생계비에 해당하는 부분은 압류금지채권으로서, 상계 대상에서 제외된다. 따라서 상계 가능 여부를 판단할 때 이러한 보호적 제한이 우선 고려된다.

V. 결론

- 임금채권은 근로자의 생활보장을 위한 특수채권으로, 사용자가 일방적으로 자신의 채권과 상계하는 것은 원칙적으로 금지된다. 다만 근로자의 명시적 동의, 과오급 임금 회수, 제한적 퇴직금 상계 등 예외적 상황에서는 상계가 허용될 수 있으며, 모든 경우에 있어 근로자의 생계권 보호와 동의의 자유가 핵심적인 판단 기준이 된다. 판례법리는 근로자의 임금보호라는 입법 취지를 실질적으로 반영하면서, 제한적 예외 상황만을 인정하는 엄격한 기준을 제시하고 있다.

<제05장 취업규칙 제02절 취업규칙의 변경>

[기출][1][2015-1-i]노동조합 동의 없이 개별 근로자의 동의로 변경한 인사규정의 효력

《[문제1] A회사의 근로자 甲이 근무하던 중 2011. 12. 6. 업무상 배임의 혐의로 구속되자, A회사는 인사규정 제33조 제3호에 따라 근로자 甲이 구속된 다음날 근로자 甲에게 휴직을 명령하였다. 이후 근로자 甲은 2012. 1. 13. 구속이 취소되어 불구속 기소 상태에서 A회사 인사규정 제34조 제1항(직원이 복직을 신청한 때에는 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 복직을 명하여야 한다)에 따라 복직을 신청하였으나, A회사는 대법원 판결 결과에 따라 복직 여부를 결정하겠다고 하면서 복직을 허락하지 않았다. 이를 위하여 A회사는 근로자 과반수로 구성된 노동조합에 동의를 요구하였으나 노동조합의 동의를 얻지 못하자 근로자들을 개별적으로 접촉하여 과반수 동의를 받아 2012. 2. 1. 인사규정을 변경하였다. 근로자 甲은 2013. 7. 8. 대법원에서 무죄판결을 선고받았다.

「중전의 인사규정 제33조 제3호」

• 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정시까지 휴직을 명령할 수 있다.

「변경된 인사규정 제33조 제3호」

• 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정 후 3개월까지 휴직을 명령할 수 있다.

근로자 甲은 (i) 2012. 2. 1. 인사규정의 변경이 효력이 없을 뿐만 아니라, (ii) 근로자 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직명령을 계속 유지한 조치는 정당성이 없는 것으로 주장한다. 이러한 근로자 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (50점)》

<문제1의 물음(i)> 노동조합 동의 없이 개별 근로자의 동의로 변경한 인사규정의 효력

I. 문제 제기

- 이 사안은 사용자가 형사사건으로 구속 또는 기소된 근로자에 대하여 휴직 명령을 할 수 있는 기간을 ‘판결확정시까지’에서 ‘판결확정 후 3개월까지’로 연장하는 내용으로 인사규정을 노동조합의 동의 없이 개별 근로자의 동의로 변경한 사안이다. 근로자 甲은 변경된 규정에 따라 복직이 지연되어 불이익을 받았으며, 이러한 「인사규정 변경이 적법하게 효력을 가지는지」 여부가 문제된다. 따라서 본 사안은 취업규칙의 불이익 변경과 근로자 동意的 적법성을 중심으로 검토할 필요가 있다. 이하에서는 근로자 甲의 주장이 타당한지 논한다.

II. 취업규칙 변경의 효력

1. 취업규칙의 불이익 변경

- 근로기준법 제94조 제1항은 사용자가 취업규칙을 작성하거나 변경할 때에는 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 동의를 얻어야 한다고 규정하고 있다. 다만, 근로자에게 불이익하게 변경되는 경우에는 반드시 동의를 필요하며, 근로조건이 개선되거나 단순한 형식 변경에 불과한 경우에는 의견 청취만으로 족하다. 불이익 변경이란, 변경된 취업규칙이 기존의 근로조건보다 근로자에게 실질적으로 불리하게 작용하는 경우를 말하며, 그 불이익의 정도는 객관적·합리적으로 판단해야 한다.

2. 동의의 주체 및 방식

(1) 노동조합이 있는 경우

- 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합의 동의를 얻어야 하며, 개별 근로자들의 동의는 법적 효력이 없다.

(2) 노동조합이 없는 경우

- 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 없는 경우에는 근로자 과반수의 동의를 받아야 한다. 이때 근로자 과반수란 전체 근로자의 과반수를 의미하며, 일부 근로자 집단의 임의적 서면 동의로는 부족하다.

(3) 동의의 의미

- 동의는 단순한 형식적 절차가 아니라, 변경의 내용과 불이익의 정도를 충분히 설명받은 후 자유로운 의사에 따라 이루어진 실질적 동의이어야 한다.

3. 불이익 변경 판단

- 판례에 따르면, 불이익 변경 여부는 취업규칙의 개정 목적, 변경 전후의 내용, 근로자에게 미치는 영향, 보완조치 등을 종합적으로 고려한다. 휴직기간을 연장하거나 복직 시기를 지연시키는 규정은 근로자의 근로 제공권과 임금 수취권을 제한하므로 명백한 불이익 변경에 해당한다.

III. 사안의 적용

1. 불이익 변경 여부

- 중전 규정은 ‘형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정시까지 휴직을 명할 수 있다’고 하였으나, 변경된 규정은 ‘판결확정 후 3개월까지로 기간을 연장하였다.’ 이는 근로자가 무죄 확정 후 즉시 복직하지 못하게 되어 근로 제공 및 임금 청구가 지연되는 결과를 초래하므로 근로자에게 명백히 불이익하다. 따라서 본 사안의 인사규정 변경은 불이익 변경에 해당한다.

2. 동의 방식의 위법성

- A회사는 변경 당시 근로자 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 얻지 못하자, 개별 근로자들을 접촉하여 근로자 과반수의 동의를 얻어 규정을 변경하였다. 그러나 근로기준법 제94조 제1항에 따르면, 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 존재하는 경우에는 반드시 그 노동조합의 동의를 받아야 하며, 개별 근로자의 동의로 이를 갈음할 수 없다. 즉, 노동조합이 존재함에도 불구하고 사용자와 개별 근로자 간의 동의 절차로 불이익 변경을 한 것은 법정 절차를 위반한 위법한 변경으로서 무효이다. 또한, A회사가 근로자들을 개별적으로 접촉하여 동의를 얻은 행위는 근로자들의 자율적 의사 형성을 침해하였을 가능성이 높아 실질적 동의 요건도 충족하지 못한다. 결국, 본 사안에서의 인사규정 변경은 형식적·실질적 요건 모두 위반된 불이익 변경으로 평가된다.

IV. 결론

- 본 사안의 인사규정 변경은 다음과 같은 이유로 효력이 없다. 첫째, 휴직기간 연장은 근로자의 근로권과 임금권을 제한하는 불이익 변경에 해당한다. 둘째, 근로기준법 제94조에 따라 근로자 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 필수적이나, 사용자는 이를 거치지 않고 개별 근로자의 동의를 받아 절차상 하자가 존재한다. 셋째, 개별 동의는 실질적 자유의사에 기초한 것으로 보기 어렵고, 근로조건의 불이익을 상쇄할 보완조치도 없었다. 따라서 2012. 2. 1. 변경된 인사규정은 효력이 없으며, 甲은 중전 규정에 따른 권리를 주장할 수 있다. 결국 A회사의 복직 거부는 정당한 근거 없이 이루어진 것으로서, 甲은 불이익 변경의 효력 부인과 함께 원상회복을 청구할 수 있을 것이다.

<제06장 인사처분.제04절 휴직>

[기출][1][2015-1-ii]노동조합 동의 없이 개별 근로자의 동의로 변경한 인사규정을 근거로 한 휴직 명령 유지의 정당성

《【문제1】 A회사의 근로자 甲이 근무하던 중 2011. 12. 6. 업무상 배임의 혐의로 구속되자, A회사는 인사규정 제33조 제3호에 따라 근로자 甲이 구속된 다음날 근로자 甲에게 휴직을 명령하였다. 이후 근로자 甲은 2012. 1. 13. 구속이 취소되어 불구속 기소 상태에서 A회사 인사규정 제34조 제1항(직원이 복직을 신청한 때에는 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 복직을 명하여야 한다)에 따라 복직을 신청하였으나, A회사는 대법원 판결 결과에 따라 복직 여부를 결정하겠다고 하면서 복직을 허락하지 않았다. 이를 위하여 A회사는 근로자 과반수로 구성된 노동조합에 동의를 요구하였으나 노동조합의 동의를 얻지 못하자 근로자들을 개별적으로 접촉하여 과반수 동의를 받아 2012. 2. 1. 인사규정을 변경하였다. 근로자 甲은 2013. 7. 8. 대법원에서 무죄판결을 선고받았다.

「중전의 인사규정 제33조 제3호」

• 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정시까지 휴직을 명령할 수 있다.

「변경된 인사규정 제33조 제3호」

• 형사사건으로 구속 또는 기소된 때에는 판결확정 후 3개월까지 휴직을 명령할 수 있다.

근로자 甲은 (i) 2012. 2. 1. 인사규정의 변경이 효력이 없을 뿐만 아니라, (ii) 근로자 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직명령을 계속 유지한 조치는 정당성이 없는 것으로 주장한다. 이러한 근로자 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (50점)》

<문제1의 물음(ii)> 노동조합 동의 없이 개별 근로자의 동의로 변경한 인사규정을 근거로 한 휴직 명령 유지의 정당성

I. 문제 제기

- 사안은 A회사가 업무상 배임 혐의로 구속된 근로자 甲의 구속이 취소되어 불구속 상태로 된 후 복직신청에 대해 계속 거부하고 있는 상황이다. 쟁점으로 <A회사가 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직 명령을 계속 유지한 조치가 정당한지> 검토할 필요가 있다. 이와 관련하여 이하에서는 휴직명령 유지 조치는 정당성이 결여된다는 근로자 甲의 주장이 타당한지 논한다.

II. 휴직 제도의 의의 및 효력

1. 휴직의 의의

- 휴직은 근로자 개인의 사정이나 회사 경영상의 이유로 근로 관계를 일시적으로 정지시키고, 그 사유가 해소되면 다시 복직시키는 제도이다. 근로 관계는 유지되지만 근로 제공 의무와 임금 지급 의무는 정지된다.

2. 휴직 명령의 정당성

- 휴직 명령은 정당한 사유가 있어야 한다. 인사규정 제33조 제3호에 따라 ‘형사사건으로 구속 또는 기소된 때’는 휴직 사유가 된다. 甲이 업무상 배임 혐의로 구속된 상황이었으므로, 2011년 12월 7일 휴직 명령은 당시로서는 정당성이 있었다.

III. 휴직 사유 소멸 및 복직 의무 (판례 법리)

1. 휴직 사유 소멸 시 복직 의무

- 대법원은 휴직 사유가 소멸하면 사용자는 특별한 사정이 없는 한 근로자를 원직에 복직시킬 의무가 있다고 본다. 이는 휴직 제도의 본질에 비추어 당연히 인정되는 의무이다.

2. 형사 기소와 휴직 사유의 소멸 판단

(1) 구속 해제

- 형사 사건으로 구속된 근로자의 경우, 구속이 해제되어 자유로운 몸이 되면 휴직 사유가 소멸된 것으로 보는 것이 일반적이다. 이는 근로자가 더 이상 근로 제공이 불가능한 상태에 있지 않기 때문이다.

(2) 불구속 기소 상태

- 구속이 해제되어 불구속 기소 상태가 되면, 근로자는 다시 정상적인 근로 제공이 가능해진다. 따라서 사용자는 근로자의 복직 신청을 받아들여야 한다.

(3) 대법원 판결 결과 대기 관행의 위법성

- 사용자가 형사 사건의 대법원 판결 확정 시점까지 복직을 거부하는 것은 근로자의 근로권을 장기간 침해하는 행위로서 원칙적으로 정당성이 없다. 근로관계 유지를 위해 극히 예외적인 경우(해당 직무의 특수성상 유지 가능성이 매우 높고 직무 수행이 현저히 부적합하며, 복직 시 회사에 막대한 손해 발생이 확실시 되는 경우)에 한해 제한적으로 허용될 수 있다.

3. 인사규정 제34조 제1항의 의미

- ‘직원이 복직을 신청한 때에는 특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 복직을 명하여야 한다’는 규정은 사용자의 복직 의무를 더욱 명확히 한 것으로, 특별한 사유가 없다면 복직을 지체 없이 허용해야 함을 의미한다.

IV. 사안의 적용

- A회사가 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직 명령을 계속 유지한 조치가 정당한지 검토한다.

1. 휴직 사유의 소멸

- 甲은 2012년 1월 13일 구속이 취소되어 불구속 기소 상태가 되었다. 이는 甲이 더 이상 신체적 구속으로 인해 근로를 제공할 수 없는 상태가 아님을 의미하므로, 휴직의 본래 사유(구속)는 소멸되었다.

2. 복직 신청 및 A회사의 거부

- 甲은 구속 취소 후 A회사 인사규정에 따라 즉시 복직을 신청했다. 그러나 A회사는 ‘대법원 판결 결과에 따라 복직 여부를 결정하겠다’면서 복직을 허락하지 않았다.

3. A회사의 복직 거부의 정당성 유무

- 甲이 구속이 취소된 상태에서 근로 제공이 가능해졌으므로, A회사는 특별한 사유가 없는 한 甲의 복직을 허용해야 한다. 형사 사건이 진행 중이라는 이유만으로 대법원 판결 확정 시까지 복직을 거부하는 것은 근로자의 근로권을 과도하게 침해하는 행위이다. 이는 휴직 제도의 취지를 벗어난 것이며,

甲이 아직 무죄 추정의 원칙에 따라 무죄로 간주되어야 한다는 점을 간과한 것이다. 특히 A회사의 인사규정 제34조 제1항은 '특별한 사유가 없는 한 10일 이내에 복직을 명하여야 한다'고 명시하고 있으므로, A회사의 복직 불허는 인사규정 자체도 위반하는 것이다.

#### **4. 변경된 인사규정의 효력 없음**

- 설령 변경된 인사규정(판결확정 후 3개월까지 휴직 명령 가능)이 유효하다고 가정하더라도, 이 규정은 2012년 2월 1일 이후에 적용되는 것이므로, 2012년 1월 13일 복직 신청 당시에는 종전 규정이 적용되어야 한다. 그리고 변경 절차를 위반하여 변경된 인사규정 자체도 무효이다.

#### **V. 결론**

- A회사가 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직 명령을 계속 유지한 조치는 정당성이 없다. 甲의 구속이 취소되어 불구속 기소 상태가 됨으로써 휴직 사유가 소멸되었고, A회사는 특별한 사유 없이 대법원 판결 확정 시까지 복직을 거부함으로써 甲의 근로권을 과도하게 침해했으며, 이는 인사규정의 복직 의무 조항에도 위반된다. 따라서 甲의 근로자 甲의 복직 신청을 받아들이지 않고 휴직명령을 계속 유지한 조치는 정당성이 없는 것이라는 주장은 타당하다.

《【문제2】 A회사에는 상시 근로자 500명이 근무하고, 근로자 과반수가 조합원으로 가입한 노동조합이 있다. A회사는 경영상 필요성에 의해 회사분할을 하기로 결정하고 1개월 동안 노동조합에게 이해와 협력을 구했으나 노동조합은 회사분할 자체를 반대하였다. 그러자 A회사는 상법상 회사분할(존속회사와 신설회사) 절차를 마친 후 분할된 업무에 종사하던 근로자 甲을 포함한 100명에게 신설회사(B회사)로 근로관계가 승계되었다며 B회사에서 근무하도록 서면으로 통보하였다. 근로자 甲이 B회사로 근로관계의 승계를 거부할 수 있는지 여부를 설명하시오. (25점)》

<문제2> 회사분할에 따른 근로관계 승계 시 개별 근로자의 거부권 행사 가능 여부

**I. 문제의 제기**

- 사안은 A회사가 상법상 회사분할을 거쳐 신설회사 B회사를 설립하고 분할 부문 근로자인 甲을 포함한 100명의 근로관계를 승계한 경우, 甲이 승계를 거부하는 상황이다. 쟁점으로 <근로자의 승계 거부권 인정 여부와 이를 판단하는 기준인 절차적 정당성 구비 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 甲의 승계 거부권 행사 가능 여부를 설명한다.

**II. 회사분할에 따른 근로관계 승계와 거부권에 관한 법리**

**1. 회사분할과 근로관계 승계의 원칙**

**(1) 포괄승계와 근로자 동의**

- 상법 제530조의10에 따라 분할 신설회사는 분할하는 회사의 권리와 의무를 승계하므로 근로관계도 원칙적으로 승계된다. 대법원은 이러한 포괄승계에 비추어 볼 때 적법한 회사분할 시 해당 사업 부문의 근로관계가 신설회사로 승계되므로 개별 근로자의 동의가 필수요건은 아니라고 본다.

**(2) 절차적 정당성의 요구**

- 다만, 헌법상 직업선택의 자유 등을 고려할 때 회사분할에 따른 근로관계 승계는 근로자의 이해와 협력을 구하는 절차를 거치는 등 절차적 정당성을 갖추어야 허용된다.

**2. 근로자의 승계 거부권(이의제기권) 인정 요건**

**(1) 절차적 정당성을 갖춘 경우 (원칙적 거부 불가)**

- 회사가 주주총회 승인 전 노동조합과 근로자들에게 분할의 배경, 목적, 승계 범위 및 신설회사 개요 등을 설명하고 이해와 협력을 구하는 절차를 거쳤다면 절차적 정당성이 인정되어 근로관계는 적법하게 승계되며 개별 근로자는 거부할 수 없다.

**(2) 특별한 사정이 있는 경우 (예외적 거부 인정)**

- 설명 및 협력 절차를 거치지 않았거나, 해고 제한 등 근로자 보호 법령을 잠탈하기 위한 방편으로 분할을 이용한 경우 근로자는 회사분할을 안 날부터 사회통념상 상당한 기간 내에 이의를 제기하여 승계를 거부하고 기존 회사에 잔류할 수 있다.

**III. 사안의 적용**

**1. A회사 분할의 절차적 정당성 충족 여부**

**(1) 이해와 협력을 구하는 절차의 이행**

- A회사는 회사분할을 결정한 후 1개월 동안 과반수 노동조합에게 이해와 협력을 구하는 절차를 수행하였다. 판례상 이해와 협력을 구하는 절차는 노동조합의 합의나 동의까지 요구하는 것은 아니므로, 비록 노조가 분할 자체를 반대하였더라도 설명과 협력 노력을 다한 이상 절차적 정당성을 충족한 것으로 봄이 타당하다.

**(2) 근로자 보호 규정 잠탈 여부**

- A회사의 분할이 경영상 필요성에 의해 결정되었고 상법상 정해진 절차를 마쳤다는 점에 비추어 볼 때, 해고 제한 규정 등 노동법상 제약을 회피하기 위한 방편으로 이용되었다고 볼 만한 특별한 사정은 존재하지 않는다.

**2. 甲의 근로관계 승계 거부 가능 여부**

**(1) 근로관계의 포괄적 승계 발생**

- A회사의 회사분할은 절차적 정당성을 갖추었고 법령 잠탈 등의 특별한 사정이 없으므로, 甲의 근로관계는 개별 동의 여부와 관계없이 분할 계획서에 따라 신설회사인 B회사로 적법하게 승계된다.

**(2) 개별 거부권 행사 가능성 차단**

- 절차적 정당성이 부정되는 등 예외적인 승계 거부 사유가 존재하지 않으므로, 甲이 상당한 기간 내에 이의를 제기하더라도 법률상 거부권의 효력은 인정되지 않는다.

**IV. 결론**

- 회사분할에 따른 근로관계 승계는 설명회 등을 통해 이해와 협력을 구하는 절차적 정당성을 갖춘 경우 개별 동의 없이도 신설회사에 포괄적으로 승계된다. 사안에서 A회사는 노조의 반대에도 불구하고 1개월간 성실히 협력을 구하는 절차를 거쳤고 법령 잠탈 목적도 없으므로 승계의 정당성이 완비되었다. 따라서 근로자 甲은 B회사로의 근로관계 승계를 거부할 수 없으며, B회사에서 근무하여야 할 의무를 부담한다.

<제04장 근로시간.제06절 연차유급휴가>

[기출][1][2016-1-1]적법한 파업 참가 근로자의 출근율 및 연차유급휴가 일수 산정 방식과 회사 주장의 정당성

《【문제1】 A회사는 근로자 500명을 고용하고 있으며 전자제품의 제조·판매를 주된 업무로 하고 있다. A회사에서는 기업별 노동조합인 B노동조합(이하 B노조)이 유일한 노동조합이고, A회사 근로자 400명이 가입되어 있다. B노조는 2015. 5. 1. 부터 같은 해 8. 31. 까지 업무를 전면적으로 거부하는 파업을 벌였다. A회사의 연간 소정근로일수는 240일이고, B노조의 파업기간은 이 소정근로일수 중 80일에 해당한다. B노조의 파업은 위법하지 않았고, A회사도 이에 대해서는 별도로 문제를 제기한 바가 없다. 한편 2008. 1. 1. 에 입사한 근로자 甲은 생산1부의 평사원으로 계속 근무해 왔다. 甲은 입사 이후 곧바로 B노조에 가입하였으며 2015년에는 B노조의 대의원으로 선출되어 파업 전 기간에 걸쳐 B노조의 파업에 참가하였다. (50점)

(물음1) 甲은 파업기간에 파업에 참여한 것 이외에는 2015년 회사에 결근한 적이 없었다. 그리고 A회사의 취업규칙과 단체협약에서는 연차 유급휴가는 근로기준법에 의한다고 규정되어 있다. 2016. 2. 甲은 개인적인 일로 A회사에 연차 유급휴가 8일을 신청하였다. 그러나 A회사는 甲이 파업 전 기간에 걸쳐 파업에 참여한 결과로 2015년에 甲이 출근한 일수가 소정근로일수의 80퍼센트가 되지 않아 근로기준법상 전년도에 80퍼센트 이상 출근한 경우에 부여되는 연차 유급휴가를 사용할 수 없다고 주장하였다. A회사의 이러한 주장의 정당성에 대하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 적법한 파업 참가 근로자의 출근율 및 연차유급휴가 일수 산정 방식과 회사 주장의 정당성

I 문제의 제기

- 본 사안은 근로자 甲이 적법한 쟁의행위인 파업에 참여한 후 연차유급휴가를 신청하였으나, A회사가 소정근로일수를 준수하지 않아 유급휴가를 사용할 수 없다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <적법한 쟁의행위 기간이 근로기준법 제60조 제1항의 출근율 산정 시 분모인 소정근로일수와 분자인 출근일수에 포함되는지> 여부 및 <이에 따른 연차 유급휴가 일수의 비례적 감축 방식>을 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 A회사의 주장의 정당성에 대해 논한다.

II 관련 법리 및 판례

1. 연차유급휴가와 소정근로일의 개념 및 산정 원칙

(1) 연차유급휴가제도의 취지

① 근로기준법 제60조 제1항

- 사용자는 1년간 80퍼센트 이상 출근한 근로자에게 15일의 연차 유급휴가를 주어야 한다. 이는 근로자에게 정신적·육체적 휴식을 제공하여 노동력의 재생산을 도모하기 위함이다.

② 출근율 산정의 기초

- 출근율은 소정근로일수 대비 출근일수의 비율로 계산하며, 소정근로일이란 법령이나 약정에 따라 당초 근로자가 근로를 제공하기로 정해진 날을 의미한다.

(2) 쟁의행위 기간과 소정근로일

① 근로의무의 정지

- 헌법과 노동조합법상 보장된 적법한 쟁의행위(파업) 기간은 근로자의 근로의무가 정당하게 정지된 기간에 해당한다.

② 소정근로일수에서의 제외

- 대법원은 적법한 쟁의행위 기간은 연차 유급휴가 출근율을 산정함에 있어 소정근로일수(분모)와 출근일수(분자) 모두에서 제외하는 것이 타당하다고 판시하였다. 이 기간을 결근으로 처리하여 연차 휴가를 부여하지 않는 것은 헌법상 보장된 노동조합의 단체행동권을 부당하게 제약하기 때문이다.

2. 쟁의행위 기간이 포함된 경우의 휴가 산정 법리

(1) 출근율 산정 공식

① 산정 방식의 정형화

- 적법한 파업 참가자의 출근율은 [실제 출근일수 / (연간 소정근로일수 - 쟁의행위 기간)]으로 계산하여야 하며, 이 비율이 80퍼센트 이상인 경우 연차 유급휴가 자체는 정상적으로 발생한다.

② 귀책사유 없는 특별 기간의 조율

- 소정근로일의무가 정지된 기간을 제외한 나머지 소정근로일 동안의 출근율이 80퍼센트 이상이라면 법률상의 연차 휴가 취득 요건을 구비한 것으로 본다.

(2) 연차유급휴가 일수의 비례적 감축

① 비례적 감축의 필요성

- 연차 유급휴가는 본질적으로 전년도에 실제로 근로를 제공한 것에 대한 대가로서의 성격을 병존적으로 가진다. 따라서 쟁의행위 기간 동안 근로를 제공하지 않은 기간에 대해서까지 온전한 휴가 일수를 부여할 수는 없다.

② 구체적 일수 산정 공식

- 대법원은 연차 유급휴가 일수를 산정할 때, [원래 발생해야 할 연차 유급휴가 일수 × (연간 소정근로일수 - 쟁의행위 기간) / 연간 소정근로일수]의 공식에 따라 비례적으로 감축하여 산정하는 것이 형평의 원칙에 부합한다고 판시하였다.

III 사안의 적용

1. 甲의 2015년도 출근율 충족 여부

(1) 계산식의 적용

- 사안에서 연간 소정근로일수는 240일이며, 적법한 파업 기간은 80일이다. 甲은 파업 기간을 제외하고 결근한 적이 없으므로 실제 출근일수는 160일(240일 - 80일)이다.

(2) 최종 출근율

- 甲의 출근율은 [160일 / (240일 - 80일)]로 계산되며, 이는 100퍼센트에 해당하므로 근로기준법 제60조 제1항의 요건인 80퍼센트 이상을 명백히 충족한다.

2. 구체적인 연차유급휴가 일수 산정 및 신청의 정당성

(1) 가산휴가를 포함한 기본 연차 일수 계산

- 甲은 2008. 1. 1.에 입사하여 2015년도는 8년 차 근무 기간에 해당한다. 근로기준법 제60조 제4항에 따른 기본 연차 15일에 근속 2년당 1일을 가산한 가산휴가 3일(8년 차 기준)을 합산하면, 원래 발생할 수 있는 총 연차 유급휴가 일수는 18일이다.

## (2) 비례 감축된 최종 발생 일수

- 판례 법리에 따라 파업 기간을 감축식에 대입하면  $[18일 \times (240일 - 80일) / 240일]$ 이 되며, 최종 계산 결과 甲에게 발생하는 연차 유급휴가 일수는 정확히 12일이 된다.

## (3) A회사 주장의 타당성 검토

- 甲이 2016. 2.에 신청한 연차 유급휴가는 8일이다. 甲의 최종 발생 연차 유급휴가 일수인 12일의 범위 내에 해당하므로, 甲은 이 휴가를 적법하게 청구하여 사용할 권리가 있다. 따라서 80퍼센트 이상 출근하지 못했다는 이유로 휴가 부여를 전면 거부하는 A회사의 주장은 정당성이 없다.

## IV. 결론

- 적법한 파업 기간은 출근율 산정 시 소정근로일수와 실제 출근일수 모두에서 제외되어야 하므로 甲의 출근율은 100퍼센트로서 연차 휴가 발생 요건을 충족한다. 다만, 실제 근로를 제공하지 않은 파업 기간에 비례하여 연차 휴가 일수를 감축하면 甲에게 부여되어야 할 연차 유급휴가는 12일이 된다. 따라서 甲이 청구한 8일의 연차 유급휴가는 법상 보장된 12일의 범위 내이므로 A회사의 거부 주장은 위법하며 정당성이 없다.

## <제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실체적 정당성>

### [기출][1][2016-1-2]이력서 허위 기재를 근거로 한 해고의 정당성

《【문제1】 A회사는 근로자 500명을 고용하고 있으며 전자제품의 제조·판매를 주된 업무로 하고 있다. A회사에서는 기업별 노동조합인 B노동조합(이하 B노조)이 유일한 노동조합이고, A회사 근로자 400명이 가입되어 있다. B노조는 2015. 5. 1. 부터 같은 해 8. 31. 까지 업무를 전면적으로 거부하는 파업을 벌였다. A회사의 연간 소정근로일수는 240일이고, B노조의 파업기간은 이 소정근로일수 중 80일에 해당한다. B노조의 파업은 위법하지 않았고, A회사도 이에 대해서는 별도로 문제를 제기한 바가 없다. 한편 2008. 1. 1. 에 입사한 근로자 甲은 생산1부의 평사원으로 계속 근무해 왔다. 甲은 입사 이후 곧바로 B노조에 가입하였으며 2015년에는 B노조의 대의원으로 선출되어 파업 전 기간에 걸쳐 B노조의 파업에 참가하였다. (50점)

(물음2) A회사는 甲이 4년제 대학을 졸업하였지만, 최종학력을 고등학교 졸업으로 입사 당시 이력서에 기재한 사실을 2016. 5. 우연히 발견하였다. 이력서 허위기재는 A회사의 취업규칙과 단체협약에서 정한 해고사유의 하나이다. A회사는 이력서 허위기재를 이유로 적법한 징계절차를 거쳐 2016. 6. 1. 甲을 해고하였다. A회사의 甲에 대한 해고가 정당한지에 대하여 논하시오(甲에 대한 해고가 부당노동행위에 해당하는지의 논점은 제외한다). (25점)》

### <문제1의 물음2> 이력서 허위 기재를 근거로 한 해고의 정당성

#### I. 문제 제기

- 사안에서는 甲이 입사 당시 최종 학력을 허위 기재한 사실이 발각되어 해고된 상황이다. 이와 관련하여 <이력서 허위 기재를 이유로 한 해고가 정당한지>가 쟁점이다. 이하에서는 이러한 해고의 정당성에 대해 논한다.

#### II. 이력서 허위 기재를 이유로 한 해고의 정당성 (판례 법리)

- 대법원은 이력서 등 채용 서류의 허위 기재를 이유로 한 해고의 정당성에 대해 다음과 같은 기준을 제시한다.

##### 1. 해고의 정당성 요건

- 근로기준법 제23조 제1항은 사용자의 정당한 이유 없는 해고를 금지한다. 이력서 허위 기재는 취업규칙 등에 징계 사유로 규정되어 있더라도, 해고가 사회통념상 현저히 부당하지 않아야 정당성이 인정된다.

##### 2. 판단 기준★

- 이력서 허위 기재를 이유로 한 해고의 정당성은 단순히 허위 기재 사실이 있다는 것만으로 인정되는 것이 아니라, 다음 요건들을 종합적으로 고려하여 판단한다.

##### (1) 허위 기재 내용의 중요성

- 허위 기재한 내용이 사용자의 채용 결정에 중대한 영향을 미쳤는지 여부. 즉, 만약 진실대로 기재했다면 사용자가 근로자를 고용하지 않았거나, 적어도 동일한 조건으로는 고용하지 않았을 것이라고 인정되는 경우.

##### (2) 고의성

- 근로자가 허위 사실을 기재한 것에 고의성이 있었는지 여부.

##### (3) 회사의 손해 또는 위험 발생 여부

- 허위 기재로 인해 회사의 경영 질서나 신뢰 관계가 훼손되었는지, 또는 업무 수행에 지장이 초래되었는지 여부.

##### (4) 시간 경과

- 허위 기재 사실이 발각되기까지의 시간 경과 및 그 동안의 근로자의 근무 실태. 장기간 성실하게 근무하여 회사에 기여한 바가 큰 경우, 해고는 가혹할 수 있다.

##### (5) 이력서 허위 기재를 해고 사유로 정한 규정의 유무

- 취업규칙이나 단체협약에 이력서 허위 기재를 해고 사유로 명시하고 있는지 여부. (이는 징계 사유의 존재 여부를 판단하는 요소이지만, 그 자체로 해고의 정당성을 보장하지는 않음)

#### III. 사안의 적용

- A사가 甲의 이력서 허위 기재를 이유로 해고한 것이 정당한지 검토한다.

##### 1. 허위 기재 내용의 중요성

- 甲은 4년제 대학을 졸업하였지만, 최종 학력을 고등학교 졸업으로 입사 당시 이력서에 기재했다. 즉, 최종 학력을 낮춰 기재한 경우이다. 통상적으로는 학력을 높여 기재하는 경우가 문제가 되지만, 이 사안은 반대이다. 학력을 낮춰 기재한 것이 채용 결정에 중대한 영향을 미쳤다고 보기는 어렵다. 오히려 회사는 고학력자를 더 선호하는 경우가 많기 때문이다. A사가 특정 직무에 대해 고등학교 졸업 학력을 채용 요건으로 명시했고, 甲이 그에 맞추기 위해 학력을 낮춰 기재했다면 그 중요성이 인정될 여지도 있으나, 사안에 그러한 명시는 없다. 일반적으로 금융회사 A와 같은 기업에서 4년제 대학 졸업이 고등학교 졸업보다 채용에 불리하게 작용할 가능성은 낮다.

##### 2. 시간 경과 및 근무 실태

- 甲은 2008년 1월 1일에 입사하여 2016년 6월 1일에 해고될 때까지 약 8년 5개월 동안 A사에 근무해 왔다. 이 기간 동안 甲은 생산1부 평사원으로 계속 근무했으며, 2015년에는 노동조합 대의원으로 선출될 정도로 성실하게 근무한 것으로 보인다. 장기간 성실하게 근무해 온 근로자를 단순히 최종 학력 허위 기재(그것도 학력을 낮춰 기재)를 이유로 해고하는 것은 비례의 원칙에 위배되어 지나치게 가혹한 처분으로 볼 수 있다.

##### 3. 회사의 손해 또는 위험 발생 여부

- 甲이 최종 학력을 낮춰 기재함으로써 A사에 어떤 실질적인 손해나 업무 수행상의 위험이 발생했는지에 대한 언급이 없다. 오히려 4년제 대학 졸업 학력이 업무 수행에 긍정적인 영향을 미쳤을 가능성도 있다. 허위 기재가 회사의 신뢰 관계를 훼손하는 것은 맞지만, 학력을 낮춰 기재한 것이 회사의 경영 질서를 문란하게 할 정도의 중대한 비위라고 보기는 어렵다.

##### 4. 취업규칙/단체협약 규정의 의미

- 이력서 허위기재는 A회사의 취업규칙과 단체협약에서 정한 해고사유의 하나이다. 이 규정은 징계 사유의 존재를 인정하는 근거가 될 수 있지만, 이 규정만으로 해고의 정당성이 자동으로 인정되는 것은 아니다. 징계 양정의 비례 원칙은 여전히 적용된다.

#### IV. 결론

- 甲의 최종 학력 허위 기재는 징계 사유에 해당할 수 있다. 그러나 甲이 학력을 높인 것이 아니라 낮춰 기재했고, 그로 인해 A사의 채용 결정에 중대한 영향을 미쳤다고 보기 어려우며, 특히 甲이 약 8년 5개월간 장기간 성실하게 근무해 왔고 허위 기재로 인해 회사에 실질적인 손해가 발생했다고 보기 어

려운 점 등을 종합적으로 고려할 때, 이력서 허위 기재를 이유로 한 해고는 사회통념상 현저히 부당하여 정당성을 인정하기 어렵다. 따라서 A사의 甲에 대한 해고는 정당하지 않다.

<제02장 근로관계의 성립.제03절 근로계약과 근로관계>

<제08장 근로관계의 종료.제03절 해고의 절차적 정당성>

[기출]11[2016-2]사용기간 만료 시 본채용 거부의 해고 여부 및 구두 통보의 정당성

《【문제2】 상시 근로자 300인을 사용하는 C회사는 사용기간을 2016. 1. 1. 부터 같은 해 6. 30. 까지로 정하여 근로자 乙을 채용하였다. C회사는 사용기간 만료 3일 전에 업무적격성이 없다는 이유로 乙에게 본 근로계약 체결의 거부를 구두로 통보하였다. C회사가 乙에게 사용기간 만료 3일 전에 본 근로계약 체결의 거부를 구두로 통보한 것이 정당한지에 대하여 설명하시오. (25점)》

#### <문제2> 사용기간 만료 시 본채용 거부의 해고 여부 및 구두 통보의 정당성

##### I. 문제의 제기

- 사안은 C회사가 사용근로자인 乙에 대하여 사용기간 만료 전에 업무적격성 부족을 이유로 본계약 체결을 거절하면서 구두로 통보한 행위의 법적 효력을 다룬다. 구체적으로는 <사용기간 만료에 따른 본계약 체결 거절의 법적 성질이 근로기준법상 해고에 해당하는지> 여부 및 이에 대해 <근로기준법 제27조의 해고사유 서면통지 의무가 엄격하게 적용되는지>가 핵심 쟁점이다. 이하에서는 이에 관한 판례법리를 살펴보고 사안에 적용하여 C회사 조치의 정당성 여부를 설명한다.

##### II. 사용근로관계와 본근로계약 체결 거절의 법적 성질 및 절차적 요건

###### 1. 본채용 거절의 법적 성질

###### (1) 사용근로관계의 의미

- 사용이란 정식 채용을 하기 전에 일정 기간 동안 근로자의 업무능력, 성실성, 자질 등 업무적격성을 관찰하고 평가하기 위해 시험적으로 고용하는 근로관계를 말한다. 이는 사용자에게 해약권이 유보된 근로계약의 성격을 지닌다.

###### (2) 본계약 체결 거절의 해고성

- 대법원은 사용기간 만료 시 본 근로계약 체결을 거절하는 것은 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서 실질상 해고에 해당하므로, 근로기준법상 해고 제한에 관한 규정이 전면적으로 준용된다고 판시한다.

###### 2. 해고사유 서면통지의무의 적용 여부

###### (1) 근로기준법 제27조의 규정 취지

- 근로기준법 제27조에 의하면 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 하며, 서면통지를 결여한 해고는 효력이 없다. 이는 사용자로 하여금 해고를 신중하게 결정하도록 유도하고, 해고의 존부와 사유를 명확히 하여 근로자가 이에 대처할 수 있도록 보장하기 위함이다.

###### (2) 사용근로자에 대한 서면통지 의무

- 대법원은 사용근로관계에서 본 근로계약 체결을 거절하는 경우에도 근로기준법 제27조가 그대로 적용되므로, 사용자는 근로자에게 거절사유를 파악하여 대처할 수 있도록 구체적·실질적인 거절사유를 서면으로 통지하여야 한다고 판시한다. 따라서 서면통지 의무를 위반한 거절 통보는 사법상 효력이 부정된다.

##### III. 사안의 적용

###### 1. 乙의 사용근로자 지위 및 본계약 거절의 해고성

- 乙은 사용기간이 2016. 1. 1.부터 같은 해 6. 30.까지로 약정된 사용근로자에 해당한다. C회사가 乙에 대하여 업무적격성 부족을 이유로 본 근로계약 체결을 거절한 행위는 사용자에게 유보된 해약권의 행사로서 실질적인 근로기준법상 해고에 해당하는 처분이다.

###### 2. 구두 통보의 법적 효력 및 정당성 여부

- C회사는 乙에게 본계약 체결 거절을 통보하면서 해고사유와 해고시기를 기재한 서면을 교부하지 않고 단지 3일 전 구두로만 통보하였다. 이는 30일 전 해고 예고(乙은 계속 근로기간 6개월로 예외 적용 안됨)를 해야하는 근로기준법 제26조를 위반한 것이다. 또한, 사용근로자에게도 강행규정으로 적용되는 근로기준법 제27조의 서면통지 의무를 직접적으로 위반하여 절차적 하자를 구성한다. 따라서 본계약 체결 거절에 객관적인 사유(실체적 사유)가 존재하는지 여부를 불문하고, C회사의 구두 통보는 절차상 중대한 하자로 인하여 사법상 효력이 인정되지 않는 무효의 처분이다.

##### IV. 결론

- C회사가 乙에게 행한 본채용 거절은 실질상 해고에 해당하므로 근로기준법 제27조에 따라 구체적인 거절 사유와 시기를 명시한 서면으로 통지하여야 한다. 그러나 C회사는 이를 구두로만 통보하였는바, 이는 강행법규인 서면통지 제도를 위반한 조치로서 절차상 정당성을 상실하여 효력이 없다. 결론적으로 乙에 대한 본 근로계약 체결의 거부를 구두로 통보한 C회사의 조치는 정당하지 않으며 사법상 위법·무효이다.

<제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실체적 정당성>

[기출][1][2017-1-1]확정되지 않은 징계사유로 단행된 해고의 정당성

《【문제1】 근로자 甲은 금융회사 A에서 근무하고 있는데, 근로자 甲이 고객으로부터 금품을 수수하였다는 투서가 접수되었다. A사는 고소를 하였고, 2015년 11월 말경 검찰은 고객으로부터 금 1,000만원을 받은 혐의로 甲을 불구속 기소하였다. 그러나 근로자 甲은 재판절차에서 변호사를 선임하여 무죄를 주장하고 있었다. 형사재판이 진행 중이던 2016년 1월 말경 A사는 근로자 甲에 대한 징계절차를 개시하여 해고로 결정하고 그 사유와 시기를 서면으로 통지하였다. 근로자 甲이 조합원으로 가입한 노동조합과 A사가 체결한 단체협약에는 아래와 같이 규정되어 있다.

- ㄱ. 직원이 고객 또는 거래처로부터 돈을 받은 경우 그 액수를 불문하고 해고사유가 된다.
- ㄴ. 징계사유가 형사사건으로 기소되면 징계절차를 개시할 수 있다.

한편, A사는 모든 근로자들과 1년 단위로 연봉계약을 체결하였다. 연봉계약서에는 기본급, 수당 및 상여금, 1년에 1개월 평균임금 상당액인 퇴직금과 이를 12개월로 분할 지급되는 금액이 기재되었다. 이에 따라 근로자 乙은 A사로부터 퇴직금 명목의 금액을 매월 균분하여 지급받았다. 이후 근로자 乙은 퇴직하면서 퇴직금 지급청구를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 근로자 甲에 대한 해고는 정당한지를 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 확정되지 않은 징계사유로 단행된 해고의 정당성

I. 문제의 제기

- 사안은 금융회사A가 기소 시 징계와 금품수수가 해고사유가 되는 규정이 있는 단체협약에 근거하여 무죄를 주장하는 甲을 형사재판이 진행 중인데도 해고를 한 상황이다. 쟁점으로 <단체협약에 규정된 해고사유가 근로기준법 제23조 제1항에 따른 정당한 이유에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 징계해고의 사유 및 양정의 정당성을 중심으로 해당 해고의 정당성에 대해 설명한다.

II. 징계해고의 정당성 요건

1. 징계사유의 존재

(1) 징계사유의 확정

- 징계사유란 근로자의 기업질서 위반행위를 의미한다. 단체협약이나 취업규칙에 징계사유가 규정되어 있다면 그 규정 자체가 근로기준법에 위반되어 무효가 아닌 한 그에 따른 징계는 원칙적으로 가능하다.

(2) 형사기소와 징계사유

- 판례는 형사사건으로 기소된 것을 징계사유나 해고법리로 삼는 경우, 그것이 단순히 기소되었다는 사실만으로 부족하고, 그 기소의 대상이 된 범죄사실이 기업질서와 직접 관련이 있거나 기업의 사회적 평가를 훼손할 만한 것이어야 한다고 본다.

2. 징계양정의 적정성

(1) 사회통념상 고용관계 계속의 기대 불가능성

- 해고는 근로자에게 가장 가혹한 징계이므로, 근로자의 유책행위가 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도로 책임 있는 사유에 해당해야 한다.

(2) 판단 기준

- 판례는 근로자의 평소 소행, 징계사유의 성격, 과거의 징계 전력, 기업질서에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

III. 사안의 적용

1. 징계사유의 정당성

(1) 단체협약의 해석

- A사의 단체협약 제1호는 금품수수액을 불문하고 해고사유로 정하고 있으며, 제2호는 기소 시 징계절차 개시를 허용하고 있다. 따라서 징계절차의 착수 자체는 단체협약에 근거한 것으로서 절차적 정당성을 가진다.

(2) 범죄사실의 실재 여부

- 다만, 징계사유가 단순히 기소 사실 그 자체가 아니라 금품수수라는 실체적 비위행위라면, 사용자는 형사재판 결과와 무관하게 독자적으로 그 비위행위의 존재를 입증해야 한다. 사안에서 甲이 무죄를 주장하고 있음에도 A사가 객관적인 비위 입증 없이 기소 사실만으로 해고를 결정했다면 징계사유의 존재를 인정하기 어려울 수 있다.

2. 징계양정의 정당성

(1) 비위행위의 중대성

- 금융회사의 특성상 고객으로부터의 금품수수는 직무의 청렴성을 심각하게 훼손하는 행위로서 기업질서 문란의 정도가 매우 크다. 금액이 1,000만 원에 달한다면 이는 사회통념상 해고가 가능한 수준의 중대한 비위로 볼 여지가 충분하다.

(2) 무죄추정의 원칙과의 조화

- 형사재판에서 무죄가 확정되지 않았더라도 징계는 형사절차와 별개로 진행될 수 있다. 그러나 甲이 강력하게 무죄를 주장하고 있고 명백한 증거가 확보되지 않은 상태에서 단행된 해고는 성급한 양정으로 판단될 소지가 있다.

IV. 결론

- 사안의 해고는 단체협약에 근거한 절차를 거쳤으나, 실체적으로 甲의 금품수수 사실이 객관적으로 입증되었는지에 따라 정당성 여부가 갈린다. 만약, A사가 검찰의 기소 내용 외에 자체 조사를 통해 금품수수 사실을 확인할 만한 증거를 확보했다면 해고는 정당하다. 그러나 단지 기소되었다는 사실만으로 징계해고를 단행했다면 이는 징계권의 남용으로서 부당해고에 해당할 가능성이 높다.

《【문제1】 근로자 甲은 금융회사 A에서 근무하고 있는데, 근로자 甲이 고객으로부터 금품을 수수하였다는 투서가 접수되었다. A사는 고소를 하였고, 2015년 11월 말경 검찰은 고객으로부터 금 1,000만원을 받은 혐의로 甲을 불구속 기소하였다. 그러나 근로자 甲은 재판절차에서 변호사를 선임하여 무죄를 주장하고 있었다. 형사재판이 진행 중이던 2016년 1월 말경 A사는 근로자 甲에 대한 징계절차를 개시하여 해고로 결정하고 그 사유와 시기를 서면으로 통지하였다. 근로자 甲이 조합원으로 가입한 노동조합과 A사가 체결한 단체협약에는 아래와 같이 규정되어 있다.

- ㄱ. 직원이 고객 또는 거래처로부터 돈을 받은 경우 그 액수를 불문하고 해고사유가 된다.
- ㄴ. 징계사유가 형사사건으로 기소되면 징계절차를 개시할 수 있다.

한편, A사는 모든 근로자들과 1년 단위로 연봉계약을 체결하였다. 연봉계약서에는 기본급, 수당 및 상여금, 1년에 1개월 평균임금 상당액인 퇴직금과 이를 12개월로 분할 지급되는 금액이 기재되었다. 이에 따라 근로자 乙은 A사로부터 퇴직금 명목의 금원을 매월 균분하여 지급받았다. 이후 근로자 乙은 퇴직하면서 퇴직금 지급청구를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 근로자 乙의 퇴직금지급 청구의 정당성에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 매월 균분하여 지급받은 퇴직금 분할 약정의 효력

**I. 문제의 제기**

- 사안에서 A사는 근로자 乙과의 연봉계약에 퇴직금을 포함하여 이를 매월 분할 지급하였고, 근로자 乙은 퇴직 후 별도로 퇴직금의 지급을 청구하고 있다. 쟁점으로 <연봉계약에 퇴직금을 포함하여 매월 분할 지급한 약정의 효력과 그에 따른 근로자 乙의 퇴직금 지급청구권 인정 여부>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 근로자 乙의 퇴직금지급 청구의 정당성에 대해 설명한다.

**II. 퇴직금 분할 약정의 효력**

**1. 퇴직금 청구권의 발생 시기**

- 퇴직금은 근로계약이 종료되는 시점에 발생하는 권리이다. 근로기준법 및 퇴직급여법의 취지상 퇴직 시 발생하는 퇴직금을 사전에 포기하거나, 발생하지도 않은 퇴직금을 매월 임금에 포함하여 지급하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

**2. 분할 약정의 유효성 판단 기준**

- 판례는 퇴직금 분할 약정이 유효하기 위해서는 그것이 퇴직금 중간정산의 요건을 갖추어야 한다고 본다. 그러나 사안과 같이 단순히 연봉액을 13분하여 그중 1개월분을 퇴직금 명목으로 매월 지급하는 방식은 중간정산의 사유에 해당하지 않으며, 강행법규인 퇴직급여법을 잠탈하는 행위로서 무효이다.

**III. 분할 약정 무효에 따른 법률관계**

**1. 근로자의 퇴직금 청구권**

- 퇴직금 분할 약정이 무효이므로 사용자가 매월 퇴직금 명목의 금원을 지급했다 하더라도 이는 퇴직금 지급으로서의 효력이 없다. 따라서 근로자는 퇴직 시점에 적법하게 산정된 퇴직금 전액을 청구할 수 있다.

**2. 이미 지급된 금원의 법적 성격**

**(1) 부당이득의 성립**

- 판례에 따르면, 퇴직금 분할 약정이 무효임에도 불구하고 사용자가 근로자에게 퇴직금 명목으로 금원을 지급했다면, 근로자는 법률상 원인 없이 이익을 얻고 사용자는 손해를 입은 것이 된다. 따라서 이 금원은 특별한 사정이 없는 한 사용자가 근로자에게 반환을 청구할 수 있는 부당이득에 해당한다.

**(2) 상계의 제한**

- 사용자는 근로자에 대해 가지는 부당이득 반환 채권을 가지고 근로자의 퇴직금 채권과 상계할 수 있다. 다만, 판례는 근로자의 생활 안정을 위해 퇴직금 채권의 2분의 1을 초과하는 부분에 대해서만 상계가 가능하다고 판시하고 있다.

**IV. 사안의 적용**

**1. 퇴직금 분할 약정의 효력 검토**

- A사와 乙이 체결한 연봉계약 중 퇴직금을 12개월로 분할하여 지급하기로 한 부분은 퇴직금 청구권의 사전 포기 내지 강행법규 위반에 해당하여 무효이다. 乙이 매월 수령한 금원은 진정한 의미의 퇴직금으로 볼 수 없다.

**2. 乙의 청구 및 반환 의무**

**(1) 퇴직금 지급 청구의 정당성**

- 乙은 퇴직급여법에 따라 퇴직 시 발생하는 퇴직금 전액을 A사에게 청구할 수 있으며, 이 청구는 정당하다.

**(2) 부당이득 반환 및 상계**

- 다만, 乙이 매월 지급받은 퇴직금 명목의 금원은 부당이득으로서 A사에게 반환해야 한다.

**V. 결론**

- 근로자 乙의 퇴직금 지급 청구는 퇴직금 분할 약정의 무효로 인하여 법적으로 정당하다. 다만, 乙이 기수령한 퇴직금 명목의 금원은 부당이득에 해당하므로 이에 대한 반환이 필요하다.

<제09장 비정규근로자.제04절 차별 시정>

[기출][1][2017-2]계약직에서 정규직으로 전환된 근로자에 대한 경력 인정 차별의 정당성 여부

《【문제2】 공공기업인 B사의 보수규정에 따르면 공개채용을 통하여 입사한 정규직 사원의 경우 공공기업 근무경력의 100%를 인정하여 초임 연봉을 정하고 있다. 한편 계약직에서 정규직으로 전환된 직원들의 경우 채용경로와 업무성격이 정규직 사원과 구별되므로, 계약직 근무경력의 50%만을 근무경력으로 인정하여 초임 연봉을 책정하고 있다. 계약직에서 정규직으로 전환된 직원인 甲은 B사의 보수규정이 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률과 근로기준법상 차별적 처우 금지규정에 위반된다고 주장하고 있는 바, 그 주장의 정당성에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제2> 계약직에서 정규직으로 전환된 근로자에 대한 경력 인정 차별의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서는 공공기업 B사가 정규직 공채 입사자와 계약직에서 정규직으로 전환된 입사자(이하 '전환자'라 한다) 간에 이전 경력 인정 비율을 100%와 50%로 다르게 설정한 보수규정을 적용한 상황이다. 쟁점으로 <해당 처우가 근로기준법 제6조의 균등대우 원칙 및 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '기간제법') 제8조의 차별적 처우 금지 조항에 위반되는지>, <과거 기간제 근로자였다는 전환자의 신분이 근로기준법상 사회적 신분에 해당하는지>, <정규직 공채자와 전환자 간의 직무 성격 차이가 차별의 합리적 이유가 될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 甲의 주장의 정당성에 대해 설명한다.

II. 기간제법상 차별적 처우 금지 위반 여부

1. 기간제법 제8조의 적용 범위

- 기간제법 제8조 제1항은 사용자가 기간제 근로자임을 이유로 당해 사업 또는 사업장에서 동종 또는 유사한 업무에 종사하는 무기계약 근로자에 비하여 차별적 처우를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있다.

2. 전환 후 차별에 대한 적용 가능성

- 기간제법의 차별 금지 규정은 원칙적으로 현재 기간제 근로자인 자를 대상으로 한다. 따라서 이미 정규직으로 전환된 근로자가 과거 기간제 근로자였다는 사실을 이유로 현재의 정규직 공채자와 차별받는 경우, 이는 기간제법 직접 적용보다는 근로기준법상 차별 금지 원칙의 관점에서 논의되는 것이 타당하다. 다만 판례는 기간제 근로자가 무기계약직으로 전환된 경우에도 전환 전후의 근로 조건 단절 여부와 입법 취지를 고려하여 판단한다.

III. 근로기준법상 균등대우 원칙 위반 여부

1. 근로기준법 제6조의 의무

- 사용자는 근로자에 대하여 남녀의 성을 이유로 차별적 대우를 하지 못하고, 국적·신앙 또는 사회적 신분을 이유로 근로조건에 대한 차별적 처우를 하지 못한다.

2. 사회적 신분의 해당 여부

(1) 사회적 신분의 정의

- 사회적 신분이란 자신의 의사나 노력으로 바꿀 수 없는 선천적 지위나 장기간 고착화된 후천적 지위를 의미한다.

(2) 고용형태의 사회적 신분성

- 최근 판례는 고용형태(정규직, 비정규직 등)가 근로자의 자유로운 의사에 따라 쉽게 변경할 수 없는 고착된 지위의 성격을 갖는 경우 이를 근로기준법상 사회적 신분으로 인정하는 경향이 있다. 따라서 전환자라는 지위는 근로기준법 제6조에서 보호하는 차별 금지 사유인 사회적 신분에 해당할 수 있다.

IV. 차별적 처우의 합리적 이유 판단

1. 판단 기준

- 차별에 합리적인 이유가 있다는 것은 동일한 가치의 노동에 대하여 다른 처우를 하는 것이 정당화될 수 있는 객관적인 사유가 존재하는 경우를 말한다. 업무의 내용, 책임의 범위, 노동의 강도, 채용의 절차 및 난이도 등이 고려 대상이 된다.

2. 사안의 쟁점별 고찰

(1) 채용 경로 및 난이도의 차이

- 공개채용과 계약직 채용은 그 절차와 경쟁률, 요구되는 역량 검증 단계에서 차이가 존재할 수 있다. 대법원은 채용 절차의 차이가 보수 체계의 차이로 이어지는 것에 대해 일정 부분 합리성을 인정하기도 한다.

(2) 업무 성격 및 가치의 차이

- B사의 보수규정이 '업무 성격이 정규직 사원과 구별됨'을 명시하고 있는데, 만약 실제로 수행하는 직무의 가치가 객관적으로 다르다면 경력 인정 비율의 차등은 합리적 이유가 될 수 있다. 그러나 명칭만 다를 뿐 실질적인 업무 내용과 책임이 동일하다면 이는 차별적 처우에 해당한다.

V. 사안의 적용

1. 비교 대상 집단의 설정

- 사안에서 甲과 같은 전환자와 공채 정규직 사원은 동일한 정규직 지위에 있으므로, 보수규정상 경력 인정 비율의 차이는 동일 집단 내에서의 고용 경로에 따른 차별에 해당한다.

2. 합리적 이유 유무의 검토

- B사가 주장하는 채용 경로와 업무 성격의 차이가 실제 직무 가치의 차이로 입증되는지가 관건이다. 전환 전 수행했던 계약직 업무가 현재 정규직 업무와 밀접한 관련이 있음에도 불구하고 단지 계약직이었다는 이유만으로 경력을 50%만 인정하는 것은 합리성을 결여했을 가능성이 크다. 특히, 공공기업 근무경력은 100% 인정하면서 동일 기관 내의 계약직 경력을 50%만 인정하는 것은 형평성에 어긋난다.

VI. 결론

- 근로자 甲의 주장은 상당한 정당성을 가진다. 고용 형태에 따른 차별은 근로기준법상 균등대우 원칙에 위배될 소지가 높으며, B사가 주장하는 채용 경로의 차이가 경력 인정 비율을 2배나 차등할 만큼의 본질적인 직무 가치 차이로 연결되지 않는다면 이는 합리적 이유 없는 차별에 해당한다. 따라서 B사의 보수규정은 근로기준법 제6조 위반으로 판단될 가능성이 높다.

《【문제1】 A사는 가방을 제조·판매하는 회사로서, 백화점을 운영하는 여러 회사들과 거래계약을 체결하여 백화점 내에 A사의 제품을 판매하는 매장을 개설·운영하고 있다. 80개에 달하는 각 매장에는 A사와 체결한 판매용역계약에 따라 A사의 제품을 판매하고 그 대가로 매월 수수료를 지급받는 판매원들이 있고, 이들의 근무기간은 4년 내지 10년이다. 판매용역계약에 따르면, 수수료는 매장의 월매출액 × 매장 수수료를 × 개인 수수료를 산식으로 산출하되, 판매원 직급별 월기준금액(매니저 300만원, 시니어 250만원, 주니어 200만원)의 85%에 미달하거나 130%를 초과하여 지급할 수 없도록 되어 있다.

2013년 3월 위와 같은 판매용역계약을 체결한 甲(주니어 판매원)을 포함한 A사의 모든 판매원들은 백화점 영업시간(10:30~20:00)에 맞추어 해당 매장에 출·퇴근하면서 A사가 정한 가격으로 A사 제품을 판매했다. A사는 각 매장과 연결된 전산망을 통해 매장의 판매실적과 근무상황 등을 실시간으로 파악했고, 수시로 업무 관련 지시를 전달했다. 또한 A사 본사 영업부 직원들이 매주 담당 매장을 방문하여 판매원들의 근무실태를 점검했다. 그 과정에서 A사는 매출부진을 이유로 매니저급 판매원과 판매용역계약을 해지하기도 했다. 판매원들은 출산, 질병 등 특별한 사유가 있거나 할인 행사로 일손이 부족할 때, A사의 사전 승낙을 받아 아르바이트 직원을 채용해 판매보조 인력으로 활용했다. A사는 비품, 아르바이트 급여 등 매장 운영에 필요한 모든 비용을 부담했다. A사는 본사 직원과 달리 판매원들에게 취업규칙을 적용하지 않았고, 사업소득세를 원천징수했으며, 판매원들을 4대보험에 가입시키지 않았다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲은 A회사에게 근로기준법 제56조 제1항에 따른 가산임금을 청구할 수 있는 근로자에 해당하는지에 대하여 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음1> 제조업체와 판매용역계약을 체결한 백화점 판매원의 근로기준법상 근로자 해당 여부

I. 문제의 제기

- 甲은 A사와 판매용역계약을 체결하여 매장에서 A사의 제품을 판매하고 일정한 수수료를 지급받아왔다. 그러나 <甲은 실질적으로 A사의 지휘·감독 아래 종속적인 노무를 제공하였다는 점에서 근로기준법상 근로자에 해당한다고 주장>할 수 있다. 이에 따라 <형식적 판매용역계약을 체결한 甲이 근로기준법 제56조 제1항에 따른 연장·야간·휴일근로 가산임금을 청구할 수 있는지가 문제된다.> 이하에서는 판매원 甲이 근로기준법상 가산임금을 청구할 수 있는 근로자에 해당하는지에 대하여 논한다.

II. 근로자성 판단의 법리

1. 근로기준법상 근로자의 개념

(1) 법적 정의

- 근로기준법 제2조 제1항 제1호는 근로자를 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 자로 정의한다. 여기서 근로 제공의 법적 성격이 형식적 계약에 의해 좌우되는 것은 아니며, 실질적 종속관계에 있는지가 근로자성 판단의 핵심이다.

(2) 실질적 판단 기준

- 대법원은 근로자성 판단에 있어 계약의 형식이 아닌 실질적 노무제공 관계를 중시한다. 따라서 판매용역계약이라는 형식보다, 실질적으로 사용자에 대한 종속성이 인정되면 근로자로 본다.

2. 실질적 종속성 판단 기준★

(1) 지휘·감독 여부

- 사용자가 업무 수행 과정에서 구체적·개별적 지휘·감독을 하는지 여부가 근로자성의 중요한 판단 기준이다.

(2) 근무시간·장소의 구속

- 노무제공자가 스스로 근무시간과 장소를 정할 수 있는지, 아니면 사용자의 통제에 따라야 하는지도 중요한 요소이다.

(3) 대체 근로 가능성

- 제3자를 직접 고용하여 업무를 대체하게 할 수 있는지 여부도 종속성 판단에 있어 의미가 있다.

(4) 보수의 성격

- 보수가 기본급 또는 고정급 형태로 지급되는지, 그리고 근로 자체의 대가인지가 근로자성 판단의 단서가 된다.

(5) 사회보장제도 가입 여부

- 4대보험 가입 여부, 세법상 원천징수 방식은 보조적 요소(사용자의 경제적 우위를 이용한 임의 적용 가능)이나, 종합적으로 근로자성 판단에 참작된다.

3. 판례의 태도

(1) 학습지 교사, 보험설계사 등 사례

- 대법원은 학습지 교사, 보험설계사 등과 같이 위탁계약 형식을 취했다라도 사용자의 지휘·감독 하에 종속적으로 근로를 제공한 경우 근로자로 인정할 바 있다.

(2) 백화점 판매원 사례

- 특히, 백화점 매장에서 특정 회사 제품만을 판매하고, 사용자 회사가 판매활동을 실질적으로 통제하는 경우 근로자로 본 판례가 존재한다.

(3) 종합적 고려 원칙

- 종속성 판단은 어느 한 요소만으로 단정할 수 없고, 여러 사정을 종합적으로 고려해야 한다는 것이 판례의 일관된 입장이다.

III. 사안의 적용

1. 종속성 판단 요소별 검토

(1) 지휘·감독의 존재

- 甲은 A사의 전산망을 통해 판매실적이 실시간으로 관리되었으며, 본사 직원들이 주기적으로 방문하여 업무지시와 점검을 하였다. 또한, 매출 부진을 이유로 계약이 해지되기도 했는데, 이는 사용자에게 의한 인사관리와 다름없는 통제에 해당한다. 따라서 실질적 지휘·감독관계가 인정된다.

(2) 근무시간·장소 지정

- 판매원들은 백화점 영업시간에 맞추어 매장에 출퇴근하였고, 임의로 근무시간을 조정할 수 없었다. 또한, 판매장소도 특정 매장으로 제한되었다. 이는 사용자가 근로자의 시간·장소를 강력하게 통제하는 경우에 해당한다.

(3) 독자적 대체 인력 채용 가능 여부

- 판매원들은 출산, 질병 등 특별사유가 있거나, 행사 시 A사의 승낙을 받아야만 대체인력을 채용할 수 있었다. 이는 사용자의 허락 없이는 대체가 불가능한 구조로, 근로자성을 강하게 시사한다.

#### (4) 보수의 성격

- 수수료 산정은 일정한 산식을 통해 결정되었으나, 직급별 기준금액의 85%~130% 범위로 제한되어 있어 사실상 일정한 고정급적 성격을 띤다. 즉, 근로의 성과보다는 근로제공 자체에 대한 대가라는 점에서 임금적 성격이 인정된다.

#### (5) 사회보험·세법상 처리

- A사는 판매원들에게 사업소득세를 원천징수하고 4대보험에 가입시키지 않았으나, 이는 근로자성 판단에 있어 보조적 사정에 불과하다. 판례에 따르면 사회보험 미가입이나 세법상 사업자 처리만으로 근로자성을 부정할 수 없다.

### 2. 종합적 검토

- 종속적 관계의 주요 요소인 지휘·감독, 근무시간·장소 지정, 대체성 여부, 보수의 고정성 등에서 근로자성이 강하게 인정된다. 따라서 甲은 실질적으로 근로기준법상 근로자에 해당한다 할 것이다.

## IV. 결론

- 甲은 A사와의 계약 명칭과는 무관하게 실질적으로 A사의 지휘·감독 하에서 종속적인 근로를 제공하였고, 그 대가로 임금적 성격을 가진 보수를 지급받았다. 따라서 근로기준법상 근로자에 해당한다. 이에 따라 甲은 근로기준법 제56조 제1항에 따른 연장·야간·휴일근로 가산임금을 청구할 수 있다.

<제03장 임금.제03절 통상임금>

[기출][1][2018-1-2]판매용역계약을 체결한 판매원이 지급받은 수수료의 통상임금 해당 여부

《[문제1] A사는 가방을 제조·판매하는 회사로서, 백화점을 운영하는 여러 회사들과 거래계약을 체결하여 백화점 내에 A사의 제품을 판매하는 매장을 개설·운영하고 있다. 80개에 달하는 각 매장에는 A사와 체결한 판매용역계약에 따라 A사의 제품을 판매하고 그 대가로 매월 수수료를 지급받는 판매원들이 있고, 이들의 근무기간은 4년 내지 10년이다. 판매용역계약에 따르면, 수수료는 매장의 월매출액 × 매장 수수료를 × 개인 수수료를 산식으로 산출하되, 판매원 직급별 월기준금액(매니저 300만원, 시니어 250만원, 주니어 200만원)의 85%에 미달하거나 130%를 초과하여 지급할 수 없도록 되어 있다.

2013년 3월 위와 같은 판매용역계약을 체결한 甲(주니어 판매원)을 포함한 A사의 모든 판매원들은 백화점 영업시간(10:30~20:00)에 맞추어 해당 매장에 출·퇴근하면서 A사가 정한 가격으로 A사 제품을 판매했다. A사는 각 매장과 연결된 전산망을 통해 매장의 판매실적과 근무상황 등을 실시간으로 파악했고, 수시로 업무 관련 지시를 전달했다. 또한 A사 본사 영업부 직원들이 매 주 담당 매장을 방문하여 판매원들의 근무실태를 점검했다. 그 과정에서 A사는 매출부진을 이유로 매니저급 판매원과의 판매용역계약을 해지하기도 했다. 판매원들은 출산, 질병 등 특별한 사유가 있거나 할인 행사로 일손이 부족할 때, A사의 사전 승낙을 받아 아르바이트 직원을 채용해 판매보조 인력으로 활용했다. A사는 비품, 아르바이트 급여 등 매장 운영에 필요한 모든 비용을 부담했다. A사는 본사 직원과 달리 판매원들에게 취업규칙을 적용하지 않았고, 사업소득세를 원천징수했으며, 판매원들을 4대보험에 가입시키지 않았다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 甲을 근로자로 가정하면 甲이 A회사로부터 지급받은 수수료가 통상임금에 해당하는지에 대하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 판매용역계약을 체결한 판매원이 지급받은 수수료의 통상임금 해당 여부

I. 문제의 제기

- 甲은 A사와 판매용역계약을 체결하여 매장에서 A사의 제품을 판매하고, 계약에 따른 산식에 의해 산정된 수수료를 지급받았다. 앞서 甲이 근로기준법상 근로자에 해당한다고 전제할 경우, 문제는 <甲이 지급받은 수수료가 근로기준법상 통상임금에 해당하는지> 여부이다. 이는 시간외·휴일·야간근로수당의 기초가 되는 임금항목을 확정하는 데 있어 실무적으로 중요한 의미를 가진다. 이하에서는 통상임금의 개념과 법리를 검토하고, 사안의 구체적 사실관계를 수수료의 통상임금 여부에 대해 논한다.

II. 통상임금의 개념 및 판단 기준

1. 법적 근거

- 임금은 근로기준법 제2조 제1항 제5호에서 사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품으로 정의한다. 또한, 통상임금은 근로기준법 시행령 제6조에서 정기성과 일률성을 규정하고, 대법원 판례는 이에 고정성을 더하여 종합적으로 정기적·일률적·고정적으로 지급되는 임금을 통상임금으로 보고 있다.

2. 판단 요소

(1) 정기성

- 일정한 간격을 두고 계속적·반복적으로 지급되는 임금이어야 한다.

(2) 일률성

- 모든 근로자 또는 일정한 조건에 달한 전체 근로자에게 균등하게 지급되는 것이어야 한다.

(3) 고정성

- 근로자가 통상적인 근로를 제공하기만 하면 그 지급 여부나 액수가 확정되어 있는 것이어야 한다.

(4) 종합적 고려

- 명칭, 산식, 지급 방식과 관계없이 실질적 성격에 따라 판단한다.

3. 관련 판례

- 대법원은 고정적 성격이 없는 성과급, 실적수당 등은 통상임금에 해당하지 않는다고 본다. 그러나 기본급 성격을 지니고 근로제공만으로 확정적으로 지급되는 부분은 통상임금에 포함된다고 하였다. 2012년 전원합의체 판결(2012다89399)은 통상임금의 범위를 근로자에게 소정근로의 대가로 지급되는 정기적·일률적·고정적 임금으로 명확히 정리하였다.

III. 사안의 적용

1. 정기성

- 甲의 수수료는 매월 매출실적을 기초로 계산되며, 매월 지급된다. 따라서 정기적 지급 요건은 충족한다.

2. 일률성

- 모든 판매원은 직급별 기준금액을 전제로 동일한 산식에 따라 수수료를 지급받는다. 따라서 직급별로는 일률적으로 적용된다 할 수 있다.

3. 고정성

(1) 산식 구조

- 수수료는 매장 월매출액 × 매장 수수료율 × 개인 수수료율로 산출되며, 다만 직급별 기준금액의 85%~130% 범위 내에서 조정된다.

(2) 문제점

- 산식상 매출액에 따라 수수료가 달라질 수 있어 전형적인 성과급적 성격을 가진다. 그러나 동시에 일정한 하한(기준금액의 85%)과 상한(기준금액의 130%)이 설정되어 있어 일정 범위 내에서 고정성이 담보된다.

(3) 검토

- 통상임금으로 인정되기 위해서는 근로자가 소정근로를 제공하는 경우 당연히 지급될 것이 확정되어야 한다. 본 사안의 수수료는 매출성과에 직접 연동되지만, 하한이 정해져 있어 일정한 금액이 보장되므로 고정성이 인정된다.

IV. 결론

- 甲이 수령한 수수료는 매월 정기적으로 지급되고 직급별로 동일한 산식이 적용된다는 점에서 정기성과 일률성은 인정된다. 또한 지급액이 매출실적에 직접 연동되어 있지만 하한이 정해져 있어 일정한 지급액이 확정되므로 고정성이 인정된다. 따라서 甲이 지급받은 수수료는 근로기준법상 임금에 해당하며, 통상임금에도 해당한다고 보는 것이 타당하다.

《【문제2】 기간의 정함이 있는 근로계약의 기간 만료 시 사용자의 계약갱신 거부를 부당해고라고 판단할 수 있는 경우에 대하여 판례법리에 따라 설명하시오. (25점)》

<문제2> 기간제 근로계약 만료 시 사용자의 갱신거절이 부당해고에 해당하는지에 관한 판례법리

**I. 문제의 제기**

- 기간제 근로계약은 원칙적으로 약정한 기간의 만료로 근로관계가 종료된다. 따라서 계약기간 만료 시 사용자가 갱신을 거부하는 것은 당연히 해고로 취급되지 않는 것이 원칙이다. 그러나 일정한 요건이 충족되는 경우 계약갱신 거부가 사실상 해고와 동일한 효과를 가지므로 근로기준법상 부당해고 여부가 문제된다. 이하에서는 판례가 정립한 법리를 중심으로, <어떠한 경우에 기간제 근로계약의 갱신거절이 부당해고로 판단될 수 있는지>를 설명한다.

**II. 기간제 근로계약의 법적 성격**

**1. 기간제 근로계약의 원칙**

- 기간제 근로계약은 계약 기간이 도래하면 근로관계가 종료되는 것이 원칙이다. 이는 근로계약의 자유와 기간약정의 구속력을 존중하는 차원에서 일반적으로 인정된다.

**2. 법령 규정 내용**

- 기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률 제4조 제1항은 사용자가 2년을 초과하여 기간제 근로자를 사용할 수 없도록 규정하여, 기간제 근로자의 남용을 제한하고 있다. 그러나 2년 미만의 계약이라 하더라도, 계약갱신 거부가 해고와 마찬가지로 부당노동행위로 다루어지는 경우가 있다.

**III. 판례 법리**

**1. 갱신기대권의 인정**

- 대법원은 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에 의하여 일정한 요건이 충족되면 계약이 갱신된다는 갱신 관행이나 규범적 근거가 있는 경우, 근로자에게 계약갱신에 대한 정당한 기대권이 발생한다고 본다. 이러한 경우 기간만료를 이유로 한 갱신 거부는 해고에 해당하여 근로기준법 제23조의 해고 제한이 적용된다.

**2. 판단 요소**

- 갱신기대권 여부의 판단 요소는 ① 취업규칙·단체협약 등에 계약갱신 관련 규정이 존재하는지 여부 ② 반복적·계속적으로 계약이 갱신되어 온 관행이 있는지 여부 ③ 사용자의 인사 운영 방식, 업무의 계속성, 근로자에 대한 평가·운영 실태 ④ 근로자가 객관적으로 보아 계약 갱신에 대한 합리적 기대를 가졌는지 여부 등이다.

**3. 갱신거부의 정당성**

- 갱신기대권이 인정되는 경우에도, 사용자가 근로자의 근무성적 부진, 업무 태만, 경영상 필요 등 합리적 사유를 들어 갱신을 거부한다면 이는 정당하다. 그러나 정당한 사유 없이 단순히 사용자 편의만을 이유로 갱신을 거부하는 것은 부당해고에 해당한다.

**IV. 구체적 적용 기준**

**1. 갱신기대권이 인정되는 경우**

- 기간제 교사, 연구원, 공공기관 무기계약직 등에서 반복적으로 계약이 갱신된 경우, 근로자에게는 갱신기대권이 인정될 수 있다. 특히, 계약갱신의 사유나 절차가 객관적으로 규율되어 있는 경우, 갱신거부는 해고와 동일한 법적 심사를 받는다.

**2. 갱신거부가 부당해고로 판단되는 경우**

- 갱신거부가 부당해고로 판단되는 경우는 ① 계약갱신 거부 사유가 구체적으로 존재하지 않거나, 사회통념상 고용관계를 지속할 수 없는 합리적 이유가 없는 경우 ② 인사평가, 근무태도, 경영상 사정 등을 이유로 하더라도, 그것이 객관적으로 합리성을 인정받을 수 없는 경우 ③ 노동조합 활동이나 고용불안 회피 등 부당한 동기에 기초한 경우 등이다.

**V. 결론**

- 기간제 근로계약은 원칙적으로 기간 만료와 동시에 종료되지만, 일정한 규범적 근거 또는 갱신 관행으로 근로자에게 갱신기대권이 발생하는 경우에는 계약갱신 거부가 곧 해고로 간주된다. 따라서 이 경우 사용자는 해고 제한 원칙에 따라 사회통념상 근로계약을 계속할 수 없을 정도의 합리적 이유가 존재해야 하며, 정당한 이유 없이 계약 갱신을 거부하는 것은 부당해고에 해당한다. 결국 판례 법리에 의하면, <계약갱신 거부가 정당한지> 여부는 근로자의 갱신 기대권의 존재와 갱신거부 사유의 합리성을 중심으로 구체적 사정을 종합적으로 판단하여야 한다.

<제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실제적 정당성>

[기출][1][2019-1-1]경영상 이유에 의한 해고 대상자 선정 기준의 위법성

《【문제1】 상시 근로자 100명을 고용하여 자동차부품을 생산하는 A회사는 최근 판매실적의 부진을 이유로 다음과 같은 해고의 기준을 가지고 甲을 포함한 생산직 근로자 12명을 선정하여 2017년 1월 2일에 정리해고를 단행하였다.

[A회사가 정한 해고 대상자 선정 기준(합계 : 100점)]

<근무태도평가(근무태도는 기본품성, 동료의식, 책임감, 자기계발로 구성) : 40점, 징계 : 10점, 근태 : 5점, 경미 사고 : 5점, 포상 : 10점, 근속기간 : 15점, 부양가족 : 15점>

그런데, 해고된 근로자 甲 등 12명 중 甲을 포함하여 10명은 징계, 근태, 경미 사고, 포상 평가에서는 최상위권 점수를 받았으나 근무태도평가에서는 최하위권 점수를 받은 반면, 정리해고 되지 않은 잔존근로자 88명 중 12명은 근무태도평가에서 만점을 받았으나 징계, 근태, 경미 사고, 포상 평가에서는 최하위권 점수를 받았다.

한편 A회사는 최근 판매부진의 실적을 만회하기 위해 자동차부품판매의 유경험자로서 다른 회사에서 좋은 판매영업성과를 올리고 있던 근로자 乙을 채용하면서 연봉 1억 원과 별도로 사이닝보너스(signing bonus)로 1억 원을 지급하고 7년간 고용을 보장하기로 하는 내용의 채용합의서를 작성하였다. A회사는 乙에게 약정한 사이닝보너스를 지급하였고, 乙은 2017년 2월 16일부터 A회사의 판매사업 부문 담당 사업부장으로 재직하다가 2018년 4월 15일 개인사유를 이유로 사직하였다. 그리고 다음과 같은 사실이 인정된다.

ㄱ. 채용합의서에는 7년간의 전속근무를 조건으로 사이닝보너스를 지급한다거나 乙이 약정근무기간 7년을 채우지 못하였을 경우 이를 반환하여야 한다는 등의 내용은 기재되어 있지 아니하다.

ㄴ. 채용합의서만으로는 약정근무기간과 고용보장기간을 각 7년으로 약정한 특별한 이유나 동기를 찾기 어렵다.

ㄷ. A회사는 채용합의 과정에서 乙에게 장기근무의 필요성이나 근무기간이 7년이어야 하는 구체적인 이유는 설명하지 아니하였다.

ㄹ. A회사는 채용합의 당시 乙에게 약정근무기간을 채우지 못할 경우 사이닝보너스를 반환하여야 한다는 사실은 고지하지 아니하였다.

다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲은 위와 같은 해고 대상자 선정기준을 가지고 정리해고 한 것은 위법하다고 주장한다. 甲의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (단, 나머지 정리해고의 유효요건은 논하지 아니함) (25점)》

<문제1의 물음1> 경영상 이유에 의한 해고 대상자 선정 기준의 위법성

## I. 문제의 제기

- 사안은 A회사가 판매실적 부진을 이유로 정리해고를 단행하면서, 그 해고 대상자 선정기준을 두고 근로자 甲이 위법성을 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <A회사가 정한 기준 중 근무태도평가의 비중과 그 운영 방식이 합리성과 공정성을 결여하였는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이와 관련한 기준을 가지고 정리해고 한 것은 위법하다는 甲의 주장의 타당성에 관하여 논한다.

## II. 관련 법리

### 1. 정리해고의 요건과 대상자 선정 기준

- 근로기준법 제24조 제2항은 경영상 이유에 의한 해고가 정당하기 위해서는 합리적이고 공정한 해고의 기준에 따라 해고 대상자를 선정할 것을 요구하고 있다. 이는 사용자가 자의적으로 특정 근로자를 배제하거나 불이익을 주지 못하도록 하여 근로자의 생존권을 보호하려는 취지이다.

### 2. 합리성과 공정성의 판단 기준

- 판례는 해고 대상자 선정기준이 합리적이고 공정한지 여부는 ① 기업의 성격, ② 근로자의 직종과 직무의 특성, ③ 선정기준 항목의 적절성, ④ 배점의 합리성, ⑤ 실제 운영 과정의 객관성 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다고 본다. 합리성이란 해당 기준이 기업의 경영상 필요와 직무 특성에 부합하는지를 의미한다. 공정성이란 객관적 지표에 따라 누구에게나 동일하게 적용될 수 있어야 하며, 사용자의 주관적 평가나 자의가 개입할 소지가 최소화되어야 한다는 것을 뜻한다.

### 3. 근무태도평가와 관련된 법리

- 근무태도는 성실성·동료의식·책임감 등 주관적 요소가 포함되므로, 이를 주요 평가항목으로 삼을 경우 사용자의 자의적 판단이 개입할 위험이 크다. 따라서 이를 해고 대상자 선정의 핵심 기준으로 삼는 것은 합리성과 공정성에 반한다는 것이 판례와 학설의 입장이다. 특히, 다른 객관적 기준(근속기간, 징계, 근태, 사고, 포상 등)을 제치고 근무태도에 과도한 배점을 부여하면 그 부당성이 심화된다.

## III. 사안의 적용

### 1. 선정기준의 구성과 배점

- A회사의 해고 대상자 선정기준은 총 100점 만점 중 근무태도평가가 40점으로 가장 큰 비중을 차지한다. 나머지 징계(10점), 근태(5점), 경미사고(5점), 포상(10점), 근속기간(15점), 부양가족(15점)에 비하여 근무태도의 배점이 현저히 높다. 문제는 근무태도의 세부 항목이 기본품성, 동료의식, 책임감, 자기계발 등 구체적이고 객관적으로 수치화하기 어려운 요소로 구성되어 있다는 점이다. 이는 객관적 검증이 곤란하고 평가자의 주관에 크게 개입할 수 있다.

### 2. 선정기준 적용의 결과

- 사안에서 드러난 바와 같이, 해고된 甲 등 10명은 징계, 근태, 사고, 포상 등 객관적 지표에서 최상위권에 속했음에도, 근무태도평가에서만 최하위권 점수를 받아 해고되었다. 반면, 정리해고되지 않은 잔존 근로자 12명은 객관적 지표에서는 최하위권임에도 불구하고, 근무태도평가에서 만점을 받아 해고를 면하였다. 이는 해고 여부가 사실상 근무태도평가에 의해 좌우되었음을 보여준다. 결국, 사용자 측이 자의적으로 특정 근로자를 선별하여 배제하는 결과가 초래되었다고 볼 수 있다.

### 3. 합리성 측면의 검토

- 경영상 위기 극복을 위한 인력 조정에서 합리적이라 함은 기업의 성과 향상 및 효율적 운영에 직접적으로 기여할 수 있는 기준을 의미한다. 징계 이력, 근태 상황, 사고 발생 여부, 포상 실적 등은 업무수행능력과 조직 기여도를 직접적으로 보여주는 객관적 자료이다. 이에 반해 근무태도평가는 성격상

추상적이며, 기업의 경영상 필요와 직접적 연관성이 낮다. 따라서 근무태도를 전체 점수의 40%에 해당하는 핵심 지표로 삼은 것은 합리성을 상실한 것이다.

#### 4. 공정성 측면의 검토

- 실제 적용 결과를 보면, 해고된 근로자들은 객관적 성과와 규율 측면에서 우수하였음에도 불구하고, 근무태도라는 주관적 항목에서 낮은 점수를 받아 불이익을 입었다. 이는 사용자가 근로자의 향후 태도나 조직 적합성 등을 이유로 사실상 선택적 배제를 한 것과 다르지 않다. 특히, 근무태도평가에서 만점을 받은 근로자 12명이 객관적 지표에서 모두 최하위권이라는 사실은, 이 평가가 공정한 기준으로 기능하지 못했음을 보여준다. 따라서 이는 근로기준법이 요구하는 공정성 요건에 명백히 반한다.

#### 5. 판례와의 비교

- 대법원은 정리해고에서 근무성적·능력·근속연수·부양가족 등을 기준으로 삼는 것은 원칙적으로 허용되지만, 객관적이지 못한 요소를 과도하게 반영하여 해고 대상자를 사실상 자의적으로 선정하는 것은 위법하다고 본다. 본 사안의 경우가 이에 해당한다.

#### IV 결론

- A회사가 정리해고를 위하여 마련한 해고 대상자 선정기준은 근무태도평가에 과도한 비중을 두고 있으며, 그 평가항목 자체가 주관적·추상적이어서 객관성과 공정성을 결여하였다. 실제 운영 결과 역시 객관적 지표에서 우수한 근로자가 배제되고, 오히려 불량한 근로자가 잔존하는 등 불합리한 결과를 초래하였다. 이는 사용자가 특정 근로자를 자의적으로 선정하는 수단으로 기능한 것으로서, 근로기준법 제24조 제2항의 합리적이고 공정한 해고의 기준에 해당한다고 보기 어렵다. 따라서 甲이 제기하는 바와 같이, 본건 해고 대상자 선정기준은 위법하며, 甲의 주장은 타당하다.

<제02장 근로관계의 성립.제02절 근로계약의 체결>

[기출][1][2019-1-2]중도 퇴사자 대상 사이닝보너스 반환 청구의 타당성

《【문제1】 상시 근로자 100명을 고용하여 자동차부품을 생산하는 A회사는 최근 판매실적의 부진을 이유로 다음과 같은 해고의 기준을 가지고 甲을 포함한 생산직 근로자 12명을 선정하여 2017년 1월 2일에 정리해고를 단행하였다.

[A회사가 정한 해고 대상자 선정 기준(합계 : 100점)]

<근무태도평가(근무태도는 기본품성, 동료의식, 책임감, 자기계발로 구성) : 40점, 징계 : 10점, 근태 : 5점, 경미 사고 : 5점, 포상 : 10점, 근속기간 : 15점, 부양가족 : 15점>

그런데, 해고된 근로자 甲 등 12명 중 甲을 포함하여 10명은 징계, 근태, 경미 사고, 포상 평가에서는 최상위권 점수를 받았으나 근무태도평가에서는 최하위권 점수를 받은 반면, 정리해고 되지 않은 잔존근로자 88명 중 12명은 근무태도평가에서 만점을 받았으나 징계, 근태, 경미 사고, 포상 평가에서는 최하위권 점수를 받았다.

한편 A회사는 최근 판매부진의 실적을 만회하기 위해 자동차부품판매의 유경험자로서 다른 회사에서 좋은 판매영업성과를 올리고 있던 근로자 乙을 채용하면서 연봉 1억 원과 별도로 사이닝보너스(signing bonus)로 1억 원을 지급하고 7년간 고용을 보장하기로 하는 내용의 채용합의서를 작성하였다. A회사는 乙에게 약정한 사이닝보너스를 지급하였고, 乙은 2017년 2월 16일부터 A회사의 판매사업 부문 담당 사업부장으로 재직하다가 2018년 4월 15일 개인사유를 이유로 사직하였다. 그리고 다음과 같은 사실이 인정된다.

ㄱ. 채용합의서에는 7년간의 전속근무를 조건으로 사이닝보너스를 지급한다거나 乙이 약정근무기간 7년을 채우지 못하였을 경우 이를 반환하여야 한다는 등의 내용은 기재되어 있지 아니하다.

ㄴ. 채용합의서만으로는 약정근무기간과 고용보장기간을 각 7년으로 약정한 특별한 이유나 동기를 찾기 어렵다.

ㄷ. A회사는 채용합의 과정에서 乙에게 장기간 근무의 필요성이나 근무기간이 7년이어야 하는 구체적인 이유는 설명하지 아니하였다.

ㄹ. A회사는 채용합의 당시 乙에게 약정근무기간을 채우지 못할 경우 사이닝보너스를 반환하여야 한다는 사실은 고지하지 아니하였다.

다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사는 乙의 사직을 이유로 乙에게 지급한 사이닝보너스를 반환할 것을 청구하였다. A회사의 청구의 타당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 중도 퇴사자 대상 사이닝보너스 반환 청구의 타당성

I. 문제의 제기

- 본 사안은 A회사가 근로자 乙에게 지급한 사이닝보너스 1억 원에 대하여, 乙이 약정한 7년의 고용보장 기간을 채우지 못하고 중도 사직하였음을 이유로 그 반환을 제기한 경우이다. 이와 관련하여 <사이닝보너스가 단순한 이직 축하금인지, 아니면 전속 근무를 조건으로 한 선금급 성격인지와 반환 약정이 부재한 상황에서 근로자의 중도 사직 시 반환 의무가 발생하는지가 쟁점이다.> 이하에서는 A회사의 반환 청구의 타당성에 관하여 논한다.

II. 사이닝보너스의 법적 성격과 반환 의무 범위

1. 사이닝보너스의 의의 및 성격 구분

(1) 이직 축하금 또는 계약 체결의 대가

- 사이닝보너스가 우수한 인력을 확보하기 위해 인재를 영입하면서 지급하는 일시금이라면, 이는 단순히 이직에 따른 보상이나 계약 체결 자체에 대한 대가로서의 성격을 가질 수 있다. 이 경우 원칙적으로 근로자에게 전속 근무 의무가 부과되지 않으며, 중도 사직 시에도 반환 의무가 발생하지 않는다.

(2) 전속 근무 조건부 선급 임금

- 반면, 사이닝보너스가 향후 일정 기간 동안 전속적으로 근무할 것을 조건으로 하여 지급된 것이라면, 이는 장래 근로에 대한 선급 임금으로서의 성격을 갖는다. 이 경우에는 약정된 근무 기간을 채우지 못했을 때 미이행 기간에 비례하여 반환해야 할 의무가 발생할 수 있다.

2. 반환 의무 발생의 판단 기준

(1) 판례의 일반적 태도

- 판례는 사이닝보너스가 임금 선급금으로서의 성격을 가져 중도 사직 시 반환 의무가 인정되기 위해서는, 당사자 사이에 일정 기간 근무하지 않았을 때 이를 반환한다는 명시적인 합의나 약정이 존재해야 한다고 본다.

(2) 약정 부재 시의 해석 원칙

- 반환 약정이 서면으로 명시되지 않은 경우라면, 채용 과정에서 장기 근무의 필요성이 구체적으로 설명되었는지, 금액의 규모가 이직 축하금으로 보기에 지나치게 큰지, 근로계약 체결의 동기가 무엇인지 등을 종합적으로 고려한다. 그러나 명시적 반환 규정이 없다면 근로자에게 불리하게 반환 의무를 추단하는 것에는 신중해야 한다는 것이 판례의 일관된 입장이다.

III. 사안의 적용

1. 채용합의서의 내용 분석

(1) 반환 약정의 부재

- A회사와 乙 사이의 채용합의서에는 7년간의 전속 근무를 조건으로 보너스를 지급한다는 내용이나, 기간 미충족 시 반환해야 한다는 규정이 전혀 기재되어 있지 않다. 이는 객관적 증거상 乙에게 반환 의무를 부과하기 어렵게 만드는 핵심적 요소이다.

(2) 고용보장 기간의 성격

- 7년의 기간은 근로자에게 강제 근무를 명하는 기간이라기보다, 사용자가 근로자의 지위를 안정적으로 보장해주기로 한 고용보장의 의미로 해석될 여지가 크다. 즉, 乙이 7년을 근무해야 할 의무가 있다기보다 A회사가 7년 동안 해고하지 않겠다는 약속으로 볼 수 있다.

2. 채용 과정의 정황 검토

(1) 설명 및 고지 의무 미이행

- A회사는 채용 합의 과정에서 乙에게 7년 근무의 구체적인 이유나 필요성을 설명하지 않았으며, 중도 사직 시 반환 의무가 발생한다는 사실도 전혀 고지하지 않았다. 근로자로서는 해당 금액을 이직에 따른 일시적 보상으로 신뢰할 수밖에 없는 상황이었다.

## (2) 특별한 동기의 결여

- 채용합의서만으로는 7년이라는 특정 기간을 설정해야만 했던 합리적 이유나 특별한 동기를 찾기 어렵다. 이는 해당 보너스가 7년 치 근로의 대가를 분할하여 선급한 것이라고 보기 어렵게 만드는 정황이다.

## 3. 검토

- 사안의 사이닝보너스는 7년간의 전속 근무를 전제로 한 선급 임금이라기보다, 유능한 인재인 乙을 영입하기 위해 계약 체결의 대가로 지급한 이직 축하금의 성격이 강하다. 따라서 명시적인 반환 약정이 없는 한 乙이 개인 사유로 사직하더라도 이를 반환할 법적 근거가 부족하다.

## IV. 결론

- 사용자인 A회사가 乙을 상대로 제기한 사이닝보너스 반환 청구는 타당하지 않다. 대법원 판례의 취지에 비추어 볼 때, 사이닝보너스의 반환 의무가 인정되려면 명시적인 반환 약정이 있거나, 실질적으로 장래 근로의 대가임이 명확히 입증되어야 한다. 그러나 본 사안에서는 반환 약정이 존재하지 않고, 채용 과정에서 반환 의무에 대한 고지도 이루어지지 않았으며, 고용보장 기간 설정의 합리적 이유도 소명되지 않았다. 따라서 乙은 수령한 사이닝보너스를 반환할 의무가 없다고 판단된다.

## <제03장 임금.제04절 임금지급의 원칙>

### [기출][1][2019-2]임금채권 양수자의 청구에 대한 사용자의 지급 의무

《【문제2】 근로기준법이 적용되는 사업장에 근무하는 근로자 甲은 사용자 乙로부터 지급받게 될 6개월분의 임금에 대한 청구권을 자신의 채권자 丙에게 양도하였으며, 이를 乙에게 내용증명으로 통지하여 乙은 이를 수령하였다. 丙이 양도받은 채권에 대하여 그 지급을 청구하면 乙은 지급할 의무가 있는지를 설명하시오. (25점)》

### <문제2> 임금채권 양수자의 청구에 대한 사용자의 지급 의무

#### I. 문제의 제기

- 사안에서 근로자 甲은 근로기준법이 적용되는 사업장에서 근무하며, 사용자 乙으로부터 향후 지급받게 될 6개월분 임금채권을 자신의 채권자 丙에게 양도하고, 이를 내용증명으로 乙에게 통지하였다. 이후 양수인 丙이 양도받은 임금채권의 지급을 乙에게 청구하려 하는 상황이다. 쟁점으로 <임금채권의 민사적 양도 가능성과 그 효력, 근로기준법상 임금 직접지급의 원칙, 사용자가 제3자에게 지급할 법적 의무가 존재하는지> 검토할 필요가 있다. 특히, <사용자가 양도 사실을 인지하였더라도, 근로자의 생계 보호와 법적 강행규정을 고려할 때 지급 의무가 어떻게 되는지>가 문제된다. 이하에서는 사용자의 임금채권 지급 의무에 대해 설명한다.

#### II. 채권의 양도성

- 민법 제449조 제1항 본문은 채권은 양도할 수 있다고 규정하고 있다. 임금채권 역시 채권의 한 종류이므로, 원칙적으로 근로자가 자신의 임금채권을 제3자에게 양도하는 것은 민사적으로 유효하다. 양도계약은 당사자 간 합의에 의해 성립하며, 근로자가 채권을 양도하고 이를 사용자에게 통지하면, 민법상 양수인은 채권자로서 권리행사를 할 수 있는 권리를 가진다. 그러나, 임금채권은 근로자의 생계수단이라는 특수성을 가진다. 따라서 채권 양도와 관련하여 민사적 효력이 인정되더라도, 근로기준법상 직접지급 원칙에 따라 사용자가 임금을 제3자에게 지급함으로써 근로자에 대한 지급 의무가 소멸하는 것은 아니다. 즉, 민사상 양도의 효력과 사용자의 지급 의무는 별도로 평가해야 한다.

#### III. 임금 직접 지급의 원칙

##### 1. 관련 규정

- 근로기준법 제43조 제1항 본문은 임금은 통화로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다는 원칙을 명시하고 있다. 이 원칙은 강행규정적 성격을 가지며, 임금채권 양도 여부와 관계없이 사용자가 근로자에게 직접 임금을 지급해야 한다는 의무를 부과한다. 이 규정은 근로자의 생활보장과 생계안전을 최우선으로 고려한 법적 장치이다.

##### 2. 관련 판례

- 대법원 판례(대법원 1988.12.13. 선고 87다카2803 전원합의체)는 근로자가 임금채권을 제3자에게 양도하였더라도, 사용자는 여전히 근로자에게 직접 지급해야 하며, 제3자에게 지급함으로써 임금 지급 의무를 면제할 수 없다고 판시하였다. 이 판례는 임금채권 양도의 민사적 효력과 임금 지급의 법적 의무를 명확히 구분하여, 사용자가 제3자에게 임금을 지급한다고 해서 근로자에 대한 지급 의무가 소멸하지 않음을 확인하고 있다. 즉, 사용자는 임금 지급 의무를 면제받기 위해 채권 양수인에게 지급할 수 없으며, 근로자에게 직접 지급함으로써 의무를 완전히 이행해야 한다.

#### IV. 사안의 적용

##### 1. 채권양도의 유효성

- 사안에서 甲이 丙에게 양도한 6개월분 임금채권은 장래 임금에 해당하며, 민사적 양도계약은 유효할 수 있다.

##### 2. 乙의 지급 의무

- 그러나 근로기준법상 직접불의 원칙에 따라 乙은 여전히 甲에게 임금을 지급할 법적 의무를 부담한다. 따라서 乙이 丙에게 지급할 경우, 민사적 양도의 효력과는 별도로 甲에 대한 지급 의무는 소멸하지 않는다. 만약 乙이 丙에게 지급하면 甲은 동일한 금액에 대해 여전히 乙을 상대로 임금 청구권을 행사할 수 있으며, 乙은 법적 분쟁이나 부당이득 반환 청구의 대상이 될 수 있다.

##### 3. 丙의 권리

- 한편, 丙은 甲과의 양도계약에 따른 권리를 행사할 수 있으나, 사용자인 乙에 대한 직접 청구권은 인정되지 않는다. 즉, 양도의 효력은 근로자와 채권자 사이의 민사적 권리관계에 국한되며, 임금 지급 의무자인 乙의 법적 의무를 변경시키지는 못한다.

#### V. 결론

- 근로자가 임금채권을 제3자에게 양도하였더라도, 사용자는 여전히 근로자에게 직접 임금을 지급해야 한다. 사용자가 제3자에게 지급할 법적 의무는 존재하지 않으며, 지급하더라도 근로자에 대한 지급 의무는 소멸하지 않는다. 사안에서 乙은 丙에게 임금을 지급할 법적 의무가 없고, 원칙적으로 甲에게 직접 지급해야 한다. 丙은 민사적 양도인 甲에게만 채권을 행사할 수 있으며, 乙에 대한 직접 지급 청구는 인정되지 않는다.

《【문제1】 A공사는 고속국도의 설치·관리 및 통행료 수납업무를 수행하는 공기업이다. 개인사업자 B는 2018. 6. 30. A공사에서 정년퇴직한 자로서, 2018. 12. 31. 수의(隨意)계약 방식으로 A공사와 통행료 수납업무에 관한 용역계약을 체결하였다(계약기간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.). B는 용역업체의 창업에 소요된 5천만 원 전액을 A공사로부터 연 1%의 이자율로 차입하여 조달하였고, 별도의 사무실을 두지 않았으며, 용역계약에 따라 A공사의 영업소에서 근무할 수납원 외에는 다른 근로자를 채용하지 않았으며, 2020. 8. 15.까지 A공사 이외의 거래처에서 발생한 매출은 없다. B는 용역계약의 이행을 위하여 2019. 1. 1. A공사로부터 소개받은 甲과 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하였다. 甲은 채용과 동시에 A공사가 관리하는 ○○영업소의 통행료 수납원으로 발령받아 계속 근무하고 있다.

한편, C사는 시설관리 등을 사업목적으로 2000. 1. 1. 설립된 회사로서 2020. 8. 15. 현재 자본금은 5억 원이며, 다수의 거래처로부터 시설관리 등의 업무를 도급받아 수행하고 있다. 다만, C사는 근로자파견사업의 허가를 받지 아니하였다. C사는 2017. 12. 31. 공개입찰 방식으로 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.의 1년의 계약기간으로 A공사와 통행료 수납업무 용역계약을 체결하였고, 이후 같은 방식으로 두 차례 계약을 갱신하였다. C사는 기존에 근무하던 수납원이 퇴직하여 결원이 생기자 구직자를 모집하여 2019. 8. 14. 乙과 1년의 계약기간으로 근로계약을 체결하였다. 乙은 채용과 동시에 A공사가 관리하는 △△영업소의 통행료 수납원으로 발령받아 근무하던 중 2020. 8. 13. 계약기간이 만료되어 C사에서 퇴사하였다. C사는 乙에게 기존과 동일한 조건으로 근로계약을 갱신할 것을 제안하였으나, 乙은 A공사에게 나를 직접 고용하라고 요구하였다. 乙이 그 제안을 거절하였다.

A공사는 사전에 정해 둔 용역대금 산정기준에 따라 B 및 C사 등 외주업체와 용역계약을 체결하였고, A공사의 영업소는 A공사의 직원인 소장, 과장, 대리, 주임과 외주업체 소속인 수납원으로 구성되어 있다. 수납원들은 A공사의 영업소 사무실로 출근하여 A공사의 로고가 새겨진 근무복과 명찰을 착용한 후 주임으로부터 지시사항을 전달받고 요금소로 이동하여 통행료 수납업무 등을 수행하였다. 또 수납원들은 교대시간 또는 근무시간 종료 후 사무실로 이동하여, 징수한 통행료를 확인한 후 주임에게 입금확인서와 개인별 근무확인서를 작성·제출하였고, 주임은 이러한 개인별 근무확인서의 내용이 A공사의 전산시스템에 자동 저장된 정보와 일치하는지 확인하고 소장의 결재를 받았다. 한편, 외주업체들은 영업소 소장에게 매월 소속 수납원들의 근무편성표, 출퇴근 사항을 보고하였다. A공사는 2018. 1. 1. 통행료 수납업무와 관련하여 고객을 응대할 때의 행동, 표정, 언어, 예절, 자세, 예외적 상황별 고객 응대 요령 등이 기재된 매뉴얼을 제작하여 외주업체에 배포하였고, 외주업체 소속 수납원들은 이러한 매뉴얼에 따라 업무를 수행하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲은 자신이 A공사에 직접 채용된 근로자라고 주장한다. 판례법리에 근거하여 甲의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (20점)》

#### <문제1의 물음1> 명목상 외주업체 소속 근로자의 실질적 사업주 판단 기준

##### I. 문제의 제기

- 개인사업자 B와 근로계약을 체결하고 A공사의 영업소에서 근무 중인 甲이 A공사의 근로자라고 주장하는 사안과 관련하여, <甲을 고용한 외주업체 대표 B가 독립된 사업주로서의 실체를 갖추었는지>, <A공사가 甲을 실질적으로 지휘·감독하여 甲과의 근로관계가 성립하는지>가 쟁점이다. 이하에서는 甲과 A공사 사이에 직접적인 근로계약관계가 존재하는지 여부를 중심으로 甲의 주장의 타당성에 관하여 논한다.

##### II. 묵시적 근로계약관계 성립에 관한 법리

###### 1. 성립 요건 및 판단 기준★

- 판례는 원고용주에게 고용되어 제3자의 사업장에서 제3자의 업무에 종사하는 자를 제3자의 근로자라고 할 수 있으려면, 원고용주는 사업주로서의 독자성이 없거나 독립성을 결하여 제3자의 노무대행기관과 동일시 할 수 있는 등 그 존재가 형식적·명목적인 것에 지나지 아니하고, 사실상 당해 피고용인은 제3자와 종속적인 관계에 있으며, 실질적으로 임금을 지급하는 자도 제3자이고, 또 근로제공의 상대방도 제3자이어서 당해 피고용인과 제3자간에 묵시적 근로관계가 성립되어 있다고 평가될 수 있어야 한다고 판시하고 있다. 이와 관련하여 다음과 같은 요건을 종합적으로 고려하여 판단한다.

###### (1) 사업주로서의 독자성 및 실체 결여

- 원고용주가 사업주로서의 외형을 갖추고 있더라도, 독자적인 자금이나 설비가 없고, 자기의 책임과 계산으로 사업을 운영하지 않으며, 사업주로서의 실체가 없는 등 그 존재가 가공적인 경우이다.

###### (2) 실질적인 지휘·감독권의 행사

- 원고용주가 근로자에 대한 채용, 해고, 임금 지급, 징계 등 인사노무관리권을 행사하지 않고, 실제로는 제3자가 근로자의 근로조건을 결정하며, 업무 수행 과정에서 직접 지휘·감독을 행사하여 실질적인 노무 제공의 상대방이 제3자인 경우이다.

###### 2. 법적 효과

- 묵시적 근로계약관계가 인정되면, 형식적인 근로계약 관계에도 불구하고 근로자와 실질적인 사용자(사용사업주) 사이에 직접 근로관계가 존재하는 것으로 간주된다. 이 경우 근로자는 실질적인 사용자(사용사업주)를 상대로 임금 청구, 고용 유지 보장 등을 요구할 수 있다.

##### III. 사안의 적용

###### 1. 외주업체 대표 B의 사업주로서의 실체성 검토

###### (1) 자금 및 자산의 종속성

- 개인사업자 B는 용역업체 창업 자금 5천만 원 전액을 A공사로부터 매우 낮은 이자율(연 1%)로 차입하여 조달하였다. 이는 자금 조달에 있어 A공사에 전적으로 의존하고 있음을 보여준다.

###### (2) 사업 인프라의 부재

- B는 별도의 사무실을 두지 않았다. 이는 독자적인 사업 시설을 갖춘 사업자로 보기 어렵게 만드는 요소 중 하나이다.

###### (3) 경영상의 독립성 결여

- B는 A공사의 퇴직자로서 수의계약 방식으로 용역권을 부여받았으며, 2020. 8. 15.까지 A공사 외의 거래처가 전혀 없어 매출의 100%를 A공사에 의존하고 있다. 또한, 수납원 외에 다른 근로자를 채용하지 않았고, 甲 또한 A공사로부터 소개받아 채용하는 등 채용 과정에서도 독자성이 결여되어 있다.

###### 2. A공사의 실질적 지휘·감독권 행사 여부

###### (1) 업무 수행의 지시 및 통제

- 수납원들은 A공사의 로고가 새겨진 복장을 착용하고, A공사 소속 직원(주임)으로부터 직접 지시사항을 전달받았다. 업무 종료 후에도 A공사 직원에게 보고서를 제출하고, 전산시스템을 통해 확인을 받는 등 업무 수행 과정 전반이 A공사의 직접적인 통제하에 있었다.

## **(2) 인사관리의 실질적 지배**

- 외주업체들은 수납원들의 근무편성표와 출퇴근 사항을 A공사 소속 영업소장에게 보고하였다. 이는 외주업체가 독자적으로 인사권을 행사하는 것이 아니라 A공사의 관리 체계 안에서 종속적으로 인력을 운영했음을 의미한다.

## **(3) 매뉴얼을 통한 구체적 통제**

- A공사가 제작하여 배포한 매뉴얼은 단순한 가이드라인을 넘어 행동, 표정, 언어, 예절 등 매우 구체적인 업무 수행 방식을 규정하고 있다. 수납원들이 이에 따라 업무를 수행한 것은 A공사가 업무의 내용과 방식을 결정했음을 보여준다.

## **IV. 결론**

- 사안의 개인사업자 B는 자금, 시설, 고객 확보 등 모든 측면에서 A공사에 전적으로 종속되어 있어 사업주로서의 독자성과 실체를 갖추지 못한 명목상의 사업주에 불과하다. 또한, 실질적인 업무 지휘·감독권과 인사관리권 역시 A공사가 행사하고 있음이 명백하다. 따라서 판례의 묵시적 근로계약관계 성립 법리에 따라 甲은 형식적인 계약 상대방인 B가 아니라 실질적인 사용자인 A공사와 직접적인 근로계약관계에 있다고 보아야 한다. 결론적으로 자신이 A공사에 직접 채용된 근로자라는 甲의 주장은 타당하다.

《[문제1] A공사는 고속국도의 설치·관리 및 통행료 수납업무를 수행하는 공기업이다. 개인사업자 B는 2018. 6. 30. A공사에서 정년퇴직한 자로서, 2018. 12. 31. 수의(隨意)계약 방식으로 A공사와 통행료 수납업무에 관한 용역계약을 체결하였다(계약기간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.). B는 용역업체의 창업에 소요된 5천만 원 전액을 A공사로부터 연 1%의 이자율로 차입하여 조달하였고, 별도의 사무실을 두지 않았으며, 용역계약에 따라 A공사의 영업소에서 근무할 수납원 외에는 다른 근로자를 채용하지 않았으며, 2020. 8. 15.까지 A공사 이외의 거래처에서 발생한 매출은 없다. B는 용역계약의 이행을 위하여 2019. 1. 1. A공사로부터 소개받은 甲과 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하였다. 甲은 채용과 동시에 A공사가 관리하는 ○○영업소의 통행료 수납원으로 발령받아 계속 근무하고 있다.

한편, C사는 시설관리 등을 사업목적으로 2000. 1. 1. 설립된 회사로서 2020. 8. 15. 현재 자본금은 5억 원이며, 다수의 거래처로부터 시설관리 등의 업무를 도급받아 수행하고 있다. 다만, C사는 근로자파견사업의 허가를 받지 아니하였다. C사는 2017. 12. 31. 공개입찰 방식으로 2018. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.의 1년의 계약기간으로 A공사와 통행료 수납업무 용역계약을 체결하였고, 이후 같은 방식으로 두 차례 계약을 갱신하였다. C사는 기존에 근무하던 수납원이 퇴직하여 결원이 생기자 구직자를 모집하여 2019. 8. 14. 乙과 1년의 계약기간으로 근로계약을 체결하였다. 乙은 채용과 동시에 A공사가 관리하는 △△영업소의 통행료 수납원으로 발령받아 근무하던 중 2020. 8. 13. 계약기간이 만료되어 C사에서 퇴사하였다. C사는 乙에게 기존과 동일한 조건으로 근로계약을 갱신할 것을 제안하였으나, 乙은 A공사에게 나를 직접 고용하라고 요구하였다. 乙이 그 제안을 거절하였다.

A공사는 사전에 정해 둔 용역대금 산정기준에 따라 B 및 C사 등 외주업체와 용역계약을 체결하였고, A공사의 영업소는 A공사의 직원인 소장, 과장, 대리, 주임과 외주업체 소속인 수납원으로 구성되어 있다. 수납원들은 A공사의 영업소 사무실로 출근하여 A공사의 로고가 새겨진 근무복과 명찰을 착용한 후 주임으로부터 지시사항을 전달받고 요금소로 이동하여 통행료 수납업무 등을 수행하였다. 또 수납원들은 교대시간 또는 근무시간 종료 후 사무실로 이동하여, 징수한 통행료를 확인한 후 주임에게 입금확인서와 개인별 근무확인서를 작성·제출하였고, 주임은 이러한 개인별 근무확인서의 내용이 A공사의 전산시스템에 자동 저장된 정보와 일치하는지 확인하고 소장의 결재를 받았다. 한편, 외주업체들은 영업소 소장에게 매월 소속 수납원들의 근무편성표, 출퇴근 사항을 보고하였다. A공사는 2018. 1. 1. 통행료 수납업무와 관련하여 고객을 응대할 때의 행동, 표정, 언어, 예절, 자세, 예외적 상황별 고객 응대 요령 등이 기재된 매뉴얼을 제작하여 외주업체에 배포하였고, 외주업체 소속 수납원들은 이러한 매뉴얼에 따라 업무를 수행하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 乙은 자신이 A공사에 파견된 근로자였음을 이유로 A공사가 자신을 직접 고용할 의무가 있다고 주장한다. 판례법리에 근거하여 乙의 주장의 타당성을 논하시오. (다만, 파견대상업무에 관한 부분은 논점에서 제외한다.) (30점)》

#### <문제1의 물음2> 통행료 수납원의 근로자파견 여부 및 무허가 파견에 따른 직접고용의무

##### I. 문제의 제기

- 사안은 A공사가 통행료 수납업무를 외주업체와 용역계약 형식으로 수행하는 과정에서, 외주업체 C사와 근로계약을 체결하고 실제 A공사의 영업소에서 근무한 乙이 자신은 실질적으로 A공사에 파견된 근로자에 해당하며, 따라서 A공사가 파견근로자보호 등에 관한 법률(이하 '파견법') 제6조의2에 따른 직접고용의무를 부담한다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <통행료수납원 乙과 A공사의 관계가 근로자파견에 해당하는지>, <근로자파견에 해당한다면 무허가 파견업체인 C사에서 乙이 1년만 근무했음에도 A공사에게 직접고용의무가 발생하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 근로자파견과 도급의 구별 및 무허가 파견에 따른 직접고용의무 법리를 살펴보고 사안에 적용하여 乙 주장의 타당성을 논한다.

##### II. 근로자파견의 판단 기준 및 직접고용의무 법리

###### 1. 근로자파견과 도급의 구별 기준

###### (1) 구별 원칙

- 근로자파견 여부는 용역계약과 같은 형식적 계약의 명칭과 무관하게 실질적인 사용 형태에 따라 판단한다.

###### (2) 대법원의 구체적 판단 기준

- 대법원은 원청이 하청 근로자에게 업무상 지휘·명령을 하는지, 하청 근로자가 원청 소속 근로자와 공동근로체를 구성하여 편입되었는지, 하청업체가 채용·배치 등 독자적 인사관리권을 행사하는지, 하청업체가 전문성과 인프라를 갖춘 독립된 기업인지, 수행 업무가 구별되는 독립적 성격인지 등을 종합 고려하여 판단한다.

###### 2. 불법파견에 따른 직접고용의무 발생 법리

###### (1) 무허가 파견의 즉시 발생

- 파견법 제6조의2 제1항 제5호에 따라 사용사업주가 허가받지 않은 자로부터 파견 역무를 제공받은 무허가 파견의 경우 직접고용의무가 발생한다. 무허가 파견은 적법 파견과 달리 사용 기간이 2년을 초과했는지 여부와 무관하게 즉시 직접고용의무가 발생한다.

###### (2) 계약 만료 시 직접고용권의 유지

- 직접고용의무는 강행규정이므로, 파견계약기간이 만료되었거나 근로자가 하청의 계약 갱신을 거절하였다 하더라도 이미 발생한 사용사업주의 직접고용의무와 근로자의 직접고용청구권은 소멸하지 않는다.

##### III. 사안의 적용

###### 1. 乙의 근로자파견 해당 여부

###### (1) 지휘·명령 및 공동근로체 편입성

- 수납원들은 A공사의 근무복을 입고 A공사 주임으로부터 직접 업무 지시를 받았으며, 퇴근 시 징수 통행료를 보고하고 전산 확인을 거쳤다. 업무 수행도 A공사의 매뉴얼에 구속되었다. 이는 A공사가 구체적인 지휘·명령을 행사하여 乙이 A공사의 공동근로체에 실질적으로 편입되었음을 보여준다.

###### (2) 인사관리 및 독자성 결여

- C사가 독립 법인격을 갖추었더라도 근무편성과 출퇴근을 매월 A공사에 보고해 통제를 받았다. 또한 수납업무는 특별한 기술이 필요 없는 표준화된 업무로서 A공사 사업의 필수적 일부이다. 따라서 C사는 인사관리 및 독자성을 결여하였으므로 乙의 근로 실질은 근로자파견에 해당한다.

###### 2. A공사의 직접고용의무 성립 여부

###### (1) 무허가 파견과 직접고용의무

- C사는 무허가 파견업체이므로 파견법을 위반한 무허가 파견에 해당한다. 무허가 파견은 즉시 직접고용의무가 발생하므로, 乙의 파견근로기간이 1년에 불과하여 2년을 초과하지 않았더라도 A공사는 乙을 직접 고용할 의무를 진다.

## (2) 갱신 거절과 고용의무 유지

- 乙이 C사의 계약 갱신 제안을 거절하고 A공사에 직접고용을 요구한 것은 적법한 권리 행사이다. 하청과의 계약 종료로 사용사업주의 고용의무가 소멸하지 않으며, 乙이 직접고용에 반대하지 않고 적극적으로 청구하므로 A공사는 乙을 직접 고용하여야 한다.

## IV. 결론

- 乙의 근로관계 실질은 근로자파견에 해당하며, C사는 무허가 파견업체이다. 무허가 파견은 파견 기간이 2년 미만이라도 사용사업주에게 즉시 직접고용의무가 발생한다. 乙이 C사의 근로계약 갱신을 거절했더라도 이미 발생한 직접고용의무는 소멸하지 않는다. 따라서 자신을 직접 고용하여야 한다는 乙의 주장은 정당하다.

<제10장 업무상 재해 등 제01절 업무상 재해>

[기출][1][2020-2]산업재해보상보험법상 2차 회식의 업무상 재해 인정 여부

《[문제2] 근로자 甲은 A회사의 상담팀에 소속된 상담원으로서, 2019. 7. 5. 오후 7시부터 같은 날 오후 9시까지 음식점에서 상담팀 책임자인 실장을 포함하여 30명의 직원과 함께 1차 회식을 하였다. 1차 회식에서 실장이 참석 직원들에게 술잔을 돌리거나 술을 권하지 않았다. 甲이 1차 회식에서 자신의 평소 주량보다 많은 술을 급하게 마시자 실장이 이를 만류하였으나, 甲은 실장의 만류에도 불구하고 계속 술을 마시 1차 회식이 끝날 당시 이미 만취한 상태였다. 1차 회식이 마무리되던 즈음 실장이 회사로부터 사용을 허락받은 회식비가 남았으니 노래연습장에 가서 2차를 하자고 제안하였다. 이에 같은 날 오후 9시 15분경 실장과 근로자 甲을 포함한 12명이 바로 옆 건물 4층에 있는 노래연습장으로 자리를 옮겨 2차 회식을 하였다.

甲은 노래연습장으로 옮기고 얼마 지나지 않아 화장실을 찾기 위해 노래연습장에서 나왔다. 같은 층에 있는 비상구 문을 열고 들어가 화장실을 찾던 중 건물 밖으로 나 있는 커다란 창문을 화장실 문으로 오인하여 밑에 놓여있는 발판을 밟고 올라가 창문을 열고 나갔다가 건물 밖으로 추락하여 골반골절 등의 부상을 입었다.

이 사건 재해가 산업재해보상보험법상 요양급여의 대상이 되는지 설명하시오. (25점)》

<문제2> 산업재해보상보험법상 2차 회식의 업무상 재해 인정 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 근로자 甲이 회식 과정에서 자발적으로 과음하여 만취한 상태로 노래연습장 비상구 창문을 화장실 문으로 오인해 추락하는 사고가 발생한 상황이다. 쟁점으로 <해당 회식이 사업주의 지배·관리하에 있었는지>, <회식 중 자발적 과음으로 발생한 추락 사고와 업무 사이에 상당인과관계가 인정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 회식 중 사고에 대한 업무상 재해 판단 기준과 과음으로 인한 사고의 상당인과관계 법리를 검토하고 이를 사안에 대입하여 요양급여 대상이 되는지 설명한다.

II. 회식 중 재해의 업무상 재해 인정 요건과 상당인과관계 법리

1. 회식 중 재해의 일반적 인정 기준

(1) 사업주의 지배·관리하의 회식

- 근로자가 사회통념상 행사나 모임의 주최자, 목적, 내용, 참가인원과 그 강제성 여부, 운영방법, 비용 부담 등에 비추어 사업주의 지배·관리를 받는 회식에 참가하던 중 재해를 입은 경우 업무상 재해로 인정될 수 있다.

(2) 통상 수반되는 위험 범위의 판단

- 회식 중 재해가 업무상 재해로 인정되려면 단순히 지배·관리하의 회식이었다는 사실만으로는 부족하며, 발생한 재해가 업무 또는 회식 과정에 일반적으로 수반되는 위험의 범위 내에 있어야 한다.

2. 회식 중 과음으로 인한 사고의 상당인과관계 판단 기준

(1) 상당인과관계 판단의 종합적 요소

- 법원은 업무와 과음, 재해 사이의 상당인과관계를 판단할 때 회식의 목적과 성격, 참석 여부의 강제성, 비용 부담 주체 등 회식 자체의 지배·관리 정도, 상급자나 다른 참석자들의 음주 권유나 강요 또는 만류 여부, 근로자 본인의 음주량 등을 종합 평가한다.

(2) 자발적 과음과 통상적 위험성 일탈

- 사업주나 상급자의 강요가 없음에도 근로자가 자발적으로 자신의 주량을 초과하여 현저한 과음을 하였고, 그것이 주된 원인이 되어 통상적으로 회식에 수반되는 위험이라고 보기 어려운 돌발적인 사고가 발생한 경우에는 상당인과관계가 인정되지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 회식의 사업주 지배·관리 여부

(1) 1차 및 2차 회식의 성격

- 1차 회식은 실장을 포함해 30명의 직원이 참가한 공식 회식이었고, 2차 노래연습장 회식 역시 실장의 주도하에 회사 승인 회식비를 사용하기로 하고 진행된 것이므로 전체적으로 사업주가 주최하고 관리한 회식에 해당한다.

(2) 지배·관리성 인정의 한계

- 따라서 甲이 참가한 1차 및 2차 회식은 외형상 사업주의 지배·관리하에 있는 업무수행의 연장선으로 볼 여지가 충분히 존재한다.

2. 과음의 자발성 및 만류 사실의 존재

(1) 강요 없는 음주와 실장의 적극적 만류

- 실장은 참석자들에게 술잔을 권하거나 음주를 강요하지 않았고, 오히려 甲이 주량을 초과하여 술을 마시자 이를 적극 만류하였다.

(2) 통상 수반되는 위험 범위의 일탈

- 노래연습장의 비상구 문 안쪽에 있는 밖으로 열린 창문을 화장실 문으로 오인해 밟고 올라가 추락한 것은 업무적 회식 과정에 일반적으로 수반되는 위험이라기보다, 甲의 자발적 과음으로 인한 통제력 상실이 결정적 원인이다.

3. 상당인과관계의 단절

(1) 재해의 직접적인 유발 원인

- 이 사건 사고는 사업주가 관리할 수 없는 甲의 자발적인 음주 행위가 주된 원인이 되어 발생하였으므로, 회식의 공익적 목적이거나 업무적 성격과 직접 결부되어 발생한 사고로 볼 수 없다.

(2) 상당인과관계의 부정

- 결국 업무적 성격을 띤 회식에 참가하였다는 외관이 존재함에도 불구하고, 자발적 과음이라는 甲의 귀책사유로 인해 업무와 재해 사이의 상당인과관계는 법률상 단절된다.

IV. 결론

- 甲이 참여한 회식이 사업주의 지배·관리하에 주최된 것이라 하더라도, 강요가 없는 상태에서 실장의 만류를 무시하고 자발적으로 주량을 초과해 과음한 것이 사고의 직접적 원인이다. 또한, 비상구 창문을 화장실로 오인해 추락한 것은 회식에 통상 수반되는 위험의 범위를 벗어난 돌발 사고에 해당하여 상당인과관계가 인정되지 않는다. 따라서 이 사건 재해는 산업재해보상보험법상 업무상 재해에 해당하지 않으므로 요양급여의 대상이 될 수 없다.

<관련 판례>

- 대법원 2017. 5. 30. 선고 2016두54589 판결 : 근로자의 음주에 대한 자발성이 없어 업무상 재해로 인정된 판례

<제05장 취업규칙.제02절 취업규칙의 변경>

[기출][1][2021-1-1]비조합원에 대한 불이익 취업규칙 적용의 효력

《【문제1】 A회사는 직급이 1급인 근로자인 甲과 2014. 3.경 기본연봉을 70,900,000원으로 정한 연봉계약을 체결하였다. A회사는 2014. 6. 25. A회사 소속 근로자의 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 받아 취업규칙인 임금피크제 운용세칙을 제정, 공고하였다. 임금피크제 운용세칙 제정으로 개정된 취업규칙은 연봉계약이 정하는 기본연봉에 복리후생비를 더한 총연봉을 임금피크 기준연봉으로 정하고, 정년이 2년 미만 남아 있는 근로자에게는 임금피크 기준연봉의 40%를 지급하도록 규정하였다. 이에 대해 甲이 임금피크제의 적용에 동의하지 아니한다는 의사를 표시하였으나 A회사가 甲에게 취업규칙에 따라 삭감된 임금을 지급하였다. 즉 A회사는 甲에게 취업규칙이 정하는 바에 따라 2014. 10. 1.부터 2015. 6. 30.까지는 정년이 2년 미만 남아 있다는 이유로 기준연봉의 60%, 2015. 7. 1.부터 2016. 6. 30.(甲의 정년퇴직일)까지는 정년이 1년 미만 남아 있다는 이유로 기준연봉의 40%를 지급하였다. A회사가 2014. 9. 23. 취업규칙에 따라 임금피크제 적용으로 감액된 임금내역을 통지하자, 甲은 단체협약에서 노동조합원 자격이 없는 자로 정한 1급 직원으로 甲에게 노동조합과의 합의 결과인 임금피크제를 적용하는 것은 위법하다고 주장한 다음, 甲은 A회사에게 임금피크제의 적용에 동의하지 아니한다는 의사를 표시하였다. 甲은 종전 업무를 그대로 수행하다가 2016. 6. 30.자로 정년퇴직하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사가 노동조합원 자격이 없는 甲에게 노동조합과의 합의 결과인 개정된 취업규칙에서 정한 임금피크제를 적용하는 것은 위법하다고 하는 甲의 주장은 정당한지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음1> 비조합원에 대한 불이익 취업규칙 적용의 효력

I. 문제 제기

- 사안에서 A회사는 노동조합 과반수의 동의를 받아 임금피크제 운용세칙을 제정하고, 정년이 임박한 근로자의 임금을 삭감하는 내용을 취업규칙에 반영하였다. 근로자 甲은 1급 직원으로서 단체협약상 노동조합원이 될 수 없다는 점을 근거로, 자신에게 임금피크제를 적용하는 것은 위법하다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <노동조합원 자격이 없는 근로자에게도 노동조합의 동의를 통한 불이익 취업규칙 변경의 효력이 미치는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 개정된 취업규칙의 임금피크제를 자신에게 적용하는 것은 위법하다고 하는 甲의 주장이 정당한지 논한다.

II. 취업규칙 불이익 변경의 법리

1. 근로기준법 제94조의 체계

- 근로기준법 제94조는 사용자가 취업규칙을 작성·변경할 때 근로자 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우 그 동의를 얻도록 규정한다. 이는 개별 근로자의 동의가 아니라 집단적 동의를 통해 절차적 정당성을 확보하고, 근로조건을 통일적으로 적용하기 위한 제도이다.

2. 취업규칙의 대외적 구속력

- 취업규칙은 근로계약의 내용을 규율하는 준칙적 효력을 가지므로, 일단 적법하게 성립·변경된 이상 사업장 내 모든 근로자에게 적용된다. 즉, 조합원 여부와 관계없이 동일한 사업장 근로자라면 그 효력이 미친다. 이는 근로조건 통일성과 형평성을 확보하기 위한 것이다.

3. 불이익 변경의 요건과 효력

(1) 절차적 요건

- 근로자 과반수노조의 동의 또는 근로자 과반수의 동의가 필요하다.

(2) 실체적 요건

- 근로조건 불이익 변경의 경우에도 기업 존립과 운영상 불가피한 필요성과 근로자 전체의 이익형량을 통해 사회적 타당성이 인정되어야 한다.

(3) 효력

- 위 요건이 충족된 경우 개별 근로자가 동의하지 않더라도 취업규칙은 적용된다.

4. 노동조합 비조합원 근로자와의 관계

- 노동조합은 조합원 이익을 대변하는 집단이지만, 근로기준법상 과반수노조의 동의권은 조합원 자격에 한정되지 않고 사업장 내 모든 근로자를 대표하는 것으로 본다. 따라서 단체협약상 조합원에서 제외된 근로자라고 하더라도, 적법하게 변경된 취업규칙의 적용을 면할 수 없다.

III. 사안의 적용

1. 취업규칙 변경의 절차적 정당성

- A회사는 소속 근로자의 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 얻어 임금피크제 운용세칙을 제정하였다. 근로자 甲은 단체협약상 조합원이 될 수 없지만, 근로기준법 제94조는 조합원 자격이 있는 근로자가 아니라 근로자 과반수로 조직된 노동조합을 요건으로 규정한다. 따라서 노동조합의 동의는 사업장 전체 근로자를 구속하는 집단적 절차로서 효력이 인정된다.

2. 적용 범위에 관한 검토

- 甲은 조합원이 아니므로 임금피크제 적용이 위법하다고 주장하였으나, 취업규칙은 근로자 개인의 조합원 자격과 무관하게 사업장 전체 근로자에게 적용된다. 대법원은 근로기준법상 과반수노조의 동의는 사업장 근로자 전체를 대표하는 것으로, 비조합원 근로자에게도 구속력이 미친다고 판시한 바 있다. 따라서 甲에게도 임금피크제 취업규칙은 적용된다.

3. 실체적 정당성

- 본 사안에서 임금피크제는 정년이 임박한 근로자의 임금을 단계적으로 삭감하는 제도로, 기업의 인건비 부담을 완화하고 고용을 유지하기 위한 제도로 도입되었다. 대법원은 임금피크제가 불이익 변경임에도 불구하고 기업 존립 및 근로자 고용 유지라는 정당한 필요성이 있다면 사회적 상당성이 인정된다고 본다. 따라서 특별한 사정이 없는 한 임금피크제 자체가 사회적으로 현저히 부당하다고 보기 어렵다.

4. 개별 동의의 불요

- 甲이 개별적으로 임금피크제 적용을 거부하는 의사를 표시하였다고 하더라도, 이는 취업규칙 효력을 저지할 수 없다. 근로기준법 체계상 집단적 동의가 확보되면 개별 근로자의 부동의에도 불구하고 불이익 변경 취업규칙은 효력이 발생한다.

IV. 결론

- 취업규칙은 근로조건을 집단적 규율규범으로서, 사업장 내 모든 근로자에게 적용된다. 근로기준법 제94조에 따른 불이익 변경의 절차가 적법하게 이행된 이상, 단체협약상 조합원 자격에서 제외된 근로자라도 그 효력을 면할 수 없다. 따라서 A회사가 노동조합 과반수의 동의를 얻어 제정한 임금피크제를 근로자 甲에게 적용한 것은 위법하다고 볼 수 없으며, 甲의 주장은 정당하지 않다.

<제05장 취업규칙.제02절 취업규칙의 변경>

[기출][1][2021-1-2]개별 근로자 대상 근로계약 대비 불이익 취업규칙의 동의 없는 적용 가능 여부

《【문제1】 A회사는 직급이 1급인 근로자인 甲과 2014. 3.경 기본연봉을 70,900,000원으로 정한 연봉계약을 체결하였다. A회사는 2014. 6. 25. A회사 소속 근로자의 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 받아 취업규칙인 임금피크제 운용세칙을 제정, 공고하였다. 임금피크제 운용세칙 제정으로 개정된 취업규칙은 연봉계약이 정하는 기본연봉에 복리후생비를 더한 총연봉을 임금피크 기준연봉으로 정하고, 정년이 2년 미만 남아 있는 근로자에게는 임금피크 기준연봉의 40%를 지급하도록 규정하였다. 이에 대해 甲이 임금피크제의 적용에 동의하지 아니한다는 의사를 표시하였으나 A회사가 甲에게 취업규칙에 따라 삭감된 임금을 지급하였다. 즉 A회사는 甲에게 취업규칙이 정하는 바에 따라 2014. 10. 1.부터 2015. 6. 30.까지는 정년이 2년 미만 남아 있다는 이유로 기준연봉의 60%, 2015. 7. 1.부터 2016. 6. 30.(甲의 정년퇴직일)까지는 정년이 1년 미만 남아 있다는 이유로 기준연봉의 40%를 지급하였다. A회사가 2014. 9. 23. 취업규칙에 따라 임금피크제 적용으로 감액된 임금내역을 통지하자, 甲은 단체협약에서 노동조합원 자격이 없는 자로 정한 1급 직원으로 甲에게 노동조합과의 합의 결과인 임금피크제를 적용하는 것은 위법하다고 주장한 다음, 甲은 A회사에게 임금피크제의 적용에 동의하지 아니한다는 의사를 표시하였다. 甲은 종전 업무를 그대로 수행하다가 2016. 6. 30.자로 정년퇴직하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사가 기본연봉을 정한 근로계약을 체결한 甲의 동의 없이 과반수로 조직된 노동조합의 동의를 얻어 개정된 취업규칙에 따라 임금피크제를 甲에게 적용할 수 있는지 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 개별 근로자 대상 근로계약 대비 불이익 취업규칙의 동의 없는 적용 가능 여부

I. 문제 제기

- 사안에서 甲은 개별 근로계약에서 기본연봉 70,900,000원을 정하였고, 이에 따라 연봉계약이 그의 근로조건을 구체적으로 확정하고 있다. 그런데 A회사는 과반수 노동조합의 동의를 얻어 불이익 취업규칙 변경에 해당하는 임금피크제 운용세칙을 제정하였고, 이를 甲에게 적용한 상황이다. 쟁점으로 <개별 근로계약으로 확정된 임금조건이 존재하는 경우에도 집단적 절차를 거쳐 개정된 취업규칙이 우선 적용될 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 취업규칙과 근로계약의 관계 및 근로자 동의 없는 불이익 변경 적용 가능성을 중심으로 임금피크제를 甲에게 적용할 수 있는지 논한다.

II. 취업규칙과 근로계약의 관계 법리

1. 근로계약의 원칙적 지위

- 근로계약은 사용자와 근로자 간에 구체적 근로조건을 확정하는 기본 법률행위이다. 근로계약으로 정한 조건은 원칙적으로 당사자 간 합의 없이는 변경될 수 없다.

2. 취업규칙의 효력

- 취업규칙은 근로계약의 내용을 규율하는 준칙적 효력을 가지며, 원칙적으로 근로계약과 동일한 효력을 가진다. 근로계약과 취업규칙의 관계에 관하여 판례는 근로계약의 내용이 취업규칙보다 우선하되, 근로계약에서 정하지 않은 사항은 취업규칙에 의해 보완된다고 본다.

3. 취업규칙 불이익 변경과 근로계약의 효력 충돌

- 근로조건 불이익 변경의 경우, 적법하게 절차가 이행된 취업규칙 변경은 그 자체로 효력을 가지지만, 기존 개별 근로계약에 명시적으로 규정된 조건을 변경하려면 원칙적으로 개별 근로자의 동의가 필요하다. 대법원 판례는 개별 근로계약에서 구체적으로 정한 임금 수준은 근로자의 동의 없이는 취업규칙의 불이익 변경으로 일방적으로 변경할 수 없다고 판시한다. 따라서 취업규칙은 근로계약의 내용으로서 일반적으로 적용되지만, 개별 근로계약이 이미 구체적으로 정한 조건보다 불리한 내용으로 일방적으로 변경할 수는 없다.

4. 단체협약·노동조합 동의와의 관계

- 근로기준법 제94조가 정한 과반수 노동조합의 동의는 사업장 전체 근로자를 대상으로 하는 집단적 효력 확보 절차에 불과하다. 그러나 이는 개별 근로계약에서 명확히 보장된 조건을 무력화하는 근거가 될 수 없다. 즉, 취업규칙 변경의 효력은 원칙적으로 근로계약에서 정하지 않은 부분에 미치는 것이지, 이미 계약으로 확정된 근로조건에는 영향을 미치지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 개별 근로계약의 존재

- 甲은 2014년 3월경 기본연봉 70,900,000원을 지급받기로 하는 명시적 연봉계약을 체결하였다. 이는 임금 수준을 구체적으로 확정된 개별 근로계약이다. 따라서 이 임금액은 근로조건 확정적 내용으로 보아야 한다.

2. 취업규칙 변경의 적용 주장

- A회사는 2014년 6월 과반수노조의 동의를 얻어 임금피크제 운용세칙을 제정하였고, 이에 따라 정년이 2년 미만 남은 甲의 임금을 삭감하였다. 그러나 이 변경은 甲의 기존 연봉계약에서 정한 금액을 직접적으로 감액하는 것이므로, 개별 근로계약상의 조건을 불이익하게 변경하는 행위에 해당한다.

3. 개별 근로자의 동의 필요성

- 불이익 취업규칙 변경은 원칙적으로 집단적 동의를 통해 효력을 인정받지만, 개별 근로계약에 이미 구체적으로 정해진 조건을 직접 변경하는 경우에는 개별 근로자의 동의가 있어야 한다. 본 사안에서 甲은 명시적으로 임금피크제 적용에 동의하지 않는다고 표시하였다. 따라서 A회사가 취업규칙 변경만으로 甲의 연봉을 삭감한 것은 위법하다.

4. 판례의 태도

- 대법원은 근로자가 이미 개별 근로계약으로 정해진 연봉을 지급받을 권리를 가진 경우, 불이익 취업규칙 변경을 이유로 사용자가 일방적으로 감액된 임금을 지급할 수는 없다고 판시하였다. 이는 본 사안에 직접 적용될 수 있는 법리이다.

IV. 결론

- 본 사안에서 A회사는 과반수 노동조합의 동의를 받아 임금피크제 취업규칙을 제정하였으나, 이는 근로자 甲과 이미 체결된 연봉계약의 구체적 임금 조건을 불이익하게 변경하는 효과를 가진다. 이러한 경우에는 개별 근로자의 명시적 동의가 필요하며, 동의가 없는 상태에서 일방적으로 적용하는 것은 위법하다. 따라서 A회사는 甲의 동의 없이 개정된 취업규칙에 따른 임금피크제를 적용할 수 없다.

## <제08장 근로관계의 종료.제04절 부당해고의 구제>

[기출][1][2021-2]정년 도달로 근로관계가 종료된 경우 부당해고 재심판정취소소송의 소의 이익 존부

《[문제2] 근로자 乙은 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하고 근무하던 중 2020. 2. 28. 취업규칙에서 정한 징계사유와 절차에 따라 징계해고 처분을 받았다. 乙은 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하였고, 관할 지방노동위원회는 2020. 6. 1., 중앙노동위원회는 2020. 9. 1. 각각 乙에 대한 해고에 정당한 이유가 있다고 보아 기각하였다. 乙은 중앙노동위원회 재심판정취소를 구하는 소송을 행정법원에 제기하였고, 소송이 진행되던 중 乙은 2020. 12. 31. 정년 도달로 당연퇴직하였다. 행정법원은 2021. 6. 1. 乙이 정년에 도달하여 당연퇴직하였으므로 소의 이익이 없다는 이유로 각하하였다. 乙의 정년 도달로 근로관계가 종료되었으므로 소의 이익이 없다는 행정법원의 각하는 정당한지 논하시오. (25점)》

### <문제2> 정년 도달로 근로관계가 종료된 경우 부당해고 재심판정취소소송의 소의 이익 존부

#### I. 문제 제기

- 본 사안은 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자 乙이 징계해고 처분을 받아 부당해고 구제신청을 제기하였고, 노동위원회 단계에서 기각되자 재심판정취소소송을 제기하였으나, 소송 도중 정년퇴직에 이르렀다는 이유로 법원이 소의 이익을 부정한 상황이다. 쟁점으로 <정년 도달로 근로관계가 종료된 경우에도 부당해고 구제명령을 다투는 소송에서 소의 이익이 인정되는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 소의 이익 개념, 노동위원회 구제 명령 제도의 목적, 부당해고 구제신청과 해고 무효확인소송의 차이를 종합적으로 고려하여 해당 행정법원의 각하가 정당한지 논한다.

#### II. 부당해고 구제명령 제도의 성격

##### 1. 구제명령 제도의 취지

- 근로기준법 제28조에서 규정한 부당해고 구제제도는 근로자의 신분과 생활을 보장하고 사용자의 자의적 해고를 방지하려는 데 목적이 있다. 노동위원회는 해고가 부당하다고 판단되면 원직복직 및 해고기간 동안의 임금상당액 지급을 명할 수 있다.

##### 2. 구제명령의 실제적 효과

- 부당해고가 인정되면 근로자는 해고기간 동안의 임금상당액을 보전받고, 복직을 통한 신분적 회복을 누릴 수 있다. 반대로 부당해고가 인정되지 않으면 사용자의 해고는 정당한 것으로 확정되어 근로자의 권리구제는 단절된다.

##### 3. 재심판정취소소송의 목적

- 노동위원회의 판정은 행정처분으로서 불복 시 행정소송법상 항고소송인 취소소송을 제기할 수 있다. 이 소송의 목적은 노동위원회의 판정이 적법한지를 다투어 구제명령 여부를 바로잡는 데 있다. 따라서 단순한 해고무효확인소송과는 구별된다.

#### III. 소의 이익과 정년 도달의 효과

##### 1. 소의 이익 일반론

- 행정소송에서 소의 이익은 소송요건으로, 소의 대상이 된 처분의 취소를 구할 필요성이 객관적으로 존재해야 한다. 통상 처분의 효력이 이미 소멸하였거나 그 취소로 법률상·사실상 이익을 얻을 수 없는 경우 소의 이익은 부정된다.

##### 2. 정년 도달 시 복직 가능성

- 정년에 이르면 근로관계는 당연히 종료되므로 부당해고 구제명령을 통해 원직복직을 명하는 것은 불가능하다. 따라서 신분 회복이라는 의미에서의 소의 이익은 소멸한다.

##### 3. 해고기간 임금상당액 지급 가능성

- 그러나 정년 도달 이전의 해고 기간 동안 근로자가 정상적으로 근로하였다면 받을 수 있었던 임금 상당액은 여전히 쟁점으로 남는다. 해고가 부당하다면 그 기간에 대해 임금 보전이 가능하므로 금전적 이익을 인정할 필요가 있다.

##### 4. 판례의 입장

- 대법원은 부당해고 구제명령은 근로자가 해고기간 동안 근로를 제공하지 못함으로써 입은 손해를 보전하고, 해고의 부당성을 확인하는 의미가 있으므로, 설령 정년에 도달하여 원직복직이 불가능하게 되었다 하더라도 해고기간 임금상당액 지급에 관한 권리구제의 필요성은 남아 있다고 판시하였다. 따라서 정년 도달을 이유로 소의 이익을 전면적으로 부정하는 것은 타당하지 않다.

#### IV. 사안의 적용

##### 1. 정년 도달 전후의 권리관계

- 乙은 2020. 2. 28. 해고되었고, 2020. 12. 31. 정년에 도달하였다. 따라서 2020. 2. 28.부터 2020. 12. 31.까지 약 10개월간은 부당해고 구제명령을 통해 보전받을 수 있는 임금상당액 청구권의 존부가 문제된다. 정년 이후에는 복직과 임금 청구가 불가능하나, 정년 이전 기간에 대한 권리구제 필요성은 여전히 존속한다.

##### 2. 행정법원의 판단의 문제점

- 행정법원은 乙이 정년에 도달하였으므로 복직이 불가능하다는 이유로 소의 이익을 부정하였다. 그러나 이는 부당해고 구제명령의 금전적 효과를 간과한 판단이다. 정년 전 해고기간 동안의 임금상당액에 관한 권리구제는 여전히 가능하므로, 소의 이익이 일부 존속한다.

##### 3. 검토

- 따라서 행정법원은 단순히 정년 도달을 이유로 소를 각하할 것이 아니라, 소의 이익을 인정하고 본안에서 해고의 정당성 여부를 심리·판단했어야 한다. 소의 일부 이익이 남아 있는 한 소송은 각하될 수 없으며, 본안 판결로 귀결되는 것이 옳다.

#### V. 결론

- 결론적으로 乙이 정년에 도달하였다고 하더라도 해고기간 동안의 임금상당액 지급 여부와 해고의 부당성 확인이라는 금전적·법률적 이익이 여전히 존재한다. 따라서 행정법원이 정년 도달을 이유로 소의 이익을 부정하여 각하한 것은 정당하지 않다. 부당해고 구제명령 제도의 목적과 대법원 판례의 입장에 비추어 볼 때, 본 사안은 본안 판단에 들어가 해고의 정당성 여부를 심리했어야 할 것이다. 결국 乙의 정년 도달에도 불구하고 소의 이익은 일부 존속하므로, 행정법원의 각하는 부당하다.

<제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실제적 정당성>

[기출][1][2022-1-1]근무성적 불량 저성과자 해고의 정당성 요건 및 해고처분의 타당성 여부

《【문제1】 A회사는 가전제품을 제조·판매하는 주식회사이다. A회사의 취업규칙은 제23조(징계사유)와는 별개로 제22조(해고사유) 제5호에서 근무성적 또는 능력이 현저하게 불량하여 직무를 수행할 수 없다고 인정되었을 때를 해고사유로 정하고 있다. A회사는 2016년부터 매년 하반기에 사무직 직원들을 대상으로 5개 등급(S등급 100점, A등급 80점, B등급 60점, C등급 40점, D등급 20점)의 인사평가 제도를 시행하고 인사평가의 기준과 항목을 공개하고 있으며 인사평가 결과에 대한 이의제기 절차도 체계적으로 마련하여 사무직 직원들에게 안내하고 있다. A회사는 1차 평가자(팀장)의 평가내용을 토대로 2차 평가(부서장)와 최종평가(담당 임원)를 하여 평가등급을 산정하고, 특히 상대평가 방식의 불합리성을 보완하고자 부서장과 담당 임원이 피평가자의 자질 등을 고려해 최저 등급에 해당하는 C, D등급을 주지 않을 수 있도록 재량을 부여하고 있다.

A회사 생산관리부 과장으로 근무하던 甲은 2016년 C등급을 받았고, 2017년부터 2019년까지 매년 D등급 및 직무경고를 받았으며, 2016년부터 2019년까지 기간의 인사평가 결과 전체 사무직 과장급 이상 직원 2,000명 중 최하위를 기록했다. A회사는 2017년부터 2019년까지 3년간의 인사평가결과를 기준으로 하위 2% 이내에 해당하는 甲을 포함한 과장급 이상 직원 40명을 대상으로 2020년 2월부터 같은 해 12월까지 직무역량 향상과 직무 재배치를 위한 교육을 실시하였다. 그 후 A회사는 2021년 1월경 甲을 생산품질지원부서에 재배치하였다. 甲은 직무 재배치 후 실시된 2021년 인사평가에서도 업무역량 부족, 부서 공동업무 관심 부족, 업무능력 습득의지 부족 등으로 평가되어 D등급을 받았다. 인사 담당 임원 乙은 甲과의 여러 차례 면담을 통해 甲의 그간 인사평가 결과가 취업규칙 제22조 제5호 해고사유에 해당할 수 있음을 상세히 설명하면서 6개월분 급여를 받는 조건으로 사직할 것을 甲에게 권고하였다. 그럼에도 불구하고 甲이 사직을 거부하자 A회사는 2022년 2월 4일 귀하가 당사의 사직 권유를 거부함에 따라 귀하와의 근로계약관계를 2022년 3월 3일부로 종료함을 통지합니다.라는 내용이 기재된 계약종료통지서를 甲에게 교부하였고, 이에 따라 甲은 2022년 3월 3일 해고되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲은 A회사의 인사평가 제도가 불공정하고 자의적이며 자신에 대한 A회사의 해고처분이 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도인 경우에 해당하지 않으므로 정당한 이유가 없는 해고로서 무효라고 주장한다. 이 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (단, 해고절차 및 해고통지의 적법성 여부는 논하지 않는다) (30점)》

<문제1의 물음1> 근무성적 불량 저성과자 해고의 정당성 요건 및 해고처분의 타당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 A회사에서 생산관리부 과장으로 근무하는 甲에 대해 근무성적 불량으로 권고사직을 권하였으나, 이에 불응하자 A회사가 甲을 해고한 상황이다. 쟁점으로 <A회사 인사평가 제도의 공정성과 객관성 여부, 甲의 근무성적 불량이 사회통념상 고용관계를 계속할 수 없을 정도에 이르렀는지> 여부이다. 이하에서는 근무성적 및 근무능력 결여를 이유로 하는 통상해고의 정당성 판단 기준에 관한 대법원의 판례 법리를 상세히 살펴보고 이를 사안에 대입하여 甲의 주장 및 해고의 정당성 여부에 대해 논한다.

II. 근무성적 불량으로 인한 해고의 정당성 법리

1. 근로기준법 제23조 제1항의 정당성 요건

(1) 일반적 제한 원칙과 실질적 정당성

- 근로기준법 제23조 제1항은 사용자는 근로자에게 정당한 이유 없이 해고하지 못한다고 규정하고 있다. 취업규칙에 해고사유를 정하고 있더라도 실질적인 정당한 이유가 인정되어야 해고가 유효하다.

(2) 사회통념상 고용관계 계속 불가능성

- 대법원은 근무성적 부진에 기초한 해고의 경우 ① 장기간에 걸쳐 근무실적이나 능력이 계속적으로 낮은 상태에 있고, ② 그 정도가 객관적으로 명백하여 근로자로 하여금 기업의 목적을 달성하는 데 현저한 지장을 초래하며, ③ 다른 근로자와의 형평성 및 조직 관리 차원에서 더 이상 고용관계를 유지하기 어렵다고 인정될 때 정당성이 인정된다고 본다. (대법원 2007.11.29. 선고 2007두1729 판결 등)

2. 저성과자 해고의 구체적 판단 기준

(1) 인사평가의 공정성과 객관성

- 근무성적 불량 판단의 기초가 되는 인사평가 기준과 방법이 취업규칙 등에서 정한 바에 따라 공정하고 객관적으로 설계 및 운영되었는지가 선험적으로 검토되어야 한다.

(2) 근무성적 불량의 정도와 개선 가능성

- 근무성적이나 근무능력이 상당 기간 동안 평균적인 수준에 미치지 못하고, 사용자가 성과 향상을 위한 교육과 직무 재배치 등의 기회를 제공하였음에도 향후 개선 가능성이 없어야 한다.

III. 인사평가 제도의 공정성 및 객관성 판단 기준

1. 평가 절차의 투명성 및 보장성

(1) 평가 항목의 사전 공개

- 인사평가의 세부 기준과 구체적인 평가 항목이 근로자들에게 사전에 투명하게 공개되고 충분히 공유되어야 자의적인 평가를 배제할 수 있다.

(2) 이의제기 및 피드백 절차

- 평가 결과에 대해 근로자가 다룰 수 있고 객관적인 조정을 거칠 수 있는 합리적인 이의제기 절차가 체계적으로 마련되어 실질적으로 작동해야 한다.

2. 평가의 실질적 공정성 및 편향 배제

(1) 다단계 평가 시스템

- 특정인의 주관적 편견이나 감정에 휘둘리지 않도록 1차, 2차 및 최종 평가로 이어지는 다단계 내지 다원화된 평가 시스템을 구비하여 신뢰성을 확보해야 한다.

(2) 상대평가의 한계 보완 장치

- 획일적인 상대평가 비율 분배로 인한 불합리성을 예방하기 위하여, 평가자에게 정성적 자질을 반영하여 등급을 조정할 수 있는 예외적 등급 재량을 보장하여야 한다.

IV. 사안의 적용

## 1. A회사 인사평가 제도의 공정성·객관성 인정 여부

### (1) 제도적 합리성의 구비

- A회사는 평가 항목 사전 공개, 체계적 이의제기 제도 운영, 3단계 다단계 평가 시행, 상대평가의 한계 극복을 위한 등급 부여 재량 등 객관적이고 공정하게 설계된 인사평가 요건을 구축하였다.

### (2) 평가 결과의 신뢰성

- 공정하게 운영된 인사평가 결과 하에서 甲은 4년간 전체 과장급 이상 직원 2,000명 중 최하위를 기록하고, 직무 재배치 이후에도 최저인 D등급을 받았으므로 평가의 객관성과 결과의 신뢰성이 충분히 인정된다.

## 2. 고용관계 계속 불가능성 및 개선 가능성 판단

### (1) 사용자의 성과 향상 조치 노력 제공

- A회사는 저성과자 甲에게 즉각적인 해고를 행사하지 않고, 약 10개월간 직무역량 향상 교육을 성실히 제공하였으며 생산품질지원부서로의 부서 이동을 통해 직무 재배치를 온전히 이행하였다.

### (2) 성과 개선 거부 및 개선 불가능성의 확정

- 甲은 부서 이동 이후에도 업무역량 부족, 부서 업무 관심 부족, 업무 습득 의지 부족 등 개선의 의지나 노력을 보이지 않고 최저인 D등급을 받아 향후에도 개선의 가능성을 전혀 인정하기 어렵다.

## V. 결론

- A회사의 인사평가는 공정성과 객관적인 기준에 따라 엄정하게 운영되었으므로 제도가 불공정하고 자의적이라는 甲의 주장은 부당하다. 또한 회사가 충분한 기간 동안 교육 기회와 직무 재배치를 통해 진지한 기회를 제공했음에도 甲의 개선 의지 결여로 근무성적 불량이 지속되어 사회통념상 고용관계를 계속하기 어려운 정당한 이유가 인정된다. 따라서 A회사의 해고처분은 정당한 이유가 있어 유효하며 무효라는 甲의 주장은 타당성이 없다.

<제08장 근로관계의 종료.제03절 해고의 절차적 정당성>

[기출][1][2022-1-2]근로자가 해고사유를 구두로 인지하고 있는 경우 해고통지서상 해고사유 기재 누락 시 근로기준법 위반 여부

《[문제1] A회사는 가전제품을 제조·판매하는 주식회사이다. A회사의 취업규칙은 제23조(징계사유)와는 별개로 제22조(해고사유) 제5호에서 근무성적 또는 능력이 현저하게 불량하여 직무를 수행할 수 없다고 인정되었을 때를 해고사유로 정하고 있다. A회사는 2016년부터 매년 하반기에 사무직 직원들을 대상으로 5개 등급(S등급 100점, A등급 80점, B등급 60점, C등급 40점, D등급 20점)의 인사평가 제도를 시행하고 인사평가의 기준과 항목을 공개하고 있으며 인사평가 결과에 대한 이의제기 절차도 체계적으로 마련하여 사무직 직원들에게 안내하고 있다. A회사는 1차 평가자(팀장)의 평가내용을 토대로 2차 평가(부서장)와 최종평가(담당 임원)를 하여 평가등급을 산정하고, 특히 상대평가 방식의 불합리성을 보완하고자 부서장과 담당 임원이 피평가자의 자질 등을 고려해 최저 등급에 해당하는 C, D등급을 주지 않을 수 있도록 재량을 부여하고 있다.

A회사 생산관리부 과장으로 근무하던 甲은 2016년 C등급을 받았고, 2017년부터 2019년까지 매년 D등급 및 직무경고를 받았으며, 2016년부터 2019년까지 기간의 인사평가 결과 전체 사무직 과장급 이상 직원 2,000명 중 최하위를 기록했다. A회사는 2017년부터 2019년까지 3년간의 인사평가결과를 기준으로 하위 2% 이내에 해당하는 甲을 포함한 과장급 이상 직원 40명을 대상으로 2020년 2월부터 같은 해 12월까지 직무역량 향상과 직무 재배치를 위한 교육을 실시하였다. 그 후 A회사는 2021년 1월경 甲을 생산품질지원부서에 재배치하였다. 甲은 직무 재배치 후 실시된 2021년 인사평가에서도 업무역량 부족, 부서 공동업무 관심 부족, 업무능력 습득의지 부족 등으로 평가되어 D등급을 받았다. 인사 담당 임원 乙은 甲과의 여러 차례 면담을 통해 甲의 그간 인사평가 결과가 취업규칙 제22조 제5호 해고사유에 해당할 수 있음을 상세히 설명하면서 6개월분 급여를 받는 조건으로 사직할 것을 甲에게 권고하였다. 그럼에도 불구하고 甲이 사직을 거부하자 A회사는 2022년 2월 4일 甲이 당사의 사직 권유를 거부함에 따라 甲과의 근로계약관계를 2022년 3월 3일부로 종료함을 통지합니다.라는 내용이 기재된 계약종료통지서를 甲에게 교부하였고, 이에 따라 甲은 2022년 3월 3일 해고되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A회사는 甲이 乙과의 면담을 통해 해고사유와 근거 규정이 무엇인지 구체적으로 알고 있었으므로 甲에게 교부한 계약종료통지서에 의한 해고통지가 근로기준법 제27조를 위반한 해고통지에 해당하지 않는다고 주장한다. 이 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음2> 근로자가 해고사유를 구두로 인지하고 있는 경우 해고통지서상 해고사유 기재 누락 시 근로기준법 위반 여부

I 문제의 제기

- 사안은 A회사에서 생산관리부 과장으로 근무하는 甲에 대해 업무역량 부족으로 권고사직을 권하였으나, 이에 불응하자 A회사가 甲을 해고한 상황이다. 쟁점으로 <A회사가 甲을 해고하면서 교부한 계약종료통지서에는 실질적 해고사유가 아닌 '사직 권유를 거부함에 따라'라고만 기재되어 있어, 이것이 근로기준법 제27조의 서면통지 의무를 충족하는지>, <사전에 구두 면담을 통해 甲이 실질적인 해고사유를 인지하고 있었던 정황이 서면통지 의무의 하자를 치유할 수 있는지> 여부를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 해고 서면통지 의무의 취지와 구체적 기재 수준에 관한 판례 법리를 살펴보고 사안에 대입하여 A회사 주장의 타당성에 관하여 논한다.

II 해고 서면통지의무의 관련 법리

1. 근로기준법 제27조의 의의 및 취지

(1) 해고의 서면통지 요건

- 근로기준법 제27조 제1항 및 제2항에 따르면, 사용자는 근로자를 해고하려면 해고사유와 해고시기를 서면으로 통지하여야 하며, 서면으로 통지하여야만 해고의 효력이 인정된다.

(2) 서면통지 제도의 입법 취지

- 이 규정은 해고사유와 시기를 명확히 하여 사후 분쟁을 신속하고 용이하게 해결하고, 사용자가 해고에 신중을 기하도록 유도하며, 근로자에게 해고에 대해 적절히 대응할 수 있는 방어 기회를 보장하는 데 그 목적이 있다.

2. 서면통지 시 해고사유의 기재 수준과 하자 여부

(1) 해고사유 기재의 구체성 요구

- 사용자가 해고사유를 서면으로 통지할 때는 근로자의 처지에서 해고사유가 무엇인지를 구체적으로 알 수 있어야 한다. 구체적인 사실이나 비위 내용의 기재 없이 단지 규정이나 조문만을 나열하거나 자의적인 결과만을 통지하는 것은 서면통지로서의 효력이 없다.

(2) 해고사유를 알고 있는 경우의 판단 및 사유 기재 누락의 효과

① 판례의 원칙적 입장

- 대법원은 해고 대상자가 이미 해고사유가 무엇인지 구체적으로 알고 있었고 그에 대해 충분히 대응할 수 있는 상황이었다면, 해고통지서에 사유를 다소 축약하거나 상세하게 기재하지 않았더라도 위 조항을 위반한 것이라고 볼 수 없다고 본다.

② 사유를 전혀 기재하지 않은 경우의 예외

- 다만, 대법원은 근로자가 해고사유를 구체적으로 알고 있었고 대응할 수 있는 상황이었다 하더라도, 사용자가 해고를 서면으로 통지하면서 해고사유를 전혀 기재하지 않았거나 실질적인 해고 원인이 아닌 사실만을 기재하였다면 이는 근로기준법 제27조를 위반한 해고통지에 해당한다고 판시하였다.

III 사안의 적용

1. 계약종료통지서상 해고사유의 부재

(1) 실질적 해고사유의 은폐

- 사안에서 A회사가 교부한 통지서에는 '사직 권유 거부로 인한 계약종료'라고 기재되어 있을 뿐이다. 사직 권유의 거부는 해고를 행하게 된 계기일 뿐, 취업규칙 제22조 제5호에 규정된 실질적인 해고사유인 '근무성적 또는 능력의 불량'은 서면 어디에도 기재되어 있지 않다.

(2) 해고사유의 완전한 기재 누락

- 결국 해당 서면에는 실질적 해고사유가 전혀 기재되어 있지 않은 것과 닮았으며, 이는 서면통지의 형식만을 빌렸을 뿐 실체적인 사유 기재 의무를 완전히 방기한 것에 해당한다.

2. 구두 면담 및 사전 인지 사정의 한계

(1) 통지의무의 강행규정성

- 근로자가 乙과의 사전 면담을 통해 해고사유를 알고 있었다는 사정만으로는 강행규정인 근로기준법 제27조의 법적 서면주의를 대체하거나 면제할 수 없다.

## (2) 하자의 치유 부정

- 대법원 법리에 비추어 볼 때, 해고사유를 전혀 기재하지 않은 절차상 하자는 근로자의 주관적 인식 여부에 의해 치유되지 않으므로, A회사의 서면 해고 통지는 위법하여 효력이 없다.

## IV. 결론

- 사용자가 근로자를 해고할 때 해고사유를 서면으로 통지하면서 실질적 해고사유를 전혀 기재하지 않았다면, 설령 근로자가 구두 면담 등을 통해 구체적인 해고사유를 이미 알고 있었다 하더라도 근로기준법 제27조에 위반되어 무효이다. 따라서 계약종료통지서에 실질적 사유인 근무성적 불량을 기재하지 않은 채 단지 사직 권유 거부만을 기재하여 행한 A회사의 해고통지는 절차상 명백히 위법하므로, 위반이 아니라는 A회사의 주장은 정당성이 없다.

<제03장 임금.제03절 통상임금>

[기출][1][2022-2]정기상여금의 고정성에 따른 통상임금 해당 여부

《【문제2】 상시 근로자 100명을 사용하여 금속 가공업을 하는 A회사와 노동조합이 체결한 단체협약 제20조는 정기상여금은 기본급의 600 % 지급률에 따라 지급하되, 지급일 이전에 입사, 복직, 휴직하는 사람의 정기상여금은 일할 계산한다.라고 규정하고 있다. 한편, A회사의 취업규칙 제30조는 입사 또는 퇴직한 날이 속하는 월의 임금(기본급 및 제수당)은 일할 계산하여 지급한다.라고 규정하고 있고, 취업규칙 제35조는 정기상여금은 지급일 현재 재직 중인 자에 한하여 지급한다.라고 규정하고 있다. A회사는 위와 같은 단체협약과 취업규칙에 따라 정기상여금을 2개월마다 기본급의 100 %씩 정기적, 계속적으로 지급하였는데, A회사가 실제로 지급일 이전에 퇴직한 근로자에게 정기상여금을 일할 지급하지 않았음을 확인할 수 있는 객관적 자료는 없었다. A회사의 정기상여금이 고정성이 있는 통상임금에 해당하는지를 논하시오. (25점)》

<문제2> 정기상여금의 고정성에 따른 통상임금 해당 여부

I. 문제의 제기

- 통상임금은 근로기준법상 각종 수당 산정의 기준이 되는 핵심 개념으로, 정기적 · 일률적 · 고정적으로 지급되는 임금을 의미한다. 정기상여금이 통상임금에 해당하는지 여부는 근로자에게 중대한 권리관계에 영향을 미치므로, 임금 항목의 성격과 지급조건을 면밀히 검토하여야 한다. 본 사안에서 A회사는 취업규칙과 단체협약을 각각 달리 규정하여, 단체협약은 상여금의 일할 계산 지급을 명시한 반면, 취업규칙은 재직자 요건을 둔 점에서 충돌이 발생한다. 이에 따라 <A회사가 지급해 온 정기상여금이 고정성이 있는 통상임금에 해당하는지>를 살펴본다.

II. 통상임금의 개념

- 통상임금은 근로기준법 시행령 제6조에서 근로자에게 정기적이고 일률적으로 소정(所定)근로 또는 총 근로에 대하여 지급하기로 정한 시간급 금액, 일급 금액, 주급금액, 월급 금액 또는 도급 금액을 말한다.라고 규정하고 있다. 또한 대법원 전원합의체(2012다89399)는 통상임금의 의미를 구체화하여, 정기성, 일률성, 고정성을 모두 충족하는 임금을 통상임금으로 본다고 판시한다.

III. 통상임금의 요건

1. 정기성

- 임금이 일정한 간격을 두고 계속적 · 반복적으로 지급되는 성질을 말한다. 상여금이라 하더라도 매년 혹은 매월 일정 시기에 반복적으로 지급된다면 정기성을 충족한다.

2. 일률성

- 모든 근로자 또는 일정한 조건을 충족하는 전체 근로자에게 지급되는 성질을 말한다. 재직 여부와 무관하게 일률적으로 지급되는 경우 일률성을 인정한다.

3. 고정성

- 근로자가 소정근로를 제공하기만 하면 지급 여부나 금액이 사전에 확정되는 성질을 의미한다. 지급조건이 사용자의 재량이나 근로자의 성과와 직접적으로 연동되지 않아야 하며, 특정 시점의 재직을 요건으로 한다면 그 요건이 고정성을 훼손할 수 있다. 대법원은 상여금이 특정 시점 재직자에게만 지급되도록 규정되어 있는 경우, 근로자가 실제로 근무를 제공했음에도 퇴직이나 휴직 등의 사유로 지급되지 않는다면 이는 고정성이 결여된다고 판시하였다(2012다89399).

IV. 사안의 적용

1. 정기성

- A회사는 정기상여금을 2개월마다 기본급의 100%씩 지급해 왔다. 이는 정기적이고 계속적인 지급이므로 정기성 요건을 충족한다.

2. 일률성

- 단체협약 제20조에 따르면 입사, 복직, 휴직자의 경우 상여금을 일할 계산하여 지급한다고 규정되어 있다. 이는 일정한 조건을 충족하는 모든 근로자에게 지급될 것을 예정하고 있으므로 일률성 요건 역시 인정된다.

3. 고정성

- 고정성 판단은 이 사안의 핵심이다. 취업규칙 제35조는 정기상여금은 지급일 현재 재직 중인 자에 한하여 지급한다고 규정하고 있어, 특정 시점의 재직을 요건으로 두고 있다. 반면, 단체협약 제20조는 일할 계산 지급 규정을 두어 재직 요건을 배제하고 있다.

4. 단체협약과 취업규칙의 관계

- 근로기준법 제96조에 따르면, 단체협약이 취업규칙보다 우선한다. 따라서 상여금 지급과 관련하여 단체협약 규정이 우선적으로 적용된다. 이 경우 지급일 이전에 퇴직한 근로자라도 재직 여부와 무관하게 소정근로를 제공하였다면 상여금을 일할 계산하여 지급받을 수 있다.

5. 실제 운영 실태

- 사안에 따르면 A회사가 실제로 지급일 이전 퇴직자에게 상여금을 일할 계산하여 지급하지 않았다는 객관적 자료는 확인되지 않는다. 이는 곧 퇴직자에게 상여금을 지급하지 않았다는 확정적 증거가 없다는 의미로, 운영 실태 역시 일할 지급 규정과 부합한다고 볼 수 있다.

6. 검토

- 결국 단체협약이 우선 적용되고, 운영 실태상 지급일 이전 퇴직자에게도 일할 지급이 이루어진 것으로 추정된다. 따라서 상여금 지급에 재직 조건이 엄격히 부가되어 있다고 보기 어렵고, 소정근로 제공을 조건으로 한 지급은 고정성을 갖춘 것으로 평가된다.

V. 결론

- 이 사건 정기상여금은 ① 2개월마다 정기적으로 지급되어 정기성이 인정되고, ② 입사 · 복직 · 휴직자에게도 일할 지급이 예정되어 일률성이 충족된다. ③ 지급일 현재 재직자 요건을 둔 취업규칙 규정은 단체협약의 일할 지급 규정에 의해 우선 배제되며, 실제 운영에서도 퇴직자에 대한 미지급 사례가 객관적으로 확인되지 않는다. 따라서 이 사건 정기상여금은 근로자가 소정근로를 제공하면 지급이 확정되는 임금으로서 고정성을 가진다고 할 수 있다. 결론적으로, A회사의 정기상여금은 정기성, 일률성, 고정성을 모두 충족하는 통상임금에 해당한다.

<제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실제적 정당성>

[기출][1][2023-1-1]경영상 이유에 의한 해고 대상자 선정 기준에 대한 합리성 및 공정성

《[문제1] A회사는 상시근로자 500명을 사용하여 전기 관련 제품을 제조·판매하는 회사이다. A회사는 2018년부터 계속적으로 매출, 영업이익, 당기순이익이 전체적으로 감소하여 A회사에 근로자 과반수 이상을 조직하여 설립·운영하고 있던 노동조합에게 사택매각, 명예퇴직 등의 경영위기를 타개하기 위한 비상경영안을 수용할 것을 제안하였다. 그러나 노동조합은 조합원의 의사를 무시한 일방적 구조조정에 반대한다는 의사를 표명하며 비상경영안 수용을 거부하였다. 그러자 A회사는 소속 근로자의 일부를 정리해고하기로 결정하고, 취업규칙이나 단체협약 등에 별도의 정함이 없었던 정리해고 대상자 선정기준을 마련하였다. A회사는 근로자들을 대상으로 정리해고를 실시함에 앞서 노동조합과의 협의 과정에서 업무적합도, 근무태도, 연령 등을 기준으로 정리해고대상자를 선정할 것임을 밝혔고, 이에 노동조합이 연령을 정리해고대상자 선정기준으로 삼는 것은 부당하다는 등의 의견을 제시하자, A회사는 노동조합의 의견 가운데 일부를 받아들여 연령을 제외하는 대신에 회사공헌도(근속연수)를 새로운 기준으로 추가하였다. 그 결과 A회사의 정리해고대상자 선정기준은 업무적합성(40%), 근무태도(30%), 임금(20%), 회사공헌도(근속연수, 10%)로 구성되었고, A회사는 위 평가 항목들에서 상대적으로 낮은 점수를 받은 근로자 甲을 비롯하여 업무상재해를 입었던 경험이 있었던 근로자, 상당기간 가족을 부양해야 할 사정이 있는 근로자 등을 포함한 근로자 60명을 2022. 5. 최종 해고하였다.

한편, 노동조합 대표자 乙은 2022. 5. 정리해고에 강하게 반대하면서 정리해고에 주도적 역할을 담당하였던 총무과장과 말다툼하는 과정에서 폭력을 행사하여 전치 5주의 상해를 입었다. 이 점에 대해 A회사는 동일한 내용으로 규정되어 있는 취업규칙과 단체협약상 징계규정에 따라 노동조합 대표자 乙을 징계하기로 결정하고, 징계위원회를 소집하였다. A회사의 대표이사는 취업규칙과 단체협약에 징계위원회는 노·사 각 2명으로 구성한다고 규정되어 있을 뿐, 징계위원의 자격이나 선임절차에 대하여 별도의 정함이 없다는 이유로 A회사 소속 인사과장과 사업장이 A회사와 동일하고 실체는 자신이 사주인 별도의 회사의 대표이사를 사측 징계위원으로, A회사 소속 근로자 2명을 노측 징계위원으로 각각 위촉하였다. 이후 징계위원회는 A회사의 취업규칙과 단체협약에는 징계사유인 사전통고와 소명기회 부여에 관한 절차는 별도로 규정되어 있지 않았기 때문에 노동조합 대표자 乙에 대해 징계사유인 사전통고 및 소명기회의 보장 없이 정직 3개월의 징계를 의결하였다. 이에 근거하여 A회사는 乙에게 정직 3개월의 징계를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) A회사의 근로자 甲은 A회사의 정리해고대상자 선정기준은 근로기준법상 합리적이고 공정한 해고의 기준에 해당되지 않는다고 주장한다. 甲의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (단, 나머지 경영상 이유에 의한 해고의 유효요건은 논하지 않는다) (25점)》

<문제1의 물음1> 경영상 이유에 의한 해고 대상자 선정 기준에 대한 합리성 및 공정성

I. 문제 제기

- 사안에서 A회사는 경영상 위기를 이유로 정리해고를 실시하면서 업무적합성(40%), 근무태도(30%), 임금(20%), 회사공헌도(근속연수, 10%)를 정리해고 대상자 선정 기준으로 삼았고, 그 결과 근로자 甲을 포함한 60명이 해고되었다. 그러나 甲은 위와 같은 선정 기준이 합리적이고 공정한 해고의 기준에 해당하지 않는다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <A회사의 정리해고 대상자 선정기준이 합리적이고 공정한 해고의 기준에 해당하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사의 선정 기준이 근로기준법상 정당한 정리해고 요건에 해당하지 않는다는 甲의 주장의 타당성에 관하여 논한다.

II. 정리해고의 정당성 요건

1. 정리해고와 근로기준법 제24조

- 근로기준법 제24조는 경영상 이유에 의한 해고를 정당화하기 위해 ① 긴박한 경영상 필요성, ② 해고를 피하기 위한 노력, ③ 해고 대상자 선정의 합리성과 공정성, ④ 근로자대표와의 성실한 협의를 요구한다. 그중 해고 대상자 선정 기준은 합리적이고 공정한 기준에 따라야 한다고 명시되어 있다.

2. 합리성과 공정성의 판단 기준

- 판례는 해고 대상자 선정기준이 합리적이고 공정한지 여부는 ① 기업의 성격, ② 근로자의 직종과 직무의 특성, ③ 선정기준 항목의 적절성, ④ 배정의 합리성, ⑤ 실제 운영 과정의 객관성 등을 종합적으로 고려하여 판단해야 한다고 본다. 합리성이란 해당 기준이 기업의 경영상 필요와 직무 특성에 부합하는지를 의미한다. 공정성이란 객관적 지표에 따라 누구에게나 동일하게 적용될 수 있어야 하며, 사용자의 주관적 평가나 자의가 개입할 소지가 최소화되어야 한다는 것을 뜻한다.

3. 연령을 기준으로 한 경우의 법리

- 연령을 직접적인 기준으로 삼는 것은 합리성이 결여된 차별적 요소로 평가되어 부당하다는 것이 확립된 판례 입장이다. 다만, 생활보호적 요소인 근속연수나 부양가족 수는 해고로 인한 근로자의 생활보호라는 관점에서 제한적으로 고려될 수 있다.

4. 임금 수준 고려의 법리

- 정리해고에서 임금 수준을 고려하는 경우, 고임금 근로자를 우선적으로 해고하여 비용 절감을 도모하는 것은 기업의 경영상 필요성 측면에서는 이해될 수 있으나, 그 자체가 합리적이고 공정한 기준으로 곧바로 인정되는 것은 아니다. 임금이 단순히 높다는 이유만으로 해고하는 것은 근로자에게 불리한 차별적 요소가 될 수 있으므로, 전체 사정을 종합적으로 고려하여야 한다.

III. 사안의 적용

1. A회사의 선정 기준 검토

- A회사는 정리해고 대상자 선정기준을 업무적합성(40%), 근무태도(30%), 임금(20%), 회사공헌도(10%)로 설정하였다. 당초에는 연령을 포함하려 하였으나, 노동조합의 반대로 이를 제외하고 근속연수를 추가하였다.

2. 업무적합성, 근무태도

- 업무적합성과 근무태도는 직무수행능력과 관련된 합리적인 요소로서, 정리해고 기준으로 삼는 데 정당성이 인정된다. 다만, 평가의 객관성과 공정성이 실제로 확보되었는지가 중요하며, 자의적이거나 차별적인 방식으로 평가가 이루어진 경우에는 합리성을 상실한다.

3. 임금 수준

- A회사가 정리해고 선정기준 중 하나로 임금을 설정한 것은 문제가 될 수 있다. 고임금자를 우선적으로 해고하는 것은 단순히 경비 절감을 위한 수단에 불과하며, 근로자의 생활보호나 공정성을 담보하는 기준과는 거리가 있다. 따라서 임금을 20%의 비중으로 반영한 것은 근로기준법상 합리적이고 공정한 해고의 기준으로 보기 어렵다.

4. 근속연수(회사공헌도)

- 근속연수를 기준으로 삼는 것은 생활보호적 요소로서 합리성이 인정될 수 있다. 그러나 이를 단순히 회사공헌도의 이름으로만 설정하고, 부양가족 여부 등 다른 생활보호적 요소를 전혀 고려하지 않은 것은 선정 기준의 공정성에 결함이 있다. 특히 본 사안에서 가족 부양 사정을 가진 근로자까지 해고

된 점은 생활보호적 관점에서 불합리하다.

#### **5. 검토**

- 정리해고 대상자 선정기준 중 업무적합성과 근무태도는 합리적이거나, 임금 수준을 고려한 점은 부당한 요소에 해당하고, 근속연수만을 제한적으로 고려하여 생활보호적 요소를 충분히 반영하지 못한 점에서 공정성이 결여되었다고 평가된다. 따라서 A회사의 선정 기준은 근로기준법이 요구하는 합리적이고 공정한 해고의 기준에 완전히 부합한다고 보기는 어렵다.

#### **IV. 결론**

- 경영상 이유에 의한 정리해고에서 해고 대상자 선정 기준은 근로자의 직무능력과 생활보호를 균형 있게 고려한 합리적이고 공정한 기준이어야 한다. 본 사안에서 A회사가 설정한 업무적합성 및 근무태도 기준은 정당성이 인정되나, 임금 수준을 고려한 것은 부당한 요소이며, 근속연수만을 부분적으로 고려하여 생활보호적 요소를 충분히 반영하지 못하였다. 따라서 甲이 주장하는 바와 같이 A회사의 정리해고 대상자 선정 기준은 근로기준법상 합리적이고 공정한 기준이라고 보기 어렵고, 甲의 주장은 타당하다.

《【문제1】 A회사는 상시근로자 500명을 사용하여 전기 관련 제품을 제조·판매하는 회사이다. A회사는 2018년부터 계속적으로 매출, 영업이익, 당기순이익이 전체적으로 감소하여 A회사에 근로자 과반수 이상을 조직하여 설립·운영하고 있던 노동조합에게 사택매각, 명예퇴직 등의 경영위기를 타개하기 위한 비상경영안을 수용할 것을 제안하였다. 그러나 노동조합은 조합원의 의사를 무시한 일방적 구조조정에 반대한다는 의사를 표명하며 비상경영안 수용을 거부하였다. 그러자 A회사는 소속 근로자의 일부를 정리해고하기로 결정하고, 취업규칙이나 단체협약 등에 별도의 정함이 없었던 정리해고 대상자 선정기준을 마련하였다. A회사는 근로자들을 대상으로 정리해고를 실시함에 앞서 노동조합과의 협의 과정에서 업무적합도, 근무태도, 연령 등을 기준으로 정리해고대상자를 선정할 것임을 밝혔고, 이에 노동조합이 연령을 정리해고대상자 선정기준으로 삼는 것은 부당하다는 등의 의견을 제시하자, A회사는 노동조합의 의견 가운데 일부를 받아들여 연령을 제외하는 대신에 회사공헌도(근속연수)를 새로운 기준으로 추가하였다. 그 결과 A회사의 정리해고대상자 선정기준은 업무적합성(40%), 근무태도(30%), 임금(20%), 회사공헌도(근속연수, 10%)로 구성되었고, A회사는 위 평가 항목들에서 상대적으로 낮은 점수를 받은 근로자甲等을 비롯하여 업무상장애를 입었던 경험이 있었던 근로자, 상당기간 가족을 부양해야 할 사정이 있는 근로자 등을 포함한 근로자 60명을 2022. 5. 최종 해고하였다.

한편, 노동조합 대표자 乙은 2022. 5. 정리해고에 강하게 반대하면서 정리해고에 주도적 역할을 담당하였던 총무과장과 말다툼하는 과정에서 폭력을 행사하여 전치 5주의 상해를 입었다. 이 점에 대해 A회사는 동일한 내용으로 규정되어 있는 취업규칙과 단체협약상 징계규정에 따라 노동조합 대표자 乙을 징계하기로 결정하고, 징계위원회를 소집하였다. A회사의 대표이사는 취업규칙과 단체협약에 징계위원회는 노·사 각 2명으로 구성한다고 규정되어 있을 뿐, 징계위원의 자격이나 선임절차에 대하여 별도의 정함이 없다는 이유로 A회사 소속 인사과장과 사업장이 A회사와 동일하고 실체는 자신이 사주인 별도의 회사의 대표이사를 사측 징계위원으로, A회사 소속 근로자 2명을 노측 징계위원으로 각각 위촉하였다. 이후 징계위원회는 A회사의 취업규칙과 단체협약에는 징계사유의 사전통고와 소명기회 부여에 관한 절차는 별도로 규정되어 있지 않았기 때문에 노동조합 대표자 乙에 대해 징계사유의 사전통고 및 소명기회의 보장 없이 정직 3개월의 징계를 의결하였다. 이에 근거하여 A회사는 乙에게 정직 3개월의 징계를 하였다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 노동조합 대표자 乙은 총무과장에 대한 폭력행사가 징계사유에 해당된다 하더라도 징계사유를 사전에 통고받거나 그에 관하여 소명할 기회를 부여받지 못하였고, 징계위원회 구성에도 중대한 하자가 있기 때문에 정직 3개월의 징계처분은 무효라고 주장한다. 노동조합 대표자 乙의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 절차의 흠결이 있는 징계의 효력에 대한 노조 대표자 주장의 타당성

I. 문제의 제기

- 사안에서 노동조합 대표자 乙은 정리해고 반대 과정에서 총무과장에게 폭력을 행사하였고, 이에 따라 A회사는 취업규칙 및 단체협약에 근거하여 징계위원회를 소집하여 乙에게 정직 3개월의 징계를 부과하였다. 그러나 乙은 징계사유에 대한 사전통고 및 소명기회 부여 절차가 없었고, 징계위원회 구성에도 중대한 하자가 있으므로 징계처분이 무효라고 다투고 있는 상황이다. 쟁점으로 <사안의 징계와 관련하여 징계위원회 구성, 사전통고, 소명기회 부여와 같은 절차를 준수하여 절차적 정당성이 무결한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 징계의 절차적 정당성 요건을 중심으로 乙의 주장에 대한 타당성에 관하여 논한다.

II. 징계의 절차적 정당성 요건

1. 사전통고 및 소명기회 보장

- 대법원은 징계사유가 발생한 경우 사용자는 근로자에게 징계사유를 사전에 통지하고, 그에 대한 진술 기회를 보장하여야 하며, 이를 결여한 징계처분은 절차적 정당성을 상실하여 무효라고 판시하였다.(대법원 1992.12.22. 선고 91다4775 판결) 이는 취업규칙이나 단체협약에 별도 규정이 없더라도 근로자에 대한 기본적 절차적 권리 보장을 요구하는 법리이다. 따라서 징계처분을 함에 있어 근로자가 방어할 기회를 가질 수 있도록 해야 한다.

2. 징계위원회의 공정한 구성

- 취업규칙 또는 단체협약에서 징계위원회 구성을 규정한 경우, 그 취지는 징계처분의 객관성과 공정성을 담보하기 위함이다. 대법원 판례는 징계위원회 구성규정을 위반하거나 그 구성에 중대한 하자가 있는 경우 징계처분은 무효라고 본다. 특히, 노·사 동수로 구성한다는 규정이 있다면, 노사 양측이 공정하게 대표성을 가진 자를 위원으로 구성하여야 하며, 사측 위원은 사용자와 독립성을 갖춘 자여야 한다. 그렇지 않고 회사의 실질적 이해관계인이나 외부의 독자적 권한이 없는 자를 위촉하는 경우 공정성이 훼손된다.

3. 절차적 정당성 흠결의 효과

- 절차적 정당성을 갖추지 못한 징계처분은 그 징계사유가 존재하더라도 무효로 본다. 이는 징계권 남용 방지와 근로자의 방어권 보장을 위한 것이다. 따라서 절차적 하자가 중대·명백하다면 징계처분의 효력은 인정되지 않는다.

III. 사안의 적용

1. 사전통고 및 소명기회의 부재

- 본 사안에서 A회사는 취업규칙 및 단체협약에 징계사유 사전통고 및 소명기회 부여 절차가 규정되어 있지 않다는 이유로 乙에게 어떠한 통보나 진술 기회도 부여하지 않았다. 그러나 앞서 본 판례법리에 의하면 이는 절차적 정당성의 필수적 요건으로서, 규정 유무와 무관하게 반드시 보장되어야 한다. 따라서 A회사의 징계절차는 중대한 하자가 있다.

2. 징계위원회 구성의 하자

- 취업규칙 및 단체협약에 징계위원회는 노·사 각 2명으로 구성한다고 되어 있음에도, A회사의 대표이사는 사측 위원으로 A회사 소속 인사과장 1인과 더불어 사실상 동일 사업장에서 운영되는 다른 회사의 대표이사를 위촉하였다. 그런데 이 다른 회사의 대표이사는 실질적으로 A회사의 사주이므로 독립적 이해관계를 가지는 제3자가 아니라 사용자의 지휘·통제를 받는 자와 동일시할 수 있다. 따라서 이는 징계위원회의 공정성을 훼손하는 구성상의 중대한 하자에 해당한다.

3. 징계사유 자체의 존재

- 乙이 총무과장에게 폭력을 행사하여 전치 5주의 상해를 입힌 사실은 기업질서를 심각하게 침해한 행위로서 징계사유에 해당함은 부인할 수 없다. 그러나 징계사유의 존부와 별개로, 절차적 정당성을 결여한 징계처분은 무효로 본다. 판례 역시 징계사유가 명백히 존재한다 하더라도 징계절차의 정당성이 결여되면 징계처분은 무효라고 판시하고 있다.

#### **Ⅳ. 결론**

- 정리하면, 본 사안에서 A회사가 노동조합 대표자 乙에게 내린 정직 3개월의 징계처분은 절차적 정당성을 결여하였다. 첫째, 징계사유에 대한 사전통고 및 소명기회 부여가 전혀 이루어지지 않아 乙의 방어권이 침해되었다. 둘째, 징계위원회가 사용자와 실질적으로 동일한 지위를 가진 자를 사측 위원으로 위촉함으로써 공정성이 심각하게 훼손되었다. 이러한 절차적 하자는 중대·명백하여 징계처분은 무효로 평가된다. 따라서 乙의 주장은 타당하다. 다만, 乙의 폭력행위는 분명히 징계사유에 해당하므로, A회사가 향후 적절한 절차를 거쳐 다시 징계를 부과하는 것은 가능하다. 결국 이 사건 징계처분은 절차적 정당성의 결여로 무효이므로 乙의 주장은 타당하다.

#### **<보충 논거>**

##### **I. 91다4775 판례의 법리**

- 대법원 1992.12.22. 선고 91다4775 판결은 다음과 같이 요약된다.
- 취업규칙이나 단체협약에 징계절차(사전통고, 소명기회 보장 등)에 관한 명시적 규정이 없는 경우, 그러한 절차를 거치지 않았다고 하여 당연히 징계가 무효가 되는 것은 아니다.
- 다만, 징계위원회 구성 규정을 위반하거나 공정성이 침해될 정도의 중대한 절차적 하자가 있는 경우에는 징계처분은 무효이다.
- 즉, 이 판례는 모든 경우에 절차적 보장이 필요하다는 일반원칙을 제시한 것이 아니라, 규정이 없는 경우 절차적 흠결만으로는 무효로 단정할 수 없다는 점을 강조했다.

##### **II. 본 사안과의 연결**

- 사안에서는 두 가지 절차 문제가 있었다.

###### **1. 사전통고·소명기회 부여의 부재**

- 판례 법리에 따르면, 취업규칙이나 단체협약에 절차 규정이 없었으므로, 이를 이유로만 무효를 주장하기는 쉽지 않다. 따라서 단순히 통고·소명 절차를 생략했다는 사정만으로는 중대한 절차적 하자라 단정하기 어렵다.

###### **2. 징계위원회 구성의 하자**

- 그러나 사안에서는 더 큰 문제가 있다. 취업규칙·단체협약에 노사 각 2명으로 구성한다는 규정이 있었음에도, A회사는 사측 위원으로 사실상 사용자 본인(다른 회사의 대표이사, 실질적으로 동일 사주)을 위촉했다. 이는 징계위원회 구성 규정 위반에 해당하고, 공정성이 현저히 훼손된 경우라 판례가 말하는 중대한 절차적 하자에 해당한다.

##### **III. 결론이 무효로 도출된 이유**

- 따라서 이 사건에서 절차적 정당성이 결여되었다는 결론이 나온 이유는, 단순히 소명기회가 없었던 점 때문만이 아니라, 징계위원회 구성 자체가 노사 동수 원칙에 위배되어 공정성을 상실했기 때문이다. 즉, 91다4775 판례의 태도에 따르면 소명절차 미비만으로는 무효라 할 수 없다지만, 본 사안에서는 징계위원회 구성의 중대한 하자가 있었기 때문에 결국 징계처분 전체가 무효라는 결론에 이른 것이다.

#### **IV. 결론**

- 소명절차 부재 → 단독으로는 무효사유 아님 (91다4775 판례 취지)
- 징계위원회 구성의 중대한 하자 → 무효사유 해당
- 따라서 본 사안에서 징계처분이 무효라는 결론은 판례 법리와 모순되지 않고, 오히려 징계위원회 구성 문제에 무게를 두었기 때문이다.

《【문제2】 A회사는 정보통신산업 등을 영위하는 회사인데, 2011. 10. A회사의 플랫폼 사업 부문이 분할되어 B회사가 설립되었다. A회사는 B회사의 주식 98.1%를 보유하고 있다. B회사는 2016. 12. 31. 기준 1조원이 넘는 자산과 독립적인 운영조직을 갖춘 회사이다. A회사는 B회사의 플랫폼 관련 전문성과 A회사의 마케팅 경쟁력을 결합한 신규 사업인 플랫폼을 기반으로 한 쇼핑, 미디어, 요식사업을 진행하였는데, 그 과정에서 B회사로부터 다수 근로자를 전출받았다. 한편 근로자 丙은 2015. 3. B회사에 입사한 직후 A회사의 플랫폼을 기반으로 한 쇼핑, 미디어, 요식사업으로 전출되어 관련 업무를 수행하였다. 위 전출과 관련해 A회사는 B회사와 B회사는 전출 근로자를 고용한 사업주로서 전출 근로자와 근로관계가 있음을 보증하고 임금 지급 등 근로관계 법령상의 사용자책임을 부담하며, A회사는 B회사가 전출 근로자와의 근로관계를 유지하기 위해 소요되는 인건비를 6개월마다 정산하여 B회사에 지급한다.는 내용의 비용정산 계약을 체결하였다. 위 계약에 따라 B회사는 근로자 丙을 비롯한 전출 근로자들에게 임금을 지급하였고 A회사는 B회사에게 전출 근로자들의 임금 상당액을 지급하였다. 2017. 7. 플랫폼을 기반으로 한 쇼핑, 미디어, 요식사업이 종료되자 丙을 비롯한 B회사의 전출 근로자들은 B회사로 복귀하여 플랫폼 사업 업무를 담당하였다. 근로자 丙은 A회사가 자신을 직접고용 하여야 할 의무가 있다고 주장한다. 근로자 丙의 주장의 타당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제2> 근로계약관계의 실질적 사용자 및 계약의 형태(도급, 전적, 파견)에 따른 직접고용의무 판단

**I. 문제 제기**

- 본 사안에서 A회사는 B회사의 자회사로서, B회사가 전출한 근로자 丙을 비롯한 다수 근로자들로부터 근로를 제공받았다. 형식상 丙은 B회사의 근로자였고, B회사가 임금을 지급하였다. 그러나 丙은 A회사의 신규 사업에 투입되어 A회사의 사업을 위한 업무를 수행하였다. 丙은 이러한 사정에 기초하여 A회사가 자신을 직접고용하여야 한다고 주장한다. 쟁점으로 <丙의 전출 근무가 도급 내지 전적의 형태인지 아니면 불법파견에 해당하는지, 나아가 A회사에 직접고용의무가 발생하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이와 같은 쟁점과 관련한 근로자 丙의 주장의 타당성에 대해 논한다.

**II. 불법 파견의 의의**

**1. 근로자파견의 개념**

- 파견근로자 보호 등에 관한 법률(이하 '파견법') 제2조 제1호에 의하면, 근로자파견이란 파견사업주가 근로자를 고용한 후 그 고용관계를 유지하면서 사용자업주의 지휘·명령을 받아 사용자업주를 위한 근로에 종사하게 하는 것을 말한다. 즉, ① 고용관계는 파견사업주와 존속하면서, ② 실질적 지휘·명령권은 사용자업주가 행사하는 구조가 전형적인 근로자파견에 해당한다.

**2. 도급 및 전적과의 구별**

- 근로자파견과 도급 또는 전적을 구별하는 기준은 실질적 지휘·명령관계의 존재 여부이다. 도급은 수급인이 독립적인 사업자로서 자기 책임과 계산하에 업무를 완수하는 것으로, 사용자업주는 근로자에 대한 직접적 지휘·명령권을 행사하지 않는다. 전적은 근로자가 원래 소속을 이탈하여 다른 사용자에게 고용관계가 이전되는 것이며, 전적이 유효하려면 근로자의 동의가 필요하다. 반면, 근로자파견은 형식적으로는 소속 회사에 고용되어 있으나 실질적으로는 타 회사의 지휘·명령 아래 근로를 제공하는 경우를 의미한다.

**3. 불법파견과 직접고용의무**

- 파견법은 원칙적으로 제조업의 직접생산공정 업무 등 일부 업종에 대해서는 파견을 금지하고 있으며, 허용되지 않는 업무에 근로자파견이 이루어진 경우 불법파견으로 본다. 불법파견의 경우, 파견법 제6조의2에 의거하여 사용자업주는 해당 근로자를 직접 고용할 의무를 부담한다. 또한 대법원도 불법파견이 인정되는 경우 사용자업주와 근로자 사이에 직접 근로계약이 성립된 것으로 본다.

**III. 사안의 적용**

**1. 형식적 근로관계**

- 근로자 丙은 B회사의 근로자로 입사하여 B회사로부터 임금을 지급받았다. A회사와는 형식상 근로계약 관계가 없었으며, A회사는 B회사와 인건비 정산 계약을 체결하는 방식으로 비용만 부담하였다.

**2. 실질적 지휘·명령 관계**

- 그러나 丙은 B회사가 아니라 A회사의 신규 사업(플랫폼 기반 쇼핑, 미디어, 요식사업)에 투입되어 A회사의 필요에 따라 업무를 수행하였다. A회사가 직접 丙의 업무내용과 수행방식에 관여하고 지휘·명령을 행사하였을 것으로 보인다. 이는 전형적인 근로자파견의 실질을 가진다.

**3. 도급 또는 전적 여부**

- 도급으로 보기는 어렵다. B회사가 독립적 사업자로서 자기 계산으로 업무를 수행한 것이 아니라, 단순히 인건비만을 A회사에 청구하는 구조였기 때문이다. 전적의 경우에도 근로자 丙의 소속이 완전히 A회사로 이전되지 않았고, 임금은 여전히 B회사가 지급하였다. 따라서 전적에도 해당하지 않는다.

**4. 불법파견 여부**

- A회사는 정보통신 및 플랫폼 관련 사업을 영위하고 있었으며, 丙이 수행한 업무는 A회사의 핵심 사업에 해당한다. 이는 도급으로 볼 여지가 없고, 실질적으로 A회사가 지휘·명령권을 행사하였다면 불법파견에 해당한다. 또한 A회사가 속한 업종은 원칙적으로 근로자파견 허용 대상이 아닐 뿐 아니라, 이 사건에서 파견사업주(B회사)는 파견사업을 전문으로 하는 사업주가 아니므로, 합법적 파견으로 평가될 수도 없다. 따라서 이는 불법파견으로 귀결된다.

**5. 직접고용의무**

- 불법파견이 성립하면 A회사는 파견법 제6조의2에 따라 丙을 직접 고용하여야 할 의무를 부담한다. 따라서 丙이 A회사를 상대로 직접고용을 주장하는 것은 법리에 부합한다.

**IV. 결론**

- 근로자파견은 형식상의 고용관계와 달리 실질적으로 사용자업주의 지휘·명령 아래 근로가 이루어지는 경우 성립한다. 본 사안에서 丙은 B회사의 근로자로 입사하였으나, 실제로는 A회사의 신규 사업 업무에 투입되어 A회사의 지휘·명령을 받았다. 이는 도급이나 전적이 아닌 근로자파견에 해당하고, 파견법상 요건을 충족하지 못하므로 불법파견으로 평가된다. 그 결과 A회사는 파견법 제6조의2에 따라 丙을 직접 고용할 의무를 부담한다. 따라서 丙의 주장은 타당하다.

《[문제1] A회사는 상시 500명의 근로자를 사용하여 골프장 운영 사업과 부동산 임대업을 영위하는 회사이다. 甲을 포함한 10명의 근로자(이하 기간제 근로자라 한다)는 1년을 계약기간으로 하는 근로계약을 체결하여 2022. 1. 1. 부터 골프장 운영 사업부문에서 일하였다. 기간제 근로자들의 근로계약서에서는 계약기간 동안 근로자의 근무실적 등을 감안하여 필요하다고 인정할 때에는 계약기간을 연장할 수 있고, 계약기간 만료 30일 전까지 상호 서면으로 이의가 없을 때에는 계약은 동일한 조건으로 자동 갱신된다.는 규정을 두고 있다. A회사는 특별한 사정이 없는 한 근로계약이 갱신될 것이라고 기간제 근로자들에게 지속적으로 말 해왔다. A회사는 기간제 근로자들에게 계약갱신의 기회를 제공하기 위하여 2022. 11. 이들에 대해 근무평가를 실시하였다. 근무평가를 실시한 후 A회사는 근무평가등급이 낮은 것을 이유로 甲에 대해서 인사위원회의 심의 없이 2022. 11. 30. 근로계약이 2022. 12. 31.자로 종료된다는 통보를 하였다. A회사는 甲을 제외한 9명의 기간제 근로자들에 대해서는 인사위원회의 심의를 거쳐 2022. 12. 15. 계약기간을 1년으로 하는 근로계약을 다시 체결하였다. A회사는 2020년과 2021년에도 계약기간의 정함이 있는 근로자들의 근무평가를 실시하여 근무평가 등급이 낮은 소수의 근로자를 제외하고, 근로계약을 갱신한 바 있다. 기간제 근로자들에 대한 근무평가에서 1차 평가는 과장이 담당하고 2차 평가는 부장이 담당하는데 그 비중은 각각 50%이다. 기간제 근로자들의 직근 상급자인 과장은 甲에 대해 대부분의 항목에서 가장 우수한 평점인 S등급을 부여하였으나 부장은 모든 평가 항목에 대하여 하위 등급인 C 내지 D등급을 부여하였다. 과장의 근무평가와는 달리 부장의 근무평가에서는 낮은 등급을 부여한 이유가 명확하지 않거나 이유 자체가 기재되어 있지 않다. 특히 근무평가기준에 따르면 A등급이 부여되었어야 하나, 부장은 평가기준과 달리 甲에 대한 근무평가에서 D등급을 부여하였다. 한편 2022년 상반기 근무평가에서 甲은 상위등급인 A등급을 받은 바 있다. 그리고 A회사는 2022. 9. 기간제 근로자들을 대상으로 하여 동료 근로자들에 대한 익명평가를 실시하였는데, 甲은 이 평가에서 담당 업무를 가장 성실하게 수행하는 근로자로 선정된 바 있다. 한편 2023년 부동산 경기 침체 등으로 A회사는 경영사정이 상당히 악화되었다. 그래서 A회사는 2023년 10월 중순경 자신의 사업 중 부동산 임대업을 B회사에 영업양도하기로 결정하였다. 乙은 2017년 A회사에 입사하여 부동산 임대업 분야에서 계속 근무하였다. 乙은 B회사의 향후 사업 전망이 불확실하다고 생각하여 자신은 A회사에 남아 골프장 운영 부문에서 일하기를 원한다고 2023. 11. 1. A회사에 통보하였다. A회사는 골프장 사업 부문에서 乙이 충분히 담당할 수 있는 업무가 공석임에도 불구하고, B회사로의 근로관계 승계를 거부하였다는 이유만으로 2023. 11. 15. 해고예고를 하여 2023. 12. 15.자로 해고하였다. 이에 따라 乙을 제외하고 2023. 12. 1. A회사에서 부동산 임대업에 종사하고 있었던 근로자 195명은 모두 B회사로 고용이 승계되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲은 자신에 대한 A회사의 갱신거절과 계약만료 통보가 부당하여 효력이 없다고 주장한다. 甲의 주장은 정당한가? (30점)》

<문제1의 물음1> 기간제 근로자에 대한 근무평가 결과에 기초한 갱신거절 통보의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안은 근로계약서상 자동 갱신 및 근무실적에 따른 계약 연장 규정이 존재하는 A회사에서 근무평가 등급이 낮은 이유로 계약만료를 통보받은 기간제 근로자 甲이 근무평가 결과의 공정성 흠결로 계약만료 통보가 부당하여 효력이 없다고 주장하는 상황이다. 쟁점으로 <甲에게 근로계약 갱신에 대한 정당한 신뢰된 갱신 기대권이 인정되는지>, <갱신 기대권이 인정될 경우 A회사가 단행한 갱신거절에 합리적인 이유가 존재하는지 판단하기 위해 甲에 대한 근무평가가 객관적이고 공정하게 이루어졌는지>, <인사위원회 심의 배제 등의 절차적 하자가 갱신거절의 효력에 미치는 영향이 어떠한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 기간제 근로자의 갱신 기대권 성립 법리와 갱신거절의 합리적 이유 판단 기준을 분석하고 이를 사안에 적용하여 甲의 주장의 정당성을 검토한다.

II. 기간제 근로자의 갱신 기대권 및 갱신거절의 합리적 이유 법리

1. 갱신 기대권의 성립 요건

(1) 규정 및 제도적 합리성

- 기간을 정한 근로계약이라 하더라도 근로계약, 취업규칙, 단체협약 등에 기간 만료에도 불구하고 일정한 요건이 충족되면 근로계약이 갱신된다는 취지의 규정이 있거나, 그러한 규정이 없더라도 근로계약이 갱신될 수 있다는 신뢰관계가 형성되어 있는지를 판단한다.

(2) 종합적 고려 기준

- 판례는 근로계약의 동기, 계약 갱신의 기준과 절차의 존재 여부, 해당 업무의 성격, 기존의 갱신 실태 및 관행 등을 종합적으로 고려하여 근로자에게 근로계약이 갱신될 수 있으리라는 정당한 기대권이 인정되는지를 기준으로 삼는다.

2. 갱신거절의 합리적 이유와 절차적 제한

(1) 합리적 이유의 존재 의무

- 근로자에게 갱신 기대권이 인정되는 경우 사용자가 정당한 이유 없이 갱신을 거절하는 것은 실질적으로 부당해고와 같아 아무런 효력이 없다. 따라서 사용자가 갱신을 거절하기 위해서는 사회통념상 객관적이고 합리적이며 공정성이 담보된 사유가 존재해야 한다.

(2) 평가의 객관성과 공정성

- 평가 기준이 자의적이거나 불분명하고, 평가자의 주관이 극단적으로 개입되어 합리성을 상실한 평가 결과에 기초한 갱신거절은 정당성을 인정받지 못한다. 또한, 단체협약이나 취업규칙 등에서 요구하는 인사위원회 심의 등 적법한 절차를 거치지 않은 경우에도 절차적 하자로 인하여 효력이 부인된다.

III. 사안의 적용

1. 甲의 갱신 기대권 성립 여부

(1) 처우 규정 및 신뢰 부여

- 근로계약서에 근무실적 감안에 따른 계약 연장 조항과 상호 서면 이의가 없을 시 자동 갱신되는 명시적 규정이 존재한다. 또한 A회사는 특별한 사정이 없는 한 계약이 갱신될 것임을 약 약속하며 지속적으로 공언해 왔다.

(2) 과거의 갱신 관행

- B사는 2020년과 2021년에도 소수의 낮은 평가등급자만을 제외하고 대부분의 근로계약을 갱신해 온 관행이 확립되어 있다. 따라서 甲을 비롯한 기간제 근로자들에게는 근로계약이 당연히 갱신될 것이라는 정당한 기대권이 인정된다.

2. 갱신거절의 실체적·절차적 정당성 검토

(1) 근무평가의 불공정성과 자의성

- 직근 상급자인 과장은 甲에 대해 최우수 등급인 S등급을 주었으나, 부장은 명확한 이유나 근거 기재 없이 최하위 등급인 C 내지 D등급을 일방적으로 부여하였다. 객관적인 근태평가기준에 따르면 A등급이어야 함에도 부장은 기준과 전혀 무관하게 D등급을 주었다. 이는 평가에 자의성이 극대화되었음을 증명한다.

## **(2) 甲의 객관적 근무 성적 우수성**

- 甲은 2022년 상반기 평가에서 A등급을 받았고 동료 근로자 익명 평가에서도 가장 성실한 근로자로 선정되었다. 이러한 다각적인 정황에 비추어 부장의 극단적인 하위 등급 평가는 보복적이거나 자의적인 조작 평가일 가능성이 지극히 높으므로 평가 결과의 합리성을 인정할 수 없다.

## **(3) 절차적 요건의 흠결**

- A회사는 다른 9명의 근로자에 대해서는 인사위원회의 심의를 거쳐 갱신계약을 체결했으나, 甲에 대해서는 인사위원회 심의 과정을 전면적으로 배제한 채 일방적인 종료 통보를 단행하였다. 이는 절차적 정의를 위반한 중대한 하자에 해당한다.

## **IV. 결론**

- 근로자 甲에게는 단체협약 규정과 사용자의 확약 및 반복된 갱신 관행에 비추어 적절한 갱신 기대권이 형성되어 있다. 그럼에도 A회사는 객관적 기준을 현저히 이탈하고 구체적 이유마저 기재되지 않은 부장의 자의적이고 공정하지 못한 최하위 평가 등급에 기하여 갱신을 거절하였다. 또한 인사위원회 심의 절차조차 생략한 심각한 절차적 위반이 동반되었다. 따라서 A회사의 갱신거절 및 계약만료 통보는 합리적인 이유와 절차적 정당성을 결여하여 법적 효력이 전혀 없으므로 甲의 주장은 정당하다고 판단된다.

《【문제1】 A회사는 상시 500명의 근로자를 사용하여 골프장 운영 사업과 부동산 임대업을 영위하는 회사이다. 甲을 포함한 10명의 근로자(이하 기간제 근로자라 한다)는 1년을 계약기간으로 하는 근로계약을 체결하여 2022. 1. 1. 부터 골프장 운영 사업부문에서 일하였다. 기간제 근로자들의 근로계약서에서는 계약기간 동안 근로자의 근무실적 등을 감안하여 필요하다고 인정할 때에는 계약기간을 연장할 수 있고, 계약기간 만료 30일 전까지 상호 서면으로 이의가 없을 때에는 계약은 동일한 조건으로 자동 갱신된다.는 규정을 두고 있다. A회사는 특별한 사정이 없는 한 근로계약이 갱신될 것이라고 기간제 근로자들에게 지속적으로 말 해왔다. A회사는 기간제 근로자들에게 계약갱신의 기회를 제공하기 위하여 2022. 11. 이들에 대해 근무평가를 실시하였다. 근무평가를 실시한 후 A회사는 근무평가등급이 낮은 것을 이유로 甲에 대해서 인사위원회의 심의 없이 2022. 11. 30. 근로계약이 2022. 12. 31.자로 종료된다는 통보를 하였다. A회사는 甲을 제외한 9명의 기간제 근로자들에 대해서는 인사위원회의 심의를 거쳐 2022. 12. 15. 계약기간을 1년으로 하는 근로계약을 다시 체결하였다. A회사는 2020년과 2021년에도 계약기간의 정함이 있는 근로자들의 근무평가를 실시하여 근무평가 등급이 낮은 소수의 근로자를 제외하고, 근로계약을 갱신한 바 있다. 기간제 근로자들에 대한 근무평가에서 1차 평가는 과장이 담당하고 2차 평가는 부장이 담당하는데 그 비중은 각각 50%이다. 기간제 근로자들의 직근 상급자인 과장은 甲에 대해 대부분의 항목에서 가장 우수한 평점인 S등급을 부여하였으나 부장은 모든 평가 항목에 대하여 하위 등급인 C 내지 D등급을 부여하였다. 과장의 근무평가와는 달리 부장의 근무평가에서는 낮은 등급을 부여한 이유가 명확하지 않거나 이유 자체가 기재되어 있지 않다. 특히 근태평가기준에 따르면 A등급이 부여되었어야 하나, 부장은 평가기준과 달리 甲에 대한 근태평가에서 D등급을 부여하였다. 한편 2022년 상반기 근무평가에서 甲은 상위등급인 A등급을 받은 바 있다. 그리고 A회사는 2022. 9. 기간제 근로자들을 대상으로 하여 동료 근로자들에 대한 익명평가를 실시하였는데, 甲은 이 평가에서 담당 업무를 가장 성실하게 수행하는 근로자로 선정된 바 있다. 한편 2023년 부동산 경기 침체 등으로 A회사는 경영사정이 상당히 악화되었다. 그래서 A회사는 2023년 10월 중순경 자신의 사업 중 부동산 임대업을 B회사에 영업양도하기로 결정하였다. 乙은 2017년 A회사에 입사하여 부동산 임대업 분야에서 계속 근무하였다. 乙은 B회사의 향후 사업 전망이 불확실하다고 생각하여 자신은 A회사에 남아 골프장 운영 부문에서 일하기를 원한다고 2023. 11. 1. A회사에 통보하였다. A회사는 골프장 사업 부문에서 乙이 충분히 담당할 수 있는 업무가 공석임에도 불구하고, B회사로의 근로관계 승계를 거부하였다는 이유만으로 2023. 11. 15. 해고예고를 하여 2023. 12. 1.자로 해고하였다. 이에 따라 乙을 제외하고 2023. 12. 1. A회사에서 부동산 임대업에 종사하고 있었던 근로자 195명은 모두 B회사로 고용이 승계되었다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) 乙은 근로관계 승계 거부만을 이유로 자신을 해고한 것이 부당하다고 주장한다. 乙의 주장은 정당한가? (해고의 절차적 정당성에 대한 논의는 제외함) (20점)》

#### <문제1의 물음2> 영업양도 상황에서 회사 잔류를 희망한 근로자의 해고에 대한 정당성

##### I. 문제의 제기

- 사안은 A회사가 부동산 임대업 부문을 B회사에 영업양도하는 과정에서, 양도 대상 사업부문에 근무하던 근로자 乙이 고용승계를 거부하고 잔류를 희망하였음에도 A회사가 이를 이유로 해고한 상황이다. 쟁점으로 <영업양도 시 근로자에게 고용승계를 거부할 수 있는 이의제기권이 인정되는지>, <이의제기를 한 근로자의 법적 지위, 사용자가 승계 거부만을 이유로 근로자를 해고할 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 乙 주장이 정당한지 검토한다.

##### II. 영업양도와 근로자 이의제기권 및 해고의 정당성 법리

###### 1. 영업양도와 근로관계의 원칙적 승계

###### (1) 고용승계의 원칙

- 영업양도가 이루어지면 양도인과 근로자 사이에 존재하던 근로계약상의 권리·의무는 양수업체인 B회사에게 원칙적으로 승계된다. 이는 영업의 인적·물적 조직의 일체성을 유지하면서 근로자의 고용 안정을 도모하기 위한 노동법상의 기본 원칙이다.

###### (2) 합의에 의한 승계 배제 및 특별한 사정

- 다만 양도인과 양수인 사이의 계약에서 고용을 승계하지 않기로 하는 별도의 특약이 존재하거나, 근로자가 고용승계를 원치 않는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 승계의 원칙이 전면 적용되지 않는다.

###### 2. 근로자의 이의제기권과 독자적 선택권

###### (1) 이의제기권의 의의와 행사 방식

- 대법원은 영업양도가 이루어지더라도 근로자가 자의에 반하여 다른 기업으로 소속이 변경되는 것을 강제할 수는 없다고 본다. 따라서 근로자는 상당한 기간 내에 이의를 제기함으로써 근로관계의 승계를 거부하고 양도인인 A회사에 잔류할 것을 선택할 권리가 있다.

###### (2) 이의제기에 따른 법적 지위

- 근로자가 적법하게 이의를 제기한 경우, 해당 근로자의 근로관계는 양수인에게 승계되지 않고 양도인인 A회사와 사이에 그대로 유지된다. 이에 따라 양도인은 당해 근로자에 대한 근로계약상의 사용자 지위를 계속 보유한다.

###### 3. 승계 거부를 이유로 한 해고의 제한 법리

###### (1) 해고의 정당한 이유 부정

- 사용자는 근로자가 영업양도에 따른 근로관계 승계를 거부하였다는 사정만을 이유로 근로기준법 제23조 제1항의 정당한 이유 없이 근로자를 해고할 수 없다. 단순한 승계 거부는 근로계약관계를 더 이상 유지할 수 없을 정도의 근로자 귀책사유에 해당하지 않기 때문이다.

###### (2) 경영상 이유에 의한 해고 요건

- 만약 양도인이 잔류한 근로자를 해고하기 위해서는 근로기준법 제24조에 따른 경영상 이유에 의한 해고(정리해고)의 엄격한 요건(긴박한 경영상의 필요성, 해고회피노력, 합리적이고 공정한 해고기준, 근로자대표와의 협의)을 개별적·구체적으로 충족하여야만 정당성이 인정된다.

##### III. 사안의 적용

###### 1. 乙의 이의제기권 행사와 법적 지위

###### (1) 적법한 기간 내의 거부 통보

- 乙은 A회사가 부동산 임대업을 B회사에 영업양도하기로 결정한 후, 실제 영업양도일인 2023. 12. 1. 이전인 2023. 11. 1.에 고용승계를 원치 않고 A회사에 남아 골프장 운영 부문에서 일하겠다는 의사를 분명히 통보하였다. 이는 상당한 기간 내에 행해진 적법한 이의제기이다.

###### (2) A회사 소속 근로자 지위의 유지

- 乙의 이의제기에 따라 乙의 근로관계는 B회사로 승계되지 않고 양도인인 A회사와의 근로관계로 그대로 유지되므로, A회사는 乙에 대한 사용자로서의 고용보장 의무를 계속 부담한다.

## 2. A회사 해고처분의 위법성 검토

### (1) 정당한 사유의 흠결

- A회사는 乙에 대한 부서 이동이나 고용 유지를 위한 진지한 노력 없이, 단순히 B회사로의 고용 승계를 거부하였다는 사실만을 근거로 乙을 해고하였다. 이는 근로기준법 제23조 제1항의 정당한 사유가 흠결된 위법한 해고이다.

### (2) 배치전환 가능성 외면과 해고 회피 노력 해태

- 당시 A회사의 골프장 사업 부문에는 乙이 충분히 담당할 수 있는 적정한 업무가 공석으로 존재하였다. 그럼에도 A회사는 乙을 해당 업무에 배치전환하지 않고 해고를 강행하였는바, 이는 해고를 방지하기 위한 최소한의 노력조차 기울이지 않은 자의적 권한 남용에 해당한다.

## IV. 결론

- 영업양도 시 근로자는 승계를 거부하고 잔류할 수 있는 권리가 있으며, 乙이 이를 적법하게 행사했음에도 고용승계 거부 자체를 해고사유로 삼은 A회사의 조치는 법적 근거가 없어 정당성을 잃는다. A회사의 골프장 부문에 대체 가능한 공석이 존재했음에도 해고회피노력 없이 행해진 해고는 부당해고에 해당한다. 따라서 A회사의 처분이 부당하다고 다툼은 乙의 주장은 전적으로 정당하다.

## <제08장 근로관계의 종료.제04절 부당해고의 구제>

### [기출][1][2024-2]부당해고 기간 중 중간수입공제의 범위와 최종 임금상당액 산정

《[문제2] 상시 100명의 근로자를 사용하여 반도체 웨이퍼를 제조하는 A회사에는 A노동조합이 설립되어 있다. 甲은 A회사 생산직 근로자인데 A노동조합 조직부장으로 활동하던 중 업무지시 위반을 이유로 해고되었다. 이에 甲은 관할 지방노동위원회에 부당해고구제신청을 하였다. 지방노동위원회는 부당해고를 인정하면서 원직복직 및 해고기간 동안 발생한 임금상당액의 지급을 내용으로 하는 구제명령을 하였고, 구제명령은 그대로 확정되었다. 甲은 해고기간 동안 A회사와 같은 업종을 경영하는 B회사에 생산직으로 취업하여 600만원의 임금을 지급받았고, 아울러 A노동조합으로부터 구제 기금 명목으로 100만원을 지급받았다. 甲이 해고기간 동안 정상적으로 근로를 제공했다더라면 받을 수 있었던 임금상당액이자 평균임금의 총액은 1,800만원인데, A회사는 위 1,800만원에서 해고기간 동안 발생한 수입 700만원 전액의 공제를 주장한다. A회사가 중간수입으로 공제하고 甲에게 지급하여야 할 최종 임금상당액은 얼마인지 판례법리에 근거하여 설명하시오. (25점)》

### <문제2> 부당해고 기간 중 중간수입공제의 범위와 최종 임금상당액 산정

#### I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사는 생산직 근로자 甲에 대한 해고 기간의 평균임금 총액인 1,800만 원에서 甲이 다른 회사인 B회사에 취업하여 얻은 소득 600만 원과 A노동조합으로부터 구제 기금 명목으로 지급받은 100만 원 등 총 700만 원 전체를 공제하겠다고 주장하고 있다. 쟁점으로 <타사 취업으로 얻은 수입인 중간수입을 사용자가 지급할 임금상당액에서 공제하는 것이 법률상 허용되는지 여부와 그 한계>, <공제 대상이 되는 중간수입의 한도액 범위가 근로기준법 제46조의 휴업수당 규정과 연계되어 어떻게 설정되는지>, <노동조합으로부터 수령한 구제 기금이 법률상 공제 대상이 되는 중간수입에 부합하는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사가 최종적으로 지급해야 할 임금상당액을 산정하고, 부당해고 기간 중 중간수입공제의 요건과 범위에 관한 대법원 판례법리를 상세히 설명한다.

#### II. 중간수입공제의 범위와 한계에 관한 판례법리

##### 1. 공제 한도로서의 휴업수당 보장 법리

###### (1) 근로기준법 제46조의 휴업수당 규정과의 관계

- 근로기준법 제46조 제1항은 사용자의 귀책사유로 휴업하는 경우에 사용자는 휴업기간 동안 그 근로자에게 평균임금의 100분의 70 이상의 수당을 지급하여야 한다고 규정하고 있다. 사용자의 부당해고는 실질적으로 사용자의 귀책사유에 의한 휴업과 동일한 성질을 가진다.

###### (2) 대법원의 일관된 판례 태도

- 대법원은 근로자가 부당해고 기간 중 다른 직장에서 얻은 중간수입을 공제할 때, 지급되어야 할 임금상당액 중에서 평균임금의 100분의 70에 해당하는 금액에 대해서는 공제할 수 없다고 판단한다. 즉, 중간수입공제를 하더라도 사용자는 최소한 근로기준법이 보장하고 있는 최저 한도인 평균임금의 70%는 근로자에게 보장해주어야 한다는 취지다.

###### (3) 중간수입공제 가능 범위의 구체적 산정 방식

- 따라서 사용자가 공제할 수 있는 구체적인 한도액은 정상적인 임금상당액(평균임금의 100%)에서 평균임금의 70%를 제외한 나머지 평균임금의 30% 범위 내로 극히 제한된다. 다른 직장에서 얻은 수입이 아무리 많더라도, 평균임금의 30%를 초과하는 금액은 사용자가 지급해야 할 임금에서 공제할 수 없다.

##### 2. 중간수입의 개념과 공제 대상의 구체적 범위

###### (1) 노동의 대가로서 얻은 수입의 한정

- 공제 대상이 되는 중간수입이란 근로자가 해고 기간 동안 사용자에 대한 노무 제공을 면함으로써 발생한 여유 시간을 타에 활용하여 노동의 대가로 얻은 실질적인 임금이나 사업 수입 등에 한정된다.

###### (2) 구제 기금 등 은혜적·일시적 급부의 배제

- 노동조합이나 기타 단체로부터 재난 구제, 생계 지원 또는 구제 기금 명목으로 지급받은 금원은 근로자가 다른 직장에 취업하여 노동을 제공한 대가로 수령한 임금이 아니다. 이는 단결권의 옹호와 조합원의 생활 안정을 위하여 노동조합이 자체 재원을 바탕으로 은혜적·사회보장적 취지에서 지급하는 부조금의 성격을 가진다. 따라서 이러한 성격의 금원은 사용자가 공제할 수 있는 민법상 중간수입의 범위에 포함되지 않는다.

#### III. 사안의 적용

##### 1. 공제 대상이 되는 수입의 범위 확정

###### (1) B회사 생산직 근무 수입

- 甲이 해고 기간 중 A회사와 동종 업종인 B회사에 생산직으로 취업하여 받은 임금 600만 원은, 해고로 인하여 생긴 여유 시간을 다른 직장에 제공하고 얻은 전형적인 노동의 대가에 해당한다. 따라서 이 600만 원은 민법 제538조 제2항 및 판례법리상 중간수입공제의 대상이 되는 금원에 부합한다.

###### (2) A노동조합의 구제 기금 수입

- 甲이 소속된 A노동조합으로부터 수령한 구제 기금 100만 원은 노무 제공 면제와 인과관계가 있는 제3자로부터의 근로 대가가 아니다. 이는 노동조합의 자주적 단결 활동 과정에서 조합원을 보호하기 위해 무상으로 급부된 지원금에 불과하므로 중간수입공제 대상에서 완전히 제외된다. 따라서 A회사가 주장하는 공제 대상 금액 700만 원 중 100만 원 부분은 법리적 근거가 결여된 부당한 주장이다.

##### 2. 최종 임금상당액의 산출 및 공제 한도 적용

###### (1) 평균임금 기준 최저 보장액 산정

- 甲이 정상적으로 근로를 제공했다더라면 받을 수 있었던 임금상당액이자 평균임금의 총액은 1,800만 원이다. 근로기준법 제46조 및 판례법리에 따라 A회사가 어떠한 경우에도 甲에게 지급을 보장해야 하는 최저 보장액(평균임금의 70%)은 1,260만 원(1,800만 원의 70%)이 된다.

###### (2) 공제 가능한 최대 한도액 설정

- A회사가 중간수입에서 공제할 수 있는 법적 한도는 전체 평균임금 총액인 1,800만 원에서 최저 보장액인 1,260만 원을 차감한 나머지 평균임금의 30%인 540만 원(1,800만 원의 30%)으로 한정된다.

###### (3) 실제 공제액의 대입 및 최종 금액 산정

- B회사에서 얻은 실제 중간수입은 600만 원으로 산정된다. 그러나 A회사가 공제할 수 있는 한도는 앞서 계산한 540만 원을 초과할 수 없다. 따라서 B회사 수입 600만 원 중 540만 원까지만 공제가 가능하고, 한도를 초과하는 600만 원의 차액분인 60만 원은 사용자가 자신의 배상 채무에서 깎을 수 없다. 결과적으로 A회사가 지급해야 할 최종 금액은 정상 임금상당액인 1,800만 원에서 공제 한도액인 540만 원을 차감한 1,260만 원이 된다.

## **V. 결론**

- 부당해고 기간 중 중간수입공제는 근로기준법상 휴업수당 규정에 따른 최저 보장 한도를 침해할 수 없으므로, 사용자는 항상 평균임금의 70%에 해당하는 금액의 지급을 보장해야 하고 공제는 평균임금의 30%를 한도로 제한된다. 또한 노동조합으로부터 수령한 구제 기금은 노동의 대가가 아니므로 공제 대상 중간수입에서 제외된다. 사안에서 사용자인 A회사가 공제할 수 있는 최대 금액은 평균임금 1,800만 원의 30%인 540만 원이며, 노동조합의 구제 기금 100만 원은 공제 대상이 아니다. 따라서 A회사가 중간수입으로 공제할 수 있는 최종 금액은 540만 원에 한정되고, 甲에게 최종적으로 지급해야 할 법적 임금상당액은 평균임금의 70%인 1,260만 원이다. 결과적으로 700만 원 전액의 공제를 주장하는 A회사의 주장은 법리적으로 타당하지 않다.

<제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실체적 정당성>

[기출][1][2025-1-1]우선재고용의무 위반에 따른 근로자 지위 인정 여부

《【문제1】 A호텔은 상시 근로자 100명을 사용하여 호텔업을 운영하는 회사이고, 甲과 乙은 A호텔의 일식당에서 조리사로 근무하던 근로자이다(甲의 입사일 : 2018. 3. 1, 乙의 입사일 : 2013. 3. 1.). A호텔은 2020년부터 코로나 사태로 심각한 경영난을 겪게 되자, 경영상 이유에 의한 해고를 실시하기로 결정하고, 근로기준법 소정의 요건을 갖추어 2020. 8. 31. 甲과 乙을 포함한 20명의 근로자를 경영상 이유로 해고하였다. 이렇게 해고된 근로자 중에 甲과 乙을 포함하여 3명이 A호텔 일식당에서 조리사로 근무하던 사람이었다. 위 해고 당시 甲은 A호텔로부터 월 500만원의 임금을 받고 있었다. 甲은 위 해고 이후 연락처를 변경한 사실이 없다. 甲은 위 해고 이후 실직 상태에서 구직을 위해 노력하다가 2023. 6. 1. 월 400만원의 임금을 받는 조건으로 B호텔에서 조리사로 채용되었다.

A호텔은 2022년 하반기부터 경영상황이 개선되자 2023. 3. 1. 乙을 일식당의 조리사로 다시 채용하였고, 2023. 8. 1. 2명을 일식당의 조리사로 신규 채용하였다. 그런데 A호텔은 일식당 조리사의 채용을 진행하면서 甲에게는 채용절차의 진행 사실을 고지하지 않았다. 甲은 2024. 10. 경 뒤늦게 A호텔이 3명의 일식당 조리사를 채용한 사실을 알게 되었고, 이에 A호텔에 B호텔을 그만두고 A호텔 일식당으로 복귀하고 싶다는 의사를 표시했으나, A호텔은 이미 위 경영상 이유에 의한 해고일로부터 3년이 경과하였다는 이유로 甲의 요청을 거부하였다. 이에 甲은 자신이 A호텔의 근로자의 지위에 있다고 주장하는 한편, A호텔은 2023. 3. 1. 부터 甲이 복직할 때까지 매월 500만원의 비율로 산정한 임금 상당액의 손해배상 의무가 있다고 주장한다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음1) 甲이 A호텔의 근로자의 지위에 있다는 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (20점)》

<문제1의 물음1> 우선재고용의무 위반에 따른 근로자 지위 인정 여부

I. 문제의 제기

- 본 사안은 A호텔이 <경영상 이유로 해고했던 근로자 甲에게 재고용 기회를 부여하지 않은 것이 근로기준법 제25조 제1항의 재고용 의무를 위반한 것인지>, 그리고 <이러한 의무 위반이 甲의 근로자 지위를 회복시킬 수 있는 법적 근거가 될 수 있는지>가 쟁점이다. 甲의 주장이 타당한지 여부를 근로기준법 및 관련 판례 법리에 따라 검토한다.

II. 경영상 이유에 의한 해고와 재고용 의무

1. 우선 재고용 의무 규정

- 근로기준법 제25조 제1항은 제24조에 따라 근로자를 해고한 사용자는 근로자를 해고한 날부터 3년 이내에 해고된 근로자가 해고 당시 담당하였던 업무와 같은 업무를 할 근로자를 채용하려고 할 경우 제24조에 따라 해고된 근로자가 원하면 그 근로자를 우선적으로 고용하여야 한다고 규정하고 있다.

2. 재고용 의무의 관련 판례

- 대법원 2016. 10. 27. 선고 2016다13437 판결은 재고용 의무의 법적 성격에 대해 다음과 같이 판시하였다.

(1) 고용 의무 강행규정

- 사용자는 재고용 의무가 발생하면 이에 응해야 하는 법적 의무가 있으며, 이는 근로자의 권리 보호를 위한 강행규정이다.

(2) 위반 시 사법상 권리 발생

- 사용자가 재고용 의무를 이행하지 않은 경우, 해고된 근로자는 사용자를 상대로 고용의 의사표시를 갈음하는 판결을 구할 사법상의 권리를 가진다.

(3) 판결 확정 시 고용관계 성립

- 법원의 판결이 확정되면, 그 판결은 사용자의 고용 의사표시와 동일한 효력을 가지므로, 사용자와 근로자 사이에 고용관계가 성립하게 된다. 이는 단순한 손해배상 청구를 넘어선 근로관계 회복의 가능성을 의미한다.

III. 사안의 적용

1. 기존 근로관계의 종료

- 甲과 A호텔 간의 기존 근로관계는 2020. 8. 31. 유효한 경영상 이유에 의한 해고로 종료되었다. 따라서 甲이 현재 A호텔의 근로자 지위에 있다는 주장은 그 자체로는 타당하지 않다.

2. 새로운 고용관계 성립 가능성

- 그러나 A호텔은 2023. 3. 1.과 2023. 8. 1.에 일식당 조리사를 재채용 및 신규 채용하여, 해고일로부터 3년 이내에 해고 당시 담당하였던 업무와 같은 업무를 할 필요가 발생했다. 따라서 A호텔은 甲에게 우선적으로 재고용 기회를 부여해야 할 의무가 있었다. A호텔이 甲에게 재고용 의무를 이행하지 않은 것은 근로기준법 제25조 제1항을 위반한 것이다. 이 의무 위반으로 인해 甲은 고용의 의사표시를 갈음하는 판결을 구할 수 있는 사법상의 권리를 취득하였다.

3. 검토

- 甲의 주장은 '자신이 A호텔의 근로자 지위에 있다'는 현재적 상태를 의미하는 것이지만, 법적으로는 A호텔이 의무를 위반했으므로 근로자 지위를 회복할 수 있는 권리가 발생했다는 의미로 해석될 수 있다. 따라서 甲은 근로기준법 제25조 제1항에 따라 A호텔을 상대로 고용의 의사표시를 구하는 소송을 제기할 수 있고, 이 소송에서 승소하여 판결이 확정되면 A호텔과 甲 사이에 새로운 근로관계가 성립하게 된다. 따라서 현재 상태가 근로자 지위에 있다고 할 수는 없다.

IV. 결론

- 甲이 A호텔의 근로자의 지위에 있다는 甲의 주장은 현재의 상태를 의미하는 것으로는 타당하지 않다. 그러나 A호텔이 근로기준법 제25조 제1항의 재고용 의무를 위반함으로써, 甲에게는 법적 소송을 통해 근로자 지위를 회복할 수 있는 권리가 발생하였다. 따라서 甲의 주장은 단순한 지위 주장으로 그치는 것이 아니라, 법적 절차를 거쳐 근로자 지위를 회복할 수 있는 정당한 권리를 가지고 있다는 점에서 타당하다.

<제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실제적 정당성>

[기출][1][2025-1-2]우선재고용의무 위반 시 손해배상의무의 발생 시점 및 배상액 산정 방식(중간수입공제)

《【문제1】 A호텔은 상시 근로자 100명을 사용하여 호텔업을 운영하는 회사이고, 甲과 乙은 A호텔의 일식당에서 조리사로 근무하던 근로자이다(甲의 입사일 : 2018. 3. 1, 乙의 입사일 : 2013. 3. 1.). A호텔은 2020년부터 코로나 사태로 심각한 경영난을 겪게 되자, 경영상 이유에 의한 해고를 실시하기로 결정하고, 근로기준법 소정의 요건을 갖추어 2020. 8. 31. 甲과 乙을 포함한 20명의 근로자를 경영상 이유로 해고하였다. 이렇게 해고된 근로자 중에 甲과 乙을 포함하여 3명이 A호텔 일식당에서 조리사로 근무하던 사람이었다. 위 해고 당시 甲은 A호텔로부터 월 500만원의 임금을 받고 있었다. 甲은 위 해고 이후 연락처를 변경한 사실이 없다. 甲은 위 해고 이후 실직 상태에서 구직을 위해 노력하다가 2023. 6. 1. 월 400만원의 임금을 받는 조건으로 B호텔에서 조리사로 채용되었다.

A호텔은 2022년 하반기부터 경영상황이 개선되자 2023. 3. 1. 乙을 일식당의 조리사로 다시 채용하였고, 2023. 8. 1. 2명을 일식당의 조리사로 신규 채용하였다. 그런데 A호텔은 일식당 조리사의 채용을 진행하면서 甲에게는 채용절차의 진행 사실을 고지하지 않았다. 甲은 2024. 10. 경 뒤늦게 A호텔이 3명의 일식당 조리사를 채용한 사실을 알게 되었고, 이에 A호텔에 B호텔을 그만두고 A호텔 일식당으로 복귀하고 싶다는 의사를 표시했으나, A호텔은 이미 위 경영상 이유에 의한 해고일로부터 3년이 경과하였다는 이유로 甲의 요청을 거부하였다. 이에 甲은 자신이 A호텔의 근로자의 지위에 있다고 주장하는 한편, A호텔은 2023. 3. 1. 부터 甲이 복직할 때까지 매월 500만원의 비율로 산정한 임금 상당액의 손해배상 의무가 있다고 주장한다. 다음 물음에 답하시오. (50점)

(물음2) A호텔이 2023. 3. 1. 부터 甲이 A호텔에 복직할 때까지 매월 500만원 비율로 산정한 손해배상의무가 있다는 甲의 주장이 타당한지 논하시오. (30점)》

<문제1의 물음2> 우선재고용의무 위반 시 손해배상의무의 발생 시점 및 배상액 산정 방식(중간수입공제)

I. 문제의 제기

- 사안에서 A호텔이 경영상 이유로 해고했던 근로자 甲을 재고용 의무 기간 내에 우선적으로 재고용하지 않은 행위에 대하여, 甲이 A호텔에 임금 상당액의 손해배상 의무가 있다고 주장하고 있다. 특히, <손해배상 의무의 발생 시점, 손해배상액 산정 방식, 甲의 주장과 실제 법리 간의 차이>가 쟁점이다. 이하에서는 甲의 주장에 관한 타당성에 대해 근로기준법 및 관련 판례법리에 따라 논한다.

II. 경영상 해고와 재고용 의무의 법적 성격

1. 재고용 의무의 법적 근거

- 근로기준법 제25조 제1항은 사용자가 경영상 이유로 근로자를 해고한 후 3년 이내에 해고 당시 담당했던 업무와 같은 업무를 할 필요가 있을 때, 해고된 근로자를 우선적으로 재고용해야 하는 의무를 규정하고 있다.

2. 재고용 의무 위반의 효과 (판례 법리)

- 대법원 판례는 근로기준법 제25조 제1항의 재고용 의무를 강행규정으로 보며, 사용자가 이를 위반할 경우 해고된 근로자에게 손해배상 책임을 진다고 판시하고 있다. 이는 사용자의 채용 재량권을 제한하는 의무를 위반했기 때문에 발생하는 법적 책임이다. 이때 손해배상의 범위는, 사용자가 의무를 이행하여 근로자를 고용했다면 근로자가 얻을 수 있었던 임금 상당액으로 산정하는 것이 일반적이다.

3. 손해배상 의무의 발생 시점

- 손해배상 의무는 사용자가 재고용 의무를 이행해야 할 시점이 도래했음에도 불구하고 이를 위반한 때에 발생한다. 따라서 손해배상액은 사용자가 재고용 의무를 이행했어야 할 시점부터 산정되어야 한다.

III. 甲의 손해배상 주장 검토

1. 손해배상 의무의 발생 시점

- A호텔은 2023. 3. 1. 乙을, 2023. 8. 1. 2명의 조리사를 재채용 또는 신규 채용하였다. 이는 근로기준법 제25조 제1항이 규정한 3년 이내 (2020. 8. 31. ~ 2023. 8. 30.)에 해고 당시와 같은 업무를 할 필요가 발생했음을 의미한다. 따라서 A호텔은 이 시점에 甲에게 우선적으로 재고용 기회를 주어야 할 의무가 있었음에도 이를 위반하였다. 2023. 3. 1.은 乙이 재채용된 시점으로, A호텔에 甲을 재고용해야 할 의무가 발생한 첫 번째 시점이다. 2023. 8. 1.은 2명의 신규 조리사가 채용된 시점으로, A호텔의 재고용 의무 위반이 지속되었음을 보여준다.

2. 손해배상액 산정 기준

- 甲은 2023. 3. 1. 부터 甲이 복직할 때까지 매월 500만원의 비율로 산정한 임금 상당액을 손해배상액으로 주장하고 있다.

(1) 임금 기준

- 甲의 주장대로 손해배상액은 해고 당시 임금인 월 500만원을 기준으로 산정될 수 있다. 이는 재고용되었을 경우 받았을 것으로 예상되는 임금 상당액이므로, 합리적인 기준이다.

(2) 손해배상 기간

- 甲은 2023. 3. 1.부터 복직할 때까지를 손해배상 기간으로 주장하고 있다. 그러나 판례는 손해배상액 산정 시 해고 근로자가 중간수입을 얻은 경우 이를 공제해야 한다고 본다.

3. 중간수입 공제

- 문제 사안에서 甲은 2023. 6. 1.부터 월 400만원의 임금을 받는 B호텔에 취업하였다. 이는 甲의 중간수입에 해당한다. 따라서 A호텔의 손해배상액은 甲의 중간수입을 공제하고 산정되어야 한다.

IV. 손해배상 의무의 범위와 산정

1. 의무 발생 시점

- A호텔의 손해배상 의무는 2023. 3. 1.에 발생하였다고 볼 수 있다. 乙이 재채용된 시점부터 A호텔은 재고용 의무를 위반했기 때문이다.

2. 손해배상액의 구체적 산정

(1) 2023. 3. 1. ~ 2023. 5. 31. (3개월)

- 甲이 실직 상태였으므로, A호텔은 이 기간 동안 월 500만원의 임금 상당액을 손해배상해야 한다.

- (500만원 × 3개월) = 1,500만원

(2) 2023. 6. 1. ~ (복직 또는 소송 종료 시까지)

- 甲이 B호텔에서 월 400만원의 임금을 받고 있으므로, 이 기간 동안의 손해배상액은 A호텔의 임금(월 500만원)과 B호텔의 임금(월 400만원)의 차액으로 산정되어야 한다.

-  $(500\text{만원} - 400\text{만원}) = \text{월 } 100\text{만원}$

- 즉, 이 기간 동안 A호텔은 매월 100만원의 손해배상 의무를 진다.

### 3. 甲 주장의 타당성

- A호텔은 2023. 3. 1. 부터 甲이 복직할 때까지 매월 500만원의 비율로 산정한 손해배상 의무가 있다고 주장하는 것은 일부 타당하지만 전부 타당하지는 않다. 손해배상 의무의 발생 시점(2023. 3. 1.)은 타당하다. 그러나 2023. 6. 1. 이후 B호텔에서 얻은 중간수입(월 400만원)을 공제하지 않고 월 500만원 전액을 손해배상액으로 주장하는 부분은 법리적으로 타당하지 않다.

### V. 결론

- A호텔이 근로기준법 제25조 제1항의 재고용 의무를 위반한 것은 사실이며, 그 의무 위반으로 인해 甲에게 손해배상 의무를 부담한다. 그러나 甲이 2023. 3. 1. 부터 A호텔에 복직할 때까지 매월 500만원 비율로 산정한 손해배상 의무가 있다고 주장하는 것은 전적으로 타당하지 않다. A호텔의 손해배상 의무는 2023. 3. 1.부터 시작되지만, 甲이 B호텔에 취업한 2023. 6. 1. 이후부터는 甲의 중간수입을 공제한 금액(월 100만원)만을 손해배상액으로 지급할 의무가 있다. 따라서 甲의 주장은 일부 타당하다.

《【문제2】 2023. 7. 26. 오전 8시경 S시 산업단지 대 A회사에서 상온에 노출되는 경우 사람에게 호흡곤란, 피부질환 등을 발생시키는 화학물질이 누출되는 사고가 발생하였다. S시 소방본부는 반경 150m 까지 통제선을 설치하고, 통제선 내에 있는 해당 근로자들에 대피를 유도하였고, 반경 1km 내 주민들에게도 창문을 폐쇄하고 외출을 자제할 것을 당부하는 대피방송을 하였다. 이와 함께 소방본부는 전문기관에 누출사고 발생지점으로부터 반경 200m 거리까지 화학물질 검출을 의뢰하였고, 오전 9시경 반경 5~10m 지점에 5~8ppm이 검출되나, 반경 10m 이상의 거리에서는 검출이 되지 않는다는 취지의 회신을 받았다. 위 사고로 A회사의 2명의 근로자가 어지럼증으로 병원에 이송되었고, 누출사고 다음 날까지 A회사 인근의 회사에서 근무하는 근로자들 30명이 두통, 어지러움 등으로 치료를 받았다. 그 가운데 3명은 통제선 밖에 있는 근로자들로 확인되었다.

丙은 누출사고 지점으로부터 반경 200m정도의 거리에 있던 B회사에 재직중인 근로자로서 B회사에 설립된 노동조합의 위원장이다. 오전 10시경 丙은 B회사의 노무이사, B회사 산업안전보건위원회 근로자위원, 지방고용노동청 소속 근로감독관 등과 누출사고에 대한 대책을 논의하였고, 당시 근로감독관은 대피를 권유하였으며 근로자위원은 丙에게 급박한 위험상황인지 여부를 객관적으로 파악하기 위해 누출사고 현장에 같이 가볼 것을 제안하였다. 그러나 丙은 이에 응하지 않았다. 이후 丙은 소방본부에 전화하여 누출된 화학물질의 인체에 미치는 영향 및 B회사에 대해 대피명령이 내려지지 않는 이유에 대해서 질의하였고, 이미 대피방송이 있었다는 취지의 답변을 들었다. 丙은 B회사의 작업장을 이탈하면서 당시 작업중이던 노동조합 소속 조합원 28명에게도 대피하라고 말하였고, 이에 따라 조합원들은 작업을 중단하고 B회사의 작업장에서 이탈하였다. 그리고 B회사의 노무이사에게도 대피명령을 내릴 수밖에 없는 상황임을 알렸다. 이에 B회사는 丙이 현장을 방문하여 객관적으로 작업중지권을 행사할 상황인지 여부를 파악할 수 있는 최소한의 노력을 거본한 점, 丙이 근로자가 아니라 노동조합 위원장으로서 작업중지권을 행사한 점에서 丙의 작업중지권 행사가 적법하지 않다고 주장하고 있다. B회사의 주장이 타당한지 서술하시오. (25점)》

<문제2> 화학물질 누출 사고에 따른 근로자 및 노동조합 위원장의 작업중지권 행사의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- 사안에서 B회사 근로자이자 노동조합 위원장인 丙은 인근 사업장의 화학물질 누출사고와 관련하여 작업장을 이탈하면서 조합원들에게도 대피를 권유하여 작업을 중단하게 하였고, 이에 대하여 B회사는 객관적 위험 확인을 위한 노력을 다하지 않았고 노동조합 위원장으로서 작업중지권을 행사하였으므로 적법하지 않다고 주장하고 있다. 쟁점으로 <丙의 작업중지권 행사에 급박한 위험이 존재하였는지>, <객관적 위험 확인을 위한 최소한의 노력을 다하였는지>, <노동조합 위원장의 지위에서 작업중지권을 행사한 것이 적법한지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 B회사의 주장이 타당한지 서술한다.

II. 산업안전보건법상 근로자의 작업중지권

1. 작업중지권의 법적 근거 및 성격

- 산업안전보건법 제52조 제1항은 근로자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 작업을 중지하고 대피할 수 있다고 규정하여, 급박한 위험에 직면한 근로자에게 작업을 중단하고 대피할 수 있는 권리를 부여하고 있다. 이는 근로자의 생명과 건강을 보호하기 위한 중대한 권리이자 사용자의 지시를 거부할 수 있는 권리이다.

2. 작업중지권 행사의 요건

- 작업중지권 행사가 정당성을 얻기 위해서는 다음과 같은 요건을 충족해야 한다.

(1) 급박한 위험의 존재

- 산업재해가 발생할 급박한 위험이 객관적으로 존재해야 한다. 단순히 위험에 대한 추상적인 우려만으로는 정당성이 인정되기 어렵다.

(2) 작업 중지 및 대피

- 근로자가 실제로 작업을 중지하고 안전한 장소로 대피하는 행위가 있어야 한다.

III. B회사의 주장에 대한 검토

- B회사는 丙의 작업중지권 행사가 적법하지 않다고 주장하면서 두 가지 이유를 제시하고 있다.

1. 현장 파악 노력 미흡 여부

- B회사는 丙이 현장을 방문하여 객관적으로 작업중지권을 행사할 상황인지 여부를 파악할 수 있는 최소한의 노력을 거부했다고 주장하고 있다. 산업안전보건법은 근로자가 작업중지권을 행사하기 전 객관적 위험 상황을 파악할 것을 요구하지만, 그 방법까지 구체적으로 정하고 있지는 않다. 사안의 경우, 丙은 소방본부, 근로감독관, 산업안전보건위원회 근로자위원 등과 협의를 진행하였고, 소방본부에는 직접 전화하여 정보를 확인하는 등 위험 여부를 파악하기 위한 상당한 노력을 기울였다. 또한, 화학물질 누출은 인체에 유해한 영향을 미치는 사고로서 현장에 직접 접근하는 것 자체가 또 다른 위험을 초래할 수 있다. 따라서 丙이 현장 접근 제안에 응하지 않았다는 이유만으로 객관적인 상황 파악 노력을 게을리했다고 단정하기는 어렵다.

2. 노동조합 위원장의 작업중지권 행사 주체 적법성

- B회사는 丙이 근로자가 아니라 노동조합 위원장으로서 작업중지권을 행사했다고 주장하고 있다. 산업안전보건법 제52조 제1항은 근로자가 작업중지권을 행사할 수 있다고 규정하고 있다. 丙은 B회사에 재직 중인 근로자이므로, 산업안전보건법상 작업중지권의 행사 주체인 근로자의 지위에 해당한다. 丙이 노동조합 위원장의 신분으로 조합원들에게 대피를 지시한 것은, 노동조합 대표자로서 조합원의 안전을 보호하기 위한 활동의 일환으로 보아야 한다. 이는 노동조합 및 노동관계조정법상 노동조합 활동의 정당성 문제와는 별개로, 산업안전보건법상 근로자로서의 권리 행사로 해석될 수 있다. 판례는 단체교섭이나 쟁의행위가 아닌 안전보건 활동은 노동조합 위원장으로서의 활동이라 하더라도 산업안전보건법상 근로자의 권리 행사로 인정하는 경향이 있다. 따라서 丙이 노동조합 위원장의 지위로 작업중지권을 행사했다는 B회사의 주장은 법적 근거가 미약하다.

IV. 사안의 적용

1. 丙의 작업중지권 행사 요건 충족 여부

(1) 급박한 위험의 존재

- 사고 인근 지역에서 근로자 30명이 두통, 어지러움 등의 증상을 호소했고, 소방본부에서도 대피방송을 했다는 점은 B회사 인근 지역에도 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있었다는 점을 입증한다. 통제선 밖에 있는 3명의 근로자도 증상을 호소한 점은 B회사가 위치한 반경 200m 지점도 안전하다고 단정하기 어렵다는 점을 보여준다.

(2) 객관적 상황 파악 노력

- 丙은 근로감독관, 소방본부, 근로자위원 등과 접촉하여 상황을 파악하려 했으므로, 객관적인 상황 파악을 위한 노력을 다했다고 볼 수 있다.

## 2. 丙의 작업중지권 행사 주체 적법성

- 丙은 B회사의 재직 중인 근로자로서 산업안전보건법상 작업중지권의 주체인 근로자에 해당한다. 노동조합 위원장으로서의 행동은 근로자의 안전 보건을 위한 정당한 활동으로 판단된다.

## V. 결론

- B회사가 丙이 현장 파악 노력을 게을리했고, 근로자가 아닌 노동조합 위원장으로서 작업중지권을 행사했다고 주장하는 것은 타당하지 않다. 丙의 작업중지권 행사는 급박한 위험이 객관적으로 존재하는 상황에서 이루어졌으며, 丙은 근로자로서 정당한 권리를 행사한 것이다. 따라서 丙의 작업중지권 행위는 적법하고, B회사의 주장은 타당하지 않다.

<제08장 근로관계의 종료.제02절 해고의 실체적 정당성>

<제08장 근로관계의 종료.제03절 해고의 절차적 정당성>

《4인 이상의 사업장에서 사용자가 근로자에게 사직을 권고하였지만, 해당 근로자는 그에 응하지 않고 근로관계를 계속 유지하고자 한다. 이와 달리 사용자는 해당 근로자의 해고를 원하고 있다. 적법한 방법이 무엇이 있는가?》

## I. 문제의 제기

### 1. 사안의 개요

- 사용자가 근로자에게 사직을 권고하였으나 근로자가 이에 동의하지 않고 근로관계의 계속 유지를 희망하는 상황이다. 근로자의 자발적 사직이나 합의에 의한 근로관계 종료가 불가능하므로, 사용자가 근로관계를 일방적으로 단절시키기 위해서는 근로기준법이 정하는 적법한 해고 절차를 밟아야 한다.

### 2. 핵심 논점

- 근로기준법상 해고는 사용자의 일방적 의사표시로 근로관계를 종료시키는 행위이므로 법적 제한이 매우 엄격하다. 해고의 적법성을 판단하는 기준은 사업장의 규모, 즉 상시근로자 수가 5인 이상인지 또는 4인 이하인지에 따라 완전히 달라진다. 이하에서는 사업장 규모별로 발생할 수 있는 법적 쟁점과 이를 해결하기 위한 구체적인 방안을 논하고자 한다.

## II. 상시근로자 수에 따른 적용 법리의 차이

### 1. 상시근로자 5인 이상 사업장

- 상시근로자 수가 5인 이상인 사업장에는 근로기준법상 해고 제한 규정이 전면 적용된다. 사용자는 근로자를 해고하기 위해 정당한 이유가 있어야 하며, 해고의 사유와 시기를 서면으로 통지하여야만 효력이 발생한다. 이를 위반하는 경우 부당해고에 해당하여 노동위원회를 통한 구제절차가 진행될 수 있다.

### 2. 상시근로자 4인 이하 사업장

- 상시근로자 수가 4인 이하인 사업장에는 근로기준법 제23조 제1항의 해고 제한 규정과 제27조의 서면 통지 의무가 적용되지 않는다. 따라서 사용자는 특별한 정당한 이유가 없더라도 근로자를 해고할 수 있고 구두로도 해고 통지가 가능하다. 다만 근로기준법 제26조에 따른 해고예고 의무는 규모와 상관없이 적용되므로 이를 반드시 이행하여야 한다.

### 3. 상시근로자 수 산정의 기준

#### (1) 산정 방법의 원칙

- 상시근로자 수는 해당 사업장에서 법 적용 사유 발생일 전 1개월 동안 사용한 근로자의 연인원을 같은 기간 동안의 가동 일수로 나누어 산정한다. 이때 기간제 근로자, 단시간 근로자, 아르바이트생 등 고용 형태를 불문하고 사용자가 직접 고용한 모든 근로자가 산정 인원에 포함된다.

#### (2) 가동 일수별 예외 기준

- 위 산정 방식에 따라 상시근로자 수가 5인 미만인 사업장이라도 가동일별로 인원을 나누어 보았을 때 5인 미만인 일수가 전체 가동 일수의 2분의 1 미만인 경우에는 5인 이상 사업장으로 취급한다. 반대로 평균값이 5인 이상이 나오더라도 5인 미만인 일수가 2분의 1 이상인 경우에는 4인 이하 사업장으로 취급하여 법을 적용한다.

## III. 상시근로자 5인 이상 사업장에서의 적법한 해고 방법

### 1. 통상해고의 요건과 절차

#### (1) 정당한 이유의 존재

- 통상해고는 근로자의 일신상 사유, 직무수행 능력 부족, 건강 상태 악화 등으로 인하여 계약상의 근로를 제공하는 것이 불가능한 경우에 행하는 해고다. 판례는 근로자의 업무능력 결여나 근무성적 불량만 단순히 주관적 평가가 아니라 상당한 기간 동안 객관적으로 증명되어야 하며, 업무 향상을 위한 교육 제공이나 직무 재배치 등 개선 기회를 부여하였음에도 교정의 여지가 없고 사회통념상 근로관계를 더 이상 유지할 수 없을 때 정당성을 인정한다.

#### (2) 객관적 입증의 필요성

- 단순히 사직 권고를 거부했다는 사실 자체는 해고의 정당한 이유가 될 수 없다. 사용자는 평소 누적된 인사평가 결과, 구체적인 업무 지시 및 이에 대한 불이행 경위서, 시달서 제출 요구 내역, 업무 태만 행위에 대한 서면 경고 등 근로자의 귀책사유나 능력 부족을 입증할 수 있는 객관적인 인사 기록 자료를 체계적으로 축적하고 있어야 한다.

### 2. 징계해고의 요건과 절차

#### (1) 실체적 정당성

- 근로자의 심각한 비위행위나 사내 규정 위반을 이유로 근로관계의 종료라는 징벌적 제재를 가하는 처분이다. 단체협약이나 취업규칙에 규정된 명확한 징계 사유가 존재하여야 하며, 비위행위의 무거움과 징계 수준 사이에 적절한 균형이 유지되어야 한다. 다른 유사 사례와의 형평성도 고려하여 사회통념상 해고가 불가피하다고 인정되는 수준이어야 실체적 정당성이 확보된다.

#### (2) 절차적 정당성

- 단체협약이나 취업규칙 등에 징계위원회의 구성, 사전 통보 시기, 본인 소명 기회 부여 등이 규정되어 있다면 이러한 절차를 철저히 이행하여야 한다. 법적으로 아무리 징계 사유가 타당하다 하더라도 사내 규정에 마련된 소송 절차나 의견 진술 절차를 누락하는 경우에는 절차적 하자로 인하여 해당 해고가 당면무효로 판정된다.

### 3. 경영상 이유에 의한 해고

#### (1) 긴박한 경영상의 필요

- 사용자가 경영 악화로 인하여 인원 감축을 단행해야 하는 경우다. 단순히 영업이익이 다소 감소한 수준을 넘어 기업의 도산을 회피하기 위한 불가피한 조치이거나 상당한 정도의 경영 합리화 조치로서 인원 정리가 객관적으로 보아 타당하다는 합리성이 입증되어야 한다.

#### (2) 해고회피 노력과 공정한 기준

- 사용자는 인위적인 인원 감축을 하기 전에 연장근로의 제한, 신규 채용 중단, 휴업 시행, 희망퇴직이나 권고사직 장려 등 고용 유지를 위한 최선의 회피 노력을 기울여야 한다. 또한 해고 대상자를 선별할 때 근무성적, 부양가족, 근속기간 등을 종합적으로 고려한 공정하고 객관적인 기준을 수립하여 성별 등을 이유로 차별하지 않아야 한다.

### (3) 노동조합 등과의 협의

- 근로기준법 제24조 제3항에 따라 사용자는 해고를 하려는 날의 50일 전까지 근로자대표에게 통보하고 성실하게 협의하여야 한다. 이 과정에서 해고의 규모와 이를 피하기 위한 구체적인 대안들이 논의되어야 하며, 이러한 일련의 법정 요건을 완벽히 충족하여야 경영상 해고가 적법한 것으로 인정된다.

## Ⅳ. 상시근로자 4인 이하 사업장에서의 적법한 해고 방법

### 1. 해고예고 의무의 준수

#### (1) 30일 전 예고 원칙

- 상시근로자 수 4인 이하인 사업장에는 해고의 정당한 이유를 요하지 않으므로 사용자의 자유로운 해고가 가능하지만, 근로기준법 제26조에 따른 해고예고 의무는 준수하여야 한다. 사용자는 적어도 해고일로부터 30일 전에 근로자에게 해고 일자과 사유를 구체적으로 알려주어야 한다.

#### (2) 해고예고수당의 지급

- 만약 30일 전에 예고를 하지 못하고 즉시 해고하고자 하거나 예고 기간이 30일 미만인 경우에는 법에 따라 30일분 이상의 통상임금을 해고예고수당으로 일시에 지급하여야 한다. 예고 기간 계산의 착오로 인하여 단 하루라도 부족하게 예고한 경우 전체 수당을 지급해야 할 의무가 발생하므로 날짜 산정에 극도로 주의하여야 한다.

### 2. 해고 제한의 예외 사유

#### (1) 근로기간에 따른 예외

- 근로자의 계속근로기간이 3개월 미만인 경우에는 해고예고 의무 자체가 적용되지 않는다. 따라서 이 경우 사용자는 30일 전 예고를 하거나 예고수당을 지급할 필요 없이 즉시 해고할 수 있다.

#### (2) 근로자의 귀책사유에 따른 예외

- 근로자가 고의로 사업에 막대한 지장을 초래하거나 재산상 손해를 끼친 경우로서 고용노동부령이 정하는 사유에 해당할 때에는 해고예고 없이 즉시 해고가 가능하다. 예 : 납품업체로부터 금품을 수수하여 생산에 차질을 빚게 하거나 회사 기밀을 경쟁업체에 누설한 경우 등이 이에 해당한다.

## Ⅴ. 공통 적용되는 적법성 확보 방안 및 유의사항

### 1. 해고 사유와 시기의 서면 통지

#### (1) 서면 통지의 강제성

- 상시근로자 5인 이상 사업장에서 해고는 반드시 서면으로 이루어져야만 효력이 발생한다. 구두, 이메일, 문자메시지, 모바일 메신저 등을 통한 해고 통지는 법이 인정하는 특별한 예외를 제외하고는 원칙적으로 서면 통지 의무 위반에 해당하여 해고 자체가 무효가 된다. 사용자는 구체적인 해고 사유와 해고 일자를 종이 문서에 명시하여 근로자에게 대면으로 교부하거나 내용증명 우편으로 송달하여야 한다.

#### (2) 서면 통지의 구체성 요건

- 서면에는 해고의 원인이 되는 비위사실이나 해고 사유를 근로자가 명확히 알고 방어할 수 있을 정도로 구체적으로 적시하여야 한다. 단순히 회사 취업규칙 제00조 위반 혹은 불성실한 업무 태도와 같이 추상적으로만 기재하면 해고 사유 서면 통지 의무를 위반한 것으로 판정될 위험이 극도로 높아진다.

### 2. 부당해고 구제신청 대비 및 합의 해지 유도

#### (1) 입증책임의 분담과 법적 리스크

- 일방적인 해고를 단행한 경우 근로자가 노동위원회에 부당해고 구제신청을 제기하면 해고의 정당성에 대한 모든 입증책임은 사용자에게 귀속된다. 5인 이상 사업장에서 부당해고로 판정될 경우 사용자는 해고 기간 동안 근로자가 정상적으로 근로를 제공하였더라면 받을 수 있었던 임금 상당액을 고스란히 지급하여야 하며 원직 복직 의무까지 부담하게 된다.

#### (2) 합의 해지를 위한 전략적 접근

- 실무적으로 일방적인 강제 해고는 사후 법적 분쟁을 유발하여 비용과 시간 면에서 엄청난 손실을 가져온다. 따라서 사직 권고를 거부하는 근로자에게 무리한 해고 조치를 취하기에 앞서, 퇴직위로금의 상향 제시나 전직 지원금 제공, 실업급여 수급 협조 등의 혜택을 제시하여 근로자가 스스로 서명하는 권고사직서나 합의해지합의서를 작성하도록 마지막까지 합의를 유도하는 것이 기업 경영상 가장 안전하고 확실한 해결책이다.

## Ⅵ. 결론

### 1. 사업장 규모별 핵심 의무

#### (1) 5인 이상 사업장의 고도 의무

- 상시근로자 5인 이상인 사업장에서는 근로자의 사직 권고 거부 시 감행하는 해고가 정당성(실체적·절차적 사유)과 서면 통지 요건을 모두 갖추어야만 적법하다. 단순한 감정적 해고나 불충분한 기록에 의존한 해고는 부당해고 판정으로 귀결될 가능성이 매우 높다.

#### (2) 4인 이하 사업장의 최소 의무

- 반면 상시근로자 4인 이하인 사업장에서는 해고 사유의 정당성이나 서면 통지 절차가 요구되지 않으므로 비교적 수월하게 근로관계를 단절할 수 있으나, 30일 전 해고예고 의무 또는 해고예고수당 지급 의무만큼은 철저히 이행하여야 법률 위반에 따른 불이익을 방지할 수 있다.

### 2. 종합적 제언

- 사용자는 무리한 해고 처분을 남발하기보다 법정 요건을 철저히 분석하고 상시근로자 수 산정을 선행하여야 한다. 아울러 분쟁을 조기에 종식하기 위해 최대한 합의에 의한 근로관계 종료로 시도하되, 부득이하게 해고를 실행할 때는 수집된 객관적 입증 자료와 서면 통지 절차를 빈틈없이 구비하여야 부당해고에 따른 치명적인 리스크를 차단할 수 있다.